STORIA DEL DIRITTO ROMANO

Prof.ssa Pia Starace

A.A. 2021-2022

Testo di riferimento : Storia del diritto romano, Mario Bretone

A cura di Pennacchio Sabrina



Premesse

I cinque significati di *Diritto Romano*

1- *Diritto romano come diritto storico:*
Cioè come l'esperienza giuridica che si è svolta nell'arco di un millennio, dalle origini sino alla compilazione giustinianea come punto di arrivo.

2- *Diritto romano come tradizione romanistica:*
Tutto quello che si è svolto dalla tradizione giustinianea in poi, come storia giuridica europea influenzata dall'esperienza romana, trasmissione giuridica romana

3- *Diritto romano come diritto comune:*
Particolare formazione storica di valore europeo che senza limitazioni spaziali e temporali si venne componendo in un corpo organico di dottrine a partire dai testi giustinianei, è quel Ius commune a cui tutti volevano rifarsi a partire dal 12-13 sec, questo patrimonio rappresentato dal diritto romano delineò il punto di riferimento da cui attingere per costruire un diritto comune, ius commune europaeum.
- Un nucleo di matrice romana e allo stesso tempo con misto di diritto canonico, con la presenza della Chiesa durante il Medioevo.

4- *Diritto romano come pandettistica:*
in Germania nel 18 sec. Sottoforma di costruzione teorica-pratica del codice giustinianeo armonizzato con le esigenze della realtà del tempo.
Fu convertito in un sistema di diritti soggettivi che ruotavano attorno all'individuo e alla sua potestà di volere.

5- *Diritto romano come romanistico:*
studio del diritto romano storico condotto da vari soggetti dei Paesi Europei, l'insieme degli studiosi del diritto romano danno vita a dottrine.

> L'oggetto del nostro studio è di fatto il diritto romano inteso come storico.

Differenza pubblico-privato

- Nel diritto romano si parla di diritto pubblico e privato in termini diversi da quelli odierni:
Non essendoci ancora un'idea di stato come la intendiamo noi, e quindi non potendo parlare di diritto pubblico *come complesso di norme che disciplinano la formazione e l'organizzazione dello stato e dei suoi enti*, che sono una cosa diversa rispetto a singoli cittadini che compongono lo stato, si parla di **diritto pubblico come diritto del popolo.** (lo dice C. Questa), si fa riferimento alla collettività, alla pluralità, alla comunità politica, alla somma dei cittadini che compongono il *populus* romano.

- E quindi con ***diritto pubblico*** si fa riferimento ai principi e criteri che regolamentano l'organizzazione politica dei cittadini.
- E per quanto concerne il **diritto privato**, la scientia iuris, quell'ambito culturale in cui i giuristi romani hanno inciso profondamente per quanto riguarda la creazione del diritto, nel diritto privato, si sono occupati prevalentemente dei *rapporti tra singoli soggetti e privati.*

Le fonti del diritto

Dire Fonti: è una metafora: “le fonti da cui sgorga il diritto” = da dove deriva il diritto.
> Noi in questo caso siamo parlando di diritto storico, per cui le fonti del diritto possono essere:

- Fonti di Cognizione
- Fonti di Produzione

Fonti di Cognizione

> Nell’ambito quindi del diritto storico, dobbiamo considerare le fonti di cognizione come fonti di conoscenza storica del diritto: Come noi conosciamo il diritto romano.

- Naturalmente sarebbe più facile se si trattasse di materia contemporanea, ma qui si parla di materia storica, e poi molto molto risalente; il problema è questo, il tempo infatti ha ormai sbiadito le tracce dell’originario diritto romano. Tanto più una realtà antica, tanto più è difficile ricostruirla precisamente. Il tempo ha un effetto di consumazione, del ricordo, delle tracce…
Però ci sono delle testimonianze con cui è possibile avvicinarsi, approssimarsi per conoscere.

- Difficilmente si riesce ad ottenere una testimonianza relativa a quel periodo in particolare e che ci è giunta intatta, è raro, infatti è da tener presente che nel corso dei millenni si è avuta una stratificazione sui documenti originali, che rende estremamente difficile una comprensione del testo autentico. Per cui, per questa materia, l’indagine è molto complessa.

Possiamo fare una prima distinzione tra:
1- Fonti tecniche
2- Fonti atecniche

Fonti Tecniche: Sono quelle che riguardano propriamente, specificamente la stria del diritto pubblico romano; quelle che vengono dalla letteratura giurisprudenziale romana (dai giuristi).
Il cerchio dei giuristi ha elaborato il suo pensiero e lo ha riversato in una letteratura: testi \ libri tecnico giuridici. —> Quanto ci è pervenuto di questo, si dice fonte tecnica.
Ma non solo, sono fonti tecniche anche documenti giuridici come ad esempio i contratti o i testamenti…

Fonti Atecniche: Sono quelle che non riguardano strettamente il diritto romano, ma guardano ad altri lati della civiltà romana, altri ambiti culturali che però di riflesso ci dicono molto del diritto.

- Possiamo fare l’esempio di Cicerone.
Soprattutto per la parte repubblicana prenderemo in esame le sue testimonianze e non dobbiamo confonderle con delle fonti tecniche:
Le testimonianze ciceroniane sono infatti fonti atecniche poiché Cicerone non è un giurista, si è versato fondamentalmente nell’oratoria, e anzi, spesso è anche polemico nei confronti de giuristi.
Oratoria e Giurisprudenza sono infatti due discipline da considerare ben distinte con finalità differenti, sebbene nella formazione si tangessero, nel momento in cui chi studia queste due discipline diventava tecnico di quella disciplina in particolare. Le professioni si distaccavano completamente.
- E nelle fonti dateci da cicerone (che sono quindi atecniche) di riflesso troveremo degli aspetti molto rilevanti Sotto il profilo giuridico, e del diritto, ad esempio in relazione alla mentalità di un certo ceto eccetera.

> Altre fonti atecniche sono, ad esempio:

- La letteratura, di qualunque genere, ad esempio teatrale, (circa le commedie Plautine per esempio si ricavano tanti elementi giuridici ad esempio rituali con riflesso giuridico nella pratica,)
- Anche altre testimonianze di tipo artistico, ad esempio la produzione di ceramiche, di oggetti di uso quotidiano, affreschi o mosaici…
- Tutto ciò che può dare indizi o elementi circa l’ambito giudiziario della storia del diritto.

Possiamo distinguere ulteriormente le fonti di cognizione in:

1- Fonti primarie
2- Fonti secondarie o derivate

Fonti primarie: Sono quelle che ci sembrano riprodurre fedelmente (senza deformazioni\elaborazioni o sovrapposizioni) lo stato dell'ordinamento giuridico romano e alcuni aspetti di esso.
- Parliamo per esempio di alcune epigrafi, pensiamo ai materiali lapidei, al materiale inscritto (es. lapidi funebri), ma anche pergamene, tavolette cerate o le monete stesse.

> Sostanzialmente tutto quel materiale che non si rovina ne tempo, che può essere un pò consumato, ma che ci è arrivato intatto e che ci da un'idea diretta di quanto è riportato in quanto non è stato certamente modificato nel corso del tempo.

Fonti secondarie o derivate: Sono quelle che per via derivata ci forniscono elaborazioni dell'ordinamento giuridico romano, e ne impongono una ricostruzione indiziaria e intuitiva.
Per esempio gli scritti greci e latini che riflettono un ambiente impregnato di cultura giuridica romana ma indirettamente.

Il problema della derivazione delle fonti di cognizione

Legato alle fonti di cognizione c'è il problema della derivazione.
Questo perché la maggior parte delle fonti di cognizione con cui abbiamo a che fare, sebbene riproducano tante e informazioni interessanti per lo più sono frutto di rielaborazioni, di riedizioni, magari risalgono a secoli dopo rispetto al momento della loro edizione.
> E questo comporta, in particolar modo nell'ambito della letteratura, che su quei testi ci sono stati stratificazioni successive sia nella copiatura sia nella diffusione dei vari manoscritti, ma anche nell'adattamento rispetto alle funzioni a cui gli scritti erano preposti.
- Per cui per riuscire a capire il dato originari c'è uno studio molto approfondito e particolare.

> **L'unica fonte diretta** che riusciamo ad avere è uno scritto di un giurista d'età classica: Gaio (II sec. d.C.)
- Gaio Scrisse un manuale di institutiones, rivolto a studenti alle prime armi con il diritto: infatti institutiones vuol dire proprio fondamenti \ pilastri su cui costruire la propria formazioni.

- Ciò che però ci importa in relazione alle fonti di cognizione, è che abbiamo avuto la fortuna di riuscire a pervenire ad una conoscenza diretta del manoscritto che riportava le *institutiones* Gaiane grazie ad una scoperta dell'800 che ha fatto riemergere i cosiddetti *palinsesti** .
cioè: le pergamene venivano utilizzate a più livelli per scriverci su, e cioè le pergamene erano usate su più livelli per riscriverci su, e grazie alla scienza, nell'800, è stato ideato un procedimento chimico che ha consentito di far riemergere la vera scrittura gaiana ecco perché ne abbiamo conoscenza diretta.

- La riscoperta di queste scritture ha permesso di attuare delle correzioni\revisioni rispetto a delle congetture riguardo il diritto privato in ambito romano.

* Palinsesto: Manoscritto di papiro o pergamena, di epoca antica o medievale, il cui testo originario (*scriptio inferior*) sia stato cancellato mediante lavaggio e raschiatura e sostituito con altro (*scriptio superior*) disposto nello stesso senso o in senso trasversale al primo.

- Le institutiones di Gaio riguardano i fondamenti del diritto privato, e di fatto rappresentano un'eccezione, perché in generale i testi giuridici, lo abbiamo visto, hanno subito vicende complicate, e infatti le fonti che ci sono pervenute per lo più appartengono ad un periodo più tardo rispetto all'eta classica:
- ad un periodo in cui si è avuta quasi un'operazione di riduzione della letteratura classica: ci fu un intervento su quel patrimonio enorme un po di ritaglio e selezione, ecco perché i testi furono ridotti\cambiati.

> L'eta post classica ha rappresentato dunque un momento si di riproduzione di quelle opere, ma in maniera manipolata, per cui quando si ha davanti una fonte risalente all'età post-classica bisogna fare un'operazione duplice: prima accertarne il valore ed il significato al momento della sua edizione, e poi intuirne il testo originario, per cui il suo significato ed il suo valore nel momento in cui è stato realizzato.

Fonti di Produzione del diritto

Le fonti di produzione si distinguono da quelle di cognizione, perché consiste in tutti quegli atti da cui scaturisce il diritto stesso, ovvero i modi costitutivi del diritto. (il diritto come si forma? Da dove ha origine? —> lo sappiamo grazie alle fonti di produzione)

- Al giorno d'oggi siamo abituati, nell'ambito del diritto positivo, a considerare il parlamento che legifera, e siamo abituati all'idea di una gerarchia di fonti, *ma nel diritto romano non è così*: Questa gerarchia non c'è.

> Ma c'è una molteplicità di fonti tutte sullo stesso piano sotto al profilo gerarchico.
Questo discorso della molteplicità delle fonti innanzitutto riguarda l'età repubblicana e classica, quindi della repubblica e del Principato, e poi vedremo anche che c'è una piccola differenza tra l'una e l'altra data dall'aggiunta di una fonte in più.

Distinguiamo allora:

1. <u>La consuetudine</u> (= *opinio iuris ac necessitatis*)
É la convinzione che quel diritto siccome è attuato ripetutamente, siccome è un comportamento che si ripete e che da buon esito, allora è valido giuridicamente.

2. <u>Le Leggi</u>
Vedremo infatti la lex publica dell'età repubblicana, e vedremo come cambia l'accezione del termine nel corso del tempo.
- Nell'età repubblicana emerge l'importanza dei comizi popolari per l'approvazione delle leggi pubbliche

3. <u>Il plebiscito</u>
I plebisciti sono le deliberazioni della plebe nei loro concilia:
- La plebe aveva delle assemblee sue proprie nelle quali deliberava e si regolamentava autonomamente.
> Vedremo che ad un certo punto plebiscito e legge si equipareranno, e cioè le regole di comportamento stabilite all'interno del plebiscito furono ritenute valide per tutti i cittadini, e non solo per la plebe.

4. <u>Gli editti dei magistrati</u>
- Le magistrature, e quindi i magistrati, sono un altro organo repubblicano che si conserva anche successivamente, la cui prerogativa era quella di emanare editti ciascuno secondo le proprie competenze.
> Gli editti avevano valore normativo (= producevano diritto) e il meccanismo che presiede a questa funzione normativa degli editti è molto particolare e lo vedremo successivamente.
- Tra i magistrati, il magistrato più importante è il pretore, e gli editti dei pretori sono quelli a cui bisogna prestare molta attenzione.

5. <u>I *senatus consulta*</u>
Che sono le deliberazioni del Senato; la stessa parola specifica un'origine consultiva, e cioè sembrano essere dei veri consigli.
In realtà, il senato di per se non aveva funzione legislativo, ma trattandosi dell'organo che racchiudeva \ concentrava in se il ceto dirigente romano, che dirige la vita politica, allora i *senatus consulta* sono dei modi di produzione del diritto.

6. *Interpretatio prudentium* (o responsi dei giuristi)

- ovvero l'interpretazione dei giuristi che si concreta nella pratica del *responso*, che è il momento in cui il giurista riferisce la sua soluzione rispetto ad un caso controverso.

> Per quanto riguarda l'età classica (= il principato) va aggiunto all'elenco un altro elemento:

7. Le costituzioni imperiali

- Ovvero le leggi del principe.
- E cioè il principe si arrogherà anche l'attività legislativa: produrrà il diritto e lo farà mediante le costituzioni imperiali.

—> Notiamo allora la molteplicità delle fonti del diritto d'età repubblicana e classica a dispetto dell'età poi in età tardo antica, durante la quale si ebbe una riduzione di questo aspetto: la molteplicità scomparve a favore della sola "legge dell'imperatore".

Cronologia

Cronologia: logica del tempo.

- C'è una logica in base a cui qualcosa accade prima o dopo, e tutto è collegato, per cui è importante avere presenti le coordinate.

- La concatenazione degli eventi è fondamentale; ma il tempo include una molteplicità di durate:

> Ci sono realtà durevoli nel tempo (come ad esempio come le assemblee popolari, e quindi i comizi che nascono in età regia, si sviluppano in età repubblicana e durano anche in età classica con dei cambiamenti, ma anche il senato stesso o le magistrature)

> Oppure si possono vedere determinati eventi storici con una visione puntuale oppure nella loro durata (ad esempio le XII tavole che sono l'esito di un compromesso tra patrizi e plebei che prevedeva la nomina di una magistratura straordinaria investita del compito di redigere queste tavole, e quindi di mettere per iscritto una legislazione;

- E noi possiamo guardare al fenomeno storico come soluzione ad un conflitto di quel momento, oppure guardare le 12 tavole nella loro durata in quanto hanno avuto una vigenza oltre misura, ma non vigenza dei contenuti quanto come modello di riferimento che è stato perpetrato nell'arco dei secoli.

> Vedi scheda "cronologia essenziale"

> Partiamo dall'età repubblicana, che viene prima dell'età regia (= ovvero quella dei 7 re); dopo la monarchia abbiamo infatti la instaurazione della repubblica.

- ETÀ DELLA REPUBBLICA —> IV sec. a.C. - I sec. a.C.

> Convenzionalmente l'età della repubblica si suddivide in

- REPUBBLICA ALTA (o periodo arcaico) → Risale al VI / metà IV a. C.
- ETÀ MEDIA DELLA REPUBBLICA → metà IV a.C. alla metà II a. C.
- ETÀ TARDA DELLA REPUBBLICA → metà II a.C. al I sec. a. C.

1 - REPUBBLICA ALTA (o Periodo arcaico) (VI sec. a.C. - metà IV a.C.)

> 451-450 a.C.
Questo è il periodo che vide la nascita, grazie al decemvirato legislativo, della Legge delle XII tavole, incise su materiale ligneo.

> 390 a.C.
- Probabile distruzione delle XII Tavole
- Le leggi stesse, il loro contenuto, nonostante la distruzione vengono tramandate, e ciò è significativo: vengono tramandate oralmente (ovviamente questo comporta piccole variazioni) e successivamente verranno trascritte nuovamente. Qualcuno, poi vedremo chi, le riporta in un'opera.

> 367 a.C. Leges Liciniae Sextiae
- Queste sono importanti perché comportano il raggiungimento di un compromesso politico tra patriziato e plebe:
1 - Riconoscono l'esercito centuriato Patrizio-plebeo anche come somma assemblea deliberante (comizi centuriati)
2 - Si ha l'accesso della plebe alle magistrature, e quindi le magistrature non sono più prerogativa solo dei Patrizi in più
3 - Si costituisce la magistratura il pretore urbano, a cui può accedere anche la plebe e ha funzione di amministrare la giustizia.

> Da questo momento in poi, la società inizia a mutare, in quanto la plebe inizia a conquistare posizioni che prima erano riservate solo ai patrizi.

2 - ETÀ MEDIA DELLA REPUBBLICA (metà IV a.C. - metà Il a.C.)

> IV - III a.C.
- proprio questa partecipazione plebea nelle cariche che prima erano appannaggio dei Patrizi, comporta uno spezzarsi del monopolio pontificale del diritto:
- Se prima, nel periodo arcaico, il diritto era monopolio\ conoscenza esclusiva, segreta delle caste sacerdotali, in particolare dei pontefici (= custodi dei segreti del diritto), nel momento in cui è possibile per i plebei accedere a queste cariche, si spezza il monopolio pontificale e la giurisprudenza si laicizza.

> 242 a.C.
- Questo è un momento importantissimo proprio per l'istituzione del praetor peregrinus, istituito accanto al praetor urbani.
- L'istituzione di questo magistrato si spiega perché ci troviamo nel periodo dell'espansione di Roma sul Mediterraneo, per cui Roma inizia ad avere rapporti anche con gli stranieri, e quindi il diritto subisce un forte contraccolpo, di conseguenza si ha il superamento del formalismo e in più occorreva che ci fosse un magistrato competente ad occuparsi delle controversie tra romani e pellegrini: i romani infatti avevano la possibilità di andare a processo, i pellegrini no.
- Con l'istituzione di questo magistrato si collega uno stravolgimento in ambito giuridico, dato dal superamento del formalismo e da un'espansione di Roma da dimensione cittadina, formalistica, arcaica ad un orizzonte provinciale caratterizzato dai rapporti commerciali.

> 198 a.C.

- Data del consolato di Sesto Elio Peto Cato
- Le XII Tavole andarono distrutte, sappiamo che furono tramandate oralmente per un periodo, fino a quando proprio questo giurista, Sesto Elio, scrisse un'opera: i Tripertita (= divisa in tre parti).
- All'interno della quale:
. Nella prima parte troviamo il testo delle XII tavole così come era pervenuto oralmente, e
. Poi le altre due parti sono dedicate una a dei moduli di diritto processuali e l'altra alle interpretazioni dei giuristi.
- E grazie a sesto Elio se oggi noi abbiamo la prima opera che contiene il testo delle XII tavole

> Metà II a.C.

1. Publio Mucio
2. Manio Manilio
3. Giunio Bruto

- Questa è la triade dei giuristi più importanti per la tradizione civilistica: scrivono delle opere che hanno ad oggetto lo *ius civile* in un modo che comincia a tracciare una linea scientifica del diritto.

3 - ETÀ TARDA DELLA REPUBBLICA (metà II a.C. - I a.C.)

> 12Ca.C. *Lex Aebutia*

- Questa è importante perché comporta un cambiamento nell'ambito del processo.
- Prima il processo era formalistico: prendeva il nome di processo *per legis actiones*.
- Già con l'istituzione del pretore peregrino le cose avevano iniziato a cambiare, in fatti si affianca il processo formulare a questo *per legis actiones*, ma la *Lex Aebutia* determinò il superamento delle legis actiones, e quindi di quei moduli procedurali arcaici;
- Tant'è che introdusse il divieto di procedere con quei moduli se si era già agito con un processo formulare —> (divieto di lege agere dopo che si era agito per formulam de eadem re)

> 95 a.C.

- Consolato di Quinto Mucio Scevola
= Giurista importantissimo in ambito di diritto civile e scrisse "18 libri di diritto civile"

> 51 a.C.

- consolato di Servio Sulpicio Rufo
= Con questo giurista vedremo i forti mutamenti delle modalità interpretative del diritto, in particolare attraverso un confronto tra Scevola e Rufo, poiché vedremo che entrerà in polemica con Scevola.

> Fine I a.C.

- crisi della Repubblica
- Si ha ora l'ascesa di Ottaviano Augusto: abilissimo stratega che riesce ad instaurare il principato

> E così si inaugura l'età del principato

- ETA' DEL PRINCIPATO = (ETA' "CLASSICA") —> (I sec. a.C. - metà Il d.C.)
> È l'età più proficua e si scandisce attraverso le dinastie:

> 27 a. c. instaurazione del Principato augusteo

> Abbiamo il succedersi delle dinastie:
- Claudi (= Dinastia Giulio-Claudia che è quella di Augiusto)
- Flavi
- Antonini
- Severi

> 235 d.C. fine della dinastia Severiana

> Dopo la della dinastia Severiana si ebbero 50 anni di anarchia militare:

> 235-284 anarchia militare
- cinquant'anni in cui c'è una situazione di disagio e difficoltà, di disordine: c'è difficoltà per il potere che viene assegnato dall'esercito che nomina momentaneamente dei generali.

- ETA' DEL DOMINATO (= PERIODO TARDO ANTICO)
> periodo caratterizzato da una forma accentuatissima di assolutismo, più del principato, ecco perché prende il nome di "dominato" ed è il periodo in cui attecchisce la realtà del codice.

> Ill - IV d.C.
- Codex Gregorianus e Codex Hermogenianus

> IV d.C.
- Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum,
- Fragmenta Vaticana;
- Epitome Ulpiani

> V d.C.
- Codificazione teodosiana
- 426 d.C. —> Legge delle citazioni

> Prima metà Vl .C.
- in Occidente Lex Romana Visigothorum (506 d.C.)
- in Oriente Compilazione giustinianea (529-534 d.C.)

Capitolo secondo: Le "leggi antiche" e il senso della tradizione

1. Da Panezio a Cicerone: "parecchi sono i gradi della società umana"

Quando si parla di legge antiche per il mondo romano, il pensiero deve correre subito alle leggi delle 12 tavole, chi sono appunto le "leggi per eccellenza", tant'è che Gaio, nei *Digesta*, quando parla di *Lex publica* pare faccia proprio allusione alle 12 tavole.

È possibile indagare le 12 tavole sotto molteplici profili:

- Nei contenuti: e quindi guardare effettivamente cosa esse disciplinassero.
- Sotto il profilo filologico-linguistico:
  I precetti contenuti nelle 12 tavole si esprimono attraverso strutture molto semplici, con frasi coincise in cui normalmente vi è una formulazione ipotetica si parte dalla protasi introdotta dal "se" che va ad individuare facilmente i presupposti per l'applicazione della norma, seguita immediatamente dall'apodosi che esplicita la norma imperativa, quindi il precetto in sé per sé.
  E tale struttura aveva anche una sonorità, una facilità di formulazione, di ripetizione e memorizzazione che che è proprio lo specchio dell'abitudine alla memorizzazione tipica della tradizione orale.
  Cicerone infatti in un passo addirittura afferma che le 12 tavole venivano ripetute come un *carme necessario*, il che è reso possibile proprio grazie alla loro formulazione coincisa, sonora e semplice.
- Sotto il profilo socio politico:
  In quanto furono l'esito del compromesso patrizio-plebeo.
  Nel V secolo infatti ci furono tutta una serie di istanze plebee che sfociarono nell'esigenza di una legislazione scritta che potesse porre fine agli abusi dei Patrizi; infatti dobbiamo considerare che il potere e l'amministrazione del diritto stesso stavano interamente nelle mani dei Patrizi che erano coloro che rivestivano la maggior parte delle cariche pubbliche, per cui la plebe subiva una serie di vessazioni che portarono all'esigenza di una certezza del diritto che poteva essere data da una legislazione scritta, all'interno della quale, peraltro, cercarono anche di scalfire i contenuti favorevoli ai Patrizi, ma con scarsi risultati.
- In un'ottica tradizionalistica:
  Analizzando le 12 tavole infatti possiamo soffermarci sul peso enorme che queste hanno avuto nella tradizione civilistica, infatti le 12 tavole ne sono alla base, sono il sostrato legislativo dello ius civile (diritto privato dei romani).
  Le 12 tavole inoltre rispecchiano il formalismo intrinseco della società arcaica romana, che punta a garantire l'efficacia degli atti del processo stesso dei negozi attraverso l'ossequio rigorosissimo alle formule solenni, ai gesti predefiniti, a riti in cui l'efficacia dipende da un involucro esteriore di formule e di gesti ed in cui non conta l'interno volere.
  Infatti le 12 tavole vanno proprio a disciplinare tutta una serie di rapporti che proprio perché disciplinati vanno ad isolarsi come giuridici nella coscienza degli uomini.
  Ma dobbiamo comunque considerare che le 12 tavole racchiudono una cultura giuridica preesistente, che si era già costituita sui mores maiorum (sulle consuetudini) che era stata trasmessa oralmente di generazione in generazione, secolo per secolo, infatti la novità delle 12 tavole non sta nei contenuti, poiché fino a quel momento erano state proprio le consuetudini a guidare le condotte della società, ma la novità sta proprio nel fatto che con le 12 tavole vediamo per la prima volta una legislazione scritta.

Il testo delle 12 tavole era inciso originariamente su tavole lignee (probabilmente legno di quercia), esse furono emanate nel V secolo tra il 451-450 a.C., e alcuni decenni dopo, attorno al 390 a.C. furono distrutte in un incendio, presumibilmente proprio l'incendio gallico del 390.

Di fatto furono tramandate poi oralmente finché un paio di secoli dopo furono trascritte da Sesto Elio Peto Cato (nei *Tripertita*), anche se è inevitabile che il testo che ci è pervenuto abbia subito variazioni talvolta non solo nell'aspetto linguistico. Anche perché la lingua è lontanissima dal latino, ad esempio, del secondo quarto del VI secolo, ma anche al latino dell'epigrafe di Spoleto, successiva le 12 tavole di oltre 200 anni: è una lingua più moderna, è un processo di modernizzazione non si può escludere nemmeno nel profilo contenutistico, infatti gli stessi commentatori e interpreti antichi riportano alle 12 tavole regole e istituti che si sono formati successivamente e che ne trovano all'interno solo uno spunto.

Per averne un'idea complessiva è stato tentato un lavoro di ricomposizione dei frammenti (distribuiti in un ordine stabilito nell'800, fondato su presupposti arbitrari e accolto sulla base di una convenzione scientifica) reso possibile dal fatto che in moltissime opere anche molto successive vengono richiamati i precetti stessi, E in effetti già da qui possiamo comprendere l'importanza delle 12 tavole anche sotto il profilo della loro durata rispetto alla data della loro emanazione, infatti richiama le 12 tavole o i singoli precetti ricorre in testi giuridici e non giuridici come se questa legge fosse rimasta in vigore sempre proprio perché contiene la disciplina fondamentale dello ius civile.

Cicerone:
Tra i vari autori, abbiamo Cicerone fa riferimento alle 12 tavole ben 4 secoli dopo la loro emanazione.
Per esempio nel *De Officis*, (definito il manuale della classe dirigente romana, composto negli ultimi mesi del 44 a.C., pochi mesi dopo le Idi marzo che avevano visto la morte di Cesare) nomina le 12 tavole ben tre volte "di volo" su argomenti specifici, è una quarta volta ne fa riferimento implicitamente.

> Nel secondo libro del De Officis, Cicerone rievoca il tema del ricorso alle leggi antiche. E pur non menzionando esplicitamente il testo delle 12 tavole, parla di leggi, essendo consapevole del fatto che nell'immaginario della civiltà romana a cui si rivolge, parlare di leggi antiche evoca automaticamente il ricordo alle 12 tavole.

(Testo pag. 37)
Dunque Cicerone inizia rifacendosi ad un'età precedente rispetto a quella repubblicana (in cui vive), e cioè l'età regia, in particolar modo fa riferimento all'investitura regia, a quando la popolazione, trovatasi in difficoltà, investiva del potere un uomo degno e quindi capace di mantenere la giustizia, che si era distinto per virtù e che reputa all'altezza del compito: garantire l'equità.
Il monarca Deve incarnare proprio l'ideale di equità, il suo compito è quello di evitare eccessive sperequazioni tra chi è più abbiente e chi meno.
(non dobbiamo dimenticare da un lato che il criterio di eguaglianza dal punto di vista ciceroniano deve comunque coniugarsi con il rispetto delle gerarchie sociali e dei gradus digitatis, dall'altro che cicerone era intriso di istanze giusnaturalistiche, per cui il diritto lo vedeva come una realizzazione dei principi di natura tre quali c'era il principio di equità inteso come "dare a ciascuno il suo" e non ledere il diritto altrui.)
E l'eguaglianza è dunque considerata la massima aspirazione del diritto, ecco che allo stesso modo questo discorso dell'investitura del monarca ai fini di garantire la giustizia, sta alla base anche delle leggi: le leggi hanno lo stesso scopo, la stessa funzione che un tempo era affidata al monarca.
Per cui le leggi, e sottintendiamo le leggi delle 12 tavole, nella narrazione di quattro secoli dopo, di un periodo che aveva già visto l'evoluzione dell'ordinamento giuridico romano da monarchia a Repubblica, sono la fonte, la garanzia dell'uguaglianza della giustizia e della sicurezza dei rapporti tra i privati cittadini.

> Un altro riferimento, sempre di Cicerone che ci permette di cogliere il valore simbolico delle 12 tavole, lo ritroviamo nel primo libro del *De Officis*, in cui Cicerone linea un disegno della società romana come una piramide capovolta che parte dalla cellula minima arrivando poi a quella più articolata, e cioè parte dall'individuo, la famiglia, e poi la città la nazione, il genere umano nella sua interezza; e nel mezzo si pone lo Stato che si presenta come una società naturale e storica.

(Testo pag.39)

Cicerone inizia ponendo a alla base della piramide capovolta il genere umano intero e il vincolo, inteso come vincolo naturalistico che tiene insieme questa società umana è la ragione e la parola, che uniscono gli uomini in una società naturale. E questo riunirsi in società, per Cicerone, è qualcosa di istintivo, di tipico del genere umano.

In questa società e poi è necessario porre una regolamentazione che disciplini le modalità di utilizzo dei beni comuni che la natura ha messo a disposizione, e distingue:

- Tutti quei beni che le leggi e il diritto civile hanno assegnato ai singoli, saranno nel loro possesso esclusivo: e qui fa riferimento ai diritti reali in particolar modo alla proprietà.
  (= Ed è qui che evoca le 12 tavole, cioè si parla di leggi e di diritto civile con un endiadi, che è una figura retorica in cui due termini si possono ritenere un tutt'uno, per cui lascia intendere che le 12 tavole sono alla base degli ius civile in quanto garantiscono il rapporto tra privati e quindi anche i diritti privati)
- E poi ci sono tutti gli altri beni per cui varrà, secondo Cicerone, il proverbio greco "tra gli amici tutto in comune".

Dopodiché Cicerone va a stabilire proprio i gradi della società umana secondo dei vincoli che vanno restringendosi:

- Anzitutto abbiamo la gente che appartiene alla stessa nazione, che parla la stessa lingua e che ha un legame saldo.
- Poi c'è la gente che appartiene alla stessa città, che ha in comune molte cose tra cui il foro, i templi, i portici, le strade, le leggi, i tribunali, e che ha un vincolo ancora più stretto.
- Poi i legami all'interno del gruppo familiare, che è ancora una volta un vincolo più intimo.

Cicerone è un oratore, è un senatore, ed è un conservatore, per cui il più delle volte nei suoi discorsi c'è un'ottica soggettiva; in effetti quella che fa non è un'analisi tecnica, che sarebbe tipica del giurista, ma Cicerone tende a fornire le sue visioni del mondo e di determinati fenomeni; in questo caso esprime una sua visione giusnaturalistica della città, del mondo e della società, dei rapporti tra gli uomini e dell'ordinamento in generale.per cui essendo lui calato nel periodo del pieno espansionismo di Roma, quindi nel periodo in cui Roma sta allargando i suoi confini colonizzando tantissimi territori, ed includendo nuove popolazioni, ecco che il suo discorso ha lo scopo di giustificare e legittimare l'espansionismo romano che dal III secolo in avanti si sviluppa notevolmente; per cui Roma avrebbe dovuto esercitare una sorta di protettorato sul mondo intero, E questa non è altro che la giustificazione delle colonizzazioni, e i temi della giustizia, del diritto naturale e dei rapporti tra i popoli ed individui erano essenziali in un contesto del genere.

E in effetti il richiamo delle leggi antiche come fondamento sul dominio privato delle cose, diviene poi metafora del dominio di Roma sugli altri popoli, per cui qui, in questo testo, Cicerone strumentalizza il motivo legislativo per cercare di far emergere l'esigenza del protettorato di Roma sugli altri popoli: quindi possiamo cogliere un duplice significato: quello più stretto in cui la rievocazione delle leggi del diritto civile sono alla base dello Stato romano e della società. E poi il discorso propagandistico dello Stato romano che deve diventare protettore sugli altri popoli.

> E questo è importante proprio perché ci consente di cogliere un altro aspetto dell'importanza simbolica delle 12 tavole in quanto il ricorso alle 12 tavole ritorna nei discorsi e nelle opere dei giuristi successivi in maniera differente, e ritorno perché i giuristi le hanno dentro di sé, Le 12 tavole sono impresse nel DNA di tutti cittadini romani.

2. Il dominio del mondo e la costituzione politica: un accenno di Polibio alle XII tavole

Polibio:

Cicerone, il cui disegno è di ispirazione panzana, ci offre un'ottica tradizionalisti Ca' che vede la coscienza del passato che si riversa continuamente nel presente, senza alcuna cesura.questo aspetto si ritrova anche nelle parole di una storico greco del III-II secolo a.C.: Polibio: autore delle *Storie* , un'opera storiografica di cui ci sono giunti intatti solo i primi cinque libri, dal sesto in poi cui sono giunti in maniera frammentaria.

Polibio non era uno storico erudito, ma si pone come testimone di un cambiamento rivoluzionario nella storia dell'umanità, e cioè si fa interprete di quegli "avvenimenti straordinari" che portano Roma a diventare un'indiscussa potenza mondiale, dominatrice assoluta di tutte le regioni della terra, il tutto nel giro di all'incirca cinquant'anni. L' analisi di Polibio infatti riguarda un periodo che va dalla seconda guerra punica, fino alla battaglia di Pidna (218-168 a.C), E comprende anche una riflessione politologica: si chiede quale potesse essere stato il sistema politico che aveva consentito a Roma di raggiungere tale espansione e tale supremazia indiscussa, e trova la risposta nella **teoria della costituzione mista**.

> Polibio sostiene infatti che la costituzione romana non è classificabile in nessuna delle categorie fondamentali (monarchia, aristocrazia, democrazia) perché queste tre forme di governo coesistono. Ecco perché costituzione mista.

E infatti sostiene che nella Repubblica romana ci sia un equilibrio tra una componente monarchica che si trova nell'attività e nella presenza dei consoli, una componente aristocratica che ravvisa nell'attività del Senato, e infine una componente democratica che ravvisa nell'attività delle assemblee popolari.

Tuttavia nonostante Polibio parli di un equilibrio che apparentemente sembra perfetto, è consapevole del fatto che ci sono delle difficoltà oggettive a mantenerlo.

> I due tratti fondamentali, che portano all'equilibrio sono:

- Annualità: In riferimento alle magistrature, queste cariche avevano durata annuale, e ciò garantiva un ricambio costante al potere.
- Collegialità: ad esempio, i consoli, non avrebbero potuto prendere alcuna decisione se non all'unanimità, ogni Console poteva esercitare il diritto di veto sull'iniziativa dell'altro, e questo garantiva una forma di controllo tale per cui si agiva sempre in maniera unitaria.

Tuttavia, nonostante i tratti popolari di questo sistema della costituzione mista siano innegabili, anche Polibio sa di non poter parlare di perfezione, in quanto se osservassimo più in profondità, ciò accorgeremmo che il vero arbitro della vita politica risulta essere il Senato:

> Infatti il Senato, formato da un'élite nobiliare patrizio-plebea svolgeva il ruolo direttivo predominante. È da questa classe (patrizio-plebea) che scaturiscono i magistrati, che convocavano l'assemblea del popolo (la quale non aveva nessun potere di iniziativa), e anche i tribuni della plebe che costituivano un collegio di 10 membri e potevano bloccare con veto ogni atto magistratuale.

> Anche se guardassimo il funzionamento delle assemblee popolari, cioè dei comizi, potremmo comprendere quanto fosse in effetti difficile conservare questo equilibrio, in quanto la reale partecipazione dei cittadini alla vita politica non era sempre assicurata:

- Molti cittadini, essendosi ormai Roma espansa così tanto, dovevano percorrere molti chilometri per poter esercitare il loro diritto di voto, e appare quasi strategico il fatto che ogni convocazione fu esclusa, ad esempio, proprio nei giorni del mercato, e cioè nei giorni in cui ci sarebbe stata un'affluenza maggiore di votanti.
- Inoltre era anche diffuso il fenomeno della clientela, e cioè c'erano dei soggetti che si prestavano a dare il proprio appoggio politico (ad esempio antichi clienti delle famiglie nobili, i liberti, popolazioni coloniali o municipali, queste ultime in relazione a coloro che gli avevano procurato la cittadinanza) in cambio di favori di vario genere.

Precisazione : Assemblee popolari:

1. Comitia Curiata

   > Prende il nome dalle “curie” , che erano associazioni sacrali, risalenti all'età reggia, e che funzionavano come unità di voto.

   > Le Curie erano 30,10 membri per ogni tribù gentilizia (Tities, Ramnes, Luceres).

   > Avevano funzioni:

   - Specialmente nell'ambito del diritto sacro, in questi casi erano presiedute dal Pontefice
   - In epoca regia, partecipavano all’*inauguratio* del Rex
   - In epoca repubblicana, avevano conservato la loro importanza riunendosi per la cosiddetta *Lex de imperio*: che era sostanzialmente l'investitura dei magistrati, e cioè la cerimonia nella quale i magistrati, una volta eletti, ricevevano il riconoscimento formale del loro potere.

   > Con l'affermarsi di altre prerogative all'interno di altri comizi, i comizi curiati andarono via via estinguendosi.

2. Comitia Centuriata

   > Anche detti *maximus comitiatus*, questi erano i comizi preponderanti, quelli che meglio rispecchiavano la realtà del popolo unito.

   > Si formarono gradualmente a partire dal periodo di Servio Tullio (VI secolo a.C.-IV secolo a.C.) per cui nell'età più remota della Repubblica.

   > I comizi centuriati erano assemblee di impronta militare, l'esercito oplitico infatti vi ritrova la sua forma politica: le centurie costituivano i quadri della leva militare e le unità di voto.

   > Erano assemblee d'origine timocratica, la popolazione era distribuita in cinque classi in base al censo, cioè a seconda della propria ricchezza (l'unità di misura della ricchezza generalmente erano i possedimenti terrieri), in questo caso il censo si traduceva nella possibilità di dotarsi di un’armatura:

   > Erano in totale 193 centurie:

   - 170 ripartite tra le cinque classi censi Tari della popolazione tra parentesi 80 solo per la prima classe)
   - 5 appartenevano agli inermi
   - 18 appartenevano alla cavalleria (quasi interamente Patrizia, formata da coloro che avevano sviluppato delle attività commerciali, e che erano stati capaci di mettere da parte una certa ricchezza)

   > La prima classe contava E i possessori di un patrimonio pari a centomila assi, solo loro potevano permettersi un'armatura con elmo, scudo, corazza e schinieri di bronzo, lancia e spada.

   Il patrimonio richiesto diminuiva per le classi successive, da 75.000 ad almeno 11.000 assi, per cui l'armamento diveniva meno oneroso, tant'è che le ultime due classi non avevano armi di difesa, ma solo lancia e giavellotto oppure fionda e pietre.

   > Nelle votazioni, si rispettava una gerarchia: si dava sempre prevalenza ai ceti più abbienti, che alla fine andavano a determinare le direttive delle azioni, infatti rispettando l'ordine gerarchico, partendo dalla prima classe che contava già da sola 80 centurie, considerando che spesso si metteva d'accordo con la classe dei cavalieri, che aveva interessi contigui ai ricchi e che contava 18 centurie, capiamo bene che già 98 unità di voto determinavano la maggioranza.

   - Di conseguenza, il meccanismo di promulgazione della legge e si democratico, ma nel momento in cui i meccanismi interni di deliberazione sono appannaggio delle classi più abbienti, e chiaro che diventa poco democratico

   > Funzioni:

   - Legislativa (votavano le leggi proposte dal magistrato che aveva la possibilità di comandare il popolo e la plebe, poiché c'erano anche i *concilia plebis* in cui erano i tribuni a convocare la plebe)
   - Elettiva dei magistrati più importanti (consoli pretori e censori)
   - Giudiziaria innanzi ai comizi centuriati si svolgevano i processi dei crimini particolarmente gravi, come quelli per cui era applicabile la pena capitale.

3. Comitia Tributa

> Questi comizi avevano una struttura diversa.
> Si erano formati in età repubblicana.
> Erano assemblee del popolo intero diviso in tribù intese come distretti territoriali della *civitas*: inizialmente erano 4 urbane e 16 rustiche, tuttavia siamo nel periodo dell'espansione di Roma, per cui ad ogni annessione di territorio le nuove zone venivano assegnate all'una o all'altra delle tribù per cui si arrivò nel 241 a.C. ad averne in totale 35.
> Ciascuna tribù costituiva un corpo votante, e la distribuzione dei cittadini in tribù avveniva secondo criteri che attenuavano la disparità con i cittadini più abbienti (tipiche dei *comitia* centuriati), perché qui si aveva una base di annessione territoriale.
> Infatti avevano funzioni:
- Legislative di competenza diversa da quelle dei comizi centuriati
- Elettive per i magistrati minori (edili curuli e questori)
> Erano convocate dal console o dal pretore.

+ *Concilia Plebis*

- Nello stesso modo dei comizi tributi, si riuniva il concilio della plebe, convocato dal tribuno della plebe, all'interno delle quali la plebe deliberava e si regolamentava autonomamente, producendo i plebisciti (Che rientrano tra le fonti di produzione del diritto).

> È da considerare che pian piano, a partire dalla *Lex ortensia* del 286 a.C., l'importanza dei comizi andò a decrescere: La *Lex Ortensia* andava ad equiparare le leggi e i plebisciti, per cui se fino al 286 A.C. i plebisciti valevano soltanto per la plebe, dalla *Lex ortensia* in poi queste deliberazioni della plebe arrivarono a valere per tutti cittadini equiparando le leggi.
- Col passare del tempo, però, molte leggi saranno dei plebisciti veri e propri.

Ritornando a Polibio…

> Nonostante questo disegno positivo della costituzione romana, dobbiamo precisare che la perfezione di cui parla Polibio non ne esclude il declino, anzi, la sua veduta non è ottimistica, ma tiene conto del fatto che **ogni costituzione ha un suo ciclo**: si trasforma, decade, e infine ritorna al suo punto iniziale, e se consideriamo in particolar modo lo stato romano, Polibio ne individua l'origine, la crescita, il culmine, e il suo mutare nel senso opposto, in quanto come effetto necessario prima o poi subirà una naturale trasformazione nel suo contrario.

- Acme
  L'acme la colloca al tempo della guerra annibalica (seconda guerra punica: 218-202 a.C), quando la costituzione mista si dimostrò essere ottima e perfetta.
- Momento iniziale
  Lo si fa a risalire a trent'anni dopo la spedizione di Serse contro la Grecia (480 a.C), e ciò ci induce a pensare che la costituzione mista a cui, scrive Polibio "i romani non arrivarono con un semplice ragionamento, ma attraverso lotte ed agitazioni" comincia il suo percorso storico con il decemvirato e la sua caduta.

> Per cui, nonostante non ci sia un riferimento esplicito, nelle Storie, alle 12 tavole, pare che sicuramente lo Polibio le considerasse un momento di svolta, le 12 tavole non possono essere sfuggiti alla coscienza storica; questo lo possiamo desumere in maniera indiretta:
Cicerone infatti ci offre la visione di Catone, contemporaneo di Polibio e probabilmente anche a lui vicino, che incarnava la sua stessa visione.

(Testo pag. 46)

In un passo del secondo libro del De Repubblica, cicerone dà voce a Catone che diventa espressione della sua epoca, e porta avanti un paragone tra:

- i popoli di altre civiltà,(in particolar modo fa riferimento ai greci)

Che affidano alla personalità di un singolo il compito di allestire un apparato normativo.

Fa tutta una serie di esempi

- I romani, che a differenza degli altri popoli hanno avuto una maturazione dello stato graduale, che ha attraversato i secoli e le generazioni: lo Stato romano non è frutto della mente di un solo individuo, ma di più menti, di più uomini, di più idee e di generazioni diverse.

> E questo è importante proprio perché nessuna mente umana da sola potrebbe far fronte a tutto ciò che è disciplinabile, ma occorre che vi sia un'esperienza storica che faccia maturare una civiltà giuridica, poiché nel corso del tempo, più menti riescono a concepire un ordinamento che si avvicini sempre di più alla perfezione.

> Qui vediamo dunque una visione storico-evolutiva dello Stato romano, abbiamo l'idea di un legame tra passato e presente senza cesure, c'è una continuità, poiché c'è il riversarsi continua del passato nel presente.

- Questa è una visione tradizionalistica che certamente rispecchia la visione di Polibio, poiché anche lui nel momento in cui parlava delle conquiste romane della costituzione romana, nel rappresentare l'elemento di grandiosità della civiltà romana parlava proprio di questo.
- E ciò che viene sottolineato è quindi una continuità, e non mutamento, e anzi le idee rivoluzionarie sono abolite rispetto ad uno storicismo evoluzionistico.

3. Le XII tavole e "l'immagine dell'antico"

La mentalità tradizionalistica intrinseca della società romana, ha delle ripercussioni anche sull'ordinamento giuridico della città, i cui settori fondamentali sono rappresentati dal binomio *leges et iura*, a cui si uniscono gli *iudicia*. Concentriamoci sul primo elemento: le *leges.*

La legge, in base alla mentalità tradizionalistica, non ha quell'incisività che ci aspetteremmo, non ha la capacità di modificare il quadro complessivo: c'è una sorta di impressionismo legislativo, di diffidenza verso la legge, che sono poi due facce della stessa medaglia.

Il ricorso alla legge è sporadico, non è frequente, piuttosto che ricorrere ad un intervento legislativo imperativo, nella civiltà romana si propende per l'interpretazione giurisprudenziale: c'è proprio una resistenza allo scalfire il sostrato della tradizione che è rappresentato dalla consuetudine.

La difficoltà è proprio quella di separarsi dal passato, di considerare la continuità in quanto nella mentalità tradizionalistica: più qualcosa era antico, tanto più era considerato autorevole.

Ma che cos'è quindi la legge?

Le parole non sono immutabili, così come abbiamo visto per i testi, anche le parole sono soggette a vicende alterne, la parola "legge" infatti non indica sempre la stessa cosa se riferita alla Roma monarchica, a quella repubblicana, o ancora quella del periodo del principato. (E lo stesso vale per "ius" in relazione alla Roma repubblica e del principato)

- Inizialmente, nel contesto dell'età monarchica: con "*leges*" si intendeva un comando autoritativo.
- Poi, nelle prime manifestazioni repubblicane: con "*leges*" si intendeva un comando unilaterale pronunciato dal magistrato, titolare dell'*imperium*, innanzi all'assemblea curiata o centuriata, ed era inoltre, secondo un'antica consuetudine, subordinata all'*auctoritas* del Senato nella sua parte patrizia, anche se questa ratifica, prima di scomparire del tutto, si trasformò in un parere favorevole sulla proposta magistratuale.

> Quindi, probabilmente, all'inizio della Repubblica la formazione della legge non coinvolgere il popolo, e solo più tardi il corpo civico interviene intervenne, ma semplicemente ratificare il comando del magistrato.

> È un giurista augusteo a darci una definizione di "*lex*" vera e propria:
"lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu"
"la legge è il comando generale del popolo o della plebe su richiesta del magistrato"

> Questa definizione, però, coglie la "legge" in una fase già matura:
Dobbiamo comunque considerarne l'itinerario:
- All'inizio era un comando unilaterale del magistrato sottoposto al Senato, successivamente interviene il corpo civile, e nel momento in cui questo giurista d'età augustea fornisce una definizione della *Lex publica* ne definisce anche un iter costituzionale, e cioè capiamo che da questo momento c'è una delibera del corpo che sia il popolo riunito o la plebe, su richiesta del magistrato: quindi c'è un'iniziativa magistratuale rispetto alla quale le assemblee popolari votano.

> Quindi anche se è una definizione matura, ci possiamo basare su questa per capire cosa fosse la *Lex publica*: e quindi capiamo che il magistrato si presentava dinanzi al maximus comitiatus, ovvero il comizio centuriato, composto formalmente in modo democratico, in cui era rappresentato tutto il corpo civico, e il magistrato sottoponeva a votazione la sua proposta che normalmente era ratifica (cioè in sostanza era scontato che alla fine venisse accettata).

> La legge inoltre, considerata nella sua dinamica, rimane essenzialmente orale così come altri atti privati e pubblici, o anche religiosi. Infatti dobbiamo considerare che il passaggio dalla dimensione orale a quella scritta e graduale, non netto, per cui nel momento in cui interviene la scrittura, non si va a confondere con l'atto legislativo vero e proprio.
Solo in epoca tardo-repubblicana il testo appare così rilevante da influire sulla stessa idea della legge, poiché prima il progetto è reso pubblico attraverso la scrittura nella *promulgatio* (comunicazione al popolo di un progetto di legge), e la proposta una volta approvata si traduce in un testo visibile a tutti.
In effetti abbiamo visto che la volontà precettiva della comunità romana si esprime significativamente nelle 12 tavole, per cui è possibile dare a questo testo legislativo un valore fondamentale: ecco perché possiamo affermare che quando diversi autori fanno riferimento alle *leges,* come ad esempio Cicerone, danno per scontato che i lettori arrivassero a pensare subito alle 12 tavole.
Proprio Cicerone nel *De legibus* afferma che solo ispirandosi al modello delle 12 tavole sarebbe stato possibile ordinare in un codice nuovo tutte le norme sul culto degli dei, sulle funzioni dei sacerdoti, sulle cerimonie religiose, sui sacrifici e sui riti funebri.e addirittura bisognava imitar neanche lo stile, perché le parole, sempre riferimento rispettando la mentalità tradizionalista dica, sono tanto più autorevoli quanto più sono antiche.

> È sempre Cicerone, stavolta nel *De Oratore,* a dedicare alle 12 tavole un elogio esplicito, seppur con finalità ben determinate:

(Testo pag.51-52)
> Innanzitutto introduce il discorso rivolgendosi a chi voglia approfondire gli studi filologici, e lo fa richiamando il nome di Elio Stilone, eccelso filologo, e suggerisce a chi voglia intraprendere questi studi di considerare tutto il diritto civile, i libri dei pontefici (sappiamo che i Pontefici erano stati i primi giuristi, avevano il monopolio del diritto e custodivano il loro sapere segreto nei loro libri) e le 12 tavole, in quanto da questi si può cogliere un'immagine fedele del mondo antico.
- Anche solo nell'uso di espressioni come “remota antichità del linguaggio” cogliamo l'idea della distanza storica, questi aspetti vengono visti da lontano rispetto a coloro a cui si rivolge Cicerone, rispetto a chi compie questi studi contemporaneamente a Cicerone, per cui sta allontanando il *ius civile* restituendo le 12 tavole ad un momento più risalente.
> Dopodiché si rivolge a chi predilige la “scienza politica” (è dubbio se con scienza politica intenda dire scienza giuridica o meno, ma comunque possiamo pensare che si riferisca a ciò che riguarda l'ordinamento giuridico romano), e a questi suggerisce di guardare alle 12 tavole in quanto disegno dell'ordinamento della città, in esse è possibile ritrovare anche gli interessi e le parti che compongono l’ordinamento.
- Notiamo che, a dispetto di quella distanza storica evocata precedentemente, qui sta passando ad un'attualità.Questo “gioco di specchi” può trovare lo sbigottimento dell'interlocutore, in quanto è chiaro che non è possibile ritrovare tutto l'ordinamento della città all'interno delle 12 tavole, non sono esaustive, ma ne fa riferimento in questi termini perché ha uno scopo apologetico dell'antico, Cicerone non vuole attenuazioni, ma vuole evocare un forte legame tra passato e presente.
> Dopodiché continua facendo riferimento a coloro che si dilettano nello studio della “filosofia”, anche in questo caso con “filosofia” probabilmente intende “scienza politica”, e quindi ciò che riguarda l'ordinamento giuridico, e ancora una volta ritroviamo l'idea che il diritto civile e le leggi delle 12 tavole siano esaustive di tutto ciò che riguarda la conoscenza dell'ordinamento giuridico della città; quando fa riferimento al diritto civile, dobbiamo intendere l'ordinamento giuridico della città nel suo insieme, almeno per ciò che riguarda i rapporti fra i singoli, e questo perché il diritto civile si forma in un'epoca remota rispetto a quella in cui scrive Cicerone, per cui le 12 tavole stesse e i libri dei pontefici ci riconducono alla sua fase più arcaica. Continua il “gioco di specchi”.

- E significativa l'iperbole del piccolo libro delle 12 tavole che “supera per il peso dell'autorità e per l'estensione del suo valore pratico intere biblioteche di filosofi”:
Dobbiamo considerare che Cicerone è esperto di filosofia, e conscio dell’enormità della letteratura filosofica, per cui quando afferma che il libro delle 12 tavole supera intere biblioteche di filosofi, utilizza questo dato amplificante in maniera consapevole, sta enfatizzando anche il valore pratico delle stesse 12 tavole, e lo sta facendo per raggiungere uno scopo particolare.
> Il suo **intento** è **ideologico**, Cicerone infatti si trova durante una fase critica della Repubblica in cui la Repubblica stessa sta vacillando, le prerogative dei senatori, classe a cui apparteneva Cicerone, sono in bilico, per cui, in questa fase in cui si stanno acutizzando anche i conflitti civili, Cicerone cerca di recuperare, strumentalizzandolo, un motivo ideologicamente forte, fondante della Repubblica: le 12 tavole. Sta dando enfasi all'antico per farsi che si recuperino i volti della Repubblica che stanno vacillando.
Dopodiché da un **valore pedagogico** alle 12 tavole, che va aldilà di ogni tempo, in quanto e grazie ai precetti che contengono che gli uomini sono in grado vincere le proprie passioni, frenare gli istinti, i desideri, difendere i beni, e "tenere lontani dei beni altrui il pensiero, gli occhi e le mani".
- Quando dice questo Cicerone fa emergere la sua ottica giusnaturalistica, fa infatti riferimento alla tutela della proprietà, e i diritti reali in generale come significativi dell’ius civile, E fa anche riferimento al processo nel momento in cui dice di tenere lontani gli occhi le mani e il pensiero dei beni altrui, fa proprio intendere la possibilità di potersi difendere, di avanzare le proprie istanze nella ipotesi di una controversia o di una conflittualità in generale: e questo è importante perché sottolinea la forza pedagogica dei valori che le 12 tavole apprestano, che sono resi inattaccabili dall'attività.

> In questo caso lo **scopo** di Cicerone è quindi **politico**, il richiamo alle 12 tavole non è alto che una strategia retorica orientata a rendere scandaloso ogni atteggiamento politico che abbia come scopo la compromissione di quell'equilibrio politico che vede a capo il ceto aristocratico che stava vacillando sotto i colpi dei conflitti civili, per cui attraverso il richiamo alla tradizione Cicerone cerca di legittimare le ineguaglianze (Cicerone era un senatore per cui era in una posizione favorita) e di mediare i conflitti.

Livio:
Abbiamo visto quindi la visione di Cicerone, quella di Polibio, e tramite Cicerone, quella di Catone che riflette quella di Polibio.
Ma ci sono anche autori successivi rispetto all'età repubblicana che menzionano le 12 tavole, ad esempio Tito Livio.
Livio è uno storico d'età augustea, autore dell’Ab urbe condita, l'opera con finalità propagandistiche rispetto al potere di Ottaviano Augusto; e Livio accenna alle 12 tavole, in particolar modo alle prime 10, alla loro discussione e approvazione, e ne fa riferimento in qualità di "fonte di tutto il diritto pubblico e privato”.
> Notiamo che nelle parole di Livio riecheggiano quelle di Cicerone, ancora una volta abbiamo l'immagine di un piccolo libro, quello delle 12 tavole, che contiene precetti esigui, scritti con una sonorità semplice e mnemonica, specchio di una società arcaica e contadina, che sono fonte di tutto il diritto.
> Anche qui è forte il **motivo ideologico** che in effetti si inseriva perfettamente nella **propaganda** augustea, ricordiamo infatti che Augusto, attraverso la propaganda, tentava di mistificare la propria scesa, strategicamente propagandava una restaurazione dell'equilibrio e delle istituzioni\ organi repubblicani, ma sappiamo che non fece altro che instaurare un potere assoluto: Con Augusto si inaugura il principato.

Capiamo bene, quindi, che in un contesto del genere il motivo delle 12 tavole si rivela utile è particolarmente adatto, Augusto infatti si poneva come continuatore della Repubblica non solo mantenendone le istituzioni, ma valorizzando anche gli *exempla maiorum*, un tratto ideologico dominante della propaganda augustea è proprio un forte richiamo i predecessori (ai *maiores*), portatori di costumi che ormai erano dei caduti nell'ultimo periodo dei conflitti civili repubblicani. (pensiamo, per esempio, alla riforma della famiglia.)

Tant'è che Augusto stesso, in alcune occasioni, ad esempio proprio per sostenere la sua riforma della famiglia, aveva recitato in Senato un'orazione sull'incremento delle nascite di Quinto Cecilio Metello Macedonico, risalente al secolo precedente; oppure, anche in un'altra occasione, utilizzo un discorso di Rutilio Rufo impiegato allo stesso modo: come un documento attuale, col fine di mostrare come non fosse lui il primo a prendersi cura di un problema che aveva già a faticato gli antichi.

E questo gli permette di ricollegarsi all'antico.

Per cui anche Livio, in linea con Augusto, cerca di stabilire un legame fra il nuovo e l'antico, di rievocare un collegamento tra tradizione e innovazione.

Possiamo ritrovare un esempio di quest'ottica nel discorso che, nel quarto libro, Livio fa pronunciare al tribuno Canuleia nel 445 a.C.: da cui appare la storia di Roma dall'età reggia agli anni centrali del V secolo come un succedersi di *res novae.*

(Testo pag.55)

In questo frammento, Livio fa un elenco di tutte le innovazioni avvenute nel corso del tempo nell'ambito dell'ordinamento giuridico della città. Fa una rassegna coincisa che attraverso il riferimento a personaggi specifici come Romolo, Pompilio, Tullio, e attraverso l'uso di espressioni come "non vi era mai-non vi erano mai stati-non c'erano" riesce a rimarcare proprio l'idea di novità e di sviluppo.

Dopodiché arriva alle 12 tavole, avvenimento recente rispetto alla sua epoca, e conclude con la domanda retorica "chi può mai credere che in una città destinata a durare in eterno e a svilupparsi immensamente non si sostituiranno nuovi poteri e sacerdoti, nuovi ordinamenti delle famiglie e degli individui?"

Per cui è plausibile, se non scontato, che ci possono essere in futuro delle novità importanti per l'ordinamento giuridico della città, in particolare possiamo far riferimento proprio all'ascesa di Augusto.

4. Ricerca giuridica e filologico-antiquaria

Le 12 tavole ricevono sin dagli inizi anche un'interpretazione nel senso tecnico-giuridico della parola.
Sono proprio le 12 tavole a costituire il fulcro della prima opera sistematica della giurisprudenza romana: i *Tripertita* di Sesto Elio, console nel 198 a.C.
Sesto Elio le scrive un commento diviso in tre parti di quel titolo, e la prima parte comprendeva il testo della legge, poi *l'interpretatio*, a cui si collegavano, nella terza parte, i moduli procedurali delle *legis actiones*. Sicuramente poneva al centro della sua ricerca le 12 tavole con uno scopo pratico, ma non solo, anche con un intento filologico-antiquario: quest'opera si colloca infatti in un contesto storico determinato: risponde al bisogno di un ceto di governo che, appropriandosi della tradizione, costruisce la sua cultura.
Dopo sesto Elio, la giurisprudenza prendi altre strade, e bisogna che si arrivi alla metà del I secolo a.C. per far si che si sposti l'interesse su un testo normativo: l'editto pretorio.
In realtà già nei decenni centrali del II secolo, il diritto civile inizia ad esprimersi in forme letterarie autonome, svincolate dal testo della legge decemvirale.

Quinto Mucio Scevola:
Ad esempio Q. Mucio Scevola, console nel 95 a.C., nella sua opera non fa riferimento alle 12 tavole, ma comunque non ignora gli istituti arcaici che vi si riconducono nonostante ormai non siano più attuali.

Servio Supicio Rufo:
Servio Sulpicio Rufo, che si pone spesso in polemica con Scevola, non si sa se abbia dedicato un commento all'antica legge, ma è certo che ne indagò attentamente il vocabolario.
Rufo, coetaneo di Cicerone, suo compagno di studi, proveniva da un'antica famiglia patrizia, fu console nel 51 a.C., ed è ricordato come abilissimo non solo nel diritto, ma anche nell'arte della dialettica, a cui per altro legava anche un gusto per la grammatica.

Antistio Labeone:
Sulla medesima linea di Servio Sulpicio Rufo, in epoca augustea, si mosse Antistio Labeone:
che pone nuovamente al centro di un commento le 12 tavole, riprendendole da un filone letterario.
Non conosciamo l'ampiezza del commento di Labeone, ma possiamo desumere che non sia di grande portata. Ne possiamo riconoscere un intento didascalico e pratico che si intreccia con l'analisi linguistica e la memoria storica delle 12 tavole, analisi che non era mera erudizione, ma attraverso questa si potevano fissare o controllare i criteri ermeneutici di portata generale: a provare questo aspetto ci sono i testi dei *libri posteriores* (Opera di Labeone pubblicata post mortem).

(Testo pag. 58)
Sesto Pomponio, ad esempio, riproduce un ragionamento labeoniano contenuto in quest'opera che descrive una *manomissio* testamentaria condizionale a cui è congiunto un legato a favore dello schiavo manomesso.
- Si pone in condizione un evento dal cui verificarsi dipende l'efficacia del negozio manomissorio: cioè lo schiavo in questione: Caleno, potrà essere libero, e avere ciò che gli spetta se "apparirà che gli abbia diligentemente tenuto i suoi conti".
Il quesito è posto in relazione a come intendere il verbo "*videbitur*" ("apparirà"), e cioè se intenderlo sul paiano dell'effettività e quindi "apparirà", oppure sul piano della potenzialità, e quindi come "potrà apparire" (*videri poterit*).
- Con questa riduzione semantica si conclude che l'evento posto in condizione si considera realizzato se l'accertamento è obiettivamente possibile, e quindi anche se non viene compiuto.
Questa interpretazione di Labeone si fonda su un richiamo agli interpreti antichi delle 12 tavole in particolare relativo all'interpretazione della disposizione decemvirale che riguardava l' *"actio acquae pluviae arcendae"* che conteneva le parole *"si aqua pluvia nocet"* che venivano in tese come se ci fosse scritto *"nocere poterit"* per cui in questo caso, bastava lo stato di pericolo, e non la produzione del danno, per esperire l'azione.

Aulo Gellio

Nel II sec. d.C. abbiamo ancora Aulo Gellio, autore delle *noctes atticae* che riporta un dibattito tra un filosofo accademico ed un giurista della sua epoca sulle XII tavole:
Questo dibattito verteva sull'analisi storico-linguistica delle XII tavole rendendole oggetto anche di una critica (quindi c'è anche un'ottica che richiama le XII tavole magari in senso critico).
Capiamo allora che le XII tavole sono una realtà presente, rispetto alla quale ci si rapporta inevitabilmente: Sono vive.

> L'analisi linguistica, aveva anche lo scopo di chiarire dettagli più lontani della legge antica, le parole e le abitudini remote che in effetti il trascorrere delle generazioni aveva cancellato dalla memoria.
Un esempio di dibattito, ci è dato da Cicerone (nel *De legibus*): è costituito dall'analisi della norma che stabiliva: *"Mulieres genas de radunto, neve lessum funeris ergo habento"* e cioè poneva il divieto alle donne di graffiasi le guance durante i funerali (che tra l'altro è una pratica diffusa ancora oggi in alcune culture popolari).
Il problema è attorno all'espressione "lessum habere".
- Lucio Acilio e Sesto Elio intesero il termine "lessus" come allusivo a qualche vestimento funebre.
- Elio Stilone, successivamente, dando loro torto, lo intese come "grido\lamento".

5. Distanza storica e abolizione della distanza

Abbiamo visto che dalla Repubblica al principato, Le 12 tavole sono oggetto di un'attenzione particolare sia nella letteratura, sia più specificatamente nella letteratura giuridica. (Cic. Carme necessario)
Dobbiamo però ricordare che le 12 tavole non sono un testo legislativo innovativo, ma la novità effettiva sta nella scrittura: I plebei infatti reclamavano una certezza del diritto che facesse fronte ad una gestione del potere basata sulla consuetudine, e che stava completamente nelle mani della classe più ricca: i Patrizi. La loro vittoria fu ottenere che quel diritto che ormai si era fermato rafforzato (le consuetudini) forse era chiuso in dei precetti scritti.
Quindi il contenuto delle 12 tavole è un contenuto risalente, e la novità sta nell'aver trascritto dei contenuti che si erano consuetudinariamente stratificati, per avere certezza del diritto.
Un altro aspetto da evidenziare è il fatto che il testo, in quanto frutto dei rapporti di una società che si stava ancora formando, non poteva essere esaustivo, non conteneva numerosissimi aspetti, tant'è che del diritto privato se ne trovano pochissime tracce.
Per cui l'immagine che ci restituisce al meglio il modo in cui i romani guardavano a quest'antica legislazione e quella del *binocolo*: ora rovesciato, ora inclinato nel verso giusto, in quanto appaiono o ingrandite e vicine, come una sorta di attualizzazione che ne coglie i contenuti superando il dato legislativo originario (es. metafora di cicerone e delle intere biblioteche di filosofi), o lontanissime ma avvicinabili attraverso un semplice gioco di lenti.
Quindi c'è una consapevolezza della distanza storica, ma anche un'abolizione della distanza storica stessa: cioè, c'è una mentalità tradizionalistica, che porta il passato nel presente, il passato è oggetto di osservazione, punto di riferimento in maniera distanziata o ravvicinata: di critica o di propaganda
> Al passato si riconosce la capacita di prolungarsi e di valere nel presente, e quel tradizionalismo consiste nel dare valore di paradigma\ di pietra miliare\ di paragone, a ciò che è antico e perdura, piuttosto che a ciò che è mutevole e transeunte (= di passaggio)
Quello che manca è la direzione verso il futuro, un orizzonte aperto e lungimirante.
Cioè noi ritroviamo nella visione degli intellettuali romani una grande valorizzazione della tradizione e del passato in relazione al presente, ma scarsa capacità di proiettarci al futuro.

Capitolo terzo: Il costume e la legge nell'esperienza arcaica

1. Tipologia

Diritto nei sistemi tradizionali:

Il diritto non moderno, o premoderno, non accetta l'idea del mutamento, poiché ha il suo principio di legittimità nella tradizione.

Diritto nelle società moderne:

Diversamente, nelle società moderne, il diritto è caratterizzato dall'aspetto della variabilità.
Il sistema giuridico delle società moderne non è vincolato da nessuna fissità sacrale, al contrario, è correggibile,modificabile (per mezzo della legislazione) a seconda delle situazioni: Il mutamento appare come qualcosa di normale, costitutivo e necessario per adeguarsi ai veloci mutamenti sociali.
Il diritto moderno è riconducibile ad una teoria strumentalistica, ed è proiettato verso il futuro che si vuole pianificare seppur appaia incerto.
In quanto positivo, è anche contingente, e cioè non viene solo "*posto*" , scelto con una decisione, ma vale per forza di una decisione.
E la positivizzazione del diritto (= la possibilità di mutarlo) è in rapporto con un'idea astratta del tempo: il momento in cui viene statuito non ha rilievo, e la forza vincolante delle norme stesse non dipende dalla loro durata. Non c'è nessuna differenza qualitativa tra il diritto vecchio e il diritto nuovo.
Tuttavia non dobbiamo pensare che la società contemporanea sia indifferenze per la conoscenza del suo passato, ma la realtà storica va colta.

2. Alcune domande sulla "legge" nei diritti antichi

Intendiamo la "legge" come: manifestazione di una volontà precettiva , vincolante (in qualche modo o misura) per una generalità di soggetti o una categoria di casi, da parte di un potere legittimato a produrla.

In questo senso più ampio, la "legge" non è un'invenzione dell'età moderna; ma potremmo risalire addirittura al III millennio a.C.

- Proprio dalla seconda metà del III millennio a.C., nella Mesopotamia, operava un potere sovrano legiferante.
- Nel II millennio, a partire dai secoli centrali, si collocano i testi legislativi Ittiti ed egizi.
- Fu importante il famoso codice di Hammurabi, che, inciso su una stele di pietra da Hammurabi il "re giusto" fondatore dell'impero babilonese, era al contempo un documento giuridico e un documento politico-propagandistico.
- Abbiamo poi nella Grecia arcaica un importante ruolo della figura del legislatore, che si incontra non solo nelle città più importanti come Atene, Tebe o Corinto, ma anche a Locri, Catania, Siracusa e Reggio. Creta stessa è considerata da sempre un centro di sapienza legislativa; proprio a Creta venne composta, nella prima metà del V secolo, la grande epigrafe di Gortina.
- A Roma, anche prima delle 12 tavole e fino i codici tardo-imperiali, vediamo un potere che emana norme.e chiaro che sono fenomeni diversi tra loro, e che dobbiamo distinguere.

> Ma da un punto di vista generale dobbiamo porci 3 domande che ci aiutano a comprendere il ruolo della legge nel quadro complessivo dell'esperienza giuridica:

1. La legge costituiva il momento più caratteristico?
2. Era affidata alla legge la modificazione\ correzione del sistema?
3. In che rapporto la legge si pone con il diritto esistente di volta in volta?

> I legislatori sumeri e babilonesi modificavano spesso le regole giuridiche procedendo a nuove codificazioni, e giustificavano il loro operare con la mancanza di leggi antiche o consuetudini.
Infatti secondo loro le leggi dovevano essere immutabili e perpetue:
immutabilità: su questo aspetto si insiste in modo impressionante nei codici e nelle raccolte (che impropriamente riteniamo "codici"), ad esempio:

- All'inizio del II millennio a.C. nella Babilonia meridionale troviamo Lìpit- ištar, re della dinastia Isin, a cui risale una raccolta di leggi completa di introduzione ed epilogo. In questa raccolta esalta il carattere equo delle misure da lui stabilite e arriva a lodare i suoi successori che sicuramente le rispetteranno, viceversa maledice coloro che distruggeranno la sua opera: per cui notiamo una sorta di "apparato protettivo" che ne stabilisce l'immutabilità.
- Allo stesso modo nel codice di Hammurabi, circa 200 anni dopo, sono contenuti riferimenti relativi alla durata del codice stesso, cioè si stabilisce che "nel trascorrere del tempo, e per sempre" ogni re dovrà osservare ciò che è inciso sulla stele, e quindi il contenuto del codice, senza cambiare le leggi e senza alterare il disegno originario.

> Questa idea di durata si può ricondurre all'origine divina del potere legiferante.
Ma c'è il problema del rapporto tra legge e diritto esistente, poiché queste raccolte antichissime non presentano mai il diritto in vigore nella sua interezza, e spesso e volentieri riproducono norme già osservate a lungo. Deduciamo quindi che la consuetudine sia un elemento fondamentale.

> Anche a Roma molte norme e istituti erano presupposti nelle 12 tavole, tuttavia non c'era più una prospettiva immobilistica, tipica invece dei legislatori antichi d'oriente.

3. Le XII Tavole e la scrittura

La tradizione giuridica romana ruota intorno alla legge delle 12 tavole, abbiamo già avuto modo di osservare le 12 tavole dal punto di vista degli intellettuali romani e greci del II e del I secolo a.C., ma non dobbiamo pensare che le 12 tavole vivano solo nella coscienza dei loro interpreti, hanno un loro tempo.

Le 12 tavole nascono nel periodo delle lotte sociali del V secolo a.C., e sono il risultato di una profonda trasformazione costituzionale: la forma di governo cambiò il potere passò dai consoli ai decemviri.
Per quanto riguarda la storia del consolato, non si sa se abbia costituito la prima magistratura suprema repubblicana, duplice e collegiale, ma comunque la sua durata fu continua per oltre mezzo secolo, seppur con notevoli interruzioni, fino agli accordi patrizio-plebei del 367 (Leges Liciniae Sextiae).

> Nel 451 fu investita di una funzione legislativa la magistratura straordinaria dei decemviri.
I primi decemviri (Non è sicuro che l'anno seguente si sia avuto un secondo decemvirato, o addirittura un terzo) furono scelti fra Patrizi (l'unico nome plebeo è quello di T. Genucio o T. Minucio, anche se si tratta di u nome interpolato). I patrizi, nobili di sangue, eredi dell'antica cavalleria dei re etruschi, concentravano nelle proprie mani sia il possesso della terra, e quindi la ricchezza, ma anche la direzione\ amministrazione della vita pubblica e della giustizia, da cui la plebe era esclusa.

> La plebe infatti aveva magistrati propri (tribuni della plebe che erano inviolabili in quanto sacralmente protetti, ed edili che erano i custodi dei templi), nei comizi tributi aveva un'assemblea, e nei comizi della plebe venivano deliberati i plebisciti che vincolavano solo la plebe, solo dopo molto tempo anche i plebisciti furono equiparati alle leggi e iniziarono a valere per tutti i cittadini romani (Con la Lex Ortensia del 286 a.C). — quasi come se "di una città sola se ne fecero due".

Non bisogna confondersi e identificare la plebe con la clientela: hanno infatti una storia distinta, anche se interferiscono l'uno con l'altro.alle stesso modo non bisogna nemmeno immaginare il ceto plebeo come omogeneo, al contrario era differenziato al suo interno e comprendeva infatti:

- Piccoli agricoltori
- Contadini privi di terra
- Commercianti e artigiani
- Famiglie di notevole potenza economica

E proprio queste ultime, il conflitto politico del V secolo a.C. assunsero un ruolo importante.

Nell'ambito di questo scontro patrizio-plebeo l'obiettivo che i plebei volevano raggiungere era soddisfare la necessità di una legislazione scritta.
Necessità che si poneva in quanto il potere si concentrava unicamente nelle mani dei patrizi, per cui i plebei erano soggetti a continue vessazioni, o comunque situazioni sfavorevoli.
In effetti, se andassimo ad analizzare i contenuti delle 12 tavole, potremmo cogliere la presenza di norme "socialmente" contraddittorie:

- Ritroviamo infatti norme favorevoli ai patrizi come ad esempio la servitù per debiti o il divieto di contrarre matrimonio con i patrizi.
- Ma vi sono anche norme che vanno chiaramente a favore dei plebei come ad esempio:
  - Chiunque era autorizzato, nella procedura esecutiva contro il debitore-proletario ("proletario" da intendere con l'accezione di "bracciante", in base alla connessione etimologica con il termine "prole"), ad intervenire per fermare l'azione del creditore e costringerlo a dimostrare che il fondamento della sua pretesa.
  - La disciplina dei funerali: il lusso, in quest'occasione, viene limitato, si abbandona uno stile nobiliare sfarzoso di origine etrusca; infatti, ad esempio, non ci potevano essere più di 10 suonatori di tibia, oppure più di tre indumenti funebri, era anche proibito sgrossare la legna per il rogo o spargere vino sul sepolcro, o ancora, I servi non potevano ungere il cadavere e coprirlo con lunghe corone (anche se si faceva eccezione per quelle "guadagnate con il proprio valore"), era inoltre proibito mettere oggetti d'oro sul rogo o interrarli (fatta eccezione per i denti qualora fossero uniti con l'oro)

> Dunque è chiara una risposta dei patrizi-decemviri alle volontà della plebe in fermento; Anche se dobbiamo considerare che ciò su cui premeva la plebe, più che scalfire i contenuti favorevoli ai patrizi, era avere una legislazione scritta, di cui, come sostiene anche Max Weber, è possibile una redazione sistematica anche solo nell'interesse della sicurezza giuridica. E inoltre, non è una novità che nell'ottica di una ricerca storico-sociologica, hanno interesse alla codificazione scritta, e quindi ad una certezza del diritto con gli strati sociali che soffrono maggiormente una mancanza di norme univocamente stabilite, e soprattutto accessibili e adatte al controllo dell'amministrazione della giustizia.

> Per noi la scrittura di una legge o di un libro è qualcosa di naturale, tuttavia nella civiltà antica è diverso: la scrittura infatti ha sempre costituito un problema anche molto tempo dopo la sua invenzione.si ragiona spesso intorno alla sua utilità o inutilità, in quanto la scrittura può essere vista come un mezzo di progresso o viceversa un pericolo per educazione\ formazione intellettuale\ organizzazione politica.

- Possiamo spingerci indietro sino ad Eschilo (drammaturgo greco antico che opera tra il quarto e il V secolo a.C.) che nel Prometeo incatenato parla del rapporto tra memoria e scrittura, che identifica come un rapporto di solidarietà, e in cui la scrittura è intesa come un mezzo di progresso.
- Al contrario, si pone in antitesi il punto di vista di Platone: nel Fedro, Platone attraverso le parole del re egizio, afferma che le lettere dispensano dall'esercitare la memoria, per cui *"arriveranno a produrre le oblio nelle anime di coloro che le abbiano apprese"*
- Anche Licurgo, fondatore della costituzione spartana, si dimostra in linea con la visione di Platone: infatti sostiene che le norme non dovessero essere scritte, in quanto, come i principi fondamentali, devono avere luogo solo nella coscienza degli uomini.anche le regole secondarie o marginali, se scritte si irrigidirebbero, impedendone un facile e continuo mutamento.

> Scrittura e oralità possono comunque coesistere, ad esempio le leggi di Caronda (VI sec. a.C.), in Grecia, che erano scritte in versi per facilitarne il ricordo orale, tant'è che le leggi si apprendevano attraverso il canto: questo era affidato mnēmones (rammentatori pubblici).

4. L’ispirazione greca

Contesto culturale in cui si formarono le 12 tavole.

La legislazione decemvirale si compie in un quadro culturale romano fortemente influenzato dalla cultura greca. Sotto il profilo della cultura e delle arti, infatti, nel V secolo Roma era molto più indietro rispetto alle Polis greche.

> In realtà, i rapporti tra Roma e l'area greca hanno origine antica, già prima del V secolo ritroviamo tracce di ceramica di importazione, ma non solo, quanto sappiamo sui culti e sulle tradizioni templari dimostra che Roma non era estranea al mondo ellenico.

Tracce maggiori di questo rapporto si collocano tra VI e V a.C., quando a Roma si svolse una notevole attività edilizia: furono infatti costruiti numerosi templi che vedono partecipare anche professionisti etruschi e della Magna Grecia (ad esempio il tempio di Cerere, che divenne l'unico archivio organizzato di Roma, e fu decorato proprio da artisti greci, che lasciarono anche inciso il proprio nome).

> Anche dal punto di vista dell'alfabetizzazione, sicuramente il mondo ellenico era più sviluppato.

Nel V a.C., polis come Mileto, Efeso o Atene, sotto questo aspetto, non sono minimamente paragonabili alla Roma dello stesso periodo.

Le 12 tavole nascono infatti in un periodo in cui a Roma saper leggere e scrivere non era diffuso a livello sociale, ma dobbiamo considerare che ogni testo legislativo non ha come unico scopo la sua propria conservazione, è fatto per essere eletto e conosciuto, per cui non dobbiamo pensare che, quando ebbero origine le 12 tavole, il popolo romano fosse una “*massa di villani analfabeti”*, ma, al contrario, le 12 tavole in quanto testo scritto ed esposto al pubblico, avevano destinatari nel corpo civico in grado di comprenderne almeno il tenore letterale.

> Uno sviluppo nell’ambito dell’esperienza letteraria si avrà nella seconda metà del III secolo a.C., in quanto nascono le prime traduzioni e imitazioni dell'epica e del dramma greco.

E solo alla fine dello III secolo, con Fabio Pittore, un patrizio, verrà scritta in greco una storia di Roma anche con lo scopo di difenderne la politica di fronte all'opinione pubblica mondiale.

- Solo agli inizi del II secolo, con Ennio, nasce una vera e propria letteratura latina (tant'è che Quinto Ennio viene considerato il padre della letteratura latina), e nelle sue opere esalta gli uomini, i costumi antichi e si fa anche interprete della teoria evemeristica (di Evemero di Messina, autore della prima metà del II secolo a.C.) secondo cui gli dei sono uomini valorosi, illustri e potenti, divinizzati dopo la loro morte.

E, ancora una volta, a testimoniare il legame con la cultura greca, tra il III e II secolo a.C. , il greco diventa una lingua molto diffusa negli ambienti colti romani, infatti in molte opere di autori romani, come Livio Andronico, Nevio o Plauto, ritroviamo titoli greci o grecismi.

> Anche l’ispirazione greca delle 12 tavole è sicura.

Livio e Dionigi narrano di un ambasceria unica ad Atene per conoscere le leggi straniere (= le leggi di Solone e delle altre città greche), o di una duplice ambasceria ad Atene e presso le città greche in Italia per informarsi sulle leggi migliori e adatte ai bisogni della comunità romana.

Nonostante questa notizia delle ambascerie inviate in Grecia non verrà più ripresa, il nesso tra le 12 tavole le leggi di Solone, o le leggi portate dalla Grecia, resta un motivo costante fino all'età tardo-antica.

(Tra l'altro c'è neanche la tradizione, secondo cui i decemviri ebbero come loro “autore” Ermodoro di Efeso, un contemporaneo e amico di Eraclito (VI-V sec. a.C.), ma in realtà è una notizia apparsa improbabile).

- In ogni caso, la notizia di un ambasceria ad Atene è plausibile (anche se ci sono dubbi su un *possibile anacronismo*, infatti, in primo luogo non si sa fino a che punto i gruppi dirigenti romani, in quel periodo, potessero spingere il loro sguardo politico fino al territorio attico, e in più, se così fosse, il modello di codice da portare a Roma avrebbe sicuramente contenuto degli emendamenti subiti dalle norme soloniche in più di un secolo di attività legislativa. Alla luce di questi aspetti, e delle tradizioni annalistica e antiquaria, siamo indotti a pensare che quella dell'ambasceria sia una leggenda costruita nel "secolo degli Scipioni", anche se alla fine da forma ad una realtà culturale autentica).

Oltre alla questione dubbia dell'invio di un ambasceria in Grecia, uno studio analitico può rendere problematica l'analogia fra singole norme decemvirali e norme che si possono ritrovare nelle varie leggi greche (anche se è lo stesso Cicerone che riconduce alle leggi soloniche la riduzione delle spese funerarie contenuta nelle 12 tavole e anche l'abolizione\ limitazione del lamento funebre).
Tuttavia è da considerare che l'idea stessa di una raccolta giuridica è un'idea tipicamente greca, in più, analizzando anche lo stile delle 12 tavole (che rimane unico e non si trova nella registrazione repubblicana posteriore) e il vocabolario tecnico, in molti casi, sembrano denunciare una chiara ispirazione ellenica.

In ogni caso, sia le leggi soloniche, sia le 12 tavole sono due tra i fenomeni legislativi più importanti del mondo antico, e nettamente distinguibili dalle grandi legislazioni dell'oriente.

Analogie:

- Entrambe hanno carattere spiccatamente laico: il legislatore non si pone come intermediario fra divinità e sudditi, ma è la città che si autodisciplina manifestandosi nella legge:la legge è infatti l'epifania della polis è la manifestazione del potere della comunità cittadina di darsi delle regole e di indirizzare la propria politica.

Differenze:

- La legislazione solonica era volta al mantenimento della polis e al risollevamento dei ceti più bassi dalle condizioni indecenti in cui versavano (garantendo loro anche solo una limitata e circoscritta rappresentanza politica), aboliva inoltre i debiti e la servitù che ne derivava stabilendo quasi un "equilibrio della ricchezza".
- Nelle 12 tavole non c'è nulla di simile, ma solo nel IV secolo si incontrano misure paragonabili a quelle delle leggi di Solone. (= le prime norme limitative di debiti si ebbero con le leggi Liciniae Sextiae del 367 a.C. riguardanti "terra, denaro e onori", e che furono approvate dopo una durissima lotta. Successivamente nel 323 (o 313) con la legge Petilia, che segna per la plebe l'inizio di una nuova libertà, si vietò che debitori fossero imprigionati: "nessuno poteva essere tenuto nei ceppi in catene a meno che non avesse compiuto qualche delitto" (Livio).

5. Il meccanismo del mutamento

La legge\ il diritto, in quanto creazione umana, non è eterno ed immutabile. Partendo dal presupposto che una legge, quando non è preceduta da un diritto legislativo già costituito, si basa sulla consuetudine.
E per quanto alla consuetudine si possa conferire autorevolezza, bisogna comunque considerare che la società va avanti, e quindi il diritto come espressione dell'uomo non può essere immobile, ma è mutevole. Nelle 12 tavole stesse, che avevano una loro origine consuetudinaria e non facevano che riversare in un testo legislativo un diritto che si era già consuetudinariamente affermato, ritroviamo un precetto, di cui ci dà testimonianza Livio, che prevede il meccanismo del mutamento: "tutto ciò che il popolo ha deliberato da ultimo, Deve considerarsi giuridicamente valido".
Il significato di questo criterio cronologico e che di fronte a due leggi contrastanti l'ultima prende il posto dell'antica: e questa è proprio la previsione della la possibilità di mutamento.
- Una prima applicazione pratica di questo precetto la si ebbe appena cinque anni dopo le 12 tavole con la *Lex Canuleia* (445 a.C.) che aboliva il divieto di matrimonio tra patrizi e plebei, E prese il posto di quel progetto decemvirale con cui era in contrasto (cioè quello in cui i matrimoni tra patrizi e plebei erano vietati) ed essendo questa legge l'ultima emanata, era quella ad essere in vigore.

Questo principio, però, non vede applicazioni così semplici, fu infatti al centro di numerosi dibattiti: era dubbio quando la volontà popolare potesse derogare a abolire una legge; cioè, siccome i comizi venivano riuniti per vari esigenze, ci si domandava se tutte le situazioni fossero idonee ad introdurre una legge nuova, e quindi se si potesse derogare e abolire una legge o solo in occasione di un'assemblea convocata apposta per promulgare una legge oppure anche in caso di convocazione, per esempio, per eleggere un magistrato.
- A tal proposito possiamo far riferimento alla vicenda del censore Appio Claudio il Cieco, eletto nel 312 a.C., che era un sostenitore della durata della carica di censore per cinque anni, quando invece c'era una legge del secolo precedente (la legge Emilia del 434 a.C.) che aveva limitato la durata della carica di censore a 18 mesi. Appio Claudio il Cieco sosteneva che la legge Emilia riguardasse solo i censori dell'anno in cui era stata emanata, mentre, e ce lo racconta sempre Livio, la nomina di lui costituiva una nuova deliberare popolare nel senso appunto delle 12 tavole. Dunque fece vale questo precetto, ma lo fece in modo non pacifico, in quanto il tribuno della plebe Publio Sempronio riteneva che questo ragionamento fosse inaccettabile e solo strumentale all'azione politica, poiché, nel senso delle 12 tavole, doveva valere la legge Emilia era stata osservata da tutti i censori fino a quel momento.
E quindi, in quest'occasione, il comizio si era riunito per l'elezione del magistrato, però aveva introdotto sostanzialmente una delibera totalmente nuova cioè quella di allungare la carica di censore.
La domanda era se valesse o meno quella legge espressa in quel contesto particolare.

Certo è che non troveremo mai una testimonianza di abrogazione di una legge, avremo solo espressamente in contrasto con leggi precedenti e che le vanno a soppiantare senza l'esplicita cancellazione della precedente legge. Per cui, in realtà, non c'è nessun ostacolo formale a che la legge possa abrogare, superare o cancellare una consuetudine (al massimo ritroviamo una valutazione critica del dato tradizionale, ma mai un'espressa cancellazione).
> Giuliano, illustre giurista del II sec. d.C, disse "tutto ciò che gli antichi hanno stabilito, si può rendere ragione, si può capire"

Un fenomeno singolare che caratterizza il diritto romano e la mentalità tradizionalistica che si spiega proprio all'interno del rapporto tra *ius e leges* (quindi tra legge e consuetudine), ed è il fenomeno delle *leges imperfectae.* Ciò ci aiuta a comprendere quanto il dato consuetudinario sia quello più forte e persistente di quello autorevole, posto che comunque alle leggi non si può negare il proprio valore innovativo del diritto: il dubbio è se queste norme consuetudinarie rappresentino un ostacolo alla capacità innovativa della legge.

Normalmente siamo abituati a considerare un meccanismo che presiede alle leggi, e dobbiamo fare una distinzione; in apertura dell'Epitome Ulpiani (operetta scolastica tarda) troviamo una classificazione delle leggi. Distinguiamo:

- Le leggi perfette sono quelle in cui al principio\ disciplina\ precetto segue una sanzione per la sua trasgressione: l'efficacia del diritto è garantita proprio dall'apparato sanzionatorio
- Le leggi imperfette contengono un precetto, ma la trasgressione di questo non corrisponde ad alcuna sanzione: non c'è né una pena né una sanzione in caso di trasgressione, ma si dispone la nullità dell'atto compiuto.

C'è inoltre una via di mezzo rispetto a leggi perfette e imperfette:
- Le leggi *minus quam perfectae* (= meno che perfette) in cui non si dispone la nullità dell'atto ma solo una pena a carico del trasgressore.

> Ci sono state varie spiegazioni per questo fenomeno:

1- Vi è chi, agli inizi del 900, spiegava questo fenomeno come "un argine elevato contro l'abuso del diritto in senso stretto, pur lasciando quest'ultimo in vigore".
Ciò significa che la consuetudine, intesa come un costume eterno e inderogabile, non verrebbe inclinata in nessun modo dalle leggi perfette, non verrebbe messa in discussione, in quanto la legge non farebbe altro che introdurre un contenuto nuovo senza munirlo della sua efficacia (= della sanzione).
E quindi le leggi imperfette non sarebbero altro che una conferma dell'inscalfibilità delle consuetudini.

2- Un altro orientamento, sulla stessa linea, ha spiegato le leggi imperfette come un fenomeno che da atto della impermeabilità della consuetudine (= del *ius*) di fronte alla legge, e cioè considerando ius e lex come due sfere distinte, come se lo *ius* non potesse essere penetrato\ permeato.
E ciò dimostrerebbe quindi l'eternità della consuetudine che non si infrangesse neanche con una legge.
(Sebbene poi la realtà della consuetudine sia smentita dalla realtà dei fatti, in quanto i contesti cambiano).

3- Un'altra visione, più pragmatistica, vede il costume\ consuetudine non come eterno e inderogabile, ma come qualcosa che è possibile scalfire, infatti le leggi imperfette dimostrerebbero proprio la difficoltà di mettere in discussione alcune situazioni radicate e consolidate (e quindi la difficoltà di dichiarare nulli alcuni negozi formali).
Secondo questa visione, quindi, la legge può applicare la consuetudine ma mai in modo esplicito, mai abrogandola e cassandola in modo esplicito, per cui le leggi imperfette sono congeniali alla mentalità tradizionalisti poiché non mettono in discussione i rapporti pregressi tra privati: dichiarano dei principi ma non è sanzionano l'inosservanza. Però producono elementi degni di considerazione che pian piano si fanno strada e possono mutare le relative discipline.

4- Secondo un'altra spiegazione, la legge può invece modificare il diritto consuetudinario, può farlo ma lo nasconde, in quanto alla legge, anche quando innova, si riconosce sempre l'unico scopo di "dichiarare" e non di costituire il diritto che indivisibile nel tempo. Ma se fosse così eviteremmo le leggi perfette che mettono in questione i diritti già acquisiti nei rapporti fra privati, e solo le leggi non perfette si dimostrerebbero idonee a non produrre il caos, poiché possono applicarsi senza scalfire l'indivisibilità temporale dello Ius.

- Dunque, consapevoli della complessità del problema (testimoniata anche dalle numerosi spiegazioni", tirando le somme, possiamo affermare che alla legge non si può negare un valore innovativo, modificativo e abrogativo del diritto, poiché è qualcosa di costitutivo della legge: nel momento in cui la legge viene emanata viene apportata una modifica al sistema.

Ed è sbagliato anche pensare che la consuetudine sia eterna e che lo ius sia inderogabile ed inscalfibile. Per cui le leggi imperfette, nel momento in cui introducono la disciplina, la immettono nel flusso vitale del diritto: non ne prevedono una sanzione, ma introducono un contenuto che gradualmente viene preso in considerazione e sedimenta il suo valore introducendo una novità che inevitabilmente può contrastare con una consuetudine pregressa.
Del resto anche le 12 tavole nel momento in cui prevedono la possibilità del mutamento, in realtà sono proprio la conferma che l'idea di inderogabilità eterna del costume è venuta meno. Questo è un momento importantissimo.
La consuetudine non viene mai esplicitamente messa discussione, ma viene modificata attraverso la legge, e le leggi imperfette dimostrano la difficoltà della mentalità tradizionalista a realizzare questa idea.
Le 12 tavole quindi aprono una via dal punto di vista della non eternità dell'inderogabilità delle consuetudini.

E questa è quasi una formulazione moderna all'interno del diritto romano, poiché abbiamo visto che specialmente nelle primissime legislazioni addirittura era presente proprio un "apparato protettivo" che riguardava l'aspetto della durata della legislazione stessa (= il legislatore si preoccupava di far rispettare quella legislazione dei propri successori), con le 12 tavole la situazione è diversa, è più moderna, leggi hanno una capacità modificatrice che seppur adattata con le leggi imperfette ad una mentalità tradizionalistica, rappresenta un passo in avanti.

6. L' "evidenza sensibile" delle forme: autonomia privata e processo

Abbiamo visto che nelle 12 tavole ritroviamo anche riferimenti sia agli atti di autonomia privata sia al processo arcaico. Non dobbiamo, però, dimenticare che, proprio gli atti di autonomia privata, così come il processo, prima di essere assunti o richiamati nel testo legislativo (in particolare al processo nelle 12 tavole si dedica un ampio spazio) sono diventati stabili congegni verbali e gestuali.

Formalismo e valore creativo della parola

> Per comprendere questi elementi bisogna porre una premessa:

In questo contesto sociale arcaico in cui le 12 tavole sono specchio di una civitas ristretta che rimarrà tale fino al III - II secolo a.C., un aspetto fondamentale è il formalismo:

> Jhering (letto: ièring), importante autore romanista tedesco dell'800, diceva che tutto il mondo romano fosse percorso da "uno sforzo di rendere visibile l'invisibile attraverso le forme", e tutta la vita privata, pubblica e religiosa è dominata dall'amore per la forma.

- Capiamo quindi che tutti gli ambiti della vita erano impregnati di rigoroso formalismo:

. Anche l'appartenenza ad un ceto si atteneva a determinate formule (c'era infatti un modo determinato di vestirsi, un determinato atteggiamento con cui porsi che rendeva visibile l'appartenenza al ceto specifico)

. Allo stesso Modo si poteva comprendere la condizione giuridica in cui si era (un cittadino libero si ritrovava rappresentato in una condizione diversa rispetto al esiliato, colui che ha già ricevuto una pena, a colui che invece era stato solamente accusato o che era ancora sotto processo).

- Quindi il concetto del formalismo è quello di portare le leggi romane entro salde forme in tutti i settori della vita, tutto era impregnato di formalismo anche a livello antropologico e sociologico; ci troviamo nei confini di una società all'interno della quale passa attraverso le forme la certezza dei rapporti che si muovono entro linea fissa e sicure: non si aveva bisogno di una manifestazione più evoluta e articolata.

(Per cui il formalismo si spiega molto di più entro una società arcaica)

Anche il diritto, in questo periodo, ha una natura formalistica, cioè presenta la necessità di adempiere a rituali con parole e gesti predeterminati che danno propriamente forma al diritto.

Si parla infatti di:

- Formalismo delle azioni: che riguarda gli atti processuali, delle actiones, con riferimento proprio alla procedura e all'attività del processo
- Formalismo negoziale: che riguarda i negozi giuridici dei privati, e che in modo analogo prevede il rigoroso rispetto di schemi, formule e riti.

C'è anche un precetto decemvirale che rende pienamente il senso del formalismo chiamando in causa due atti di autonomia privata: *"se si compie un mancipium o un nexum, il diritto sia così come con la lingua si sono pronunciate le parole."*

- E cioè: così come si è pronunciato, così come la lingua ha pronunciato la formula, così sia il diritto.

> Vediamo quindi sia la rigidità del formalismo, ma soprattutto l'idea del ***valore performativo del linguaggio*** (addirittura qualcuno ha parlato di valore magico della parola): sono le formule, è la parola che da sostanza\ crea il diritto attraverso le modalità rigorose con cui la formula è espressa (e quindi ogni volta che si conclude, in questo caso, un *nexum* o un *mancipium)*.

Nell'analisi di questi atti, dobbiamo quindi partire dal presupposto che la forma ha una rilevanza esaustiva, ciò che conta non è la volontà\ l'intenzionalità, ma la validità o la nullità di qualsiasi atto dipende esclusivamente dalla forma: l'atto difettoso nella forma è nullo irrevocabilmente, così come l'atto che non presenta difetti formali e irrevocabilmente valido.

Proceso civile arcaico: processo per legis actiones

Al processo, quindi ai modi della procedura giudiziaria, è dedicato largo spazio nelle stesse 12 tavole, e già questo ci fa capire quanto fosse importante: in quanto il processo è il volto più espressivo del diritto.
(il giudizio come atto di sovranità collettiva e, al pari della legge, un momento caratteristico nella formazione della città.)

> Nel mondo romano arcaico, il processo privato è un sistema di *legis actiones*.

Terminologia:
Un tentativo di spiegare il significato di *"legis actiones"* attraverso un'indagine terminologica, seppur riscontrando qualche difficoltà, fu compiuto da Gaio.

Gaio, maestro antonino del II secolo d.C., è l'autore delle *institutiones* (= un manuale istituzionale di cui abbiamo anche conoscenza diretta, cosa rarissima per le fonti risalenti all'età classica), questo manuale era rivolto ai giovanissimi che si approcciavano il diritto, presenta proprio le fondamenta del diritto privato, e nel quarto libro si occupa delle azioni (= cioè di ciò che avviene durante il processo).

Gaio, rendendolo didatticamente efficace, affronta il tema delle actiones con una sorta di linea storica risalendo alle origini remote (in quanto nella sua epoca il processo era cambiato rispetto alle *legis actiones*)

11. Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur vel ideo, quod legibus proditae erant (quippe tunc edicta pratoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur), vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo inmutabiles proinde atque leges observabantur.

Unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, cum debuisset arbores nominare eo, quod lex XI tabularum, ex qua de vitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur.

12. Lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per iudicis postulationem, per condictionem, per manus iniectionem, per pignoris capionem.

11. Le azioni, che gli antichi usavano, si chiamavano *azioni di legge*, o perché introdotte da leggi *(dato che a quel tempo gli editti del pretore, con i quali molte azioni sono state introdotte, ancora non usavano)*, o perché adeguate alle parole delle leggi stesse *e per ciò custodite immutabili al pari di leggi.*

Onde a colui che avendo agito per taglio di viti in modo da nominare le viti nell'azione fu risposto che aveva perso la causa, in quanto avrebbe dovuto far menzione di alberi, giacché la legge delle XII tavole [451-450 a. C.], in base alla quale l'azione per taglio di viti competeva, parlava genericamente di alberi tagliati.

12. Secondo legge si agiva in cinque modi: con scommessa, per richiesta di giudice, per intimazione, mettendo la mano addosso, per presa di pegno.

Par. **11)** Gaio sta cercando di spiegare perché questo processo si chiama *"per legis actiones"* .
Individua due spiegazioni:

1- Perché introdotte da leggi, e quindi basate su delle leggi.

> Aggiunge un inciso: *"Dato che a quel tempo gli editti del pretore, con i quali molte azioni sono state introdotte, ancora non usavano"*
- Dice questo perché nell'età antonina, periodo in cui visse Gaio, si era venuto a creare un processo diverso detto *processo formulare* che di fatto era un'evoluzione del processo, e si basava sugli editti dei pretori, e Gaio, dato che si rivolge ad un pubblico di giovani studenti, con questo inciso, vuole rendere l'idea del passato remoto a cui risale ciò che sta esponendo, rispetto alla sua epoca.

2- Perché ricalcate sulle parole delle leggi stesse.

> Continua facendo riferimento all'immutabilità delle parole pronunciate durante il processo, e dice "e per ciò custodite immutabili al pari di leggi."
> Dopodiché fa proprio un esempio della rigidità assoluta: Fa riferimento al precetto decemvirale che conteneva la disciplina di un tipo di azione relativa al taglio degli *arbores* (alberi).

- Fa l'esempio di un cittadino che avendo subito il taglio di alcune viti da parte di un altro, volle intentare un'azione\ volle andare in processo per recuperare il danno subito da colui che aveva danneggiato le viti.

- In questa situazione, l'attore (colui che aveva subito il danno) doveva intentare un'azione che fosse strettamente attinente alla previsione della legge, doveva essere formalmente ineccepibile: per cui la parola da utilizzare doveva essere "arbores" e non "vitis".
- Dunque nel momento in cui l'attore aveva pronunciato "vitis" anziché "*arbores*" nella formula con cui stava intentando l'azione, nonostante le viti siano incluse nella categoria alberi, costui aveva perso inevitabilmente la causa.
- E questo perché non è la razionalità a comandare, ma la forma.

—> Questo esempio esprime appieno il senso della rigidità del formalismo processuale (e quindi delle legis actiones) poiché vediamo che anche solo una sottile inesattezza terminologica non era contemplabile: la formula andavo osservata in maniera rigorosissima.

La difficolta di Gaio:

Gaio arranca un po' nella definizione, e questo perché ogni volta che il giurista si avventura in un'etimologia, dato che non esisteva una scienza terminologica esatta che andasse alla radice terminologica della parola, lo fa ricercando assonanze e somiglianze che potessero essere funzionali al contributo che si voleva esprimere, talvolta generando in errori o imprecisioni.

> Nel nostro caso, un'analisi successiva, più approfondita, ha prodotto proposte più pertinenti sul perché il processo arcaico sia definito "per legis actiones":

- Dobbiamo concentrarci sul termine *"Lex"*: se si scava bene tra i vari significati del termine *"lex"* si trova anche quello di *"rito"* \ *"congegno formale"*.E quindi *"lege agere"* (agire secondo legge) può essere inteso anche come *agire secondo un rito\ congegno formale.*

> Ecco che ci ritroviamo perfettamente con un significato (terminologicamente più fondato) di legis actiones.

12) Nel paragrafo successivo, gaio elenca i 5 tipi di legis actiones che noi distinguiamo in due gruppi a seconda del loro scopo\ funzione:

1 - *Legis actiones di accertamento* (o *di cognizione*, o *cognitorie*):
- Legis actio per sacramentum
- Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
- Legis actio per condictionem

2- *Legis actiones esecutive*
- Legis actio per manus iniectionem (o manus iniectio)
- Legis actio per pignoris capionem

> Prima di trattare nel dettaglio ognuno di questi tipi di processo, occorre porre delle premesse:

—> Distinzione Magistrato - Giudice

Noi siamo abituati a considerare magistrato e giudice come sinonimi.
In ambito romano non è così:

- Magistrato:
  Sappiamo che nel mondo romano le magistrature sono molteplici, il magistrato implicato nel processo civile arcaico è il *Praetor Urbanus* (Pretore urbano):
  - Fu istituito nel 367 a.C. con le *Leges Liciniae Sextiae*.
  - È titolare di:
    - ***Imperium*** (che sarebbe il potere fondamentale)
    - ***Coercitio*** (ha il potere di attuare misure coercitive)
    - ***Iurisdictio*** (è competente a livello giurisdizionale: presiede il tribunale.
      Iurisdictio, da ius dicere "dire\ affermare il diritto": è il potere, di cui sono dotati alcuni magistrati detti giusdicenti, di impostare in termini giuridici la controversia: il magistrato indica la norma idonea al caso su cui il processo si deve svolgere).
  - Giudice:
    In quest'ambito il giudice (*iudex*) era:
    - Un privato cittadino, non istituzionalmente collocato nell'organigramma della res publica, talvolta anche sprovvisto di cognizioni giuridiche.
    - Ma che è un *vir bonus*, cioè ha mostrato alla società, attraverso la sua condotta, un equilibrio, delle qualità tali per cui può essere investito del **compito** di formarsi un convincimento ed emanare la sentenza attraverso l'attività dello *iudicare.*

—> Dobbiamo quindi distinguere *Ius dicere - Iudicare*

- ius dicere che è prerogativa del pretore
- iudicare: la *iudicatio* è prerogativa del iudex

—> Il processo civile arcaico si divide in due parti:

- A questa distinzione tra le prerogative dell'una e dell'altra figura che intervengono nel processo corrisponde la distinzione in fasi del processo civile arcaico:

  - La fase *in iure*
    = Presieduta dal magistrato (*iure* ha valore locativo: *"innanzi al tribunale del magistrato"*)
    che quindi è titolare della *iurisdictio*, ed è in questa fase, innanzi al magistrato giusidcente, che si imposta la controversia. (non è il magistrato colui che emana la sentenza).
  - La fase *apud iudicem*
    = Presieduta dal giudice (*apud iudicem*: *"presso il giudice"*) che ha la *iudicatio* ed è colui che emana la sentenza.

1. *Legis actiones di accertamento* (o *di cognizione*, o *cognitorie*)

> Sono quelle azioni che hanno come obiettivo l'accertamento di determinate situazioni giuridiche: ecco perché "di cognizione". Lo scopo è proprio la conoscenza della verità giuridica\processuale\ che emerge dal processo.
- Ad esempio vanno ad accertare la titolarità di un diritto (ci può essere un proprietario che rivendica la sua proprietà su una determinata cosa, e quindi quell'azione mira all'accertamento di questo titolo di proprietà)

Nel processo troviamo:
> Le due parti, la cui presenza è necessaria:
- Attore = colui che ha l'iniziativa, che avanza la pretesa, cioè colui che intenta l'azione giudiziaria (in senso tecnico l'azione è proprio l'iniziativa processuale dell'attore)
- Convenuto = colui che viene *"vocato in ius"* (chiamato in giudizio)

> Pretore e Giudice innanzi ai quali si svolgono rispettivamente la fase in iuris e la fase apud iudicem.

> Due o più testimoni innanzi ai quali avviene lo scambio delle dichiarazioni.

<u>Fase in iure:</u>

- Si svolge innanzi al pretore:
  Al quale spetta un ruolo meramente direttivo e di controllo dell'attività delle parti per far si che tutto si svolga in modo corretto sotto al profilo formalistico (poiché, ovviamente, è richiesta la pronuncia di parole solenni e il compimento di gesti definiti).
- Si inizia con la *"in ius vocatio"*:

> L'attore deve convocare in giudizio l'avversario intimandogli di seguirlo dinanzi al magistrato, talvolta anche trascinandolo con la forza, ma comunque secondo modalità rigorosamente stabilite.
(Nelle 12 tavole è proprio indicato che qualora il convenuto rifiutasse di andare in tribunale, allora l'attore doveva afferrarlo, se il convenuto tergiversava o si impuntava, l'attore gli doveva "imporre la mano", qualora invece il convenuto non riuscisse ad andare innanzi al magistrato poiché "malattia o età" erano di ostacolo, allora l'attore doveva fornire un giumento e, se non vuoleva, non prepari un carro coperto.
- Cit. pag.95 -)

- Si procede con la *"litis contestatio"*:

> Lo scambio delle dichiarazioni delle parti prende il nome di *"litis contestatio"* , e avviene innanzi a dei testimoni: cioè le due parti chiamano i presenti a testimoni delle dichiarazioni, invitandoli a tenerne buona memoria per le dichiarazioni che verranno fatte di fronte al giudice (= tutto ciò per preservare la corretta e rigorosa osservanza delle formule), Infatti con la litis contestatio le parti esponevano sinteticamente le loro ragioni da far valere davanti al *iudex* che poi le avrebbe valutate e avrebbe deciso la sua sentenza.

<u>Fase apud iudicem:</u>

- Si svolge innanzi al giudice

Il giudice, singolo o collettivo, che, a seguito dello scambio delle dichiarazioni delle parti, dopo aver raccolto ed escluso le prove, doveva emanare la sentenza come esito conclusivo dell'azione giudiziaria, alla quale (sentenza) non era opponibile nessun'altra *legis actio*.

1) *Legis actio per sacramentum*

Questa legis actio è quella su cui abbiamo più notizie (che ci sono pervenute da Gaio)
> Poteva essere espedita

- In rem = Per rapporti di tipo reale (= attinenti alle res)
  Aveva lo scopo di perseguire la res presso chiunque e si trovi, cioè potevano essere intentate verso chiunque si trovi nel rapporto con la res.
- In personam = Per rapporti di tipo obbligatorio
  Aveva lo scopo di far valere un'obbligazione, cioè la responsabilità conseguente ad un mancato adempimento. Per cui era intentabile sono nei riguardi del soggetto che è inadempiente.
  Cioè, siccome è un'azione a presidio di un rapporto obbligatorio (che nasce con un'obbligazione tra le parti) allora l'azione deve perseguire l'inadempimento dell'obbligazione, per cui l'azione può essere intentata solo nei confronti del soggetto inadempiente.

> Legis actio per sacramentum in rem

La *Legis actio per sacramentum in rem* è quella su cui abbiamo più notizie, ma lo schema È analogo rispetto a quella *in personam.*

Fase in iure:
> È necessaria sia la presenza delle parti, sia la presenza fisica della res contesa (tant'è che quando si trattava ad esempio di un fondo, ci si recava sul fondo stesso a celebrare il processo).

- Si comincia con la *in ius vocatio* dell'attore:
  L'attore convoca l'avversario (il convenuto) innanzi al magistrato.
- Si procede con la *litis contestatio*:
  Quindi avviene uno scambio di dichiarazioni formali e solenni tra le parti in presenza dei testimoni.
  > Se guardiamo però alle dichiarazioni che queste due parti si scambiano, sembrano quasi essere tutte e due parti attrici: tutte e due sullo stesso piano. Infatti notiamo che:
  - L'attore pronuncia la formula vindicatoria
    Es. "Io dico che questa cosa è mia secondo diritto dei quiriti"
  - Il convenuto pronuncia una contra vindicatio
    Es. "Anche io dico che questa cosa è mia"
  > Quindi sono sul piano di parità: ciascuno fa un'affermazione uguale ma contraria all'altra rispetto alla titolarità di un diritto sulla *res* contesa.
  > La *litis contestatio* è accompagnata inoltre da un *simbolismo gestuale*:
  - la res, che che abbiamo visto doveva essere presente fisicamente durante il processo, viene infatti percossa con una festuca (simulacro della lancia, era una sorta di bastone simbolo di ogni dominio e *potestas*)

  > Immediatamente dopo questo rituale, il magistrato, sempre attraverso parole solenni, ordina alle parti di lasciare libera la *res.*

  > E poi ne da il possesso temporaneo a quella delle due parti che fornisce maggiori garanzie di restituzione della *res* dopo la sentenza. (Questo perché la res stessa, durante lo svolgimento della sentenza potrebbe produrre frutti\ valore, ad esempio nel caso di un fondo, e la restituzione deve essere fatta in maniera completa, quindi compresa del valore aggiunto, alla fine del processo, dopo la sentenza)
  - Si facevano inoltre intervenire dei garanti di questa restituzione della cosa e dei frutti eventualmente prodotti che prendono il nome di *Praedes lìtis et vindiciàrum.*
- A questo punto le due parti si sfidavano al *sacramentum*: il sacramento non è altro che è un giuramento\ una scommessa (inizialmente era un giuramento religioso, poi venne sostituito da una scommessa di tipo pecuniario). Le due parti si sfidano a pagare all'erario una determinata somma di denaro in caso di soccombenza, anche qui con delle parole solenni.
- E anche qui intervengono dei garanti che prendono il nome di praedes sacramenti.

Fase apud iudicem:

Con il sacramento si chiude la fase in iure. (che abbiamo visto essere caratterizzata dalla gestualità della festuca, dalla presenza dei garanti, dalla direzione del magistrato con ruolo direttivo di controllo)

Se tutto avviene regolarmente si procede con la fase apud iudicem:

- in questa fase il giudice deve esprimersi tramite la sentenza.
- Probabilmente ci sarà anche l'esclusione delle prove (cioè delle prove che le parti avevano portato a sostegno del proprio buon diritto)

> E la sentenza e sarà in relazione a quale dei due sacramenta (quelle affermazioni su cui le parti si erano sfidate) sia iustum e quale iniustum:

> La sentenza si esprime in questi termini:

"Utrius sacramentum iustum, utrius iniustum sit"

= cioè quale sacramento sia conforme al diritto e quale no delle due parti.

- Quindi indirettamente si sancisce la soccombenza di una parte rispetto all'altra, e la soccombenza significa pagare la somma di denaro stabilita.

> Questo è l'esito conclusivo: la condanna a pagare la *summa* stabilita durante il sacramentum.

> Legis actio per sacramentum in personam

Lo schema è analogo.

- Nella fase *in iure*, sempre con parole solenni e seguendo una rigida formula, l'attore affermava che convenuto avesse contratto un debito nei suoi confronti indicandone anche la somma.

Rivolto al contendente chiedeva di confermare o negare.

- In caso di negazione si passava alla sfida reciproca, al *sacramentum,* e poi si continuava come per la *legis actio per sacramentum in rem*.
- La *summa sacramenti*, pagata dalla parte la cui affermazione risultava infondata, veniva incassata dall'erario e non dalla controparte.

2) *Legis actio per iudicis arbitrive postulationem*

> Questa legis actio hai il suo momento caratteristico nella richiesta di un giudice o di un arbitro.

> Vi si ricorreva per divisione di cose comuni, ad esempio coeredità, oppure per regolamento di confini, oppure per far valere un credito da stipulazione (cioè originato dalla *sponsio*).

> In questa legis actio tutte le parti che volevano regolamentare questa suddivisione di cose comuni chiedevano la nomina di un giudice (o di un arbitro nel momento in cui c'era bisogno di trattare controversie in cui bisognava avere conoscenze specifiche tecniche o capacità di valutazione economica).

> Proprio perché c'è un interesse comune delle parti ad ottenere ciascuno la propria quota di "cosa inizialmente comune" , in questo tipo di legis actio c'è una sorta di mancanza di controversia, per cui è difficile distinguere tra attori e convenuti.

> È da Gaio che sappiamo che questa azione veniva utilizzata per le obbligazioni nascenti da *sponsio:*

> **Sponsio:**
> La *Sponsio* (o *stipulatio*) si configura nell'epoca delle 12 tavole come un contratto verbale molto semplice: consiste in uno scambio contestuale e solenne di domanda e risposta tra:
> - Il futuro creditore che interroga e chiede: *"Spondes?"*
> - Il futuro debitore che promette e afferma *"Spondeo"*

> *S*e qualcuno si era impegnato con questa promessa solenne dando origine ad un'obbligazione, nel caso in cui era stato inadempiente, nei suoi confronti era possibile agire con una *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*, e si procedeva cosi:

- L'attore affermava nei confronti dell'avversario il suo credito con un congegno verbale apposito, e affermava che il convenuto fossi obbligato nei suoi confronti in base ad una *sponsio*.
- Come per la *legis actio per sacramentum in personam*, anche in questo caso l'attore (creditore) chiedeva al convenuto (debitore) se affermasse o negasse (il tutto con formule solenni)
- A questo punto qualora il convenuto negasse si affermava la nomina di un giudice o di un arbitro e si passava al momento dell'accertamento della sussistenza della *sponsio*, e quindi all'accertamento della promessa.

3) *Legis actio per condictionem*

> Che non è nelle XII tavole, ma è stata introdotta da leggi successive tra il III-II d.C. (Da una legge Silia per I debiti consistenti in una somma certa di denaro, ed estesa da una legge Calpurnia ai debiti di cose individualmente o quantitativamente determinate.)

> La *legis actio per condictionem* può essere intentata per debiti di certa pecunia o di certa res:

- Di somme di denaro: "certa pecunia"
- Di cose determinate: "certa res"

> Anche qui

- C'è l'affermazione solenne dell'attore relativa all'esistenza del debito,.
- L'attore afferma che il convenuto è tenuto nei suoi confronti a dare (es.) centomila sesterzi (= certa pecunia), e quindi esplicita la somma\ o la cosa in particolare per cui il convenuto è debitore.
- Poi chiede se il convenuto affermi o neghi invitando il convenuto a prendere posizione.
- Ove il convenuto neghi, allora si ha l'intimazione (ecco perché *conditio*) a presentarsi innanzi al magistrato entro 30 giorni per ricevere la designazione del iudex che determini poi la sentenza.
(Si ricorreva a questo processo nei casi legislativamente previsti)
- Il trentesimo giorno le parti si recavano innanzi al pretore per scegliere il giudice e il compito del giudice era quello di accertare l'esistenza del debito.

2. *Legis actiones esecutive*

> Sono quelle azioni che mirano a dare seguito, appunto dare esecuzione, a delle situazioni già accertate.

- Ad esempio, se c'è stata una sentenza che ha decretato l'appartenenza di un bene ad un soggetto (dando luogo ad un titolo esecutivo) ma vi è la renitenza del condannato che non esegue la sentenza, chi ha la sentenza dalla sua parte, alla possibilità di intentare un'azione per garantirsi l'effettività di quella pronunzia.

> Ecco perché si dicono esecutive: danno esecuzioni a casi già accertati, oppure a dei casi in cui è previsto legislativamente esercitare questo tipo di azione.

1) *Legis actio per manus iniectionem (o manus iniectio)*

La *manus iniectio* aveva luogo
- Sia nel caso in cui vi era stata una sentenza contro un debitore inadempiente, e quindi il creditore era legittimato a compiere un'azione esecutiva: proprio *la manus iniectio*.
- Sia nel caso di una *confessio in iure*: cioè è anche possibile che un debitore confessasse innanzi al magistrato di essere realmente inadempiente e che dovesse dar luogo ad un'obbligazione. E anche in questo caso si ricorreva alla *manus iniectio*.

Accadeva che:
- Una volta accertato il debito, si danno al debitore 30 giorni per dar seguito alla sentenza, e cioè per pagare il debito riconosciuto.
- Passati i 30 giorni, il creditore doveva portare il debitore in tribunale, e se la sentenza non veniva eseguita e nessuno interveniva in tribunale a favore del debitore, il creditore poteva impossessarsi, con la forza, del debitore insolvente (proprio la persona fisica del debitore).
- Quindi il debitore veniva legato con catene o ceppi ai piedi, anche in questo caso secondo procedimenti stabiliti, infatti non dovevano essere meno di 15 libbre, e veniva trascinato a casa del creditore.
- Qualora non riuscisse a mantenersi autonomamente, era stabilito che il debitore fosse nutrito con una focaccia di farro al giorno in quantità prefissate (una libbra).
- Nei successivi 60 giorni veniva condotto per tre volte al mercato pubblico proclamando la sua situazione e la somma di cui era debitore: con lo scopo di ottenere il riscatto di questo debito da parte di qualcuno.
- Se nessuno, in queste tre volte, intendeva riscattarne il debito, allora l'attore poteva ucciderlo o venderlo come schiavo in territorio straniero (si dice *Trans Tiberi* "oltre il Tevere", che veniva considerato già territorio straniero).

> Oltre che per lo svolgimento rigorosamente formalistico, la manus iniectio ci permette di cogliere anche il senso dell'antichità\ arcaicità delle legis actio:
- Siamo infatti in un contesto arcaico, che utilizzava metodi anche socialmente visibili, in quanto le varie condizioni dovevano essere conosciute da tutta la società quasi umiliando l'inadempiente. (Vedi il fatto che il debitore fosse trascinato a casa del creditore, o l'esposizione della propria situazione al mercato)

- Tant'è che addirittura nelle 12 tavole si prevede un precetto secondo cui, qualora vi fossero più creditori che avevano subito inadempienza dallo stesso debitore, nel momento in cui non riuscivano ad ottenere il risarcimento dei vari debiti, insoddisfatti, avrebbero potuto uccidere il debitore dividendolo in parti come simbolo di una soddisfazione comune.

- E questi sono procedimenti arcaici, cruenti e rudimentali, che ovviamente ben presto vennero superati. Sono retaggi di una società meno evoluta, che però verranno superati, infatti questo riscatto da una situazione di assoggettamento per debiti verrà poi non più sottoposto a questo genere di soddisfacimento, ma verrà sostituito da uno stato di prigionia che durava finché il debitore, attraverso il suo lavoro, fosse riuscito a riscattare il debito.

2) *Legis actio per pignoris capionem*

> Gaio quando descrive questa azione *"per presa di pegno"* dice che in realtà è un procedimento un po sui generis: un po' singolare, che quasi poco sembra una *legis actio*, in quanto presenta caratteristiche tutte sue:

- Si volgeva al di fuori del tribunale, per cui in assenza del magistrato, e talvolta anche in assenza dello stesso avversario.

- Poteva essere attuata anche nei giorni nefasti
  (C'era il calendario dei giorni fasti e nefasti, in particolare nei giorni nefasti non si svolgevano determinate attività, comprese quelle processuali: cioè le legis actiones non avvenivano nei giorni nefasti, eccetto questa per pignoris capionem)

> La legis actio per pignoris capionem aveva luogo nel momento in cui il creditore si impadroniva, egli stesso, dei beni del debitore:

- Quest'impossessamento avveniva attraverso la pronuncia di parole determinate: "certa verba", ma senza l'intervento o il concorso di nessun organo statuale, e quindi notiamo che il potere pubblico, in questo caso, sembra quasi in secondo piano rispetto all'agire del singolo (aspetto che in realtà si nota anche nella *manus iniectio* o nella *sponsio*).

- lo scopo era fare pressione psicologica sul debitore per indurlo ad adempiere a ciò per cui era stato condannato, e quindi indurlo a pagare il debito; Questo perché, ovviamente, il debitore non avrebbe restituito quei beni finché il debitore non l'avesse risarcito del debito, e dobbiamo considerare che nel mondo romano, col passare di un determinato periodo di tempo, il possessore di una determinata cosa, in questo caso dei beni del debitore, poteva diventarne addirittura proprietario.

Atti di autonomia privata di trasferimento della proprietà

Abbiamo visto che ciò che caratterizza le varie leges actiones è il formalismo.
Lo stesso formalismo appare anche negli atti di autonomia privata\ nei negozi giuridici, ad esempio nei modi di acquisto della proprietà.
> Anche in questo caso bisogna porre delle premesse:
- E la proprietà si articolano in modo diverso a seconda delle categorie di res.
- È infatti possibile classificare le res in base ai risvolti che hanno fatto, e cioè sulla base del fatto che possono essere o non essere oggetto di determinati atti negoziali.

> Distinguiamo

1) ***Res mancipi:***

Sono *res* che possono essere trasferite con l'atto di trasferimento della proprietà della *mancipatio.*
Sono quelle più preziose ed economicamente più rilevanti in quella società arcaica e rurale di cui stiamo parlando, che verso queste res ha un occhio di riguardo.
- Ne comprendiamo l'importanza dato il loro numero esiguo, sono solo 4:
  1- Servi
  2- Animali da tiro e da soma
  3- Fondi
  4- Le servitù rustiche (e cioè le servitù di passaggio o con i carri, o col bestiame, o a piedi, o il passaggio dell'acqua).

> Per trasferire la proprietà di queste res mancipi occorreva appunto la *mancipatio* (o *mancipium*).

2) ***Res nec mancipi:***

Le *res nec mancipi* sono tutte le altre, quelle che non rientrano tra queste quattro e che sono soggette ad altri modi di trasferimento.

Mancipatio (o Mancipium)

> È l'atto di trasferimento da una sfera potestativa all'altra delle res mancipi.

> Si trasferisce proprio il *Dominium*: la proprietà.

Si parla di *"Dominium ex iure quiritium"* (il dominio in base al diritto dei quiriti) che è il nucleo più risalente della società romana: Il "*Dominium*" inquadra proprio la proprietà, il diritto reale pieno\ assoluto\ per eccellenza.

> Anche qui, appunto, c'è un'importanza rigorosa del formalismo, perché sia efficace, la mancipatio deve essere eseguita nel rispetto rigoroso di determinati elementi.

> Nella mancipatio occorreva che fossero presenti determinati soggetti:

- Mancipio dans: Colui che da il mancipio, è colui che trasferisce: l'alienante.
- Mancipio accipiens: Colui che riceve (l'acquirente)
- Libripens: Colui che è preposto a tenere la bilancia.

  La *mancipatio* è infatti definita un gestum *"per aes et libram"* cioè avviene con la presenza del il bronzo e della bilancia. Quindi abbiamo il libripens che tiene la bilancia e hai il compito di pesare il bronzo che è il corrispettivo dell'acquisto: all'inizio era bronzo non montato, dopodiché al posto del bronzo iniziarono ad essere usate le monete coniate.
  Questa cerimonia della pesatura, tuttavia, divenne via via anacronistica fino ad arrivare a conservare solo un valore simbolico.
- 5 Testimoni: È necessario che intervenga un corpo di cinque testimoni che devono essere cittadini romani maschi puberi, che in quanto corpo testimoniale rappresentano il corpo sociale, poiché il trasferimento da una sfera potestativa ad un'altra di una res mancipi, e quindi di un qualcosa di economicamente prezioso, in una società così ristretta e chiusa era un avvenimento importantissimo, per cui con questi cinque testimoni era come se il passaggio di proprietà venisse constatato da tutta la società.

Modalità di svolgimento:

Qui vediamo che la parola ha un'efficacia creativa del diritto:

> Infatti c'è una formula che deve essere pronunciata dal mancipio accipiens (dall'acquirente) : la *formula vindicatoria:* che non è altro che un'affermazione perentoria dell'acquirente, cioè comporta perentoriamente la titolarità del bene. Nel momento in cui si pronuncia, in questo caso la *formula vindicatoria*, il diritto si crea.

> Con il mancipium si attua uno scambio fra cosa e prezzo, ma non si riduce al suo contenuto economico, tutto è accompagnato da una gestualità, dall'importanza della forma, infatti "*Mancipare*" indica solo tardi il *"trasferire"*, in origine equivaleva a *"manu capere"*: "prendere con la mano".

È infatti l'acquirente, protagonista di quest'atto, che prende in mano la cosa e la dichiara sua attraverso la pronunzia della formula vindicatoria:

- Quindi il *mancipio accipiens* afferma solennemente:
  "io dico che questa cosa è mia sento il diritto dei quiriti"
- La res che si vuole acquistare deve essere presente durante la *mancipatio*.
- A questa affermazione perentoria e rigorosa da parte dell'acquirente corrisponde un silenzio dall'altra parte: il *mancipio dans* rimane in silenzio, ma ciò non significa che la sua posizione sia defilata e che non abbia importanza, perché comunque è, sì, silente nell'atto, ma interverrà poi nel gioco delle responsabilità laddove l'acquirente, per esempio, si veda turbato da una rivendicazione della stessa cosa da parte di un terzo e quindi dovrà chiamare l'alienante a garanzia dell'avvenuto scambio, e quindi a supportare la sua stessa rivendicazione del bene.
- Mentre il mancipio accipiens pronunciava la formula in maniera rituale, doveva poggiare sulla bilancia mantenuta dal libripens il bronzo, corrispettivo della res, che poi veniva dato all'alienante.

> Vedremo che la mancipatio somiglia a quella che poi sarà la empito venditio, cioè la compravendita, lo scambio di cosa contro prezzo, e questo ci fa capire che nessuna figura giuridica nasce per caso, ma come evoluzione o adattamento all'esigenza umana quotidiana del diritto, degli scambi e dei rapporti tra privati.

Nexum

Questo è un altro atto negoziale rigidamente formalistico, di cui non si sa tanto poiché ci sono pervenute poche testimonianze a riguardo.
Si sa che anche questo fosse un gesto *per aes et libram*, quindi, evidentemente, funzionava sempre con il bronzo la bilancia come per la mancipatio, ma in questo caso abbiamo: Un assoggettamento materiale fisico del debitore o di un suo sottoposto al creditore in funzione di garanzia per l'adempimento dei debiti.
> Quindi immaginiamo che avvenisse come la mancipatio, che richiedesse quindi la pronuncia di certa verba e la presenza del bronzo e della bilancia, ma che ad oggetto veniva presa la persona fisica del debitore che si assoggettava in qualità di garanzia di un adempimento del debito.

> Mai come stavolta dobbiamo cogliere quanto il contenuto volitivo non contasse minimamente, nessun uomo si spingerebbe a tanto, ma ciò che conta sono solo i comportamenti formulari che si basano sulla gestualità e sulla pronuncia di determinate formule, conta il modo in cui viene realizzato l'atto esteriormente.

In iure cessio

> Un altro modo di acquisto della proprietà, che stavolta riguarda le *res nec mancipi*, è la *in iure cessio*.
> Questo negozio scaturisce dall'adattamento in termini negoziali della *legis actio per sacramentum in rem*.
> Abbiamo visto che questa legis actio comportava una *vindicatio* e una *contra vindicatio* di attore contro convenuto come se fossero sullo stesso piano, ma comunque, ovviamente, c'è una controversia.
> Quello schema innanzi al magistrato, *in iure*, si conserva e lo si adatta ad uno schema negoziale.

> "*Cessio*" indica proprio l'atto del ritirarsi, in particolare l'atto di ritirarsi innanzi al tribunale del magistrato; E in questo negozio vediamo:

- Colui che vuole acquistare fa una vera e propria *vindicatio*, fa un'affermazione di titolarità della cosa pronunciando la *formula vindicatoria* innanzi al magistrato, quasi come se avanzasse una pretesa processuale.
- Ma naturalmente non si può considerare un vero processo, anche perché l'altra parte, anziché fare una *contra vindicatio*, tace. Non si impianta una controversia.
- Il magistrato di fronte a questa situazione non fa altro che *addicere rem*, cioè fa *l'addictio:* l'assegnazione della *res* a colui che ne ha rivendicato la proprietà.

> Per cui abbiamo che è un finto processo, perché ovviamente la parte alienante, convenuta di fronte al magistrato, anziché fare una *contra vindicatio*, tace e non impianta alcuna controversia, sicché il magistrato possa assegnare con l'addictio della res rivendicata.

Formalismo Interpretativo

Possiamo guardare alla In iure cessio come ad un primo esempio di formalismo interpretativo.
Il formalismo interpretativo è l'altra faccia del formalismo, si colloca in un piano inverso rispetto a quello giuridico, poiché **consiste**: nella tendenza ad interpretare un insieme di parole orali o scritte secondo una rigorosa fedeltà al dato letterale.
> Questo tipo di formalismo è frutto di un pensiero giuridico altamente raffinato, evoluto, che non si limita all'invenzione tecnica di forme e di formule, ma arriva a spostare su un nuovo piano l'autonomia già raggiunta della funzione giuridica; attraverso le forme si vanno a soddisfare bisogni pratici.
> facendo riferimento a questo tipo di elaborazione, Jhering definisce questo formalismo come *"una creazione giuridica cosciente e calcolata, una lingua dei segni mediata profondamente"*
> È posto in essere dai primi giuristi, tecnici del diritto: i pontefici
- In un'ottica del tutto formalistica, dobbiamo intendere che costoro interpretassero non spiegando un dato letterale, ma elaborando schemi e formule, e quindi congegni formali, che non andassero a tradire il dato legislativo (le 12 tavole) al fine di sortire effetti nuovi che vadano aldilà del concepimento originario di determinate figure espresse nelle 12 tavole stesse.
> Un altro esempio ne è la *Emancipatio*.

7. Un “codice di Contadini” ?

Emancipatio

È uno degli esempi più emblematici di formalismo interpretativo, e cioè è uno dei frutti di quella particolare attività interpretativa dei dei primi giuristi (i pontefici).

L’ *Emancipatio* è quel meccanismo che portava proprio all’emancipazione di un figlio nei confronti del potere del padre, e cioè permetteva di far fuoriuscire il figlio dalla *potestas* paterna.

> Altri esempi di “meccanismi” nati dall’attività di *interpretatio* dei pontefici sono: La *in iure cessio* (che riguardava l’acquisto delle *res nec mancipi*), la *manomissio vindicta* (che riguardava la liberazione dello schiavo dal *dominium* del padrone), la *conventio in manum* (con la quale il marito assumeva la *manus* sulla moglie) o anche l’*adrogatio* (con cui un soggetto *sui iuris* diminuiva la sua posizione facendosi adottare da un *pater familias* spesso a scopo testamentario)

Soggetti:

1. *Pater familias*

> È un soggetto *sui iuris*, cioè avente una propria autonomia e non sottostà al potere altrui.
> Al contrario, esercita la patria potestas sui suoi sottoposti (sui figli)

- Precisiamo che la *potestas* così come il *dominium* o la *manus* sono forme di esercizio del potere nei rapporti privatistici, sono rapporti tra superiore e sottoposto:
  - la *patria potestas* è il potere del padre rispetto al figlio
  - il *dominium* è il potere che il *dominus* (il padrone) ha sul *servus*
  - la *manus* è il potere del marito sulla moglie

2. Il *Filius*

> È un soggetto alieni iuris, che l'espressione usata per indicare quelle persone che sono soggette al potere altrui, in questo caso del *pater familias.*

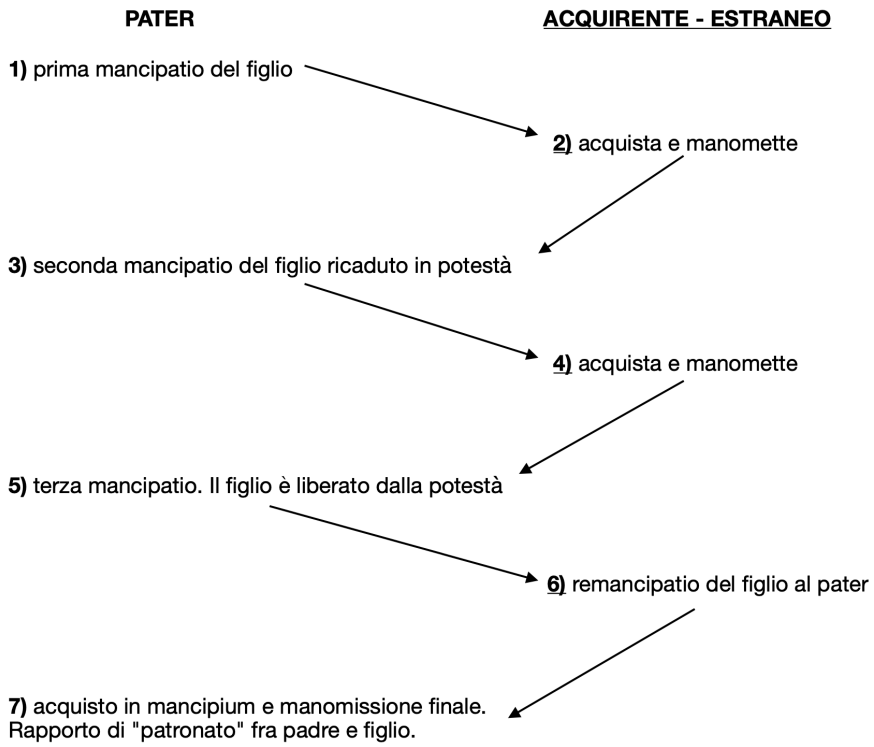
3. Acquirente estraneo

> Che si presta al gioco,poiché vedremo che in effetti questa emancipatio non è altro che un gioco formalistico.

Scopo:

L’ *Emancipatio* dunque ha lo scopo di far fuoriuscire il figlio dalla potestà paterna e farlo diventare un soggetto *sui iuris*.

Svolgimento:



> Abbiamo un susseguirsi di:

- *Mancipationes*:
atti di trasferimento della cosa nella sfera potestativa altrui; in questo caso del figlio nella sfera potestativa dell’acquirente estraneo.

- *Manumissiones*:
atti di liberazione dello schiavo dal dominium del padrone; in questo caso del figlio dal dominium dell’acquirente.

1- Il **padre**, per prima cosa, fa una ***mancipatio*** del figlio all'acquirente.

2- L'**acquirente** acquista dunque il figlio, il quale cade nel suo *mancipium* (generico potere su cose o persone) — Poi fa una ***manomissio*** del figlio il quale ricade nuovamente nella *potestas* paterna.

3- Il **padre** fa una seconda ***mancipatio*** del figlio all'acquirente.

4- L'**acquirente**, ancora una volta, acquista il figlio che ricade nel *mancipium* dell'acquirente — e poi fa la ***manomissio*** in modo che, ancora una volta, ricada nella potestas paterna.

5- Il **padre** fa la terza ***mancipatio*** facendo scattare il precetto decemvirale che vieta la vendita del figlio per più di tre volte; Per cui il figlio è ormai libero definitivamente dalla potestas paterna.

6- L'**acquirente** per la terza volta ha acquistato il figlio (che ora, ovviamente, si trova nel suo *mancipium*) — fa una *remancipatio* (mancipatio del figlio al padre).

7- Il **padre** allora acquista il figlio che rientra non più nella sua *patria potestas* ormai estinta, ma nel suo *mancipium* , e infine fa l'ultima ***manomissio*** liberando il figlio definitivamente.

> Al termine dell' Emancipatio il tipo di rapporto che si conserva tra il filius liberato e il pater sarà pari al tipo di rapporto che si crea tra il liberto (schiavo liberato) e il patrono (ex dominus che l'ha liberato), per cui ci sono, sì, delle forme di ossequio e riconoscenza, ma resta il fatto che il liberto è un uomo libero.

Il formalismo interpretativo nella mancipatio:

C'è un versetto delle 12 tavole che prevede questa Emancipatio:

XII Tab. 4.2: "*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto"*.

(Se il padre ha venduto il figlio per tre volte, il figlio sia libero dal padre)

* cogliamo l'occasione per evidenziare il modo di formulazione dei progetti delle 12 tavole: notiamo la concisione, la sonorità, la facilità mnemonica data dalla formulazione ipotetica all'inizio e poi il precetto imperativo subito dopo.

> Questo precetto decemvirale prevedeva già l'ipotesi della fuoriuscita del figlio dalla potestà paterna, ma era una norma che aveva lo scopo di sanzionare una condotta illecita e riprovevole:
- Vi erano, infatti, padri che esercitando abusivamente la propria *patria potestas* vendevano i propri figli (la prole era un bene redditizio) più volte, facendo una speculazione.
- Ed è proprio per arginare questa libertà del *pater* sul *filius,* e quindi per limitare questo comportamento abusivo, che nacque il precetto che impediva ai padri di vendere i figli per più di tre volte.

> Vi erano, però, anche dei padri che volevano emancipare (far uscire dalla propria *potestas*) i propri figli benevolmente.
- Ed ecco che, al fronte di questa necessità, vediamo in azione la tecnica interpretativa dei giuristi pontefici: Attraverso l'attività dell'*interpretatio*, i pontefici sfruttarono il precetto decemvirale che vietava la vendita dei figli per più di tre volte, e generarono un complesso meccanismo di 7 atti formali consecutivi che aveva lo scopo di liberare intenzionalmente il figlio dalla *patria potestas*.
> Notiamo allora che, siccome il formalismo costituisce quasi una gabbia da cui è impossibile uscire in base ad un mero atto di discrezionalità, i giuristi pontefici riescono a veicolare la volontà del padre dell'emancipazione del figlio apprestando un nuovo strumento giuridico\ congegno formale che parte da un'osservanza stretta del precetto in questione e porta ad un risultato nuovo:
- Non vediamo infatti una sanzione per il comportamento abusivo paterno (come sarebbe stato nel caso dell'applicazione rigorosa del precetto decemvirale)
- Ma quasi con funzione scenica, il padre, in accordo con un soggetto altro (l'acquirente estraneo) che si presta al gioco, fittiziamente allestiscono e pongono in essere questo meccanismo di 7 atti formali che ha come scopo ultimo quello di far fuoriuscire il figlio dalla potestà paterna.
> Ecco un esempio concreto di come l'interpretazione viene attuata alle formule, ed ecco perché non possiamo, in un contesto formalistico, considerare l'interpretazione come "letterale".

Precisazione: La parentela ed il ruolo del pater familias

Considerando anche solo la *manus iniectio* o il *nexum* possiamo renderci conto di quanto la società delle 12 tavole sia una società profondamente arcaica e poco evoluta, ed in questo panorama arcaico si inserisce anche la famiglia che si caratterizza per essere patriarcale e agnatizia.

> La ***parentela*** poteva essere di due tipi, e anzi possiamo considerare la *cognatio* come il *genus* più ampio, e l'adgnatio come una *spiecies*:

• *Cognatio*:
È la parentela di fondamento naturalistico, cioè fra persone che discendono l'una dall'altra, o che hanno almeno un ascendente comune.

• *Adgnatio*:
È la parentela a vincolo potestativo, cioè sono *adgnati* i parenti in linea maschile che furono soggetti alla potestà di uno stesso capofamiglia, o lo sarebbero se gli fosse ancora vivente, poiché tra gli adgnati rientrano i *sui*, cioè coloro che sono immediatamente sottoposti alla *patria potestas* o alla *manus*, e sono destinati a diventare automaticamente *sui iuris* alla morte del capofamiglia (ma la morte del capofamiglia non li esclude, appunto, dalla parentela agnatizia).

- Dalla struttura del gruppo familiare dipende anche il regime successorio in cui hanno rilievo gli elementi gentilizi: infatti c'è proprio un precetto nelle 12 tavole relativo alla tutela testamentaria che prevedeva che il patrimonio di qualcuno privo di un erede che era morto senza aver fatto testamento spettasse all'agnato più prossimo, qualora non vi fosse neanche un agnato, era disposto che quel patrimonio aspettasse ai gentili, e cioè agli appartenenti alla stessa gens che era una parentela che possiamo definire più ampliata rispetto alla *cognatio*, e che si basa sulla discendenza di sangue da uno stesso capostipite ma lontano nel tempo.

> La ***patria potestas*:**

- Questa è un istituto singolare che non ho quasi riscontro al di fuori della cultura romana, tant'è che gli scrittori greci ne parlano con una punta di meraviglia.

- Nella famiglia il padre agisce come un re, addirittura, anche se con valore simbolico, può esercitare il diritto di vita e di morte sui figli, elemento a cui si fa riferimento anche nelle 12 tavole dove appare come il tratto caratteristico della *patria potestas* nell'antico formulario dell'adrogatio.
Solo molto tardi venne negato in linea di principio, esplicitamente nel codice teodosiano, ma la coscienza giuridica aveva trovato il modo di ostacolarlo implicitamente\indirettamente anche prima.

In ogni caso, solo il pater familias:
- Era proprietario di un patrimonio e diviene titolare di diritti.
- Può istituire un erede.
- Può essere parte in un processo rispondere dei debiti che assume.

Notiamo dunque che il padre costituisce il fulcro\il centro della famiglia, e questa precettistica etica, ha il suo fondamento nella consuetudine. Catone, ad esempio, disse a tal proposito che "gli antenati posero in primo luogo il nome di padre, subito dopo quello di *patrono** "

- Capiamo allora che la collocazione del pater da sempre aveva occupato il gradino più alto.

* Il *patronus* (protettore) era nella Roma antica un cittadino di una certa autorevolezza, in genere patrizio, chiamato così per via del legame, detto di patrocinio, appunto, di protezione, che aveva con i clientes; Il suo ruolo, sancito nelle 12 tavole, era quello di non ingannare il cliente, a cui seguiva quello di proteggere i pupilli affidati alla propria tutela.

- Un’immagine emblematica di pater familias la ricaviamo da cicerone che nel *Cato maior* ci offre la presentazione di Appio Claudio Cieco:
  - Cicerone ci dice che Appio Claudio era sia *pater* (Di quattro figli e cinque figlie, a capo di una famiglia grande) ma anche patrono e aveva una numerosissima clientela.
  - Afferma che esercitasse un avere propria signoria, era temuto dagli schiavi, ed era rispettato da tutti: quasi come se l'essere caro a tutti fosse direttamente proporzionale al timore che avevano di lui.
  - Conclude proprio dicendo che “in casa sua erano in onore il costume e la regola di vita degli antenati” e da questo riferimento ai *mores* degli antenati capiamo l’origine consuetudinaria del ruolo del *pater familias*.

Precisazione: Un codice di contadini

> Un’altro elemento che dobbiamo cogliere nel panorama arcaico delle 12 tavole è il rapporto che c'è con il mondo agricolo; non dobbiamo dimenticare che siamo in una società ancora circoscritta che aveva un'economia prettamente agricola, non è un caso che tra le *res mancipi*, che sappiamo essere quelle più preziosi e importanti, ritroviamo anche i fondi che erano la fonte di ricchezza principale dell’epoca. Nella disciplina giuridica il fondo aveva proprio una posizione privilegiata, ad esempio nell'acquisto per usucapione richiede un periodo di due anni a discapito di tutte le altre cose per cui ne basta uno.

Ma ci sono anche tante norme che regolano i rapporti tra fondi, ad esempio nelle 12 tavole compare un'azione specifica per determinare i confini, oppure compare anche il caso in cui un albero inclinato dal vento deve essere per forza rimosso dal fondo altrui e se i frutti vi sono caduti è possibile raccoglierli, ancora, non è lecito a scavare i canali o costruire dighe nel proprio fondo per farsi che l'acqua piovana si riversa in quello del vicino, o ancora, è vietato togliere il palo di cui un altro proprietario si è servito per sostenere la casa o la vigna.

È proprio alla luce di questi elementi che il romanista Paul Frederic Girard arrivò a definire le 12 tavole come *“un codice di contadini”*, e seppur largamente condiviso, negli ultimi anni si è tentato di modificare questo giudizio, in quanto le 12 tavole non sono altro che la legislazione di una *civitas* la cui economia si determinava in senso agrario, tuttavia non mancava la conoscenza di altri modi di formazione del patrimonio: a dimostrare ciò possiamo, per esempio, considerare la regolamentazione privilegiata del processo con gli stranieri (che testimonia interessi commerciali) o anche la riforma del processo per i rapporti obbligatori (segno di un esteso impiego del prestito), anche se sono situazioni non estremamente comuni per l'epoca, tant'è che il fenomeno della servitù per debiti o anche l'istituto della *manus iniectio* rimangono elementi ancorati ad una concezione del credito come un fenomeno eccezionale straordinario.

> Anche nell’ambito delle ***norme penali*** è possibile ritrovare alcune figure criminose strettamente legate alla vita contadina (che tra l’altro ci permettono di aprire uno scorcio sulla realtà sociale e psicologica della società romana), ad esempio:

- Chi durante la notte avesse usato come pascolo un campo coltivato sottraendo o distruggendo il raccolto sarebbe stato punito con l’impiccagione la quale aveva valore di sacrificio in onore di Cerere dea della terra.
- Chi avesse tagliato furtivamente alberi altrui sarebbe andato incontro ad una pena pecuniaria.
- Chi avesse incendiato la casa altrui e i covoni di grano sarebbe stato prima fustigato e poi arso vivo.

È soprattutto nella sfera penalistica che possiamo cogliere una sorta di primitivismo legislativo che seppur riconoscibile anche in quelli che abbiamo visto essere le procedure private e processuali (es. manus iniectio), nelle norme penali sembra quasi un dato esasperato, tanto che oltre a crimini, delitti e pene, specchio di una società arcaica e ristretta, emerge anche il carattere della credenza nell’efficacia di arti e formule magiche.

Vediamo infatti che:

- Attraverso l'attività del comizio centuriato, lo stato è giudice della vita e della morte di un cittadino (il che costituiva un limite sia alla giurisdizione dei magistrati, sia all'attività dei tribunali straordinari plebei) — Proprio dinanzi ai comizi centuriati avveniva la *provocatio ad populum* (appello al popolo). Un cittadino condannato o inquisito dal magistrato o sottoposto alla sua coercitio, aveva, in alcuni casi, la possibilità di compiere la *provocatio ad populum* che aveva lo scopo di mutare la pena capitale in altra pena se così stabilito da un giudizio popolare:

  > - Questo istituto fu introdotto nel 509 a.C. dalla lex Valeria de provocatione che stabilì che nessun magistrato mettessi a morte fosse gas è un cittadino romano senza tener conto dell'appello del popolo
  > - Nel 449 a.C. con la *lex Valeria Horatia*, immediatamente successiva alla caduta dei decemviri si stabilì il divieto della creazione delle magistrature libere dalla provocato.
  > - Infine, nel 300 a.C. con un'altra lex Valeria si convalidò quanto espresso nella prima, considerando il regolare e riprovevole il comportamento trasgressivo del magistrato.
  > - Un'ulteriore conferma della *provocatio ad populum* si ebbe con tre leggi Porcie del II sec. a.C.

- L'intervento punitivo pubblico si aveva senza dubbio in questi casi:
  - In caso di alto tradimento.
  - In caso di *perduellio* (attentato alle libertà cittadine).
  - Incerti delitti sacrali molto gravi.

  > Questi sono i casi in cui il soggetto direttamente colpito dal fatto criminoso non è il singolo ma la comunità intera.
- L'idea di una vendetta privata dell'offeso era comunque radicata:
- In caso di **omicidio** assume rilievo il singolo e l'intervento dello stato sembra quasi indiretto; L'assassino che agiva intenzionalmente era infatti sottoposto alla vendetta del gruppo familiare dell'offeso, il potere pubblico doveva semplicemente accertare la colpevolezza nel momento in cui il reo non era stato né colto il fragrante né aveva confessato. Era prassi sottrarsi la vendetta va la condanna capitale fuggendo in esilio, e secondo una pratica forse non ignota in età decemvirale, il magistrato decretava la proibizione dell'acqua e del fuoco, per cui il fuggitivo era costretto a vivere fuori dal territorio romano.
- In caso di **furto**, anche il ladro se veniva sorpreso di notte o se in pieno giorno si difendeva con le armi, poteva essere ucciso; nel secondo caso (quando era sorpreso di giorno con delle armi), siccome la disciplina del furto era complessa specialmente in mancanza di flagranza, si doveva mettere in atto la procedura dell'*endoplorato* (chiamare a gran voce) che aveva il fine di garantire la presenza di testimoni, e quindi rendere indiscutibilmente legittimo il comportamento del derubato (che doveva appunto uccidere il ladro).
- Anche in caso di lesioni fisiche le pene potevano variare a seconda della gravità della lesione; Quando la lesione era particolarmente grave si ricorreva al taglione (evitabile con un patto tra offeso e offensore),o in alternativa erano previste pene pecuniarie più o meno gravose in base all'entità della lesione.
- Ritroviamo anche la possibilità di danneggiare una persona per mezzo di incantesimi:
- In ambito rurale quando attraverso incantesimi e vere e proprie formule magiche, si impediva che le spighe maturassero, si tentava di renderle vuote, o addirittura di attrarle dal fondo altrui nel proprio, Ecco che si era puniti con una sanzione che tuttavia ci è ignota, ma che sarebbe potuta essere anche la morte.
- Altre volte si ricorreva il potere magico delle parole come strumento punitivo:
- Ad esempio nella pratica della *obvagulatio*: che si vedeva rifiutata la testimonianza da parte di qualcuno che aveva assistito ad un atto librale o all'instaurazione di una controversia giudiziaria, aveva la possibilità di recarsi davanti alla porta del testimone disobbediente e pronunciavi per tre giorni formule di maledizione o infamia.

> il fatto che le 12 tavole siano estremamente precise nella definizione delle pene determinate per ogni crimine, è un elemento degno di nota, per cui si è addirittura arrivati ad affermare che le 12 tavole lasciano emergere un'idea moderna in un contesto primitivo.

Capitolo quarto: sacerdoti e interpreti

1. Il segreto pontificale
2. Una “lingua di segni”

Nel mondo arcaico romano i primi tecnici del diritto, che tra l'altro abbiamo visto misurarsi con questo primo tipo di interpretazione (formalismo interpretativo), sono i pontefici.

Possiamo distinguere varie categorie\ ordini sacerdotali che si distribuiscono seguendo una gerarchia:

- Rex sacrorum
- Flamini
- Auguri
- Feziali
- Pontefici
- Duoviri (poi decemviri e quindicemviri)

> Nel rispetto di questa scala gerarchica, i pontefici, (con il pontefice massimo a capo del collegio) si ritrovano al quinto posto, tuttavia la loro importanza ed incidenza sotto il profilo della vita cittadina quotidiana (possiamo addirittura arrivare ad affermare che la controllassero), porta questi sacerdoti a rivestire una posizione di preminenza che va aldilà della stessa gerarchia.
- Anche se abbastanza improbabile, si presume che in origine i pontefici fossero gli ingegneri della comunità, e che traessero il loro nome dall'ufficio di dirigere la costruzione e il taglio del ponte sul Tevere.

> Le loro attività erano, però, assai più importanti:

- Controllavano ogni cerimonia religiosa privata o pubblica (dal culto degli dei, ai riti espiatori, alle onoranze funebri)
- Il *pontifex maximus* consacrava i *Rex sacrorum* ed i Flamini maggiori
- Il *pontifex maximus* creava le vestali ed esercitava su di loro un potere disciplinare
- Solo i pontefici conoscevano il segreto delle misure e dei numeri
- E per questo furono incaricati di detenere il calendario dello Stato
- Annunciavano al popolo il novilunio, il plenilunio ed i giorni festivi
- Custodivano la storia della città registrando poi gli avvenimenti più importanti (es. carestie ed eclissi)
- Controllavano che ogni atto religioso o giurisdizionale avvenisse nel giorno corretto;

  C’era infatti una componente sacrale e religiosa non irrilevante nello svolgimento della vita quotidiana, ecco perchè i pontefici controllavano, ad esempio, le eclissi di luna e di sole, in quanto anche i fenomeni naturali erano determinanti per lo svolgimento di specifiche attività —> Inoltre, in quanto detentori del calendario, erano i pontefici a conoscere i giorni fasti e nefasti, e cioè i giorni in cui potevano essere svolte delle attività come il mercato, le votazioni, le attività dei tribunali o in generale occasioni di riunione dei cittadini per dar vita ad attività rilevanti per la vita cittadina.

> È sbagliato pensare ai pontefici come a dei maghi o profeti, ma bisogna considerarli dei veri e propri tecnici ed esperti; Erano figure sacerdotali estremamente presenti nella vita cittadina, ma non solo, i primi tecnici del diritto dono proprio i pontefici, i giuristi-pontefici sono i primi giuristi nella sfera umana e sacrale (sfere strettamente connesse tra loro, basti pensare che dai giorni fasti e fasti dipendesse l’attività del tribunale)

- Custodivano infatti la conoscenza del diritto in maniera segreta. (si parla proprio di monopolio pontificale della conoscenza giuridica)

Tant’è che possiamo addirittura affermare che i pontefici assunsero il dominio de diritto privato, in quanto non intervenivano solo quando l'agire degli uomini toccava la sfera del sacro, ma intervenivano come interpreti e consiglieri in ogni ambito della vita giuridica.

Precisazione: differenza tra diritto pubblico e diritto privato nel mono romano

Nel diritto romano si parla di diritto pubblico e privato in termini diversi da quelli odierni.
> Non essendoci ancora un'idea di stato come la intendiamo noi, e quindi non potendo parlare di diritto pubblico *come complesso di norme che disciplinano la formazione e l'organizzazione dello stato e dei suoi enti,* si parla di **diritto pubblico** come di "diritto del popolo" (lo dice Questa) —> E quindi con diritto pubblico si fa riferimento ai principi e criteri che regolamentano l'organizzazione politica dei cittadini, con riferimento proprio alla collettività\ alla pluralità\ alla comunità politica\ alla somma dei cittadini che compongono il *populus* romano.
> Per quanto concerne, invece, il **diritto privato** ha a che fare con l'utilità e l'interesse dei singoli; sono i privati che hanno relazioni tra loro. Si parla allora di *scientia iuris*, quell'ambito culturale in cui i giuristi romani hanno inciso profondamente per quanto riguarda la creazione del diritto, nel diritto privato, si sono occupati prevalentemente dei *rapporti tra singoli soggetti e privati.*

> I giuristi pontefici, avevano dunque il monopolio del diritto privato, ne conservavano il segreto nei loro archivi, e questo era segno anche di una volontà di conservazione ereditaria del potere, in quanto conoscere il diritto e gestire la vita quotidiana era una prerogativa esclusiva sinonimo di potere è appannaggio dei giuristi pontefici (che erano di estrazione patrizia).

>> Il solo momento comunicativo era costituito dal ***responso***.
- Cioè un consiglio tecnico in risposta ad un quesito giuridico che l'esperto\ il giurista, in questo caso il giurista pontefice, fornisce a chiunque gli si rivolga.

>> La caratteristica dei responsi attraverso i quali dispensavano il loro sapere, è la ***laconicità oracolare***:
- Dire che è un responso è laconico sta significare che è un responso in cui il momento dell'argomentazione della spiegazione non è esplicitato, è oscuro: si passa direttamente il risultato.
Per cui il responso laconico dei pontefici non era altro che una risposta senza l'articolazione del ragionamento che aveva portato a quella conclusione.

La laconicità oracolare non è altro che il riflesso di quell'estrema solennità caratteristica di tutto ciò che riguardava la sfera pontificale:
- Era solenne il modo con il quale tutti coloro i quali intendevano porre in essere un qualsiasi atto (come concludere un negozio o avventurarsi in una controversia giudiziaria) si recavano presso i pontefici, quindi presso l'abitazione di queste figure enigmatiche quasi come fossero un oracolo.
Chiaramente, in un'ottica rigidamente formalistica, era necessario consultare i pontefici, esperti del diritto, in quanto un errore qualunque nell'ambito, ad esempio di una *legis actiones*, avrebbe comportato o una ripetizione infinita dell'atto, o addirittura il prodursi del torto anziché della ragione, in sostanza il non raggiungimento dell'intento giuridico.
- Ed era solenne il responso fornito dai pontefici che non era sciolto\ spiegato ma aveva un che di enigmatico: andava compreso per com'era per come era stata corrisposto.

>> A partire proprio dal *responso* possiamo individuare la ***triade*** che sintetizza le ***prerogative dei pontefici***:

- ***Respondere:***
  - Attività del dare consigli tecnici: dare il responso in sé e per se, che poi è qualcosa che include anche le altre due (cavere e agere)
- ***Cavere***
  - Allestimento di schemi negoziali (cavere allude al significato di garanzia, quindi garantire la correttezza delle azioni giuridiche)
- ***Agere***
  - Allestimento di schemi processuali (che indicano come agire proprio in un processo

- Queste sono le attività nelle quali si articola il *responso*, e quindi l'indicazione della tecnica sull'esatta modalità da seguire per realizzare il negozio giuridico: i pontefici quindi suggerivano lo schema negoziale adeguato per ottenere un determinato risultato e per intraprendere correttamente una controversia giudiziale nella maniera corretta per avanzare correttamente tutte le proprie pretese.

>>Alla base del contenuto del *responso* troviamo l'attività interpretativa dei pontefici: l'***interpretatio***

L'*interpretatio* (che abbiamo già visto con il formalismo interpretativo) non è da intendere come una spiegazione del significato più o meno recondito del dato legislativo, ma in un contesto formalistico, dobbiamo intendere con interpretatio: la creazione di congegni e formule.

- I pontefici, dunque, attraverso il tecnicismo giuridico della loro attività interpretativa, che possiamo definire come "l'altra faccia del formalismo", creavano congegni e formulari che adattavano il diritto alle esigenze concrete nella vita cittadina sviluppandone le potenzialità senza mai tradire il precetto della legge. Attraverso l'interpretazione pontificale si aprivano nuovi spazi all'autonomia negoziale dei privati;
> Si parla di *interpretatio* in senso statico:
- *Interpretatio* in senso dinamico: È quella cui siamo abituati noi, è l'interpretazione del dato normativo.
- *Interpretatio* in senso statico: È l'elaborazione di formule congegni formalistici.

> Esempi di interpretazione pontificale:

- ***Emancipatio***:
  Abbiamo già visto l'emancipatio, che , in uno sforzo continuo di farsi coprire dalla legge, di essere fedeli alla legge anche solo in superficie ma non nella sostanza, porta ad un risultato nuovo: sfruttando quel precetto che impediva al padre di vendere un figlio per più di tre volte, sfruttando abusivamente la sua patria potestà, si arrivò a sviluppare un meccanismo che permetteva di liberare il figlio dalla patria potestas intenzionalmente e benevolmente.

- ***In iure cessio***:
  Anche questa ci è già nota come adattamento non contenzioso della *legis actio per sacramentum in rem* a fini negoziali e abbiamo visto che consisteva in una vera e propria *revindica* fittizia svolta dinanzi al magistrato, del bene da acquistare: questa si adattava a diverse situazioni anche al di fuori della sfera del diritto di proprietà, venite infatti utilizzata per creazioni di rapporti associativi, per l'adozione o anche per il trasferimento o dell'eredità deferita\ acquisita, o della tutela (in quanto potere personale).

- ***Mancipatio***:
  Anche la mancipatio ci è già nota, e anche questa assunse usi più vari, arrivò a trasformarsi in una vendita simbolica in quanto il prezzo non venne più pagato al momento del rito, ma divenne anche un negozio astratto sia per compiere una donazione o una costituzione di dote, ma anche per garantire un debito, affidare una cosa in custodia, acquistare la potestà sulla moglie o anche per disporre del proprio patrimonio in vista della morte, e quindi a scopo testamentario.
  Esempi:

  > *Mancipatio familiae*
  Familia: come significato di famiglia veniva considerato proprio il patrimonio.
  E infatti si parla di *mancipatio del patrimonio*.
  I soggetti presenti durante l'atto erano:
  - Mancipio dans: testatore (o ereditando) che trasferiva il proprio patrimonio ad un altro soggetto
  - Familae emptor: colui a cui veniva trasferito il patrimonio; Era un soggetto della famiglia, acquirente del patrimonio (in realtà era un *amicus*, legato da rapporti di fiducia con ereditando).

Era colui che tramite questo atto di *mancipatio* (dopo aver pronunciato la formula *mancipatoria*) acquisiva questo patrimonio dovendolo poi destinare, *post mortem*, ai soggetti a cui l'alienante avrebbe voluto fosse destinato.

- La mancipatio familiae, dettata e assecondata dall'intelligenza tecnica dei pontefici, rappresenta una prima forma di evoluzione, una prima forma testamentaria di adattamento della mancipatio.

Ma presentava diversi difetti, in quanto:

- Non c'era nessuna garanzia che l'acquirente poi seguisse le volontà del testatore, in quanto, oggettivamente, era un acquirente a tutti gli effetti, e l'eventuale destinazione del patrimonio acquisito ad altri, era affidata solamente alla sua lealtà e onestà; di fatto era solo l'acquirente ad aver ricevuto il testamento tramite la mancipatio familiae che no era altro che un atto di trasferimento da una sfera potestativa all'altra.
- I pontefici, allora, per ovviare al problema della destinazione del patrimonio, elaborarono una versione ulteriore di questa mancipatio familiae arrivando al:

> *Testamentum per aes et libram.*

In questo tipo testamento mancipatorio la destinazione del patrimonio post mortem ai soggetti destinatari era più sicura e garantita.

Dal nome intuiamo che ci fosse l'intervento del bronzo e della bilancia, benché sia comunque una *mancipatio*.

I soggetti erano:

- Il testatore (mancipio dans)

> A cui si riconosce un'ampissima potestas\ libertà di disporre del suo patrimonio attraverso una dichiarazione, sempre formale, che prende il nome di *nuncupatio*, ma che era contenuta in tavolette cerate (conteneva delle dichiarazioni del testatore nelle quali designava solennemente gli eredi; Queste dichiarazioni rimanevano nelle tavolette e non venivano lette).

- L'amicus (mancipio accipiens)

> Che è l'acquirente del patrimonio, che pronuncia la formula *vindicatoria* all'alienante-testatore, il che rende questo testamentum per aes et libram una mancipatio in piena regola:

"Affermo che il tuo patrimonio è nella mia custodia per un incarico da adempiere; mi sia acquistato con questo bronzo e questa bilancia di bronzo, perché tu possa fare testamento secondo la legge pubblica"

Da questa formula, dunque, in maniera esplicita, risultava che il *mancipio accipiens*\ acquirente fosse un *amicus* (quindi si esplicitava la condizione di soggetto fiduciario che si prestava a questo rituale) poiché era necessario che comparisse per realizzare il rito.

Dopodichè, a differenza di quanto accadeva nella mancipatio, l'alienante-testatore non taceva, ma chiamando in causa i cittadini che assistevano all'atto rispondeva all'acquirente con una formula nella quale c'era il rinvio alle *nuncupationes* (cioè alle sue dichiarazioni solenni contenute nelle tavolette)

"Com'è scritto in queste tavole cerate, così dispongo lego a testo,
e così voi, Quiriti, dovrete prestarmi testimonianza."

In tal modo si aveva la garanzia che non fosse l'*amicus* lui a detenere il gioco, ma che le volontà contenute nelle *nuncupationes* fossero poi realizzate *post mortem*.

> Con il *testamentum per aes et libram*, vediamo non solo un adattamento della mancipatio a scopo testamentario, ma vediamo anche un'evoluzione della stessa *mancipatio familiae* correttiva di determinate falle, ma che avveniva comunque in maniera rigidamente formale.

- ***Manomissio vindicta***

Era l'atto grazie al quale lo schiavo aveva la possibilità di fuoriuscire dal dominium del padrone attraverso una *manomissio*.

- C'erano varie modalità per liberare i servi, e la *manomissio vindicta* era un'adattamento della stessa *legis actio per sacramentum in rem* (si dice adattamento a scopo manumissorio) però con <u>oggetto del processo</u>: lo schiavo e la liberazione dello stesso.
Si impiantava, infatti, un vero e proprio processo:

- <u>L'attore</u>: era il soggetto che, in questo caso, faceva asserzione di libertà.
Prendeva il nome di *adsertor libertatis* e attraverso una formula specifica affermava la libertà del servo.
- Dall'altra parte c'era il dominus dello schiavo che si prestava al gioco, in quanto la sua volontà liberare lo schiavo.

- Mentre l'adsertor libertatis pronunciava la formula adeguata e percuoteva il corpo del servo con una festuca, il dominus taceva, per cui il magistrato, in assenza di contrapposizione assegnava allo schiavo la libertà.

- ***Matrimonio***
> Il potere dell'uomo\marito sulla donna prende il nome di manus.

> Abbiamo due tipi di matrimonio:
- Cum manu: posto in essere mediante le forme previste per l'acquisto della manus da parte del marito.
- Sine manu: si fonda sulla semplice reciproca volontà dei coniugi di essere marito e moglie.

(Vi erano dunque due diverse condizioni della donna sposata:
- uxor in manu: la quale era sotto la patria potestas del marito;
- uxor sine manu, la quale conservava il suo stato originario.)

> Il matrimonio cum manu era accompagnato dunque dalla cosiddetta ***conventio in manum:***
- È quell'atto con cui la donna entra nella sfera di potere del marito o del padre del marito (a seconda che il marito sia figlio o a sua volta *pater familias*), recidendo ogni legame con la famiglia agnatizia d'origine con cui poi non avrà più alcun tipo di collegamento.

La conventio in manum, e quindi il matrimonio, avveniva in tre modi:

1- Coemptio matrimonii causa
2- Usus
3- Confarreatio

→ Questi due rientravano nella sfera esclusiva del diritto civile

1- <u>*Coemptio matrimonii causa*</u>

È una vera e propria mancipatio, una vendita espressamente compita matrimonii causa, e cioè con lo scopo del matrimonio:

- Il marito, infatti, fittiziamente comprava\ faceva atto di acquisto tramite *mancipatio* della donna, pronunciando, quindi, le formula adattata a questo scopo\ al diverso oggetto del negozio;
Per cui, fingendo di pesare il bronzo sulla bilancia, affermava il suo potere (la sua manus) sulla donna.

2- <u>*Usus*</u>
- Che era un caso di applicazione dell'usucapione il quale andava a riparare, dopo un anno, ad un errore od omissione della coemptio.

3- <u>*Confarreatio*</u>
- Il nome evoca la focaccia di farro vediamo infatti che in questo caso, gli sposi si univano per mezzo dell'acqua, del fuoco e del farro mischiato col sale, in quanto il farro era il cibo più sacro e antico, e veniva proprio spezzata una focaccia di farro simbolo di una vita insieme che comincia.

Gli sposi sedevano con il capo velato su sgabelli tenuti insieme e coperti da una pelle ovina e c'era la pronuncia di parole rituali.
Questo rituale avveniva dinanzi al pontefice massimo, a 10 testimoni che intervengono al rito e ad un altro sacerdote: il *flamen dialis*.
E si ha questo passaggio della donna nella manus del marito.

> Oltre all'intervento nella fase di adattamento tecnico, e quindi di elaborazione dei congegni formalisti, era indispensabile la presenza dei pontefici, in particolare dei pontefici massimi in alcune cerimonie rituali, ad esempio l'***adrogatio*** spesso abbinata al ***testamentum calatis comitiis***.

L'*adrogatio*:
Consiste nell'adozione di un soggetto *sui iuris* da parte di un altro pater familias.
- Cioè il soggetto *sui iuris*, autonomo, che non è assoggettato a nessuno, diminuisce il suo status facendosi adottare da un altro soggetto *sui iuris*.
- Questo spesso accadeva a scopo testamentario; Chi, non aveva eredi, infatti, poteva decidere di adottarli, per cui l'adrogatio risultava essere vantaggiosa per entrambi i soggetti coinvolti.

Spesso, contestualmente all'adrogatio si aveva luogo anche l'istituto del ***testamentum calatis comitiis***;
- Questi due istituti, abbinati, si svolgevano innanzi ai comizi centuriati presieduti dal pontefice massimo.
- Ciò si spiega perché non dobbiamo dimenticare che siamo sempre di fronte ad una *civitas* chiusa e ristretta, per cui l'assoggettamento di un pater familias da parte di un altro pater familias aveva una sua rilevanza sociale, per cui lo svolgimento di quest'atto aveva anche valore religioso per il destino dei propri familiari, passare da una sfera familiare all'altra comportava un cambiamento proprio dei nuclei familiari

Il pontefice e quindi presiedeva l'assemblea delle curie, e pronunciava in maniera solenne una formula.
(La formula adoperata in questo contesto del *testamentum calatis comitiis* con adozione ci è pervenuta grazie ad Aulo Gellio, importantissimo antiquario, autore delle N*octes Atticae*, del II secolo d.C.)

"Dichiarate imperativamente, secondo la vostra volontà, che Lucio Valerio sia figlio di Lucio Tizio per diritto e la legge come se fosse nato da quel padre e dalla madre che gli è unita nella famiglia, e che l'uno abbia sull'altro il potere della vita e di morte, così come il padre l'ha nei confronti del figlio. Questo, nel modo che ho detto, o Quiriti vi chiedo."

Capitolo quinto: Oltre il formalismo

1. Contadini e mercanti

Fra III e II secolo a.C. lo scenario economico, sociale e giuridico muta, Roma, seppur tardi, scopre il mare, ed i romani da "*idrofobi"* divennero "*anfibi*". Questa è un'espressione molto efficace per indicare quel processo di trasformazione dell'economia romana che da una dimensione agricolo-pastorale, circoscritta anche dal punto di vista territoriale (territorio italico), passa ad una dimensione molto meno ristretta\ cittadina, si apre a nuovi orizzonti, solca il Mediterraneo, tutto grazie ad uno slancio nuovo delle attività commerciali ed imprenditoriali che gli permettono di entrare in rapporto con nuovi popoli, nuove merci, nuovi costumi e di conseguenza anche nuove attività negoziali economiche.

Il Mediterraneo, in particolare vantava un'importanza strategica ed economica ineguagliabile, che tra l'altro perderà solo nel XVI secolo, quando, dopo la scoperta dell'America il centro si sposta nell'Atlantico.

Sin dal VI-V secolo a.C., la potenza indiscussa sui traffici mercantili mediterranei era Cartagine, che era al culmine della sua potenza marittima, e manteneva anche rapporti d'affari ed alleanza con le città etrusche.

È proprio alla fine del VI secolo a.C. che risale il primo trattato con Cartagine che coinvolge anche Roma in prima persona (recita infatti: "fra romani e gli alleati dei Romani, e i Cartaginesi e gli alleati dei cartaginesi"), anche se, in realtà, è probabile che questo trattato da una parte rifletta maggiormente lo spirito commerciale e militare punico rispetto a quello romano, dall'altra che riguardi più i bisogni delle città alleate di Roma che Roma stessa.

(Testo pag. 121)

Il trattato prevedeva che:

- Né i romani né i loro alleati potessero navigare oltre il promontorio Bello, se non perché costretti da una tempesta o da nemici, in tali casi si dovevano allontanare entro cinque giorni, e non potevano acquistare o ricevere nulla eccetto quanto necessario per l'eventuale riparazione della nave o eventuali sacrifici.
- Coloro che giungevano per commerciare, non potevano compiere nessun negozio se non vi era l'intervento di un banditore o di uno scriba pubblico, e per le merci vendute alla presenza dell'uno dell'altro, l'obbligo nei confronti del venditore ricadeva sotto la garanzia pubblica.
- Se un romano giungeva in Sicilia nella zona dominata dei cartaginesi, poteva godere di uguali diritti.
- I cartaginesi non dovevano recare danno ai popoli di Ardea, Anzio, della città dei Laurenti (Lavinio), di Circei, di Terracina ne ad alcun altro dei popoli latini sottomessi ai romani, mentre nei confronti di quelli non sottomessi dovevano astenersi dal colpire le loro città e qualora ne avessero presa qualcuna, dovevano restituirla intatta ai romani.
- I Cartaginesi non dovevano costruire fortezze nel Lazio, e se penetravano in assetto di guerra in quel territorio non vi dovevano trascorrere la notte.

> A patire dal III secolo a.C., però, a Roma si registrò una tendenza imperialistica molto spiccata che portò ad un'espansione del dominio di Roma sul Mediterraneo, furono conquistati i territori italici, i romani si spinsero anche in Sicilia, dove i Fenici avevano le loro colonie, e nacquero così i primi dominii provinciali. Ma non solo, sarà lo scontro con Cartagine: le tre guerre puniche che si avvicendarono tra III e II sec. a.C. e che terminarono con il trionfo di Roma a far si che i romani si affermassero come grande potenza mercantile nel traffico del Mediterraneo.

- E sono proprio questi eventi a cui fa riferimento Polibio quando parla di "avvenimenti straordinari" di portata enorme e straordinaria rilevanza politica, che avevano portato Polibio a formulare la teoria della costituzione mista per spiegare come Roma fosse riuscita, nel giro di così poco tempo, a diventare un'indiscussa potenza mondiale.

> L’egemonia di Roma sul Mediterraneo è straordinaria, in questo periodo nacquero nuove e molteplici possibilità di scambio e quindi nuove attività commerciali, grazie all’affluenza di forza lavoro e merci, allo sfruttamento delle miniere, alla crescita continua delle fonti finanziarie e della circolazione di denaro.

(Quando si parla di attività commerciali, è bene specificare che il commercio si svolgeva normalmente all'interno di un'area ristretta dalla quale usciva soltanto per lo scambio di beni di lusso, di semi-lusso O beni di prima necessità come il ferro o il sale)

- Il fondamento dell'economia antica è l'agricoltura, tant'è che a Roma, non solo influisce sulla vita religiosa e politica, ma anche sul vocabolario; Ad esempio il termine per indicare i “ricchi” era *locupletes* che è un termine che allude proprio ai campi.
- Nel contadino più che nel mercante è possibile scorgere un modello etico, nel *De Senectute* (opera filosofica composta nel 44 a.C. poco prima della morte dell’autore), Cicerone, attraverso il personaggio di Catone afferma che “chi coltiva i campi ha un conto aperto con la terra, che non si rifiuta mai di obbedire; e mai non rende a usura quel che ha ricevuto, quando con minore, quando, come accade perlopiù, con maggiore interesse”.

Il *bonus agricola* è anche un soldato valoroso e può essere identificato con l'ideale di *vir bonus*.
(Questo anacronismo, in realtà è tollerabile nell’ambito di un’economia che sta conoscendo la crisi della piccola proprietà, l’espandersi di latifondo e lavoro servile ed il sostituirsi del lusso alla parsimonia).

Con lo sviluppo di queste nuove realtà economiche sociali, e poi anche giuridiche, al modello etico del contadino si va a contrapporre quello del mercante la cui connotazione non è tanto positiva.

(Testo pag.124)

- Cicerone, che sappiamo essere un conservatore, nel *De Republica* afferma infatti che nelle città di mare, e quindi quelle che improntano la propria economia sulle attività commerciali, c'è anche una sorta di degenerazione dei costumi: questo perché ci si confronta con nuove lingue e usanze con cui è facile prendere familiarità, e di conseguenza oltre ad importare merci, importano anche costumi stranieri.
Per cui nessuna istituzione, pur se antica, potrebbe conservarsi integra.
Anche coloro che abitano in queste città, quelle di mare, si allontanano sempre di più dai luoghi natii e dalle tradizioni, tanto che se anche dovessero ritornare nelle proprie città natale se ne allontanerebbero col “vagare del pensiero”

> Il mercante è comunque visto come un uomo tenace e teso al guadagno ma I suoi averi sono esposti ad un rischio continuo, E non bisogna, in realtà, disprezzare la mercatura in quanto, in definitiva, il suo scopo ultimo è nella proprietà della terra.

Contemporaneamente a questo nuovo assetto economico e politico, anche la società assume una fisionomia differente.

- I conflitti sociali tra patrizi e plebei avevano ormai portato alle *Leges Liciniae Sexstiae* con le quali la classe dirigente aveva perso l'appannaggio di certe posizioni di rilevanza a favore della plebe.

- Anche la nobilitas si era trasformata, poiché comprendeva non solo la nobilitas di sangue, ma anche la nobilitas degli onori, quella degli *homines novi*, cioè coloro che partendo da un’estrazione sociale più bassa, erano riusciti a svolgere il *cursus honorum* ed a rivestire cariche importanti (come il consolato) nobilitando così la propria stirpe e facendo sentire anche le istanze delle classi sociali inferiori.
La nobilitas conosce al suo interno gradi diversi, lo strato più alto è quello senatorio, e variano poi dal punto di vista della ricchezza e del prestigio, e la base economica rimane ancora il possesso fondiario.

- Lo stesso vale per il nuovo ceto degli ***equites*** (i cavalieri) che si afferma accanto a quello senatorio.
I cavalieri sono coloro che pian piano, in questo periodo, riuscirono ad assumere un proprio peso sotto il profilo anche economico, si parla infatti di affaristi, banchieri, imprenditori o appaltatori di imposte , la cui ricchezza proviene da attività che sono diverse da quel modello del *vir bonus\ bonus agricola* soldato vittorioso, incarnano proprio un altro stereotipo di uomo nel senso commerciale, mercantile del guadagno.

In effetti anche i cavalieri sono grandi proprietari agricoli, o tendono ad esserlo e vedono nel possesso fondiario, punto, l'obiettivo di ogni loro investimento.
La definizione istituzionale di questo ceto come ordine equestre appartiene alla tarda repubblica, si determinò, innanzitutto, un limite censitario minimo che valeva tra l'altro anche per i senatori; Anche questo è infatti un ceto gerarchico, la cui appartenenza diventerà, tra l'altro, ereditaria:
Per entrare a far parte della prima classe di questo ordinamento centuriato era richiesto un censo di almeno centomila assi, per accedere alla cavalleria, alla quale solo i migliori potevano ambire, bisognava avere un senso pari o superiore a quattrocentomila sesterzi.
Il presupposto è formale era l'iscrizione censoria ad una delle 18 centurie equestri (da cui senatori erano esclusi) e potevano quindi partecipare alle attività di votazione dei comizi centuriati, nei quali avevano un peso non indifferente (per l'elezione dei magistrati, l'abrogazione delle leggi e le attività giurisdizionale) in quanto sommando il loro voto a quello delle classi censuarie più ampie, riuscivano ad essere decisivi per le decisioni, facevano da ago della bilancia, in quanto erano 193, di cui 80 appartenenti alla prima classe e 18 agli equites; sommando il tutto capiamo che costituivano la maggioranza.

> C’erano poi i gruppi subalterni che comprendevano plebe e schiavi:

-La plebe è costituita sempre meno di piccoli commercianti artigiani e di contadini che ancora coltivano in fondo proprio. È di fatto una massa proletarizzata in cui confluiscono nullatenenti e contadini impoveriti che vivevano perlopiù di elargizioni e occasioni di lavoro o, eventualmente, per sostenere gli uomini politici disposti ad aiutarla.
- Aumenta tra l'altro anche il numero degli schiavi in modo considerevole, e nonostante i movimenti popolari, e le rivolte servili siano molto forti, non riusciranno mai ad essere in grado di far saltare il sistema della società stessa.

Digressione: Le magistrature repubblicane

La Repubblica si organizza\ contempla al suo interno determinati organi:

> Abbiamo il *popolo*, che si riunisce nelle varie assemblee (*comitia curiata, centuriata* e *tributa*)

> Il *senato*: quell'organo che aveva un ruolo di direzione politica, all'interno del quale confluivano tutti gli ex magistrati che hanno importanza elevatissima

> E infine le magistrature

Le magistrature repubblicane, che altro non sono che cariche pubbliche elettive e temporanee, si rifanno ad un'organizzazione primitiva, e via via, col passare del tempo, si va definendo la loro autonomia:

- In origine, con la *Lex curiata de imperio,* l'assemblea curiata ratificava\ riconosceva formalmente il potere al magistrato: l'***imperium****.

Con l'*imperium,* che indica il potere militare, il magistrato assumeva proprio una funzione di "capo", è proprio sul potere militare che infatti si fondava la sua forza, pur ricercando l'approvazione popolare.

La *suprema carica* inizialmente veniva probabilmente rivestita da due magistrati: si ritiene che fossero i *consules*, però alcune testimonianze, poiché la *suprema carica* si identificava nel potere militare, ritengono che il nome dei primi magistrati fosse quello di pretori (da *pre-ire* che indicherebbe proprio l'andare avanti, il tenere\ condurre il comando militare)

> Oltre a quelli militari, però, la magistratura prevedeva anche anche dei poteri civili che vanno pian piano a delinearsi, e abbracciava i due campi che poi furono designati come *coercitio* e *iurisdcitio*.
- Quindi l'*imperium* inteso in senso stretto è il comando militare.
- In senso più ampio include la *coercitio* e la *iurisditio*:

  - La *coercitio* è l'esercizio di poteri coercitivi, di sanzioni punitive: la possibilità di infliggere delle sanzioni punitive\pene;
  - La *Iurisditio* concerne i poteri giurisdizionali: *dicere ius*, rivestire delle funzioni nell'amministrazione della giustizia

    > A ciò si aggiungevano degli strumenti nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali:

    1 - lo *ius agendum cum populo:*
    La facoltà di convocare il popolo in assemblea e di proporre la votazione delle candidature di altri magistrati o la votazione delle leggi;

    2 - lo *ius agendi cum senato.*
    La facoltà di convocare il senato e di interrogarlo su determinate questioni;

* L'*imperium* poteva inoltre essere:
- *Imperium militiae:*
  Esercitato non a Roma, nel campo militare, in ambito di operazioni militari.
  - Comportava la possibilità di punire a propria discrezione, da parte del magistrato, il cittadino che si fosse reso colpevole di alcune trasgressioni, quindi disciplinandolo con pene corporali e addirittura anche di farlo giustiziare
- Imperium domi
  Quindi nella circoscrizione di Roma, che quindi comportava dei limiti maggiori;
  - Vi era ad esempio la possibilità per il cittadino minacciato di punizione (da parte di un magistrato) di appellarsi al popolo in base alla *Lex Valeria de provocatione* del 320 a.C. che regolamentava proprio questa opportunità del cittadino che si vedeva perseguitato dalla possibilità di incorrere in sanzioni molto gravi di invocare l'aiuto del popolo, convocato in assemblea, per sottrarsi alle pene.

(E questo ci fa capire quanto importante fosse l'imperium e cosa comportasse; Quindi imperium militiate che dava possibilità di punizione addirittura fino a decidere la morte del cittadino, e poi l'imperium domi che in qualche misura era morigerato dalla possibilità del cittadino di chiedere aiuto al popolo.)

Le magistrature potevano essere dotate o meno di queste prerogative, in base a ciò venivano definite:
- *cum imperio*
- *sine imperio*.

> L'altra caratteristica generale delle magistrature è che hanno una ***durata annuale*** e questo rappresenta un limite in realtà, perché siamo in una repubblica, per cui non ci può essere il pericolo che qualcuno detenga il potere per troppo tempo e che vada a diventare poi un potere personale;
- La repubblica comporta un equilibrio sia degli organi tra loro, sia all'interno degli stessi organi.
E la durata annuale rappresenta proprio un limite che vada a contenere i poteri magistratuali.

> Allo stesso scopo vi è anche la caratteristica della ***collegialità***: infatti ci sono almeno due magistrati per ogni carica, il che significa che ciascuno può esercitare *l'intercessio*: quindi ha un diritto di veto nei confronti delle decisioni dell'altro (ciò significa che bisogna che ci sia per forza l'unanimità perché c'è un controllo reciproco in base al quale nessuno può prevalere sull'altro in maniera totale).

- Questo bilanciamento dei poteri del magistrato dato dalla durata e dalla collegialità con il potere dell'*intercessio* è estremamente importante.

Magistrature *cum imperio*
Possono essere
- Ordinarie
- Straordinarie

1- Ordinarie

Le magistrature ordinarie sono quelle magistrature che nella normalità dello svolgimento della vita della repubblica debbono funzionare, sono in carica e si rinnovano annualmente:

> Tra le magistrature cum imperio ordinarie abbiamo:

• *Consoli*
Hanno il comando militare (appunto l'imperium), possono ordinare leve militari, imporre tributi, convocare i comizi, presentare proposte di legge, convocare il senato (*ius agendi cum popolo o cum senato*) a cui sottoporre una questione determinata, poi ancora, possono emanare ordinanze, combinare sanzioni anche senza processo in esecuzione di ordini, e poi detengono il potere di *iurisdictio civile.*

• *Pretori*
- Istituiti nel 367 a.C. con le *leges liciniae sextiae,* avevano poteri molto vicini a quelli del console, tant'è che in alcuni casi potevano addirittura sostituirli;
- I pretori avevano un'importante funzione della iurisdictio, in maniera più marcata, ad esempio abbiamo visto nel processo *per legis actiones* il ruolo del *praetor urbanus*, ma vedremo anche nel diritto commerciale l'istituzione del *praetor peregrinus* che avrà molta importanza nella *iurisdictio* tra *cives* romani e anche stranieri.

2- Straordinarie
Le magistrature straordinarie vengono nominate solo in circostanze eccezionali, ad esempio i situazioni di crisi generale della stabilità della repubblica:

> Tra le magistrature cum imperio straordinarie abbiamo:

• *Dittatore*
Si tratta soggetto che viene nominato e assume determinati poteri in situazioni critiche per traghettare la repubblica fino a trovarsi nuovamente in una condizione di normalità.

• Magister equitum
Che è subordinato al dittatore; un esempio ne sono i *decemviri latini,* nominati appositamente per dare vita alle leggi delle 12 tavole, quindi con dei compiti specifici in situazioni straordinarie, non convenzionali.

Magistrature *sine imperio*
- Ma dotate di *aliqua potestas*, quindi di un altro tipo di specifiche funzioni statali
> Sono:

- *Questori*

Che amministrano l'*aerarium*, quindi il patrimonio dello Stato, del fisco, la riscossione dei tributi; nel tempo il numero dei questori cresce da 2 a 20;

- *Censori*

Che hanno un compito molto particolare:
Venivano eletti 2 censori ogni 5 anni per 18 mesi e svolgevano proprio la funzione di controllo\ di aggiornamento delle liste dei cittadini (del censimento) e anche la loro distribuzione nelle varie classi,
- Infatti sappiamo che i *comitia centuriata* avevano come caratteristica quella di essere divisi in cinque classi ciascuna con un determinato censo, e quindi bisognava che queste liste fossero costantemente aggiornate in quanto erano determinanti nella votazione delle leggi, ma anche per l'elezione dei magistrati.
- E per lo stesso motivo era importante che fossero liste aggiornate per la divisione in tribù, e quindi la distribuzione territoriale degli stessi cittadini.
- Provvedevano anche all'ammissione degli ex magistrato nel senato
- Davano gli appalti in appalto agli imprenditori i lavoratori pubblici.
- E concedevano in affitto le terre statali.
> Tra l'altro l'idea del censore evoca anche un'attività di controllo dei costumi, quindi la loro carica prevedeva un certo prestigio poiché godevano di una forma di controllo sui costumi dei cittadini morigerandoli in qualche maniera.

- *Edili curuli*

- Si chiamano così per la sella *curulis* che è il seggio\ la sedia del giudice che era senza schienale, trasportabile su un carro accompagnato da *littori:* soggetti che tenevano dei fasci recanti delle verghe e degli scudi che sono simboli della *coercitio*, e quindi della possibilità di procedere alla *verberatio:* fustigazione, e la decapitazione.
- Questi avevano funzioni di polizia del mercato e delle strade, quindi di controllo.
- Avevano la giurisdizione delle liti di mercato e in certe questioni di orine pubblico.
> Quindi la *iurisdictio* degli edili curulei si esplicava per lo più in questioni soprattutto di commercio, quindi nelle liti di mercato, ad esempio le compravendite di schiavi, o alcuni commerci tipici di alcuni momenti dello svolgimento del mercato dei beni di mercato, le controversie nascenti del mercato.

- Tribuni plebis

I *tribuni plebis*, direttamente eletti dai *concilia plebis*, preposti a difendere proprio i loro interessi contro le genti patrizie dominanti.
Veniva fatto un giuramento solenne dei plebei con cui essi si impegnavano a vendicare con la morte qualsiasi offesa ai tribuni, e questo assicurava ai *tribuna* stessi la cosiddetta *sacrosanctitas*: la sacrosantità, cioè l'inviolabilità della loro persona per tutta la durata della loro carica. Essi prestavano aiuto ad ogni singolo cittadino per soprusi e ingiustizie, e convocavano i *concilia plebis*.

> Il *cursus honorum* poteva prevedere, dopo 10 ani di servizio nell'esercito, l'accesso alla questura, poi all'attività curulea, poi alla pretura, e poi al consolato.
- La carica più elevata era appunto il consolato.

2. Il diritto commerciale

In questo nuovo contesto economico che prevedeva da una parte il rapportarsi con gli stranieri e dall'altra la necessità di una maggiore velocità nella prassi giuridica, venne a galla l'inadeguatezza del *ius civile*, considerato "*vetus*" il cui estremo formalismo iniziò ad essere percepito come un limite ed una difficoltà: nasce allora il ***diritto commerciale*** romano, una nuova realtà giuridica caratterizzata dal superamento del formalismo.

Questa è, però, un'espressione da usare con i dovuti accorgimenti:
> Nella sua ***accezione moderna***, intendiamo il diritto commerciale come un ramo speciale\ autonomo dell'ordinamento giuridico in cui regole e istituti riguardano propriamente il commercio inteso come traffico organizzato; Questa accezione di *ius mercatorum* che va a definirsi nel medioevo, attualmente la utilizziamo solo in rapporto a quelle società che hanno uno specifico corpo di norme le quali regolano l'attività commerciale.

> Non possiamo però trasporre questa accezione al diritto commerciale romano.
Non che nel mondo romano nel mondo greco non esistessero degli istituti propri del commercio (in particolare commercio marittimo), ad esempio nel mondo greco ricordiamo le δίκαι ἐμπορικαὶ le "azioni commerciali" che si caratterizzano per avere una procedura rapida, di fatti è proprio questa l'esigenza del diritto commerciale. Ciò però non andavano implicare una contrapposizione tra gli atti commerciali dello e gli atti di diritto civile.

Il ***significato*** che bisogna dare alla locuzione "diritto commerciale" romano, ha un significato molto più ampio: è una realtà giuridica nuova che va intesa come complesso normativo scevro di formalismo, che nasce per far fronte alle esigenze dei traffici mercantili nel Mediterraneo e doveva essere utile non solo ai mercanti e ma aperto a cittadini e stranieri.

L'espressione che identifica il diritto commerciale inteso in tal senso, e che va a contrapporsi al *ius civile*, è infatti *ius gentium*: diritto delle *gentes:* dei popoli.
- E questo proprio perché si tratta di una sfera normativa\ di un complesso di diritti e prerogative che possono essere utilizzati da tutte le *gentes* che si trovano in rapporto con i romani.

> Bisogna sempre stare attenti all'ottica con cui ci si accosta alle definizioni, in questo caso risulta opportuno comprendere il rapporto tra le sfere normative:

1- In una prima analisi di tipo giuridico-comparativa tra *ius gentium* in rapporto al *ius civile*, ne potremmo cogliere una prima differenza:

- Il *ius civile* era ad uso esclusivo dei *cives* romani, l'espressione arcaica *"ius Quiritium"* ne è significativa.
  Lo straniero era infatti privo di tutela giudiziaria, ad eccezione di casi particolari come trattati internazionali o la concessione dello *ius commercium* (che era la facoltà di compiere negozi civilistici patrimoniali), o del *conubium* (che, allo stesso modo, era la facoltà di concludere un valido matrimonio).

- Il *ius gentium*, al contrario, riguarda tutti i popoli, comprende un apparato normativo per il commercio che poteva essere applicato tra cittadini e stranieri o anche per stranieri tra loro (in territorio romano).
Ad esempio: la *potestas* sugli schiavi (riscontrabile *ugualmente presso tutti i popoli*), tutela sugli impuberi (presente nel *diritto di ogni città*), cattura in guerra, *alluvio* o *traditio* come modi di acquisto del dominio, *numeratio pecuniae* , permuta, ripetizione di cose tenute senza titolo giustificativo, uso del lido, concessione di un bene in precario, proibizione dell'incesto;

2- D'altro canto, se applicassimo un'analisi giuridico-sistematica, potremmo cogliere tra *ius gentium* e *ius civile*, una certa vicinanza, in quanto sono ricompresi nel *ius gentium* alcuni istituti di origine civilistica, che appunto vengono estesi oltre l'ambito strettamente cittadino.
  (E quindi potremmo dire che anziché differenziarsi, lo *ius gentium* tenda ad avvicinarsi al *ius civile*, tant'è che, ricordiamo, nessun istituto nasce dal nulla, ma è il frutto di una elaborazione dei giuristi a partire da matrici più remote ed arcaiche).
Alcuni *esempi* di istituti che si estendono agli stranieri sono: la *stipulatio* e l' *acceptilatio,* ed il *depositum* e il *commodatum* trovano posto fra le *conventiones iuris gentium*;

3- In un senso filosofico-speculativo, invece da alcune testimonianze abbiamo la possibilità di riflettere sul rapporto tra *ius gentium* e *ius naturale*

- Secondo un'interpretazione gaiana, infatti, trapela che talvolta *ius gentium* può essere identificato con *ius naturale*, in quanto è possibile affermare che si fondi a priori su una *ratio naturalis* che lo rende suscettibile di applicazione generalizzata a tutti i popoli.
- Talvolta, però, il rapporto *ius gentium-ius naturale* viene impostato in senso gerarchico, cioè, mentre *ius gentium* riguarderebbe solo gli uomini, con *ius naturale* si intende una sfera che abbraccia tutti gli esseri viventi della terra, per cui è possibile individuare *ius gentium* come una specificazione (una *species*) di un più ampio *ius naturale* (*genus*).

(Ma comunque da giurista giurista siano diverse impostazioni, possiamo infatti farvi rientrare anche una serie di principi e valori che vengono in mente quando si parla di ius naturale, che hanno un respiro ampio)

4- Possiamo inoltre guardare lo *ius gentium* in rapporto allo *ius honorarium*

Lo *Ius honorarium*, da *honos, honoris*, fa riferimento alle cariche magistratuali, quindi è il diritto che deriva\ che è inerente alla comunità dei magistrati, **(vedi digressione sulle magistrature).**

In particolare possiamo intendere solo *ius praetorium* poiché l'attività più rilevante è quella del *praetor.*

In questo periodo, nel 242 a.C., venne istituito (accanto al *praetor urbanus*) il *praetor peregrinus* che è un magistrato preposto a gestire liti tra *cives* e *peregrini* stranieri, oppure semplicemente tra stranieri.

Proprio con l'istituzione del pretore peregrino che rapporti di diritto commerciale non rimasero senza tutela.

> Tant'è che anche in ambito processuale si ha un'evoluzione;

- Accanto alle *legis actiones* nell'ambito dello *ius civile*, che erano prerogativa solo dei *cives romani*,
- Nasce un altro tipo di processo, poiché le controversie iniziarono ad insorgere anche in rapporto con gli stranieri, per cui era necessario un processo che fosse aperto anche agli stranieri e che non fosse intrappolato nelle forme rigide delle *legis actiones*: il <u>*processo formulare*</u>, che era privo di formalismo e che offre tutela processuale ai *nova negotia* del *ius gentium.* (Da non confondere con quello *formale* arcaico)

(Ripresa più completa dell'argomento all'inizio del paragrafo 4. Il pretore e l'editto)

> Oltre alle esigenze del rapporto con gli stranieri, un'altra caratteristica fondamentale dello *ius gentium* è il ***superamento del formalismo***:

Chiaramente, le dinamiche del commercio non potevano sopportare le formule "trappola" del formalismo, che rallentavano e complicavano lo svolgimento del processo.

Si andarono allora a formare dei *"nova negotia"* sempre nell'ambito del diritto privato, e quindi relativi a soggetti privati, ma che avevano caratteristiche strutturali estremamente diverse da quelle impregnate di rigido formalismo del ius civile;

- Nell'ambito del ius civile erano i rigidi canoni formali a produrre il diritto (come ad esempio la pronuncia di "*certa verba*", la solennità, il compimento di gesti predeterminati, il rito. insomma, tutti quei requisiti oggettivi e soggettivi che servivano per produrre il diritto), qui la forma ha una rilevanza esaustiva, la validità o la nullità di qualsiasi atto dipende esclusivamente dalla forma.
- Nell'ambito del *ius gentium*, tutto ciò si perde a favore della ***volontà***: ora conta l'interno volere.

Accanto agli istituti del ius civile si aggiungono dei *nova negotia* che sono dei veri e propri contratti <u>*consensuali*</u> (e quindi è diritto privato, riguardano il rapporto tra privati), cioè sono contratti che si perfezionano in relazione al consenso liberamente manifestato dalle parti.

3. Le regole del gioco

Dunque con le nuove esigenze imposte dalla nuova realtà commerciale si rende necessaria da una parte la tutela giuridica dello straniero, e dall'altra il superamento del formalismo (che sta proprio nella consensualità), in quanto gli antichi negozi dello ius civile (il *mancipium*, la *in iure cessio* o la *sponsio*) e le antiche procedura, risultavano inadeguate risolvere le difficoltà che ora la prassi stava ponendo per la prima volta.

Nascono i ***nova negotia***:
1- *Locatio conductio* (locazione-conduzione)
2- *Mandatum* (mandato)
3- *Societas* (società)
4- *Emptio venditio* (detta anche compravendita consensuale)

> Quando si parla di *ius gentium* si para proprio di questi quattro *nova negotia* che in sintesi sono:
> - Sono privi di formalismo.
> - Gli effetti non si determinano in base al rispetto della forma ma in base alla volontà, e la parola è solo uno strumento attraverso il quale manifestare la volontà
> - Nel momento in cui le volontà dei contraenti convergono si parla di consenso:
> - E infatti sono quattro contratti consensuali: cioè le obbligazioni in capo ai contraenti nascono nel momento in cui viene manifestato il loro consenso.
> E questo, ovviamente, è quanto di più consono ai commerci, poiché i commerci richiedono rapidità, richiedono istituti\ negozi che siano agili, per cui, l'elemento caratterizzante quale può essere se non il fatto che gli effetti si sortiscano in virtù della volontà manifestata dai contraenti?
> - Infatti l'astrazione che il diritto commerciale introduce, non ha nulla a che fare con quella implicita "dell'evidenza sensibile" delle forme arcaiche, ma ora l'astrazione è la tipicità stessa del rapporto, che dipende solo dalla sua funzione pratico-economica.

Bona fides

> Nella prassi di questi nuovi contratti, il rapporto obbligatorio è sorretto dalla "buona fede", che non è un atteggiamento etico, ma è proprio un elemento che fa parte di questi istituti\ contratti che consiste nella persuasione che occorre rispettare le regole del gioco; subentra quindi elemento nuovo: la *bona fides,* che determina e giustifica la tutela giurisdizionale.

Si può ricondurre la *fides* latina al valore Greco della *πίστις*, entrambi i termini rientrano nel campo semantico della "fiducia".

L'origine di questa *fides*, di questa fiducia, che si va poi tecnicizzando, è da ravvisare nella *πίστις* greca; Aristotele, nell'Etica Nicomachea (trattato filosofico composto da dieci libri), in particolare nell'ottavo e nel nono libro, interamente dedicati all'amicizia, ci offre una compiuta elaborazione teorica che riconduce la *fides* alla *φιλία* ("amicizia") che può essere fondata o sull'utile, oppure essere determinata dal piacere reciproco, e la forma più rara e duratura si ha solo fra gli uomini virtuosi il cui amore è rivolto essenzialmente al bene.

In particolare la *pistis* assume rilievo nell'ambito dell'amicizia utilitaria\ utilitaristica, e di questa, per far capire su cosa poi si fondino i rapporti tra gli esseri umani (in particolare i privati dal punto di vista giuridico), possiamo distinguerne due specie: una morale e una legale.

(Testo pag. 135)

- Nell'ottavo libro dell'Etica Nicomachea, Aristotele spiega, appunto, che la controversia è un momento patologico del rapporto, "nasce, perlopiù nel momento in cui gli uomini non sciolgono i loro vincoli secondo lo stesso tipo di amicizia col quale gli hanno contratti", e cioè è un attrito a generare la controversia:
La controversia processuale nasce ad esempio quando un'amicizia (utilitaristica) viene tradita\ quando si viene meno agli accordi presi, cioè, non è un qualcosa di prestabilito, non c'è un accordo che stabilisca il

momento in cui quel rapporto d'amicizia deve terminare dopo aver prodotto una controversia, ma bisogna che accada qualche attrito che comporti proprio la controversia (es. il ritardo del pagamento di un debito)

- Nell'ambito dell'amicizia utilitaristica, che lega i soggetti per utilità, esiste l'amicizia legale, che è un rapporto legale di fiducia fondato sui determinati patti\ termini convenuti.
Possiamo considerare due forme di amicizia legale:

1- La sua forma puramente commerciale che consiste in uno scambio immediato "da mano a mano", cioè è un rapporto attuale che si consuma materialmente tra i soggetti (privati).

2- La sua forma più liberale che consiste in un accordo circa lo scambio, differito nel tempo; l'elemento caratterizzante è proprio il differimento temporale.
Capiamo allora quanto, specialmente in questo caso, sia importante l'elemento dell'amicizia, della fiducia, poiché, per pattuire uno scambio non immediato, c'è bisogno che ciascuno si fidi dell'altro.
In tutti i rapporti, specialmente negoziali, l'affidabilità dei due o più soggetti coinvolti è essenziale, se volessimo fare un esempio attuale, ancora oggi nel momento in cui si entra in un negozio per acquistare una determinata cosa, noi clienti siamo compiendo un atto di fiducia nei confronti del commerciante, tant'è che se pensassimo che quel determinato commerciante non sia onesto, e quindi se non ci fidassimo, chiaramente non acquisteremo in quel negozio specifico.

Per cui capiamo che alla base dei rapporti di scambio o dei rapporti negoziali in generale, ci deve essere la fiducia reciproca.

- Aristotele conclude precisando che in alcuni Stati non ci sono azioni giudiziarie per questo genere di rapporti, ma coloro che stringono accordi sulla base della fiducia (*katà pistin*) "sanno di dover sopportare le conseguenze", e in effetti, rapportandoci all'epoca in cui viveva Aristotele, dobbiamo considerare che ci fosse la possibilità di subire delle conseguenze a causa della trasgressione di quel vincolo di fiducia.

> Dalle parole di Aristotele, abbiamo la possibilità di comprendere il fatto che questo concetto di fiducia non è un valore giuridico del tutto nuovo, naturalmente, già esisteva, ma vediamo come subisca un'elaborazione tecnica tramutandosi poi in quella che dobbiamo intendere come *bona fides* che è anche un'azione di onestà, affidabilità, di rispetto nei confronti delle promesse non formali.

> La *bona fides* è quindi una categoria, estremamente rilevante, che rievoca la reciproca fiducia tra le parti del rapporto contrattuale, e ne fonda il vincolo seguendo, allo stesso tempo, la misura del comportamento delle parti ed il criterio della responsabilità di chi vi trasgredisca.

Proprio in base a ciò l'elemento della *bona fides* fornisce al giudice un ampio margine di discrezionalità nel momento dell'emanazione della sentenza: si parla infatti di ***iudicia bonae fidei***.

- Cioè, essendo la buona fede l'elemento oggettivo di cui tener conto nell'ambito dell'adempimento delle obbligazioni, e che va proprio a tutelare questi contratti consensuali privi di formalismo, nel momento in cui il giudice andava ad emanare la sentenza (nella seconda fase del processo formulare), non si limitava semplicemente a condannare o assolvere, ma, in una più ampia discrezionalità, quando doveva stabilire di chi fosse e in che misura la responsabilità, doveva andare a considerare la buona fede delle parti contraenti.

- Infatti, oltre al rapporto, la fiducia ha il suo modo concreto di manifestarsi (può avere tante manifestazioni), E questo perché nell'ambito di una qualsiasi vendita, società, locazione, mandato, ciò che ciascuna parte si aspetta dall'altra non è incancellabile, può avere le più ampie modalità esecutive, espressive di aspettative reciproche, quindi, quando poi il rapporto entra in patologia e si crea una controversia, il giudice, in concreto, per il modo in cui si è esplicato quel rapporto, doveva stabilire la misura della responsabilità e l'azione era buona fede che presiedeva il rapporto stesso

• ***Locatio conductio***

> Nell'ambito di questo contratto di locazione-conduzione, le parti in capo alle quali nasce l'obbligazione sono il locatore ed il conduttore:

- Il locatore si impegna a mettere nella materiale disponibilità del conduttore una cosa mobile o immobile purché inconsumabile, per un periodo di tempo limitato e\o ad uno scopo ben preciso. (Vi rientra anche il trasporto marittimo o come locazione della nave o come locazione del carico)
- Il conduttore, si impegna ad averla in consegna ed a restituirla una dopo essersene servito per il periodo di tempo stabilito, o dopo averla manipolata o trasportata nel modo convenuto, ma con l'obbligo di pagare un corrispettivo che prende il nome di *merces* ("mercede")

> Questo è un contratto:

- Consensuale poiché le obbligazioni nascono nel momento in cui convergono le volontà delle due parti.
- (Bilaterale perfetto)
- Sinallagmatico poiché ci sono prestazioni corrispettive, quindi prestazione e controprestazione.
- A titolo oneroso in quanto il conduttore all'obbligo di pagare la mercede.

> Considerando la *Locatio conductio* un *genus*, possiamo individuarne diverse *species*;

Distinguiamo infatti:

1. Locatio condutio rei

Che è la locazione-conduzione della "cosa", in cui il locatore cede al conduttore il temporaneo uso o godimento di una res (mobile o immobile purché inconsumabile) dietro pagamento della mercede (c'è sempre il pagamento di un corrispettivo)

2. Locatio condutio operarum

Che è la locazione-conduzione delle opere, in cui il locatore mette a disposizione del conduttore i propri servigi, le proprie opere, sempre con il pagamento di un corrispettivo.

- Pensiamo a questa *locatio-condutio* come all'origine dei rapporti di lavoro.

3. Locatio condutio operis

La locazione conduzione operis è il contatto di locazione-conduzione intesa come obbligazione di risultato, cioè il locatore mette a disposizione del conduttore dei materiali di sua proprietà su cui lo stesso conduttore si impegna prestare un servizio o un lavoro(come una manipolazione o un trasporto) con lo scopo di raggiungere uno specifico risultato a vantaggio del locatore, che in questo caso è colui che deve pagare un corrispettivo (la *merces*) al conduttore.

Esempi: trasporto di un carico, lavaggio di biancheria, lavorazione dell'oro…

• ***Mandatum***

È un contratto stipulato tra due parti: un mandatario ed un mandante

- Si ha un *mandatum* nel momento in cui il mandatario si impegna nei confronti del mandante a fare gratuitamente qualcosa di cui il mandante gli dà incarico; In altre parole: il mandante dà l'incarico al mandatario di svolgere una determinata attività e il mandatario la deve svolgere gratuitamente.
- Ovviamente, però, nel caso in cui il mandatario incorra in spese o in danni nell'esercizio del suo mandato, potrà rivalersi nei confronti del mandante (per l'eventuale risarcimento).

Questo è un contratto:

- Consensuale
- Bilaterale imperfetto poiché l'obbligo (che è quello di eseguire l'incarico gratuitamente) scaturisce solo in capo al mandatario, ***ma*** nell'ipotesi in cui intervengano delle spese per l'esecuzione del mandato o eventualmente il mandatario incorre in danni, può esserci la rivendicazione nei confronti del mandante per ottenere il risarcimento: ciò vuol dire che in tali casi scaturisce un obbligo anche a capo del mandante.

> Capiamo che, nell'ambito dei commerci, questo fosse un contratto estremamente utile, pensiamo ad esempio all'ipotesi in cui ci fosse la necessità di dover svolgere degli incarichi in territori lontani, e non potendo essere fisicamente presente, spesso si ricorreva questo tipo di contratto per conferire incarichi ad altri soggetti di avere la possibilità di eseguire delle attività non in prima persona.

• ***Societas***

La *societas iuris gentium*, come, in realtà, tutte le istituzioni, non era nata dal nulla, ma ha una sua discendenza remota, Gaio, nelle institutiones la individua come terza species del genus societas, una sorta di terza evoluzione: dal *consorzio dei fratelli coeredi* si arriva *alla societas ius gentium.*

- Il consorzio di fratelli coeredi (o *consortium ercto non cito* "senza divisione del dominio") si veniva a creare nel momento in cui, alla morte di un *pater familias*, in virtù della *fraternitas*, tutti *fratres* che erano sottoposti al potere del *pater familias* deceduto (si dicono *fratres sui*) diventavano comproprietari del patrimonio indiviso del *pater familias*, cioè il patrimonio non veniva diviso per ogni *frater* che poteva gestire la propria fetta in autonomia, ma rimaneva tutto intero, gestito a pari rilevanza da tutti i fratelli.
- Sullo stesso modello del consorzio dei fratelli coeredi si viene a formare un nuovo tipo di società che potremmo definire *societas iuris civilis*, che comprende soggetti estranei, che non hanno il vincolo della *fraternitas*, ma che vogliono perseguire il compito di una cogestione patrimoniale.
- Si arriva poi a quest'ultimo tipo di società: la *societas iuris gentium* che nasce proprio in relazione alle nuove esigenze poste dallo sviluppo dell'economia commerciale;

È un contratto consensuale plurilaterale che, che si contrae "con il nudo consenso" tra due o più soggetti\ soci estranei, non legati da alcun vincolo, che stipulano una vera e propria collaborazione associativa. Quindi volontariamente (e non, ad esempio, per uno status familiare vero o fittizio che sia ma per un "*consensus*") vanno a creare un vincolo impegnandosi a mettere in comune beni, denaro o opere, per perseguire scopi determinati vantaggiosi per tutti, come l'esercizio di un'attività economica o di un singolo ramo del commercio, e profitti e perdite venivano poi divisi.

- Quindi vediamo che l'individuo non ho più rilievo in quanto membro di un gruppo come accadeva nell'ambito del consorzio dei fratelli coeredi, ma rilievo nella sua individualità: il soggetto si rivela in quanto tale, tanto che conta moltissimo la fedeltà tra i soci, tra persona e persona, al punto che al venir meno di uno solo dei soci, andava distinguersi l'intera società (si dice infatti *intuitu personae* letteralmente "avuto riguardo alla persona" proprio perché si dà particolare rilevanza a ciascun soggetto contraente).

• ***Emptio venditio***

La compravendita romana non va associata a quella attuale, si tratta di un contratto <u>consensuale</u> in cui :

- Il <u>venditore</u> si obbliga a garantire al compratore, il pacifico godimento\ la disponibilità, della *res* oggetto di scambio che prende il nome di *merx* ("merce" da non confondere con la *merces* "mercede" del *mandatum*)
- E il <u>compratore</u> si obbliga a versare il corrispettivo in denaro.

Così come il consorzio dei fratelli coeredi e la *societas*, è possibile mettere in relazione la *mancipatio* e la *emptio venditio* in quanto in entrambi i casi vediamo uno scambio di cosa contro prezzo, ma analizzando la *emptio venditio* possiamo notare quanto essa sia rappresentativa del superamento del formalismo (che in realtà è il minimo comune denominatore di questi *nova negotia* che si contraggono in modi liberi, scevri da tutte le modalità ritualistiche del formalismo)

- <u>*Mancipatio*</u>

La mancipatio È il negozio costitutivo del dominium, cioè, siamo nell'ambito dei diritti reali, e si tratta proprio del modo di acquisto della proprietà sulle res mancipi

E per essere valida, e sortire l'effetto voluto (acquisto della proprietà) la mangi patio doveva essere svolta nel pieno rispetto di tutte quelle caratteristiche rigidamente formali, e quindi rispettando il ruolo del mancipio dans che restava in silenzio, il mancipio accipiens che pronunciava la formula vendicatori, il libripens che teneva la bilancia, e poi ancora, il simbolico percuotere la res con la festuca, poi la presenza del bronzo che veniva posto sulla bilancia, la pronuncia di "certa verba" in presenza di un determinato numero di testimoni…

Solo compiendo correttamente tutte le attività rituali e determinate, allora la proprietà della res poteva passare da una sfera potestativa all'altra.

> *Emptio vendictio*

> Con la *emptio vendictio*, la struttura cambia radicalmente;

- Innanzitutto si tratta di un contratto, quindi siamo nell'ambito dell'obbligazioni, per cui una prima differenza sta nel fatto che per la mancipatio l'efficacia\ il fine immediato sta nel trasferimento del diritto di proprietà, mentre la *emptio vendictio* ha invece efficacia obbligatoria, l'effetto immediato è la creazione di un vincolo obbligatorio in capo alle due parti che si stipula in virtù del consenso liberamente manifestato dai contraenti: il venditore si obbliga a consegnare la *merx*, il compratore a pagarne il prezzo (quindi cosa e prezzo non si trasferiscono subito da un soggetto all'altro), lo scambio verrà realizzato in un momento successivo all'accordo, ecco perché, anche qui l'importanza della bona *fides* è fondamentale.
(E tutto ciò accade senza nessun necessario ritualismo, senza che vi vi sia la presenza di un numero specifico di testimoni, senza che vi sia la necessaria presenza della merx, addirittura senza la necessaria presenza fisica di tutti i contraenti).

- Nel corso del tempo, poi matureranno i termini dell'*usucapione:*

Per cui la cosa che è stata ricevuta dal compratore nel suo pacifico godimento (della quale è quindi in possesso*) a seguito del decorso del tempo, se questo possesso avrà determinate caratteristiche, farà maturare la proprietà.

* *Possesso*:
È il rapporto di fatto con la *res,* giuridicamente rilevante, in cui conta la materiale disponibilità.
È il *corpus possidere*: il possedere materialmente una *res*, ma lo stesso tempo anche l'intenzione di comportarsi verso questa res come se fosse propria.
Con "possesso" parla proprio di *corpore et animo possidere*, in riferimento, appunto a questo rapporto di fatto con la res, che comporta da una parte la materiale disponibilità, e dall'altra questo atteggiamento\ intenzione nei confronti della res di comportarsi come proprietario rispetto a quest'ultima, con la volontà di difenderla e conservarla.

* La *proprietà* è ben diversa:
È il dominio assoluto, il diritto reale per eccellenza.
Le caratteristiche del *dominium* sono pienezza, assolutezza ed elasticità.
- Va proprio ad escludere l'ingerenza altrui dal proprio rapporto con la *res* che è un rapporto di dominio assoluto il quale viene a svilupparsi in base ad un regolare titolo acquisitivo.
- La *mancipatio*, ad esempio, rappresenta un titolo idoneo ad acquistare la proprietà delle *res mancipi*, per cui dopo questo atto di autonomia privata, il proprietario può disporre della *res* che ormai è rientrata nel suo *dominium*\proprietà nel modo in cui crede, addirittura può anche istituire, su quella cosa specifica, dei diritti di godimento a favore di altri (e questo è proprio l'elasticità del *dominium*).
Quindi il *dominus*, ad esempio, può istituire un usufrutto sulla cosa a favore di un altro soggetto mantenendone il titolo potestativo, e quindi la nuda proprietà, per cui può dare il diritto di godere e fruire dei beni, dei vantaggi e dei profitti della cosa all'usufruttuario; ma all'estinguersi dell'usufrutto il *dominus* rientra pienamente nel *dominium* della *res*.

> L'*usucapione* non è altro che un tipo di possesso particolarmente qualificato, la possiamo identificare proprio come un altro modo di acquisto della proprietà che è connesso al decorso del tempo.
> Ma perché vi sia questo effetto, devono ricorrere a determinati requisiti:

- Deve trattarsi di una *res abilis*: una cosa idonea ad essere usucapita (es. una cosa che deriva da un furto o che sia *extracommercium* non si può usucapire; un ladro che sottrae una cosa ad altri, col passare del tempo è paradossale che abbia la possibilità di diventarne proprietario).
- Deve esserci il *Titulus*: cioè ci deve essere la giusta causa acquisitiva, ad esempio la compravendita, una donazione, qualunque titolo acquisitivo del possesso che purché sia legittimo.
- La *Possessio*: rapporto di fatto con la cosa
- La *Bona Fides*: ci deve essere un rapporto con la cosa che deve essere stato intrapreso in piena onestà.

- E infine abbiamo l'elemento del *tempus*: rifacendoci ad una norma decemvirale avremo che è un anno per le cose immobili, e per le cose mobili.

> Quindi, quando ricorrono tutti questi elementi, e si ha questo rapporto di fatto particolarmente qualificato (cioè che presenta tutti questi elementi) con la *res*, basterà che trascorra un anno se si tratta di cosa mobile, due anni se si tratta di cosa immobile, affinché il soggetto usucapisca il bene, cioè affinché ne diventi proprietario in senso di dominus.

> Ritornando alla *emptio vendictio*, possiamo quindi affermare che la *emptio venditio* abbia una efficacia obbligatoria, perché succede che il venditore immette il compratore nel possesso (diverso dalla proprietà), e quindi il compratore sarà *tendenzialmente* poi, col passare del tempo, il *dominus* della *res* che è stata scambiata e per cui ha pagato il prezzo.

(La compravendita greca)

La compravendita romana è caratterizzata dall'originalità dell'idea consensualista.
L'idea consensualista non la incontriamo mai nel diritto greco, babilonese, egizio, ebraico o germanico.
> La compravendita greca (*one kai prasis*) è dominata dalla nozione del "*cash sale*", cioè in essa vige il principio della surrogazione: Per esistere ha bisogno che:
- il prezzo si sostituisca alla merce nel patrimonio del venditore.
- la merce si sostituisca al prezzo nel patrimonio del compratore.

Per stabilire questo momento, si dà la precedenza a quello fra i due che risultasse più rapide devi dente (il pagamento del prezzo), e se la cosa da vendere è caduta nelle mani del futuro compratore, il venditore può sempre rivendicarla finché il prezzo non gli sia stato pagato.
Notiamo che c'è un mutamento di qualcosa nel mondo visibile, in cui ogni accordo, in vista di questo spostamento da un patrimonio all'altro, ha solo il valore di un accordo preliminare e fra venditore e compratore non si crea nessun rapporto obbligatorio.

> Tuttavia si intravede forse una compravendita obbligatoria anche nel mondo greco, colta da Gernet, in cui vediamo tre aspetti rilevanti:

1- le obbligazioni reciproche del venditore e del compratore dipendono ciascuna dall'adempimento (o di un inizio dell'adempimento) dell'altra, nessuna delle parti potrebbe pretendere che l'altra adempia, se non ha adempiuto essa stessa la propria obbligazione.

2- la *pistis* (=fiducia) opera come criterio regolatore del negozio.

3- lo scritto ha un valore essenziale e la fiducia vi trova il suo sostegno.

> La compravendita greca, quando non si esaurisce in un atto "a contanti", è un'operazione in più tempi. Invece la *emptio venditio* si compie in un solo istante e in virtù del consenso.

4. Il pretore e l'editto

Il proceso formulare

Abbiamo visto che, in sostanza, le esigenze poste dal nuovo sviluppo economico commerciale erano da una parte l'abbandono del formalismo per accelerare i vari negozi, dall'altra la tutela giuridica dello straniero, ma anche (la tutela) dei *nova negotia.*

> Nel 242 a.C., accanto alla magistratura del pretore urbano (Istituita nel 267 a.C. con le *Leges Liciniae Sextiae*) che avevamo visto in azione nell'ambito del processo per *legis actiones* in particolare nella prima fase *in iure*, si istituì la magistratura del *Praetor peregrinus* (a cui poteva accedere anche la plebe) che aveva la funzione di amministrare la giustizia (così come il pretore urbano, anche il *Praetor peregrinus* aveva la *iurisdictio,* che ovviamente rientra nell'*imperium*), in particolar modo è innanzi al praetor peregrinus si inaugura il processo formulare:

- E cioè con l'introduzione del *praetor peregrinus* si avrà la possibilità di instaurare un processo anche tra cittadini stranieri e romani o cittadini stranieri tra loro (ma sempre in suolo italico, in quanto siamo sempre in una magistratura romana), e quindi i rapporti di diritto commerciale non rimasero senza tutela.

> Quindi anche in ambito processuale si ha un'evoluzione;
Infatti non esiste *ius* senza *actio*, non c'è diritto o istituto che possa esistere se non vi è il mezzo processuale che possa difenderlo (il giudizio); Diritto e azione sono due facce della stessa medaglia, per cui con la nascita dei nova negozia era nata la necessità di un tipo di processo che fosse più adatto.
- Se in ambito arcaico il *ius civile* si caratterizzava per l'esasperato formalismo negoziale (es. *mancipatio*) e processuale (*legis actiones*) tra l'altro *legis actiones* erano prerogativa solo dei cittadini romani.
- Con lo *ius gentium* la situazione cambia, innanzitutto si ha il superamento del formalismo, per cui il processo per *legis actione*s risulta essere inadeguato per offrire tutela ai *nova negotia* che di formale non avevano nulla, e si caratterizzano per velocità e dimensione consensuale, ma non solo, proprio perché il processo per *legis actiones* poteva riguardare solo e unicamente i cittadini romani, risulta chiaro che l'sarebbero state limitative in un contesto in cui si stava inserendo anche una forte presenza straniera in ambito negoziale\ commerciale.

> Quindi, accanto al processo civile arcaico per *legis actiones* nell'ambito dello *ius civile, con il ius gentium* nasce un altro tipo di processo: il ***processo formulare***
(Privo di formalismo, offre tutela processuale ai *nova negotia* ed è aperto anche agli stranieri)

> Questa nuova procedura fondata sulla ***formula***, coesiste con quella più antica delle *legis actiones*, ma tende gradualmente a sostituirla; A tal proposito ricordiamo degli eventi normativi importanti;
- Circa nel II secolo a.C. si colloca la *Lex Ebuzia de formulis*
È di contenuto è incerto, ma sappiamo che a questa si ricollega la limitazione dell'uso delle *legis actiones* riconoscendo ai cittadini la possibilità di ricorrere al processo formulare.
Ma siccome la legge non poteva abolire gli antichi istituti del *ius civile* (infatti sappiamo quanto fosse importante nel mondo romano antico la mentalità tradizionalista, proprio in base a questa si impediva la cassazione esplicita degli istituti del ius civile), per cui la *Lex Ebuzia* andava si limitava a rendere facoltativo il ricorso alla procedura formulare, e, una volta che si fosse agito con questa determinata procedura rispetto ad una questione, vietava la possibilità di ricorrere ad un processo per *legis actiones* con riguardo al medesimo oggetto.
- All'età augustea risale invece la *Lex Gulia* che alla fine andò ad abolire quasi del tutto l'antico processo delle *legis actiones*.

> Vediamo quindi come questa procedura formulare va prendendo piede, quasi soppiantando l'antico processo civile arcaico; inoltre se all'inizio era stata inaugurata dal pretore peregrino, pian piano venne esteso il suo impiego anche al pretore urbano, per cui possiamo parlare di pretore in generale.

> Abbiamo già visto che vi erano comunque già stati dei rapporti con gli stranieri nell'età più risalente, tuttavia questi venivano risolti maniera differente, con dei trattati di volta in volta oppure con istituti a loro favore, c'erano delle forme ad hoc che di volta in volta, nel momento del rapporto con lo straniero, disciplinare in generale la situazione (ad esempio: l'*hospitium* che era una forma di ospitalità\ solidarietà, c'erano poi i *fodera*, i "patti")
- Ma ora, in concomitanza con l'emissione del diritto commerciale, con la nascita del processo formulare, c'è la pena istituzionalmente garantita per ogni tipo di controversia.

La formula ed il processo
Quando si parla di processo formulare si parla anche di *Litigare per formulas*.
*"*Formula" è un termine che abbiamo già trovato nell'ambito del formalismo giuridico (es. *formula vindicatoria*), o comunque nei congegni formali, verbali e gestuali che si riconducono all'idea di formula.

> Ma nel nuovo processo formulare, la "formula" (o *iudicium*) è un'altra cosa
In sostanza è un atto scritto in cui il magistrato riassume quanto accaduto nella prima fase del processo (dinanzi appunto al pretore), e che contiene tutti gli elementi per mezzo dei quali il giudice potrà poi emanare la sentenza.
Definizione tecnica: Formula (detta anche *iudicium*) è il programma giudiziale della controversia, cioè lo schema scritto che inquadra la lite, in cui sono distinguibili diverse parti (*partes formularium*).

Svolgimento del processo

> A differenza di quanto accadesse nell'ambito del processo arcaico, notiamo che nel processo formulare il ruolo del magistrato assume molto più rilievo:

- Nelle *legis actiones* , Infatti il magistrato\ pretore urbano aveva ruolo di "controllore", doveva soltanto verificare l'ossequio rigoroso della procedura formale.

- Nel processo formulare il magistrato ha un ruolo più discrezionale importantissimo nella direzione della fase iniziale: (interviene a correggere e inquadrare correttamente la controversia)

> Cioè (e questa è una somiglianza con le *legis actiones*) nel processo formulare si conserva una netta struttura bifasica e vediamo che:

• Fase *in iure*
- Era quella presieduta dal magistrato che è il pretore (ma in generale, anche altri magistrati, poiché si facevano le azioni in base alla propria competenza; comunque quella più significativa era quella del pretore)
- In questa fase avviene l'impostazione della controversia: le parti discutono liberamente il rapporto controverso, ed è l'attore (colui che ha l'iniziativa processuale) che dopo averla individuata, propone la formula con cui inquadrare quel determinato rapporto controverso.
- Alla luce di questo libero dibattito\ ampia discussione (in cui tra l'altro non ci sono più i ruoli ben precisi pesti dal formalismo) il pretore ha il compito di aiutare le attore e convenuto ad inquadrare correttamente (e in questo sta la discrezionalità) la controversia:
  - Può ritenere che la formula proposta dall'attore sia quella giusta, perché la controversia evidentemente è rispecchiata in essa,
  - Oppure può denegare l'azione perché non riscontra i presupposti della stessa controversia, quindi non è fondata, e se non la ritiene fondata la deroga, la respinge.
  - Oppure può aiutare ad inquadrarla diversamente, perché se ne ravvisa degli altri schemi ma la ritiene fondata, allora può offrire un altro schema che inquadra la medesima controversia.

> Cambia anche il significato della *litis contestatio* perché nel processo arcaico tra la fase *in iure* e la fase *apud iudicem* c'è la *litis contestatio* che significa proprio contestazione della lite dinanzi ai testimoni.

- Il processo arcaico è corale, per cui testimoni che sono chiamati alla fine della fase in iure ad essere testi di quanto accaduto.
- Con il processo formulare la *litis contestatio* non ha più questo significato, è sempre il momento di sbarramento tra la fase *in iure* e la fase *apud iudicem,* ma con *litis contestatio* si intende la lettura\ l'accordo delle parti sulla formula scritta, che è insieme ad un composto dinanzi al pretore, e da quel momento in poi non si potrà più cambiare nulla, e tra l'altro non si potrà neanche ripetere un processo per la stessa questione che si è consolidata nella *litis contestatio.*

• Fase *apud iudicem*
- Questa è la fase che si svolge di fronte al giudice, com'è il processo civile arcaico, anche in questo caso non si tratta di un giudice di professione, non è una figura istituzionale, ma è un privato cittadino scelto in base a quelle equilibrio, quelle doti che deve aver dimostrato nella sua condotta quotidiana e che gli vengono riconosciuti dalla società.
- E proprio perché ritenuto in grado di formarsi un convincimento più equilibrato possibile, viene incaricato del compito di emanare la sentenza.

* Ricordiamo che il giudice, soprattutto nelle iudicia bonae fidei (legati a quelle figure negoziali in cui abbiamo rilevato la bona fides in qualità di criterio di affidabilità) nel momento della controversia godeva di un ampio margine di discrezionalità nell'individuare le responsabilità in campo, perché potrà approfondire\ formarsi un convincimento anche in base alla modalità in cui veramente concretamente quel rapporto si è esplicato in relazione al tipo di compravendita\ al tipo di mandato\ di società\ di locazione-conduzione, alle caratteristiche dei soggetti, all'oggetto, alle usanze dei luoghi, alle aspettative reciproche…
E quindi poi la responsabilità sarà commisurata al concreto manifestarsi del rapporto
Notiamo maggior elasticità anche nella sentenza: Manca il rigido formalismo totalmente.

Partes formularium
(Schema fornito dalla prof.ssa "la struttura della formula")

> Formula (detta anche *iudicium*) è il programma giudiziale della controversia, cioè lo schema scritto che inquadra la lite, in cui sono distinguibili diverse parti (*partes formularium*).
Normalmente ha una struttura ipotetico-alternativa (si paret - si non paret) cioè "se parrà" che vi siano questi elementi presupposti, il giudice condanni, "se non parrà" il giudice assolva.

- Capiamo quindi che la formula era proprio un periodo, una frase che poteva essere in sede più o meno articolata e poteva contenere tutta una serie di proposizioni che andavano riempirsi di contenuto esplicando le peculiarità di quella determinata controversia.

(Negli esempi, in via, appunto, esemplificativa, non potendo mettere i nomi reali, si usavano determinati nomi evocativi come:
Aulo Agerio: richiama l'agere, e infatti rappresenta l'attore, colui che agisce.
Numerio Negidio (che letteralmente significa "colui che nega", e rappresenta il convenuto).

> le parti della formula possono essere diverse, e non necessariamente tutte sempre presenti:

1- *Iudicis Nominatio*

In apertura, si comincia con la nomina del giudice, E cioè di colui che sarà deputato a conoscere il caso ed incaricato di emanare la sentenza.

es. *Iudex Titius esto* "Tizio sia giudice"

2- *Demonstratio*

È la parte della formula in cui vi si precisano i presupposti dell'azione, cioè vengono enunciati tutti gli elementi atti ad identificare il rapporto dedotto in giudizio cioè: Titolo - causa\ ragione giustificativa dell'azione.

es. *Quod Aulus Agerius hominem vendidit*
- Poiché Aulo Agerio ha venduto uno schiavo
Cioè: poiché l'attore ha venduto uno schiavo: qui fa riferimento al rapporto che giustifica l'azione: c'è stata una compravendita di schiavo

es. *Quod A. Agerius apud N. Negidium hominem deposuit*.
- Presupposto è che vi è stato un deposito da parte di A. Agerio presso N.Negidio

3- *Intentio*

Contiene la pretesa dell'attore, cioè l'enunciazione del rapporto dedotto in giudizio sulla base del quale si chiede il provvedimento del giudice.

es. *si paret N. Negidium A. Agerio sestertium decem milia dare oportere;*
- Se parrà (al giudice) che Numerio Negidio debba pagare ad Aulo Agerio diecimila sesterzi
Cioè: se ci saranno tutti i presupposti per cui sussiste il dovere di versare diecimila sesterzi ad Aulo Agerio da parte di Nerdio (e il giudice supporterà questa obbligazione), allora condannerà, diversamente (se non parrà), no.

> Notiamo il verbo "*oportere*" che è proprio significativo di una obbligazione civilistica (essere tenuti a fare una prestazione)

> Notiamo allora che questa frase ipotetica inquadra la pretesa dell'attore: vuole rivendicare il suo ruolo di creditore, ha prestato dei soldi e non li ha ancora ricevuti dal debitore (qui nasce la controversia)

es. *quidquid paret N. Negidium A. Agerio dare facere oportere;*
- Qualunque cosa parrà che Numerio Negidio sia tenuto a fare (una prestazione; di dare o di fare qualcosa) nei confronti di Aulo Agerio.
> Questo è più generico.

es. *si paret hominem ex iure Quiritium A. Agerii esse.*
- se parrà che lo schiavo appartenga secondo il diritto dei Quiriti ad A. **Agerio**
Cioè nel caso di una controversa relativa alla titolarità di una res (Se parrà che lo schiavo sia nella proprietà del donatore") in questo consiste l'oggetto della controversia, la pretesa dell'attore consiste in questo: appurare la titolarità di quell'oggetto.

4- *Adiudicatio (eventualmente)*

Questa è una parte della formula che si trova solo nei nei processi divisori (quando si deve procedere ad assegnare singole cose o porzioni di cose a soggetti contendenti; ad esempio divisioni di coeredità, di comproprietà, o regolamento dei confini; Che poi sarebbe ciò per cui nelle XII Tavole era prevista la

legis actio per iuris arbitribe postulatione).

- In questo caso si investe il giudice del potere di assegnare a ciascuna della parti in causa la proprietà esclusiva di singole cose o porzioni di cose tramite un discorso imperativo concluso con la voce verbale *adiudicatio*.

es. quantum adiudicari oportet, iudex Titio adiudicato.

- Nella misura in cui si è tenuti ad essere aggiudicati di qualcosa che deve essere assegnato, allora igiridce assegna a Tizio
- Quindi bisognerà appurare in questi processi cosa spetta a ciascuno.

> La Adiudicatio diventa anche un modo costitutivo della società, poiché a seguito di questa aggiudicazione, ciascuno sarà titolare della sua parte dell'imperium su quella cosa.

5- <u>*Condemnatio*</u>

Con essa si attribuisce al giudice il potere di condannare o di assolvere, e si fissa eventualmente l'ammontare in denaro della condanna o come determinarlo.

es. Iudex N. Negidium A. Agerio sestertium decem milia condemna: si non paret, absolve;

- Se parrà al giudice condanni Negidio a dare diecimila sesterzi ad Agerio, se non parrà, lo assolva.

es. ludex N. Negidium A. Agerio dumtaxat decem milia condemna: si non paret, absolvito.

6- <u>*Exceptio*</u> *(eventualmente)*

La costruzione della formula si ha appunto nella fase *in iure* in cui il magistrato ascolta le istanze delle parti e si ritrova a dover individuare la formula che calzi perfettamente a quel rapporto controverso, in modo da poter sviluppare una sentenza adeguata, perché poi una volta terminata la fase in iure, la formula non potrà più essere cambiata.

- È possibile che a seguito di questo dibattimento che avviene innanzi al magistrato si aggiungano anche delle *exceptiones*:

La ***exceptio*** è quella clausola inserita su richiesta e nell'interesse del convenuto, prima della *condemnatio*, ed è diretta a contrapporre all'azione una circostanza che le toglie efficacia. (È la difesa del convenuto, una clausola negativa della condanna).

- Quindi il convenuto può introdurre un elemento che posa privare di efficacia la pretesa dell'attore e paralizzare l'azione stessa.

Poi ci possono essere anche le ***replicationes***, una serie di risposte ulteriori, *duplicatio*...

> La formula può essere molto articolata, e la formula cosi intesa si può vedere come un puzzle che composto da varie partes che, ben congegnate, sono la perfetta descrizione del rapporto controverso, e quindi garantiscono la tutela adeguata, che si conforma perfettamente alla controversia.

> Notiamo allora come diverso sia il processo formulare rispetto alla rigidità delle *legis actiones*.

Dove si trovano le formule alla base del processo formulare?
Nell'editto del pretore

Anche il pretore, come ogni magistrato in base alle proprie competenze, ha la facoltà di emanare editti (i consoli ad esempio esplicavano questa facoltà nell'esercizio del potere militare e civile, un editto tra la tizio era quello dei censori, rispetto al quale le innovazioni saltavano gli occhi ma anche gli edili la cui competenza sguardava le liti di mercato…): hanno lo *ius edicendi*.

Con riguardo al pretore urbano, però, questa facoltà di emanare editti (il suo editto in particolare assume valore paradigmatico) ebbe un esito non momentaneo o occasionale, ma duraturo e unico.

Prima di farsi eleggere, proprio per farsi eleggere, il pretore aveva bisogno di fare propaganda, e utilizzava l'editto come strumento propagandistico, infatti già annunciava quali rapporti avrebbe tutelato nell'editto che avrebbe emanato qualora fosse stato eletto cioè quali fossero le ipotesi in cui avrebbe nominato un giudice a coloro che si fossero rivolti a lui come parti di una controversia giudiziaria, elencando poi i mezzi di tutela che si proponeva di concedere ed applicare nel corso del suo ufficio.

Così facendo, infatti, faceva capire quali fossero i suoi indirizzi politici

Capiamo quindi che già nel periodo di propaganda politica, la promessa di dare strumenti a tutela di determinati rapporti (che si traduce nel concedere formule a tutela di questi rapporti) era un momento tanto importante da avere una forte valenza politica.

> In un primo momento lo comunicava oralmente al popolo:

Assumendo la magistratura, il pretore saliva alla tribuno e denunciava le regole che avrebbe osservato nell'esercizio della sua carica almeno le grandi linee o evidenziando le parti nuove.

Ma non solo, a scopo propagandistico parlava anche di sé e dei suoi antenati "secondo il costume antico"

- In effetti questo intreccio in un unico discorso di due elementi che potrebbero apparire, nella nostra realtà, come nettamente distinti, a Roma era frequente, in quanto quasi come se la politica si presentasse come un teatro, il rapporto con la folla era il modo più immediato di diventare popolari.

> La pubblicazione per iscritto del programma edittale avveniva nel foro, il cuore della vita cittadina in cui avvenivano gli eventi più significativi, con lo scopo, proprio, di renderlo pubblico e accessibile a chiunque vi si recasse.

Il testo, più precisamente, era riportato a caratteri medio grandi, neri e rossi, su tavole di legno imbiancate ("*album*"): si parla di albo edittale (proprio per il colore bianco delle tavole).

Nell'editto, quindi, il pretore, ormai in carica, dichiarava i criteri che avrebbe seguito nell'esercizio della sua giurisdizione: quindi svolgendo in particolar modo una funzione giurisdizionale: regolamentava l'agire processuale.

In effetti in uno scenario simbolico composto da *exempla*, nell'editto, il pretore andava a prefigurare le diverse ipotesi in cui avrebbe concesso determinate azioni.

Chiunque avesse voluto intentare un'azione giudiziaria, poteva condurre il convenuto innanzi all'albo pretorio e mostrargli la formula che avrebbe richiesto contro di lui.

L'Editto conteneva:

- Le formule processuali
- Le eccezioni (e quindi le modalità attraverso cui i convenuti avrebbero potuto difendersi)
- I *remedia*, che sono rimedi di altra natura, non necessariamente formule, che potevano essere chieste al pretore per situazioni urgenti e che quindi avevano carattere più immediato

> Tuttavia non era sicuro che l'editto, anche una volta pubblicato, trovasse realmente applicazione, cioè "non legava le mani al magistrato"; il pretore avrebbe comunque potuto esaminare le circostanze del caso

concreto ed eventualmente derogare la concezione dell'editto, prevedere un altro, oppure in via decretale, (con un altro decreto durante l'anno di carica) poteva concedere altre azioni non presenti nell'editto stesso. Quindi l'editto era una traccia importante del programma, dei criteri della *iurisdictio* pretoria, ma allo stesso tempo poteva anche avere degli aggiustamenti in corso d'opera, perché il pretore era continuamente legato alla realtà, e quindi poteva anche decretare nel momento in cui si presentavano altre situazioni in cui ne emergeva il bisogno.

Questa era una libertà, o se vogliamo, discrezionalità conciliabile con un uso corretto della *iurisdictio*; talvolta, però, vi erano delle violazioni neanche poco frequenti, ad esempio, in Sicilia, ricordiamo Verre che abuso estremamente del proprio potere.

E questo perchè, in effetti l'osservanza dell'editto non era vincolata formalmente ai suoi criteri, ma vincolare l'attività pretoria non c'era nulla eccetto la *fides* e la *dignitas*, motivo per cui nel 67 a.C. si sentì la necessità di emanare una la lex: *la Lex Cornelia* che stabilì l'obbligo dei pretori di rispettare l'editto, nel quale (editto), tra l'altro, era previsto il caso di denegata giustizia per disonestà di chi doveva amministrarla.

Editto fragile ma persistente (da integrare con par.7 del capitolo sesto)

La durata dell'editto era annuale (così com'è il periodo in carica del pretore): cessata la carica, l'editto perdeva formalmente ogni efficacia e veniva sostituito da quello del pretore successivo.
- Tuttavia le norme pretorie passavano spesso da un editto all'altro, per cui duravano molto più a lungo del testo in cui erano scritte, oltre l'annualità della sua vigenza costituzionale. Come in un gioco di conservazione e innovazione.

> Proprio in questi aspetti possiamo cogliere il *dinamismo* dell'editto che consentiva di star dietro alle esigenze del trascorrere del tempo:

- Da una parte l'editto si caratterizza quindi per la sua intrinseca ***fragilità***:
  Ha una sua caducità legata alla durata della carica pretoria.

- Ma dall'altra rimane ***persistente***:
  Tutte quelle norme, quei criteri, quelle formule o rimedi che nell'applicazione pratica davano buona prova di sé e si rivelavano funzionali ed efficaci per regolare determinate situazione, venivano ripresi nell'editto successivo del pretore e successivo e così via, sottoponendosi al vaglio dell'applicazione pratica di anno in anno. Come se fossero detriti alla foce di un fiume, l'editto va accrescendosi, e molte parti persistono e perdurano nel corso del tempo (sarebbe sbagliato dire che si stabilizzino, ma mostrano la loro efficacia col passare del tempo)

> In questo modo si ha una tralatizietà (proprio nel senso di questo trasmettersi delle norme processuali che poi ne caratterizza la persistenza), un'alluvionalità, un continuo sedimentarsi nel corso del tempo di quelle parti dell'editto (criteri\ azioni) che venivano ritenuti adeguati e funzionali.
- Contemporaneamente veniva svolto un lavoro di innovazione attraverso il rimpiazzo di quegli elementi che ormai risultavano inefficaci, per cui cadevano in desuetudine e venivano, appunto, sostituiti da strumenti che più si adeguavano alle esigenze reali concrete che venivano a crearsi col trascorrere del tempo.

> Dobbiamo cogliere nell'editto una capacità plastica di star dietro a casi concreti, in quanto le realtà economiche presentano rapporti molto diversi nelle sfaccettature nelle modalità, per cui volta per volta sorgono nuovi e diversi problemi, che vengono posti ai giuristi, e proprio i giuristi formulano i loro ragionamenti e vai hanno gli strumenti in atto suggerendole, applicandole o formulandone degli altri.
<u>*Poiché di fatto, chi stabiliva che una norma desse buona prova di se? I giuristi (vedi par.7 cap.6)*</u>

Quindi possiamo individuare una sorta di intermittenza tra *validità* ed *effettività*:
- considerando l'aspetto della validità, dobbiamo ricollegare all'annualità.

- a questo aspetto si contrappone, però, l'effettività, che riguarda quella parte dell'editto che dà buona prova di sé e si va ad accumulare da editto in editto.

L'editto pretorio ebbe il suo disegno definitivo in età adrianea:

Il principe (Adriano), nel II secolo d.C. affidò Salvio Giuliano il compito di realizzare quello che poi sarà l'***edictum perpetuum*** ("l'editto perpetuo") che è una forma di stabilizzazione\ cristallizzazione dell'editto e del suo formarsi alluvionale, perché ormai era sostanzialmente esaurita l'attività del pretore e aveva assunto il suo nucleo stabile; Nucleo che Salvio Giuliano riordinò e raccolse proprio nell'editto perpetuo.

Questo dato è di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione del contenuto edittale, ci da proprio l'idea di questo svolgimento del testo edittale nel corso del tempo, che a suo interno presenta anche un suo ordine ed un suo assetto.
Oltre ai commentari precedenti all'opera di Salvio Giuliano sugli editti, dall'editto così rappresentato nel suo esito maturo (l'editto perpetuo) in poi, i commentari dei giuristi tesero a rifarsi solo a questo.

E dato che nessun esemplare autentico dell'albo pretorio è mai stato scoperto, e allo stesso modo non abbiamo dell'editto alcuna conoscenza diretta né dalla redazione giulianea, né da qualsiasi altra redazione più risalente (che eruditi antiquari del II secolo potevano ancora leggere nella biblioteca del tempio di Traiano), proprio grazie ai commentari giurisprudenziali (noti perlopiù dalla compilazione Giustinianea) è stato possibile ricostruire l'editto perpetuo attraverso un procedimento analogo, e anzi, più ambizioso e sottile, di quello seguito per la ricostruzione delle 12 tavole.

> Tutto questo lavoro che cominciò già nel tardo 500, permise al giurista tedesco ***Otto Lenel***, alla fine dell'800, di assemblare una ricostruzione del testo edittale a cui noi ancora oggi facciamo affidamento e consideriamo definitiva.

> L'editto perpetuo non si configura come un "tutto sistematico" (cit. Lenel), non si presenta come un insieme ordinato sistematicamente (cioè secondo un ordine razionale interno con dei nessi logici), non ha niente a che fare con la realtà del codice; a tal punto che il suo "ordine" è stato ritenuto piuttosto un "disordine".

- La verità è che l'editto si sottrae ad una successione espositiva teoricamente orientata (anche la redazione di Salvio Giuliano rimase vincolata a punti di vista pratici) proprio perché riflette il modo alluvionale con cui si è venuto formando nel corso del tempo.

- Nonostante, però, questa disorganicità intrinseca, è stato possibile ravvisare, seppur in un modo non sistematico e organico come si penserebbe per il codice, una suddivisione dell'editto perpetuo che fu organizzato in cinque settori o nuclei in cui si ritenne che la materia risultasse distribuita:

1 - Introduzione della lite e il suo svolgimento dinanzi al magistrato
2 - Giurisdizione ordinaria
3 - Mezzi urgenti di tutela giuridica
4 - Esecuzione della sentenza e procedure fallimentari presso i debitori insolventi
5 - Eccezioni processuali e le stipulazioni pretorie.

> Peraltro, l'assetto edittale prevedeva una distribuzione in rubriche e titoli, che pare abbia rappresentato una falsa riga uno schema un modello per altre opere dei giuristi.
- Lo stesso Giuliano, autore anche di *Digesta* si cimentò con questa tipologia letteraria casistico-problematica, che poi ha tutta la sua evoluzione a partire dalla scuola serviana, e anche i suoi *Digesta* si impostano sullo schema edittale (su quest'ordine\ disordine) e commentare.
I commentari agli editti, poi, essendo commenti alle varie rubriche edittali, ne seguono l'ordine.
Tra i giuristi che scrivono questi commentari edittali ricordiamo in particolare Ulpiano e Paolo

Specifiche sulla divisione in parti nel sistema Leneliano:

1 - Comprende i titoli 1-13

> Vi rientrano i *vadimonia* (fino al 6° titolo) e le *in integrum restitutiones* (10°)

- Si ricorreva al ***vadimonium*** quando il dibattito processuale dinanzi al magistrato non si era esaurito in una sola udienza, quindi il pretore autorizzava l'attore ad imporre al convenuto, per mezzo del *vadimonium*, la promessa di ricomparire in tribunale a una data certa:
Cioè è l'invito a presentarsi per la prima fase del giudizio, in un giorno certo, ad un'ora in un luogo stabiliti che l'attore rivolge al convenuto il quale promette attraverso una *stipulatio* penale, una *summa vadimonii* in caso di inadempienza.
Questo istituto andò sviluppandosi anche oltre questo ambito fino a prendere il posto della *in ius vocatio*.

- Con la pronuncia di una ***in integrum restitutio*** in determinate circostanze, il pretore reintegrava un soggetto nella sua precedente situazione giuridica:
Ciò avveniva quando un negozio giuridico era stato concluso da un minore di 25 anni o quando una delle parti aveva subito violenza dall'altra.
Infatti la caduta in prigionia o l'assenza per un motivo di interesse pubblico poteva impedire l'esercizio di un diritto e giustificarne la restituzione. La *in integrum restitutio* eliminava, in alcuni casi, gli effetti della litis contestatio, ristabilendo il rapporto dedotto in giudizio.

2 - Comprende i titoli 14-24 — **3 -** Comprende i titoli 25-35 — **4 -** Comprende i titoli 36-42

5 - Comprende i titoli 43-45

> Vi rientrano:

Gli ***Interdicta:***
- Sono degli ordini pretorii di natura amministrativa , che impongono l'esibizione di cose o di persone, o la restituzione di cose e la distruzione di opere, o l'astensione da determinati atti.
- Si distinguono in **e sibitorii** , **restitutorii** , **proibitorii** .
- Per mezzo degli *interdicta* avviene la tutela del possesso (rapporto di fatto con la cosa).

Gli ***Exceptiones***
- Sono clausole da inserire nella formula processuale.
- Riassumono i rilievi del convenuto che avevano ricevuto l'approvazione pretoria.
- Il giudice dovrà tenere conto delle circostanze che le *exceptiones* mettono in rilievo e assolvere il convenuto dopo averle accettate.

Gli ***stipulationes praetoriae***
- Sono dei negozi obbligatori;
- Si delinea una forma di autodifesa consensuale ordinata dal pretore in virtù del suo *imperium*: , cioè hanno funzione di garanzia.
- Il pretore può imporne la conclusione con vari mezzi (es. *denegatio actionis* o concedendo una *missio in possessionem* alla controparte).

La ***Cautio damni infecti***
- È la promessa solenne di risarcire il danno eventuale, che il proprietario di un fondo deve prestare al proprietario del fondo vicino, quando la condizione del suo immobile o la costruzione di un'opera nuova determinano uno stato di pericolo.
- Il rifiuto di prestare la *cautio* dà luogo alla *missio in possessionem* a favore dell'altro proprietario

> Proprio perchè nell'editto manca una rigorosa distribuzione delle materie le azioni penali che seguono al 31º titolo, si ritrovano dopo il 23º, mentre le *missiones in possessionem* sono raggruppate nel 38º titolo

5. Ius honorarium

Funzione normativa del pretore

Possiamo attribuire al pretore una funzione normativa.
Dobbiamo però partire dal presupposto che né il pretore è un legislatore, né l'editto, nonostante sia definito anche *lex annua*, è una legge.

> In effetti nel momento in cui si parla di "norma" non ci si riferisce solo alla legge, ma norma può essere anche un contratto fra privati, comunque qualcosa che regolamenta, una regola.
Per cui con funzione normativa, sì, si include anche l'ipotesi della funzione legislativa, ma non necessariamente; piuttosto ci deve riportare all'idea di regolamentazione.

- Noi siamo infatti abituati a riconoscere la legge (in quanto dato formale poste in essere dall'organo deputato a fare il diritto) come unica fonte di produzione normativa.
- In età repubblicana con "legge" si identifica la *Lex publica (o rogata*) che fu definita da Ateio Capitone, giurista d'età augustea, come il comando generale del popolo su proposta del magistrato interrogante
E questo riflette l'iter formativo della legge, cioè i consoli, che sono i magistrati che hanno funzione legislativa, promuovono una legge che deve essere approvata dal popolo riunito nel comizio centuriato.
(Ecco perché si parla di comando generale del popolo manifestato nel comizio centuriato su proposta del magistrato che lo interroga).

> Tuttavia, in età repubblicana, il diritto romano prevede una molteplicità di fonti di produzione normativa, non c'è solo la legge, e tra queste compare anche l'editto pretorio.
Produzione normativa, non legislativa, poiché la legge è una norma, ma non tutte le norme sono leggi.
- In particolare la legge non è una norma qualsiasi, ma è una fonte di produzione normativa\ del diritto qualificata dal fatto di essere prodotta dall'organo legiferante previsto nell'ordinamento e seguendo determinate modalità.

(solo in età imperiale, a partire dal 27 a.C. in poi, dato che Augusto e si era appropriato di tutti i poteri dei magistrati, tra cui il *ius edicendi*, che era quello caratterizzante dei magistrati di rango superiore (che prevedeva l'emanazione degli editti per regolamentare la propria attività) anche l'imperatore inizierà ad emanare degli editti: l'editto del magistrato però non è minimamente paragonabile a quello dell'imperatore, poiché solo l'editto imperiale sarà considerato una vera propria legge, in quanto rientra tra gli atti normativi del principe, e quindi tra le costituzioni imperiali chi sono, appunto, editti, mandati, iscritti, e decreta)

Ma quindi, come fa il pretore a produrre diritto?
Prerogativa del pretore e l'amministrazione della giustizia, la giurisdizione: ha la *iurisdictio*, che gli consente di determinare il diritto applicabile ad una situazione controversa su cui il giudice deve pronunciare una sentenza, cioè interviene ad applicare il diritto nel momento patologico del processo, il suo compito era quello di trovare l'istituto, contenuto nel suo editto, più adatto che si agganciasse e che fosse applicato alla fattispecie processuale che gli era stata sottoposta.

- Tant'è che in ambito processuale la differenza essenziale nel ruolo del magistrato tra processo civile arcaico e processo formulare era proprio la possibilità che il pretore aveva di intervenire, di collaborare con le parti, nella fase *in iure*, per far siche la controversia fosse inquadrata nel modo corretto (nel processo civile arcaico, invece, restava in silenzio a controllare che tutto cadesse nel modo più consono a quanto previsto dal formalismo).

> Tutte le azioni che il pretore rendeva disponibili erano racchiuse nell'editto, per cui la funzione normativa del pretore sta proprio nel regolamentare l'agire processuale dando rilevanza giuridica a determinati strumenti di tutela inserendoli nell'editto.

Ius Honorarium (o Praetorium)

Lo *Ius honorarium*, da *honos, honoris*, fa riferimento alle cariche magistratuali, quindi è il diritto che deriva\ che è inerente all'attività dei magistrati.
> In particolare possiamo intendere solo *ius praetorium* poiché l'attività più rilevante, lo *ius edicendum* più incisivo (nonostante lo abbiano più magistrati) è quello del *praetor,* che esercitando lo strumento della *iurisdictio* regola l'agire processuale indicando e creando le norme da seguire per agire in giudizio, cioè fornisce gli strumenti di difesa per gestire situazioni controversie.

(Le formule che rientrano nel ius honorarium sono poi quelle che persistono all'annualità della durata edittale, sono quelle che vengono riprese dopo aver dato buona prova di se)

Alla luce del ruolo del pretore nell'ambito del processo formulare, capiamo che lo *ius praetorium* nasce proprio tra le pieghe del processo, ed infatti è costituito da tutte le norme di invenzione pretoria (quindi quelle contenute nell'editto), e costituisce un vero e proprio complesso giuridico\ sfera normativa distinta.

> Ecco perchè si parla di funzione strumentale: fornisce gli strumenti in una controversia da impiantare; ed è da questa funzione strumentale che vediamo la nascita di quella sfera normativa che è il *ius honorarium*.

> Ma bisogna capire come, da questa funzione strumentale, si è andata a creare in senso sostanziale una serie di norme, di istituti che formano una sfera normativa dell'ordinamento, appunto lo *ius honorarium*, che si affianca allo *ius civile* da un lato presupponendolo, dall'altro distinguendosi da esso.

- C'è infatti un <u>rapporto bivalente</u> con lo ius civile.

Infatti da una parte si inscrive come una nuova sfera del diritto cittadino, d'altra parte va a tutelare situazioni che lo ius civile non avrebbe mai preso in considerazione, e va anche a supplire ad alcune lacune dello stesso *ius civile*, ed in questo modo si arricchisce e si evolve.

> Attraverso l'editto del pretore:
- Da un lato si raccoglievano tutti i mezzi di tutela giudiziaria e che contenevano tutti gli articoli alla base del diritto cittadino e commerciale.
- Dall'altro lato venivano abbandonati dei vecchi istituti che si rivelavano in applicabili, antiquati. (È evidente la necessità di stare al passo con l'evoluzione della realtà).

> Un esempio è il delitto di ***iniuria*** attraverso cui capiamo che ci sono dei nuclei di *ius civile* che vengono naturalmente conservati e tutelati in maniera diversa, più elastica secondo i tempi, che segue la maturazione della società, il pretore si fa interprete delle esigenze di tale società.
Infatti vediamo che:
> Innanzitutto dobbiamo precisare che l'*iniuria* è una forma di illecito privato (non lede l'apparato dello *ius publico* con interesse collettivo, ma siamo appunto nell'ambito del diritto privato per cui si traduce in una responsabilità nel processo privato) che ***originariamente*** era concepito come un danneggiamento di tipo materiale alla persona (ad esempio gli schiaffi, ossa fratturate, qualsiasi tipo di danno fisico), c'era proprio un contatto materiale;
- Successivamente, però, andò ad evolversi smaterializzandosi e assumendo il significato di semplice "offesa" in senso ampio.

- Questo illecito privato era incluso nelle stesse 12 tavole che prevedevano una punizione di 25 assi. Questa era una cifra molto esigua; Si racconta a tal proposito l'aneddoto degli *schiaffi di Lucio Verazio*: Si racconta che costui, Lucio Verazio, andasse in giro con una bisaccia piena di assi, a sbeffeggiare a destra e sinistra, e lo faceva con noncuranza proprio perchè essendo esigua era la sanzione in cui sarebbe incorso, gli sarebbe bastato pagare 25 assi.
- Successivamente, dunque, fu soppiantato da un giudizio recuperatorio mirato al risarcimento:

Il calcolo della pena era rimesso al giudice, che doveva stabilirlo in relazione al tipo di ingiuria che era stata posta in essere, e quindi la misura della pena e aumentava in base alla gravità dell'ingiuria.
Capiamo quindi che ogni situazione viene sottoposta ad una valutazione più elastica e adeguata al tipo di offesa arrecata.

Azioni pretorie

> Ci sono poi altri interessi che emergono per la prima volta e che vanno a definirsi giuridicamente solo nel programma edittale, ad esempio: ***Deposito*** e ***Comodato.***

> Vediamo come, in questo caso, il diritto privato preesistente rimane presupposto, ma attraverso una carica innovativa, il pretore va a difendere l'istituto da situazioni che fino al momento pur essendo praticate, erano sprovviste di una vera e propria tutela.

Sono due contratti reali (cioè si perfezionano con la consegna della res)
- il deposito ha come funzione la custodia (gratuita) della cosa, con l'obbligo per il depositario di restituirla.
- il comodato ha come funzione l'uso (gratuito) della cosa secondo quanto concordato, anche in questo caso dopo essere stata utilizzata nei termini concordati, doveva essere restituita integra al concedente.

> Sarebbe sbagliato pensare che prima non ci fossero forme di affidamento in custodia di cose ad altri soggetti, c'erano comunque forme di prestito d'uso, ma non erano tutelate, erano forme in uso presidiate dalla loro propria azione; erano situazioni attuali (nel senso che si attuavano), tanto che il pretore riteneva che non avessero una tutela loro specifica in ambito civile, quindi non creavano degli obblighi veri e propri di restituzione ad esempio della res data in custodia.

> In questo scorgiamo la *funzione innovativa inventiva*, importantissima, del pretore per la quale, nel momento in cui rilevava situazioni sprovviste di una certa rilevanza nell'ambito del *ius civile*, ma economicamente rilevanti, concedeva l'azione corrispondente: creava cioè la formula adeguata per tutelare queste istituzioni e, i questo caso tutelare il soggetto colpito dalla mancata restituzione della cosa data in custodia consentendogli la possibilità di agire in giudizio e ottenere quanto gli spettava.

- ***Actio in factum***

Costituisce, forse, lo strumento pretorio più rappresentativo dell'attività creativa del pretore:
> Queste formule, infatti, vengono date al di fuori di qualsiasi riferimento anche solo indiretto a rapporti tutelati dallo *ius civile.*
- Cioè nel momento in cui il pretore ritiene meritevole di tutela una situazione che gli viene prospettata, che non è prevista in alcun modo nello *ius civile*, poiché, magari è una situazione nuova che si sta realizzando per la prima volta, allora concede le ***actiones in factum***.
(Che quindi non hanno nessun legame con delle situazioni previste dallo ius civile)

> Attraverso questo tipo di azione il pretore crea delle strutture e delle formule che andavano a descrivere al proprio interno il patto\ le circostanze del patto, a cui si ricollega l'obbligo della parte di tenere quella determinata prestazione, e si invita il giudice a condannare o ad assolvere a seconda che siano provate o meno certe circostanze di fatto descritte nella formula.
- Per cui il fatto, poiché ritenuto degno di tutela dal pretore, acquista rilevanza giuridica.

> Le *actiones in factu*m potevano essere concesse caso per caso, spesso la giurisprudenza comporta l'iniziativa del magistrato individuando delle situazioni in cui si addice un rimedio del genere, o il più delle volte possono essere inserite nell'editto con delle clausole, seguiti quindi da formule tipiche, e passando da un pretore all'altro acquistano stabilità pari a quella delle formule ***in ius conceptae**** (basate sul *ius civile*)

> Capiamo quindi l'importantissimo meccanismo di produzione che sta nelle mani del pretore, che attraverso quest'azione\ questa formula, va a dare tutela processuale ad una situazione non prevista prima, sta creando un istituto che, non era contenuto, ma nel momento in cui viene creato, applicato, e da buona prova di sé, allora i pretori che si susseguiranno. Di conseguenza l'istituto che viene tutelato per la prima volta da un'azione in fatto, diviene a pieno titolo un istituto vero e proprio del ius civile.

> L'esempio più comune di *actio in factum* è quello del ***deposito***:

E non significa che non esistesse, ma era una situazione che non aveva rilevanza giuridica, capitava che qualcuno affidandosi all'altro lasciasse una proprie cose in custodia, ma ciò trovava fondamento su semplici elementi etici, di rispetto della parola e della fiducia tra amici.

(Deposito e comodato furono protetti prima dalle ***actiones in factum conceptae,*** poi da un'azione di buona fede, qualcosa di analogo accade per la gestione di affari altrui.)

(Testo pag.147-148)

Se il deposito non è stato causato da un tumulto o un incendio o un crollo o un naufragio, darò un'azione nella misura del valore della cosa;
Per quelle cose, invece, che sono state depositate nelle circostanze prima descritte, darò un'azione contro il depositario per il doppio del valore, e contro l'erede del depositario per l'equivalente, se il comportamento doloso è imputabile al defunto, per il doppio se è imputabile lo stesso erede.
Se risulta che l'attore ha dato in deposito al convenuto un tavolo d'argento, e che questo, per il dolo del convenuto, non è stato restituito, il giudice condanni il convenuto a pagare all'attore una somma pari al valore che la cosa avrà nel momento della condanna.
Se la premessa non risulta accertata, il giudice assolva.
Poiché l'attore ha dato in deposito il convenuto un tavolo d'argento,-e questo è il rapporto in discussione,- il giudice condanni il convenuto a dare all'attore, o a fare, quanto per quel rapporto è necessario secondo buona fede. Se la promessa non risulta accertata, il giudice assolva.

Iudicis nominatio:
(Si nomina il soggetto selezionato, personalmente scelto ed incaricato del compito di emanare la sentenza)
- Tizio sia giudice

intentio:
- Se parrà che Aulo Agerio (attore) abbia depositato presso Numerio Negidio (convenuto) un piatto d'argento, (quindi gliel'abbia dato in custodia questo piatto d'argento) e quello non è stato restituito con intenzione dolosa del convenuto (quindi vi è il dolo nella mancata restituzione),

condemnatio:
Se parrà questo, allora il giudice condanni Numero Negidio nei riguardi di Aulo Agerio a una somma di denaro pari al valore che la cosa avrà al momento della condanna *(quanti ea res erit*); se non parrà (se la premessa non risulti accertata) assolva.

<u>> Quindi vediamo:</u>
- La descrizione del fatto (nella *intentio*), che in questo caso è "io ho dato a te in custodia un patto d'argento\ l'argenteria, perché la custodissi, però tu al momento di restituirmela non l'hai fatto, di conseguenza se il giudice potrà convincersi che questo è accaduto, che c'è un inadempimento rispetto alla restituzione, allora ti condannerà ad una somma pari al valore che la cosa avrà nel momento della condanna. Se tutto ciò non ci sarà allora tu sarai assolto".

- Quindi c'è solo un riferimento al fatto della consegna dell'argenteria\cosa stessa in custodia e della mancata dolosa restituzione, non c'è nessun obbligo giuridico basato sul *ius civile*, quindi l'oportere qui non c'è perché non esisteva, ma è il pretore che così facendo ha introdotto\dato rilevanza giuridica al fatto.

- ***In bonis habere***

L'attività del pretore, però, ha un suo rilievo anche quando non è innovativa e riprende gli istituti dello *ius civile*: il pretore, cioè, può apprestare tutele parallele a quelle dello *ius civile* che poi addirittura arrivano a sostituire piano piano, nel tempo, quelle civilistiche.
Un esempio riguarda la proprietà:
- Proprietà civilistica in senso assoluto: *Dominium ex iure Quiritium* (a cui si contrappone:)
- Proprietà pretoria detta *"in bonis habere"*

Nella compravendita (*emptio vendictio*)

(Actio in ius concepta ex fide bona)

Successivamente alla concezione di quest'*actio in factum* per il deposito, cosi come per quella del comodato (che sono due figure che vanno di pari passo), il pretore elaborò un'*azione civile di buona fede.*
> Questo tipo di azione si colloca all'interno del *ius civile\ gentium (?)* nel quale si fa espresso riferimento ad un obbligo del convenuto a tenere un determinato comportamento proprio in base alla buona fede che sottosta al rapporto.

- Quindi un'*actio in ius concepta ex fide bona,* dando buona prova di se viene elaborato diventa un vero e proprio obbligo in senso civilistico.
- E quindi si ha un'evoluzione della figura del deposito e del comodato (e qui vediamo come gli istituti vengono concretizzandosi e realizzandosi grazie all'impulso pretorio e all'innovazione pretroia).

Prima si da rilevanza a queste figure concedendo un *actio in factum*, poiché si realizzavano ma erano sprovviste di tutela, poi queste azioni danno buona prova di se e allora vengono elaborate delle formule (ex fide bona) che da dignità civilistica al deposito e al comodato.
Formula *in ius concepta ex fide bona* (Successivamente alla concessione di un'actio in factum, il pretore elabora un'azione civile di buona fede dove, cioè, si fa riferimento ad un obbligo civilisticamente riconosciuto del convenuto - oportere - a tenere un determinato comportamento proprio in base alla buona fede che sottostà al rapporto).
> C'è la *iudicis noinatio*
Tudex Titius esto (iudicis nominatio). Tizio sia giudice.
> Poi c'è la demonstratio che è introdotta dal Quod e che richiama il titolo giustificativo\la causa\il rapporto alla base dell'azione stessa
Quod Aulus Agerius apud Numerium Negidium
mensam argenteam deposuit (demonstratio),
Poichè l'attore ha depositato presso il convenuto un piatto d'argento, della quale questione si tratta,
> Poi c'è l'intentio
qua de re agitur, quidquid ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona (intentio),
il giudice condanni il convenuto nei riguardi dell'attore
a quanto per quel rapporto sia tenuto a dare o fare in base alla buona fede.
> Condemnatio
eiusiudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato. Si non paret absolvito (condemnatio).
Se non parrà
accertata la premessa, assolva.

Quindi vediamo un essere tenuto a dare o a fare, e quindi alla prestazione che ci si aspettava da lui in base alla buona fede (che presiede\sottostà al rapporto contrattuale, alle reciproche aspettative (di lealtà, affidabilità, onestà) delle parti, e poi quando vengono introdotte nella formula danno al giudice un ampio margine di discrezionalità nel pronunciare la sentenza perchè questa sentenza deve essere commisurata alle modalità concrete con cui è avvenuto il comodato o il deposito.
Actiones i factum sono significative dell'inventiva pretoria che addirittura attraverso l'editto può immettere la tutela a livello giudiziario e dare rilevanza giuridica a figure che non erano contemplate di tutela nel ius civile, ed in questo modo immetterle nel flusso alluvionale dell'editto, dopo aver dato buona prova di se e creare dei veri e propri, concretare e dare valore ad istituti veri e propri presidiati da un oportere che sono diventati dei contratti da cui scaturiscono delle obbligazioni civilistcamente intese.
Vediamo quindi il ius honorarium

Distringiamo le actio in factum conceptae dalle actio in ius conceptae:

- Le actio in ius conceptae sono quelle che il pretore crea in relazione ad un istituto che non è contenuto nel ius civile

*Le formule in ***ius conceptae*** rispetto a quelle *in factum* (che si fondano su circostanze di fatto) si formano sull'affermazione di un diritto soggettivo dell'attore oppure un obbligo giuridico del convenuto

es. *la cosa è di Aulo Agerio* (attore) e quindi c'è l'affermazione del diritto di proprietà; Oppure il convenuto è tenuto a fare qualcosa nei confronti dell'attore e quindi c'è l'affermazione dell'esistenza di un diritto\ condizione,

Funzioni del pretore:

• Adiutoria Il pretore con i suoi rimedi agevola l'applicazione del diritto civile (funzione adiutoria), interviene e aiuta. Esempio è la lex imperfecta Cincia: le leggi imperfette sono quelle leggi che prevedono una disciplina ma poi non hanno un apparato sanzionatorio, non vi è una tutela. La lex cincia riguardava le donazioni oltre una certa unità. Essa non aveva apparato sanzionatorio, ma il pretore interviene a dotare di un rimedio queste donazioni soprattutto dal punto di vista del donante che può difendersi, attraverso exceptio, durante un processo. Il pretore in concreto realizza l'efficacia di questa lex che in diritto civile non aveva tutela.
•Il pretore ha anche funzione suppletiva (supplere), quando egli lascia intatte le norme dello ius civile ma le continua giungendo fin dove queste non giungevano; le sviluppa ulteriormente insomma, cerca di eliminare le lacune al loro interno.
•Inoltre, il pretore ha **funzione correttiva:** quando la norma civile è disapplicata e una pretoria la sostituisce.

Capitolo sesto: Una professione aristocratica

1. Il giureconsulto laico

La laicizzazione del diritto

Per tutto il periodo arcaico, quindi quello della Repubblica alta, la giurisprudenza e il diritto rimangono prerogativa unicamente dei pontefici, solo alla fine del IV secolo a.C., con l'inizio dell'età media della Repubblica, si inizia ad avere una giurisprudenza al di fuori del collegio pontificale, e bisognerà attendere gli inizi del II secolo a.C. per iniziare a vedere la costruzione in modo sistematico di un corpo di dottrine.

Per cui la giurisprudenza dalla media Repubblica in avanti sarà laica (e vedremo anche aristocratica), assistiamo infatti ad una vera e propria laicizzazione del diritto: si spezza il monopolio pontificale del diritto.

Questo accade perché proprio in questo periodo, alla fine del IV secolo a.C. ci furono alcuni rivolgimenti politico-sociali che ebbero come conseguenza l'ingresso graduale dei plebei a tutta una serie di cariche che prima erano prerogativa dei patrizi (gli stessi pontefici erano di estrazione patrizia, tant'è che spesso il sacerdozio pontificale e le magistrature coincidevano nella stessa persona).

In particolar modo questo accadde, alla fine del periodo arcaico, quando a seguito di alcuni rivolgimenti politico-sociali, si arrivò alle L*eges Liciniae sextiae* del 367 a.C., con le quali si raggiunse un compromesso politico tra patriziato e plebe, per cui:

- Venne riconosciuto l'esercito centuriato patrizio-plebeo anche come somma assemblea deliberante (e cioè il comizio centuriato), ma non solo,

- La plebe iniziò a farsi strada nelle magistrature che smisero di essere prerogativa dei patrizi

- E si costituì la magistratura del pretore urbano, che aveva il compito di amministrare la giustizia, e anche a questa magistratura poteva accedere la plebe.

> Da questo momento, in poi la società iniziò a mutare, e fu proprio questa partecipazione plebea nelle cariche che prima erano appannaggio patrizio, a porre fine al monopolio pontificale del diritto;
Anche il collegio dei pontefici, infatti, era di composizione patrizia, e spesso il sacerdozio pontificale e le magistrature coincidevano nella stessa persona:
- Questo dato è testimoniato da Cicerone, che nel *De Oratore* afferma:

“ i cittadini più ragguardevoli illustre custodivano la religione amministrando bene la Repubblica, e la Repubblica interpretando sapientemente la religione”.

> Tra IV e III secolo a.C., le cose, appunto, cambiarono, ed il diritto diventò conoscenza anche di altri soggetti.

Per comprendere meglio questo passaggio ci possono essere utili alcuni dati aneddotici:

> ***L’aneddotica***:
La narrazione via aneddoti, non è necessariamente corrispondente a realtà, non si tratta di fatti sempre effettivamente realizzatisi.
Ma gli aneddoti si mescolano alla realtà, sono delle vicende verosimili, che possono avere un fondo di verità storica, ma che hanno spesso un valore simbolico rispetto al quale bisogna cercare sempre il reale significato della vicenda narrata che non necessariamente è sempre un fatto vero.
- L’aneddotica è importante proprio perché ci da segnali che bisogna approfondire per comprendere la portata simbolica di un evento.

1- Primo aneddoto significativo è quello di Appio Claudio Cieco:
Appio Claudio Cieco fu console nel 307 e nuovamente nel 296;
- E scrisse un'opera intitolata *de usurpationibus*;
- Il titolo è significativo, ha già una sua evocazione importante:
Fa riferimento ad una *usurpatio* dello *ius*: l'usurpazione\ la sottrazione in maniera abusiva di alcune prerogative politiche.

> Molti però avanzano dei dubbi sulla reale esistenza di quest'opera, in quanto presupporrebbe l'esistenza di scritti giuridici, che però iniziarono ad apparire il secolo successivo.
Ecco perchè gli si da solo valore simbolico.

2- Secondo aneddoto vede come protagonista Gneo Flavio:
(Che per altro era lo scriba di Appio Claudio, quindi un suo segretario), e si narra che addirittura avesse pubblicato il calendario pontificale, che avesse raccolto i formulari delle azioni custoditi negli archivi segreti dei pontefici, e che avesse ricevuto una tale gratitudine dei cittadini tanto da essere letto come magistrato edile.

> Anche in questo caso, dobbiamo dare valore simbolico all'aneddoto, in quanto è impossibile che dopo un atto così grave, cioè quello di aver pubblicato il calendario pontificale ed i formulari delle azioni, fosse stato addirittura eletto come magistrato, in quanto è più realistico pensare che un comportamento del genere avrebbe potuto procurargli una sanzione elevatissima, anche una pena di morte.
- Possiamo, al massimo, pensare che si fosse limitato a raccogliere\ prendere nota, di volta in volta, delle varie azioni concesse dei pontefici, persino le fattispecie, allestendo un suo formulario, forse con l'aiuto e la guida del suo patrono Appio Claudio .

3- Un altro aneddoto riguarda Tiberio Coruncanio:
Si narra che fosse stato il primo plebeo ad assolvere ai vari compiti di pontefice massimo (e qui abbiamo l'esempio perfetto di come si stravolsero i sistemi preesistenti), e si racconta addirittura che avesse reso pubbliche le consultazioni dei pontefici, per cui aveva aperto la possibilità di recarsi da lui a chiedere un responso non più in maniera privata, ma pubblicamente, quindi tutti potevano ascoltare il responso.

> Anche di questo aneddoto dobbiamo leggerne il valore simbolico, in quanto è strano che da un momento all'altro abbia reso pubbliche le udienze dei pontefici senza aver riscontrato resistenze.
- Per cui al massimo possiamo pensare che l'abbia potuto fare sulla base di uno stato di fatto preesistente, e cioè che questa pratica di conoscenza pubblica dei responsi pontificali già si fosse affermata, e che Tiberio abbia semplicemente dato una spinta a questa pratica.

(**4-)** È leggendario anche il personaggio di Gaio Papirio.
Colui che aveva pubblicato nuovamente, dopo la cacciata dei re, le norme sacrali di Numa

>> Questi aneddoti vanno proprio a sottolineare dei momenti traumatici rispetto a quanto, fino a quel momento si era svolto tradizionalmente, ed è possibile ricondurli alla laicizzazione del diritto.

> È necessario, però, calare questi aneddoti nel contesto storico più appropriato, e cioè quello delle conquiste plebee che consentirono l'accesso alle cariche pubbliche, al sacerdozio pontificale, al collegio degli auri o alla redistribuzione delle terre, anche a uomini di bassa estrazione sociale che ebbero la possibilità di conquistare un ruolo sociale più rilevante.

> Ci sono, inoltre dei plebisciti che intervengono in questo periodo (nel giro di un decennio) e che sono molto significativi nell'ambito di questa trasformazione dell'assetto sociale in cui la plebe inizio a fare le proprie conquiste:

1- Plebiscito ovinio ("riforma censoria")
Collocabile al il 312 a.C. (poi soppressa nel 304 a.C.)
- Distribuì fra tutte le tribù gli uomini di più bassi natali.
- Trasferiva dai consoli ai censori il compito di aumentare il numero dei senatori integrando delle componenti plebee (si parla di figli di liberti) e quindi i plebei avevano la possibilità di accedere a questo organo della direzione della vita politica romana: il senato.
- E già questo è significativo per comprendere come i plebei avevano iniziato ad inserirsi nella macchina repubblicana in maniera sempre più massiccia.

2- Lex Valeria de provocatione
Databile al 300 a.C.
- Che introduce l'appello al popolo: e cioè uno strumento attraverso cui un cittadino accusato di un crimine la cui sanzione era particolarmente onerosa (anche pena di morte), avrebbe potuto rivolgersi al popolo riunito nei comizi chiedendo di impedire l'esecuzione della sua pena. E quindi cercando l'appoggio popolare per sollevarlo da questa gravosa sanzione\condanna pronunziata dal magistrato; ed era il modo di tutelare il plebeo da queste condanne pesanti talvolta anche vessatorie e dall'esercizio di una coercitio in maniera vessatoria nei confronti di questi soggetti. (prende il nome di *provocatio ad populum*).

3- Plebiscito ogulnio
Anche questo databile al 300 a.C.
- Anche questo importante perché fu proprio il plebiscito ogulnio ad aumentare il numero dei pontefici consentendo l'accesso alla carica pontificale ai plebei.
E questo decretò la fine del monopolio Patrizio nell'ambito delle funzioni religiose.

> Dobbiamo però considerare che le conquiste plebee erano state graduali, sicuramente alla fine del IV secolo a.C. (quindi nel 300 a.C.) le divergenze tra patrizi e plebei erano più attenuata rispetto al passato, ma non possiamo pensare che la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza che ha avuto origine da queste rivendicazioni della plebe, fosse un processo estraneo ai patrizi, poiché ci si sarebbe dovuti aspettare un patriziato più istituzionalistico rispetto a questi nuovi rivolgimenti della vita giuridica ormai sempre più laicizzata.

> Avvenne quindi che sacerdozio e professione giuridica si separarono, possono coesistere nella stessa persona, ma senza confondersi.
Cioè, se prima solo un pontefice poteva essere giurista, ora non è più una prerogativa necessaria: essere pontefici è un plus valore, qualcosa di prestigioso, ma ciò non toglie che per essere un giurista si possono rivestire anche altri ruoli.

Fisionomia del giurista (o giureconsulto) repubblicano laico

Aldilà di quelle personali, ogni giurista repubblicano laico presenta delle caratteristiche determinate.
Una delle costanti è la ***competenza tecnica***: quando pensiamo al giurista dobbiamo pensare ad uno specialista che svolge un ruolo sociale particolare.

> Possiamo individuare vari termini per delineare la figura del giurista, ciascuno dei quali, di volta in volta, pone l'accento su un profilo differente:

- Una prima scelta definitoria è l'espressione: ***iuris consultus***
  = "gureconsulto" : questa pone l'accento sul momento della consultazione, cioè il momento in cui il giurista viene consultato\ gli viene richiesta una consulenza per avere una risposta tecnica (un responso); Per cui coglie il giurista nel momento dell'interpretazione che è poi seguita dal responso.

- È possibile usare anche l'espressione: iuris peritus
  = "giurisperito" che è proprio l'esperto in ambito giuridico: si vuole porre l'accento sulla sua competenza nel campo del diritto.

- Un'altra espressione è: *iuris prudens*
  = "giurisprudente" : che si riallaccia al concetto più ampio di *prudentia* nel senso meno tecnico del termine, quasi nel senso di "saggezza" —> Con iuris prudens s'intende colui che è sapiente, e con questa scelta definitoria si vuole porre l'accento proprio sulla sua sapienza, che non è caratterizzata solo in senso pratico, ma anche in senso specialistico e tecnico: Infatti si consultava lo *iuris prudens*, ad esempio, per il matrimonio di una figlia, per l'acquisto di un fondo o per avere consigli su come coltivarlo, in generale su qualsiasi tipo di affare.
  Per cui c'era da parte dello *iuris prudens* un voler mettere a disposizione la propria sapienza\ saggezza per tutti cittadini, qualsiasi fosse la loro estrazione sociale (il consiglio tecnico del giurista può indirizzarsi ad un cittadino qualunque mosso da un proprio interesse, ad un magistrato, ad un giudice alle prese con un caso nuovo e difficile)

  > In sintesi
  > - *Iuris consultus* = pone l'accento sula consulenza
  > - *Iuris peritus* = pone l'accento sulla competenza giuridica.
  > - *Iuris prudens* = pone l'accento su una sapienza al largo raggio

> Possiamo affermare che il giureconsulto svolgesse la funzione mediatrice fra il diritto ed i suoi utenti.
Si rendeva disponibile in luoghi facilmente raggiungibili da tutti, il foro o una casa che poteva essere propria oppure appositamente donata dallo Stato (es. Publio Cornelio Scipione Nasica, contemporaneo di Mario Manilio ne ebbe una sulla via Sacra)
Si rivolgevano al giureconsulto:

- Sia magistrati o giudici (ricordiamo la differenza fra queste due figure), in particolar modo i giudici interessati ad esercitare correttamente la *iudicatio*, non avendo competenze tecniche, il più delle volte, dove vado orientarsi tra le tesi contrastanti sulla base delle prove che venivano portate il processo, per cui poteva capitare che in un caso particolarmente difficile e controverso questi chiedessero il parere del iuris peritus.
- Ma anche, e soprattutto, i cittadini privati, i quali, specialmente in un contesto caratterizzato dal formalismo esasperato, per non incorrere in errori nell'ossequio delle formule, si rivolgevano al giurista per raggiungere la finalità più appropriata (ad esempio il cittadino che doveva porre in essere un'attività negoziale chiedeva al giurista lo schema negoziale adeguato, piuttosto che, colui che doveva intentare una controversia chiedeva lo schema processuale idoneo: ci si voleva garantire la correttezza delle operazioni giuridiche compiute nel momento del negozio o del processo. Rif. attività del *cavere*)

> Capiamo quindi che il giurista era a disposizione di tutti cittadini, c'è proprio un rapporto tra giurista e profano (nel senso di colui che non sa di diritto) che necessita di un esperto che lo indirizzi per il meglio.
La pratica del responso era, d'altra parte, anche un efficace strumento propagandistico, in un giro elettorale, giura e consulto mettendo a servizio degli altri la sua competenza acquistava fama.

(Citazione Pag. 160-161)
> Cicerone, in uno dei suoi dialoghi del *De Oratore*, attraverso le parole dell'oratore Antonio, ci fornisce una vera e propria definizione di giureconsulto repubblicano:

"Se si domandasse a chi spetti veramente a quel nome, io direi: a colui che è esperto delle leggi, e delle norme consuetudinarie che cittadini osservano come privati; impiega questa sua competenza sia per dare pareri, sia per allestire schemi negoziali o processuali".

In queste poche parole, ma significative possiamo tra l'altro porre l'accento:

- Sull'aspetto della distinzione tra *lex* e *consuetudo*, e quindi su quel binomio tra *leges* e *iura* che capiamo essere un motivo ricorrente.
Cicerone infatti distingue:
Da un lato il diritto che si forma attraverso l'attività comiziale (e quindi l'attività dei comizi centuriati che votano la proposta magistratuale)
Dall'altro lato il diritto che ha origine consuetudinaria: fa riferimento proprio a quello ius, quel sostrato consuetudinario estremamente importante secondo la mentalità tradizionalista di cui Cicerone è permeato completamente e che si carica di enorme valore.

- E ritroviamo anche la triade del *respondere-cavere-agere* che, così come per i pontefici, costituisce le prerogative dell'attività del giureconsulto che però svolge senza più vincoli sacerdotali o sacrali, e che assumono un valore pubblico nuovo, sganciato da quella solennità tipica dei pontefici, in quanto siamo in uno già conclamata laicizzazione del diritto.
Oltre, quindi, a rivestire quell'importante ruolo di mediatore nella società tra utenti del diritto ed il diritto stesso, allo stesso tempo, attraverso il *respondere* (comprensiva del *cavere* e dell'*agere*), si fa interprete e artefice del diritto, è il giurista che lo costituisce, che ne valuta l'applicazione, e che valuta la potenzialità di determinati schemi e atti, proponendone a sua volta di nuovi.

> Spesso l'attività del *respondere* combaciava con quella del *docere*, in quanto sia nella casa sia nel foro, dove il giureconsulto svolgeva la sua attività, vi si ritrovavano non solo i clienti, ma anche gli allievi, che ascoltavano i responsi; Non che i giureconsulti dedicassero tempo all'insegnamento, ma permettevano a coloro che volevano imparare e di assistere ascoltare i vari responsi che assumevano così anche una congiuntura didattica.

Il giureconsulto nell'ambito del suo contesto sociale: "una professione aristocratica" - Schulz
Il giureconsulto repubblicano oltre a caratterizzarsi come laico, si caratterizza per essere ***aristocratico***.
Per comprendere meglio questo aspetto dobbiamo fare riferimento a quanto afferma Fritz Schulz, storico tedesco del diritto romano, in uno stralcio della sua opera "storia della giurisprudenza romana" che rappresentò tutto un orientamento di studi che delinea la giurisprudenza repubblicana come una professione aristocratica.

> *"Adopreremo il termine scienza giuridica in un senso più ampio dell'ordinario. Comunemente, esso indica soltanto il pensiero sistematico intorno al diritto vigente (dogmatica giuridica), con esclusione, in particolare, della formazione del diritto.*
> *In ogni caso, così esso è stato inteso nelle precedenti trattazioni di scienza giuridica romana, ma i difetti di tali esposizioni hanno dimostrato che una così angusta concezione della scienza giuridica è priva di valore per lo storico."*

>> Questa è una premessa metodologica:
Schulz premette di starsi approcciando a questo argomento in maniera diversa dalle modalità che lo avevano preceduto. Avverte subito il lettore del fatto che sta utilizzando l'espressione "scienza giuridica" in maniera più ampia rispetto a quanto inteso finora, a suo avviso in modo troppo restrittivo, perché aveva prevalso l'impostazione dogmatica (dogmatica giuridica) che aveva indicato con "scienza giuridica" solo il pensiero sistematico intorno al diritto vigente, trascurando il momento della formazione del diritto.

Ma allo storico non interessa solo questo: allo storco interessa l'iter di formazione, e non il concetto dogmatico, cristallizzato, senza riferimenti temporali.
Per cui Schulz enuncia\ propone un'altro modo d'intendere "scienza giuridica":

> *"La nostra concezione della scienza giuridica (o giurisprudenza - consideriamo i termini come sinonimi) abbraccia ogni attività professionale concernente il diritto, quindi la sua formazione, applicazione, esposizione e trasmissione."*

>> Schulz evidenzia in effetti una sinonimia tra *"scientia iuris"* e *"iuris prudentia"* nella quale dobbiamo cogliere il riferimento a coloro che hanno costruito la *scientia iuris*: i giuristi.
Ed è proprio attraverso l'attività dei giuristi che si concretizzano tutti i momenti della vita del diritto: quando si crea, quando viene applicato a fattispecie concrete, poi cita l'esposizione, e quindi quando viene comunicato, ed infine la trasmissione, cioè il sapere giuridico si trasmette, viene tramandato.
Ed è in questo modo articolato che va intesa la scientia iuris: c'è proprio un'estensione del significato rispetto all'impostazione dogmatica che poco vale per lo storico.

> *" Il termine professione non deve essere limitato alle attività dirette a guadagnarsi la vita o ad altri scopi economici. Alle sue origini, che sono cristiane esso non aveva tale significato, e il concetto di attività professionale, non diretta, o non necessariamente diretta, a fini economici, è indispensabile per una corretta analisi sociologica del mondo antico."*

>> Al tempo di Schulz, e a maggior ragione, oggi, quando si parla quando si parla di professione immediatamente pensiamo che il professionista è colui che va pagato per la sua attività: per noi la retribuzione è scontata anche solo per le consulenze.
Ma per il diritto romano non è così: l'idea di professionalità, che con le sue "origini cristiane" rimanda all'idea di vocazione, non è legata alla retribuzione.
Dobbiamo accantonare il legame con la finalità economica, non c'è l'interesse a perseguire il denaro, è necessario spogliarsi di questi preconcetto per comprendere l'attività dei giuristi: la scientia iuris\ la professionalità\ professione di chi coltiva la scientia iuris\ Non c'è uno scopo economico di chi svolge la professione della scientia iuris.

> *"Il suo concetto implicito è quello di dedizione durevole ad una sfera definita di attività, in antitesi al dilettantismo occasionale."*

>> Ci fa capire proprio lo specialismo; L'idea di professione non è collegata alla retribuzione, ad un interesse economico, ma è legata al profondersi in maniera durevole e continuativa, non occasionale (come hobby o interesse di passaggio, in modo dilettantesco) a coltivare la conoscenza del diritto.
É in questo che sta lo specialismo, perché si potrebbe avere un'infarinatura di diritto solo leggendo qualche legge inerente al problema che abbiamo, ma l'avvocato competente e specialista è una cosa diversa: Deve essere specializzato.

> *"Siffatto occuparsi costantemente di una materia determinata genera una familiarità di specializzazione che va oltre la mera conoscenza generale. Noi diamo il nome di scienza alla conoscenza specializzata così prodotta, in una (insieme con) con le attività dirette ad ottenerla."*

>> Questa "materia determinata" indica l'occuparsi di un settore specifico, ad esempio l'avvocato conosce il diritto ma magari è amministrativista (conosce bene la materia amministrativa) per cui ha una competenza approfondita circoscritta.

"Per noi dunque il termine scienza giuridica, o giurisprudenza, abbraccia ogni forma di attività professionale nel campo del diritto, e il termine giurista comprende tutti coloro che si dedicano a tali attività. Per es., il iudex classico non era giurista, o lo era soltanto per accidens: ad occhi romani la conoscenza professionale del diritto non era parte delle sue qualificazioni; egli era il rappresentante del senso comune."

>> Quindi con "scienza giuridica" bisogna intendere tutte le attività professionali (nel senso che abbiamo visto, disinteressato economicamente) nel campo del diritto, ad esempio, il giudice, che come sappiamo non era un tecnico, non è un giurista, ma piuttosto un rappresentante del senso comune.

"D'altra parte, i membri della cancelleria imperiale che redigevano i numerosi rescritti di Diocleziano, erano giuristi, sebbene non occupassero cattedre accademiche né scrivessero libri, ma conservassero stretto anonimato burocratico. I rescritti, che rappresentano la loro attività letteraria, appartengono alla giurisprudenza, ad altrettanto buon titolo dei responsa del praefectus praetorio Papiniano."

>> Questa è un'ulteriore riflessione per dire che il tecnicismo si ravvisa anche in quegli anonimi giuristi d'età tardo antica che redigevano i rescritti, e allo stesso modo, con coordinate temporali differenti in età tardo classica fa riferimento a Papiniano con i suoi responsa.

> Quindi, quando si parla di "professione aristocratica" si fa riferimento all'attività del giurista ponendo l'accento sulla professione in quanto scienza tecnica priva di qualsiasi interesse\ finalità economico, per cui come dedizione durevole e continuativa, non dilettantesca, alla conoscenza e alla coltivazione della conoscenza del diritto.
Ed è "aristocratica" proprio perché, non essendo retribuita, poteva essere svolta solo da chi aveva già una ricchezza, un'ampia rendita, e quindi d'estrazione sociale elevata: gli aristocratici.
In quanto gli aristocratici non avevano bisogno di procurarsi guadagno tramite questa determinata attività, e quindi potevano dedicare la vita a questa *scientia iuris.*

> Per completare la caratterizzazione di Schulz ed intendere meglio l'elemento dell'estrazione aristocratica dei giuristi professionisti del diritto, è opportuno citare la riflessione di Weber relativa a quelli che per lui sono i "notabili", in quanto sono perfettamente assimilabili ai professionisti aristocratici di Schulz, ma anche a quelli che Machiavelli descrive come "Gentiluomini"

- ***Weber***

Weber, sociologo tedesco dello scorso secolo, affermava che:

"Si devono chiamare notabili, Honoratioren, quelle persone che sono in grado, per la loro condizione economica, di esercitare un'attività continuativa, anche se accessoria, all'interno di un gruppo, dirigendolo e amministrandolo, senza un compenso oppure con un compenso onorario o nominale; e che godono di una considerazione sociale, fondata non importa su quale base, che offre loro la possibilità di rivestire uffici… Il presupposto necessario della posizione dei notabili, - in questo significato primario, che è quello di poter vivere per la politica senza dover vivere di essa, - è un grado specifico di "libertà" dai propri affari privati. Lo posseggono particolarmente i redditieri di ogni specie,- di fondi, di schiavi, di bestiame, di case, di titoli"

- La riflessione di Weber è un po' più generale, non è strettamente riferita al diritto, ma la sua definizione di "notabile" si addice perfettamente al giurista professionista aristocratico a cui fa riferimento Schulz.

- Weber definisce i notabili come coloro i quali per la loro condizione economica possono dedicarsi in maniera continuativa ad un'attività senza dover necessariamente ricevere un compenso, al massimo questo compenso può essere simbolico\ onorario.

- Già il termine "notabile" lascia intendere qualcosa, in questo caso qualcuno, degno di nota, e ciò ci fa capire che c'è una risposta della società che riconosce a questi soggetti un certo ruolo, in quanto si mettono in evidenza per la loro sapienza, per le modalità con cui svolgono la loro attività al punto tale da creare una sorta di consenso, prestigio, da parte della popolazione.
Sono queste caratteristiche, questo ruolo che rivestono nella società, che li portano ad essere in grado di rivestire determinati uffici.
- Quindi il significato primario di "notabile" è proprio quello di poter vivere per la politica senza dover vivere di essa, e cioè hanno la possibilità di dedicarsi alla politica senza bisogno di una retribuzione, e il vantaggio di poter esercitare questa attività senza essere retribuiti consente di essere"liberi", in quanto non si è deviati dal raggiungimento di interessi personali.
- Ed i soggetti che possono rientrare nel gruppo dei notabili non sono altro che i ricchi, coloro che appartengono ad un determinato ceto, poiché hanno un reddito indipendente dall'attività politica o giuridica. Per cui possono svolgere attività sia in ambito politico che in ambito giuridico, ed il non dover perseguire un guadagno gli dava libertà da tutto, e faceva riscuotere a questi soggetti un determinato prestigio da parte della società permettendogli di rivestire incarichi pubblici.

- ***Machiavelli***
In linea con quanto affermava Weber sui notabili, Machiavelli descrive i gentiluomini come coloro che

> *"oziosi, vivono delle rendite delle loro possessioni abbondantemente, senza avere cura alcuna o di coltivazione o di altra necessaria fatica vivere"*

E quindi sono persone "oziose" cioè in grado di disporre del proprio tempo, che lo sfruttano coltivando in maniera specialistica un determinato ramo del sapere, che potrebbe anche essere, appunto, il diritto.

> ***Cicerone***, a tal proposito, nel De Oratore delinea un paragone tra i giureconsulti romani d'età repubblicana ed i pragmatici greci, al fine di mettere in risalto determinate qualità di questi nuovi esperti del diritto.

> *"A ben guardare, enorme il divario dai pragmatici greci: uomini di bassa condizione sociale, che, spinti dal magro guadagno, offrono agli oratori nei processi la loro assistenza in materia giuridica"*

- I pragmatici greci vengono descritti come uomini di bassa condizione sociale che coltivavano la cultura giuridica ma che si mettevano a disposizione dei privati spinti da un magro guadagno.

- Capiamo che quindi sono figure estremamente diverse dai giureconsulti aristocratici laici che vantavano grande prestigio nella società; prestigio che era determinato: dall'origine, dalla posizione sociale, dai meriti militari e civili e dall'età avanzata.

1- L'origine
La classe dei giuristi si caratterizza per la ***nobilitas.***
Quando si utilizza l'aggettivo "aristocratico" si va a sottolineare anche questo: l'origine nobile.
Ma bisogna fare una precisazione, dobbiamo infatti considerare la nobilitas come composta da:
> Aristocrazia di sangue
> Aristocrazia degli onori

- Quando si parla di aristocrazia di sangue, si fa riferimento ai patrizi che ereditano la propria condizione d'onore dalla famiglia di appartenenza, per cui è quella nobiltà per discendenza. Era l'aristocrazia di sangue il gruppo sociale che inizialmente monopolizzava la gestione della vita pubblica in contrapposizione ai plebei sempre legati ad una condizione più abbietta (i clientes, coloro che erano legati a personaggi influenti e che in cambio di favori rendevano loro dei servizi, ad esempio, erano spesso plebei)

- Quando si parla, invece, di aristocrazia degli onori si fa riferimento ad una nuova aristocrazia composta dagli omines novi, cioè:

Quando furono emanate le *Leges Liciniae Sextiae*, che consentirono ai plebei l'accesso a delle cariche che prima erano appannaggio dei Patrizi, la società iniziò a trasformarsi, ed è in questo contesto che emerse l' "aristocrazia degli onori", che fa proprio riferimento ad un nuovo gruppo sociale composto da quei plebei che riuscirono, in un certo senso, a nobilitare la loro discendenza\satirpe rivestendo delle cariche magistratuali.

Lo stesso Cicerone, ad esempio, è un homo novus, un uomo d'estrazione più bassa che riveste cariche pubbliche.

2- La posizione sociale.

Certamente la ***ricchezza*** era un requisito fondamentale, una posizione economica agiata contava, in quanto appunto si poteva permettere di svolgere l'attività del giurista colui che avrà una particolare situazione di censo.

3- Nell'età repubblicana, inoltre, c'era un forte legame tra giurisprudenza e servizio dello Stato, il giureconsulto era infatti autorevole anche come uomo di governo: i giuristi erano in primo luogo ***impegnati in attività pubbliche***, e quindi politiche, militari e civili.

Rivestivano cariche pubbliche, con maggiore o minor fortuna (spesso rivestivano magistrature, cariche consolari, o comunque percorrevano il cursus honorum più o meno fino alla fine).

Non dobbiamo però confondere i due aspetti, che rimangono comunque distinti, in quanto il giureconsulto agisce sempre come un privato: la sua attività è autonoma rispetto alle cariche ricoperte di volta in volta.

4- E quanto più vasto era l'impegno quotidiano sul piano delle attività politiche, militari e civili, tanto maggiore è ***l'auctoritas***.

L'Auctoritas ("autorevolezza") è un altro termine importante che da una connotazione importante alla figura del giurista.

L'auctoritas non è altro che quel valore aggiunto, quella prerogativa corrisposta dalla società al giurista impegnato in incarichi pubblici con riguardo alle sue capacità, che il giurista mette, appunto, in mostra attraverso il suo comportamento, cioè nel suo impegno verso la società.

E per guadagnarsi *l'auctoritas* bisognava avere talento ed una grande capacità intuitiva nell'ambito specifico, e quindi dimostrare di saper svolgere il ruolo in cui ci si era impegnati, e una volta acquistata l'*auctoritas* era come se si imprimesse questa qualità nel soggetto:

Cicerone stesso, nel De Oratore afferma che *nella pratica del responso* (che per chi la esercita è fonte di *auctoritas*) *valesse più dell'ingegno necessario per acquistarla.*

E ciò ci fa capire quanto questa caratteristica fosse importante soprattutto nell'ambito del responso, in quanto il responso che deriva da un giurista dotato di *auctoritas* ha un'incidenza notevolissima soprattutto nell'ambito del processo, e infatti la garanzia della validità del responso si collega proprio all'autorevolezza di chi lo emana\ espone\ fornisce.

5- Un altro aspetto fondamentale era la ***virtus***.

Quando si parla di *virtus*, non dobbiamo intendere il termine nell'accezione di "valore\ forza eroica dell'ἀρετή omerica; Ma nel mondo romano della Repubblica la virtus è un valore eminentemente aristocratico (ha riscontro quindi nella nobilitas in senso lato) che si manifestava in tutti gli ambiti della vita, sia nella sfera interiore dell'uomo, sia nelle forme esterne dell'agire intenzionale e responsabile.

- Da una parte, quindi, e qui si esplicava nel modo più idoneo, la *virtus* si manifestava nel buon governo dello stato, attraverso le proprie qualità civili, militari (e quindi essere un buon condottiero e rivestire incarichi militari con successo), ma non solo, anche nella coltivazione della *scientia iuris* alla continua ricerca dell'eccellenza.

- Dall'altra parte, la virtus del giurista si può riscontrare anche nel momento in cui lo vediamo calarsi in ambito familiare e privato: Si coltiva la virtù attraverso, ad esempio, la buona gestione del proprio nucleo familiare, e quindi essere un buon *pater familias*, ma anche attraverso la gestione delle proprie sostanze economiche, e poiché normalmente la ricchezza si misurava in proprietà terriere, in questo caso la virtù si concretizzava nell'essere un *bonus agricola* (un buon coltivatore, amministratore delle proprietà terriere).

6- È degno di nota anche l'aspetto delle ***senectus.***

(Testo pag. 156)

In questo passo del De Oratore, Cicerone fa emergere il fatto che la giurisprudenza, l'attività del giurista (la scientia iuris) può essere anche un rifugio in vecchiaia dopo una vita svolta nell'ambito dell'attività politica, e lo fa attraverso le parole di Licinio Crasso:

> *"Per una vecchiaia che si voglia circondata di gente e di onori, quale più nobile asilo che l'interpretazione del diritto? Quanto a me, io mi sono procurato questo sostegno fin dalla prima giovinezza, non solo per i bisogni della mia attività forense, ma anche per il decoro e il lustro della vecchiaia:…"*

Alla vecchiaia, appunto, la senectus si dava un'impotente valore, in quanto per i romani era un momento in cui la fisionomia si completava e si potevano coltivare tutta una nuova serie di interessi.
Il senex era considerato molto autorevole, e mettere a disposizione la propria autorità che dava lustro appunto alla vecchiaia

> *"...così quando le forze cominceranno ad abbandonarmi, - e questo giorno ormai si approssima, io potrò difendere la mia casa dalla solitudine…"*

Proprio perché verrà contattato da una serie di persone intenzionata ad attingere ai suoi responsi.

> *"Non c'è nulla, io penso, di più onorevole di un vecchio, che dopo aver ricoperto le cariche pubbliche e adempiuto i suoi compiti al servizio dello stato possa dire a buon diritto, come in Ennio Apollo Pizio, di essere colui «al quale», se non «i popoli e i re», almeno tutti i concittadini «chiedono consiglio, incerti del loro destino: ed io col mio aiuto da incerti certi e fermi nei loro disegni li rimando, affinché non trattino alla cieca cose complicate»".*

Quindi qui c'è il concetto della certezza, della garanzia, della sicurezza che lo specialismo di chi coltiva la *scientia iuris* può fornire alla società come una garanzia per i cittadini e per il buon andamento del diritto.

(Testo pag. 159)

Cicerone nel De Oratore delinea la figura di Catone il censore in cui ritroviamo la summa di tutte le caratteristiche che il giureconsulto repubblicano laico deve avere.
- Catone tra l'altro fu anche pontefice massimo, e non dobbiamo dimenticare che questa non era una prerogativa essenziale, ma solo un elemento che dava ulteriore prestigio.

> *"Forse perché aveva appreso il diritto civile non trattava cause? O perché esercitava l'oratoria, trascurava la scienza del diritto? Egli si applicò in entrambe le discipline, e si distinse in entrambe. Forse la fama acquisita con la cura degli interessi privati affievolì il suo impegno nella vita politica? Nessuno fu più influente di lui dinanzi al popolo, o migliore di lui in senato; fu anche, senza dubbio, un ottimo generale; infine non vi fu nulla che in quel tempo si potesse sapere o apprendere nella nostra città, che egli non abbia indagato e saputo, e anche trattato nei suoi scritti"*

Catone il censore rappresenta l'ideale del giureconsulto repubblicano laico perchè presenta tutte le caratteristiche che contraddistinguono questa figura:
- Conosceva lo ius civile ed esercitava anche l'oratoria forense, conosceva entrambe le discipline e praticava, eccellendo, tanto l'una quanto l'altra, a differenza di altri che si specializzavano in una delle due.
- La sua capacità di badare i propri affari privati non fece mai si che intaccassero il suo impegno politico.
- Aveva un forte riscontro sotto il profilo del prestigio giuridico presso i cittadini.
- Fu un attimo senatore a cui tutti prestavano ascolto grazie alla sua auctoritas.
- Anche le sue capacità militari erano molto spiccate.
- Coltivava la sua cultura al largo raggio e non solo, scriveva anche delle opere nelle quali trovavano piena espressione il suo talento e del suo ingegno.

La memoria

Un'altra caratteristica che torna nelle fonti e che si addice ai giuristi è la ***memoria*** del giureconsulto. Perché tra la memoria e il sapere tecnico corre un *nesso dinamico*, in quanto per il giureconsulto, più che per ogni altra carica specifica, la memoria è un atto caratteristico e significativo, è un bene fragile ma necessario, che egli deve possedere al massimo grado insieme a ponderazione, prontezza, diligenza, perspicacia (tutto questo Cicerone lo ravvisa in Servio).
> Quindi la memoria è una qualità da coltivare e assume quasi un valore esemplare, diviene paradigmatica nella condizione comune, tant'è che addirittura quando emerge il concetto per cui l'oratore deve avere una memoria salda proprio nell'esprimere, nel recitare le orazioni (ed è una dote che va esercitata con l'oratoria), non si trova di meglio che ispirarsi alla memoria dei giureconsulti.
- Quindi questa caratteristica del giureconsulto diviene una pietra di paragone persino per le qualità che l'oratore deve sviluppare, è una facoltà che si incontra e che va in pari con l'acume dei dialettici, la ricchezza di pensiero dei filosofi, l'inventiva linguistica dei poeti, la voce o l'abilità nel recitare dei grandi attori tragici: è una qualità importantissima.

Perchè è importante?

Perchè è proprio attraverso l'eloquenza che noi possiamo capire il valore della memoria del giureconsulto. Proviamo ad immaginare che, affinché un discorso possa essere articolato nel modo più proficuo possibile, bisogna trovare\ individuare gli argomenti e disporli in modo ordinato, consequenziale, intellegibile, comprensibile, logico e quindi convincente nel senso del ragionamento, e quindi bisogna adattare le parole nei casi opportuni, e per fare questo bisogna avere il discorso ben saldo nella mente.
- La memoria del giureconsulto è la sorella gemella della scrittura, non è solo lo scrigno delle idee fornite dall'invenzione e la custodia di tutte le parti della retorica, ma accompagna l'intero discorso.
> Infatti, se volessimo fare un parallelo tra oratore e giurista:
- L'oratore ha come qualità la persuasione per far breccia\portare a sé l'uditorio, deve attrarne l'empatia del duo interlocutore, e quindi sceglie nell'esperienza accumulata e tesaurizzata 8appunto nella memoria) ciò di cui ha bisogno per ogni singola causa e poi dispone in modo ordinato il suo discorso.
- Il giureconsulto in realtà non è che usa la memoria come ufficio retorico, perché il giureconsulto ha come suo obbiettivo la verità giuridica, va alla ricerca della soluzione più adeguata\ più vera in relazione a determinate circostanze o contingenze, per un caso specifico; per cui della memoria come ufficio retorico in se e per se non sa che farsene, però comunque va in contro ad una realtà da decifrare, e quindi è importante la memoria anche per lui specialmente tenendo conto della dimensione della oralità attraverso cui si muove la cultura del tempo.
> Quando il giurista interpretava, inoltre, non aveva la possibilità di consultare archivi o indici, ma si trovava da solo, difronte al suo pubblico a dover fornire la soluzione; Quindi nella sua mente doveva evocare dal suo patrimonio mnemonico, le conoscenze che gli derivano dagli studi e dalla tradizione.
Tra l'altro svolgeva una funzione pubblica autorevolissima, era una guida della società e quindi, nel momento in cui doveva fornire una risposta, doveva scavare nella sua memoria e allestirne una che fosse ben costruita.
> Nulla impediva dunque di attingere, nella propria memoria, da casi analoghi: quindi il lavoro di memorizzazione era anche una premessa che precedeva, eventualmente, la stesura di alcuni scritti.

2. Diritto, filosofia e arti liberali

Come si formava il giurista?: Il sapere enciclopedico.

La formazione del giurista non prevedeva solo la lettura dei libri degli altri giuristi, ma era ampia e variegata, non era strettamente legata al diritto in quanto era comprensiva di altre materie che vi si discostavano, ad esempio la filosofa, la dialettica e le tecniche di organizzazione del discorso e quindi l'esercizio oratorio, ma anche lo studio della grammatica. Le arti liberali (grammatica, dialettica e retorica) rientravano nel tirocinio di ognuno, si studiavano da manuali e compendi, e a tal proposito è importante il nome di Ermagora di Temno che nella metà del II a.C. aveva esposto la precettistica delle arti liberali in maniera sistematica.
Un discorso più ampio riguarda invece la filosofia, che si studiasse da scritti greci o adattamenti in traduzione latina, è comunque incerto quanto questa potesse essere presente, concretamente, nelle attività del giurista; Uno studio o comunque interesse per la filosofia da parte dei giuristi è da supporre, e sarebbe sbagliato pensare il contrario, il dubbio è se questo interesse abbia solo valore personale, se lo si coltivasse per se (come sosteneva Varrone, letterato e grammatico romano), poiché in effetti non si sa in che misura il pensiero filosofico incidesse sulle proprie opere e sul pensiero proprio di oratori e giuristi.

(Testo pag. 164)

Cicerone in un brano autobiografico contenuto nei Topica, opera di retorica, fa riferimento ai tempi giovanili della sua formazione.
Cicerone non è un giurista, ma dobbiamo ricordare che la preparazione dell'oratore e quella del giurista spesso corrispondevano finché poi non si decideva di specializzarsi o nell'una o nell'altra arte, eco perchè il contenuto di questo passo ciceroniano, per quel che riguarda la sua formazione, può essere valido per qualsiasi giovane volesse preparasi a dedicarsi all'attività forense o pubblica.

> *"Studiavo con passione, scrivendo, leggendo e declamando quasi ogni giorno; ma i miei interessi non si limitavano a questi esercizi oratori.... Con impegno mi dedicavo anche allo studio del diritto civile... Riflettevo notte e giorno, su ogni zona del sapere... Mi esercitavo in vari campi e in modo particolare nella dialettica..."*

- Dal brano emerge dunque una cosante dedizione allo studio, alla scrittura, al declamare (e quindi fare esercizi retorici): l'imprescindibilità dell'esercizio della recitatio, appunto, l'esercizio oratorio, si colloca perfettamente in una cultura che demandava all'oralità il compito della sua trasmissione e conservazione.
- I suoi interessi, però, non si limitavano solo alle materie del campo oratorio, che Cicerone, da oratore privilegiava, e dice proprio *"i miei interessi erano più ampi di quanto appena detto"*, e vediamo che comprendevano in primis lo studio del diritto civile, e poi espande il raggio a "ogni zona del sapere", e ritorna poi sull'arte liberale della dialettica, che è quella branca della filosofia che si occupa del ragionamento, dell'organizzazione logica del discorso e che dunque è strettamente di supporto all'oratoria.

> Alcuni esempi di giuristi che possiamo calare nel modello di preparazione che ci offre Cicerone sono:
- Servio Sulpicio Rufo, uomo coltissimo, contemporaneo e anche amico di Cicerone, aveva proprio avuto una formazione parallela a quella ciceroniana, specializzandosi poi in ambito giuridico e non oratorio, seppur anche eccellente oratore, curò molto la sua preparazione oratoria oltre a quella delle arti liberali, costituendosi una cultura molteplice. Servio Sulpicio Rufo è, addirittura, agli occhi di Cicerone, "quasi l'ultimo giurista degno di questo nome".
- Ma anche Antistio Labeone, che seppur non fu mai oratore, specializzatosi nel diritto, curò estremamente le altre arti liberali, approfondendo in particolar modo la grammatica; Quasi come un vero e proprio filologo poneva una particolare attenzione sul significato delle parole latine e sulle regole con cui si formano, e fu capace di mescolare quest'arte a quella giuridica inserendo e sfruttando nei suoi ragionamenti anche quella che oggi è la ricerca etimologica delle parole.

> Il modello di formazione\sapere del giurista era quindi enciclopedico (o totalitario), indipendentemente dal fatto che ci si potesse specializzare in un determinato settore, la cultura era molteplice e spaziava dalla filosofia, all'oratoria, alla grammatica, alla dialettica, alla retorica. E faceva parte di questo sapere enciclopedico anche il *ius civile* (inteso nel suo significato di diritto civile).

Almeno fino al tempo di Catone (II secolo a.C.) il modello del sapere enciclopedico come impostazione di formazione dell'uomo colto rimase invariato, ma nei decenni che seguirono andò via via modificandosi. Dobbiamo infatti considerare che assisteremo alla fine della repubblica già nell'età di Giulio Cesare (conclusasi con le idi di marzo del 44 a.C.), e proprio in questo periodo, pian piano, la cultura si andò trasformandosi, e si ebbe una sorta di crisi della scienza giuridica, in quanto ci furono dei forti cambiamenti nella concezione stessa del giurista di età repubblicana: proprio la concezione differente dell'*auctoritas* sarà il segnale di mutamento rispetto alle caratteristiche del giurista repubblicano.
Addirittura i giuristi iniziarono a tenersi lontani dalla vita pubblica e dalle cariche magistratuali, e si dedicavano anche semplicemente all'insegnamento o gli studi. E cambiò anche questa idea onnicomprensiva del sapere rispetto ad un sapere che privilegia solo una zona, non isolandola, ma accentuandone la specializzazione e quindi la competenza.

Cicerone, che vivere questi momenti in cui la Repubblica vacilla dimostrandosi particolarmente sensibile, per cui, anche se questo cambio di impostazione della formazione avvenne in concomitanza con dei cambiamenti storici, non in maniera traumatica, Cicerone lo avverte fortemente questo cambiamento, e se ne fa testimone:

(Testo pag. 166)

In questo passo tratto dal De Oratore di Cicerone, l'autore ci dà un'idea di come andasse inteso il sapere\ la formazione fino a quel momento, ed esprime un rammarico verso ciò che lui sente che sta accadendo, in quanto sta avvenendo questo passaggio dall'enciclopedia in favore di una sorta di maggiore specialismo.

> *"Non solo questa disciplina oratoria,...ma molte altre, hanno visto ridotto il proprio àmbito per la divisione e la separazione in settori specialistici."*

- Inizia offrendoci un quadro generale in cui prende atto di una situazione che è sotto i suoi occhi, cioè nota che tanto l'oratoria quanto altre discipline si stanno "restringendo" in quanto si sta procedendo verso un'intensificazione dello specialismo.

> *"Credi forse... che al tempo del grande Ippocrate di Cos alcuni medici curassero le malattie, altri le ferite, altri gli occhi? e che, quando Euclide e Archimede si occupavano di geometria, Damone e Aristosseno di musica, Aristofane e Callimaco di critica letteraria, queste discipline fossero così frantumate che nessuno potesse comprenderne la fondamentale unità, ma ciascuno ritagliasse per sé la sua zona di ricerca?"*

- È proprio in queste domande retoriche che Cicerone esprime tutto quel rammarico per l'abbandono di questa conoscenza onnicomprensiva; Fa riferimento in ambito medico, geometrico, musicale e della critica letterale, ad una serie di personaggi che erano dei sapienti che dominavano non solo la propria zona del sapere ma che si erano formati in maniera completa, che avevano una visione complessiva, e che non avevano fatto della propria specializzazione una conoscenza settoriale.

> *"Per quanto mi riguarda, io ho spesso sentito dire da mio padre e da mio suocero, che anche fra noi coloro che volevano distinguersi ed acquistar fama per la loro saggezza, erano soliti abbracciare tutto il sapere almeno quel sapere che allora costituiva il patrimonio della nostra città."*

- Fa riferimento alle generazioni precedenti, per le quali, come per lui, quest'idea del sapere ogni comprensivo era la base della sapienza e della saggezza, e costoro erano depositari di un sapere che si tramandava oralmente e che toccava vari ambiti.

"Essi si ricordavano di Sesto Elio;"

- Nomina Sesto Elio, autore dei tripartita, nei quali trascrisse una copia della 12 tavole, ed emerge che questo personaggio fosse molto importante anche per una generazione precedente rispetto al suocero e al padre di Cicerone.

"ma anche noi abbiamo visto "Manio Manilio passeggiare su e giù per il foro, - segno questo che uno si poneva con la sua esperienza a disposizione di tutti i suoi concittadini."

- Nomina, poi, Manio Manilio, giurista del II secolo a.C., che diventa emblema di quei giuristi che anche proprio fisicamente, passeggiando per il foro, mettevano a disposizione dei cittadini la loro sapienza.

"Da costoro,- sia che passeggiassero nel modo che si è detto, sia che sedessero a casa sul loro seggio -si andava allora per consultarli non solo su questioni giuridiche, ma anche sul matrimonio di una figlia, sull'acquisto di un fondo, sulla coltivazione di un campo, insomma su ogni genere di doveri o di affari."

- Le due modalità per la consultazione dei giuristi erano dunque quella più informale che avveniva nel foro, e quella più solenne che prevedeva che ci si recasse a casa del giureconsulto "presso il loro seggio".
- E vediamo dunque che i giuristi non venivano consultati solo su questioni giuridiche, ma anche per ricevere consigli ad esempio sul matrimonio di una figlia, sull'acquisto di un fondo sulla coltivazione di un campo, ogni genere di dovere o affare. Ricordiamo che il giurista è un *prudens*, ha una *prudentia*, una saggezza, che andava oltre alle vicende giuridiche.

"Questa era la saggezza del vecchio Publio Crasso, di Tiberio Coruncanio, di Scipione il bisavolo di mio genero, uomo prudente e avveduto."

- Menziona poi altri personaggi risalendo ancora più indietro con le generazioni, con sempre più nostalgia dei tempi del sapere ogni comprensivo enciclopedico.

"Furono tutti pontefici massimi, e si ricorreva a loro in ogni difficoltà, di natura religiosa o profana; essi fornivano l'appoggio sicuro del loro consiglio, in senato e nelle assemblee popolari, nelle cause degli amici, in pace e in guerra."

- In questa fase finale ciò che Cicerone sottolinea e che dobbiamo cogliere è l'importanza della certezza del diritto, dei rapporti che passavano attraverso il ruolo di questi sapienti che vengono definiti come un appoggio sicuro, erano un punto di riferimento elevatissimo per tutti cittadini romani: attraverso il loro consiglio si poteva ottenere certezza degli atti che toccavano i vari ambiti privatistici e pubblicistici.

> Questo brano è importante perché quella che Cicerone avverte come una crisi, è di fatto un'evoluzione dettata dalle contingenze della storia; Il sapere enciclopedico lascia spazio ad un specializzazione che non vuol dire però "isolamento".
Quest'avanzamento dello specialismo agli occhi di Cicerone ha come conseguenza il fatto di poter essere giuristi senza necessariamente dover eseguire delle cariche pubbliche, praticando solo la scientia iuris, ma pian piano, la scientia iuris inizia a distaccarsi *dall'auctoritas*: si distaccano *auctoritas* e responso, in quanto con la fine della repubblica e l'inizio del principato, *l'auctoritas* diventerà un tratto distintivo del principe, mentre la *scientia iuris* rimarrà sempre prerogativa del giurista.

L'*auctoritas*, dunque, dall'essere un tratto distintivo, perde la sua essenzialità, in età augustea i giuristi non saranno più necessariamente impegnati in campo politico, ma ciò non comporta una minore importanza.

3. Atteggiamento oracolare

Abbiamo visto che per un lungo periodo di tempo il sapere giuridico era stato unicamente nelle mani dei giuristi pontefici i quali veicolavano la loro sapienza attraverso l'attività del responso che si caratterizzava per essere un tipo di responso laconico, cioè privo di spiegazione.

Il respondere si articolava dunque nel cavere e nell'agere componendo una triade che fornisce un'idea più articolata di responso in quanto allestimento di schemi processuali o negoziali; questa triade nel momento, poi, della laicizzazione del diritto iniziò ad assumere un valore pubblico, poiché il giurista non è più necessariamente pontefice massimo, ma è un giureconsulto aristocratico laico libero anche da quella solennità e segretezza che caratterizzava il giurista pontefice.
Il responso, dunque, si ritrova nel momento in cui avviene l'interpretazione del giurista, è il momento in cui il giurista fornisce il consiglio tecnico al quesito sul caso concreto.

Inoltre, già nella tarda repubblica, anche il diritto si era trasformato e non era più estremamente legato al formalismo, questo era stato proprio superato: possiamo addirittura affermare che il sostrato della laicizzazione del diritto sia proprio il superamento del formalismo.

> Per comprendere appieno questo cambiamento dei caratteri del responso, possiamo far riferimento ad un frammento aneddotico fornitoci da Pomponio che si si ritrova nel primo libro dei Digesta della compilazione Giustinianea (cogliamo l'occasione per evidenziare quanto i Digesta siano una fonte essenziale da cui poter ricavare la conoscenza del pensiero dei giuristi antichi)

- Pomponio, giurista del II secolo d.C. che vive in età Antonina, in particolare sotto Antonino Pio, scrisse un'opera in cui ripercorre la storia del diritto, della città e delle magistrature, e prende il nome di "Enchiridion" che vuol dire proprio "manualetto", e se non in tutta l'opera almeno in una parte di essa, ripercorre le singole figure dei giuristi evidenziandone la loro incidenza e cogliendone alcune caratteristiche principali.

Il frammento in questione è un aneddoto, per cui, nonostante ci sia un fondo di verità o comunque verosimiglianza, ciò che dobbiamo realmente cogliere e il suo significato simbolico.

In questo caso bisogna cogliere, alla luce dei fatti narrati, la notevole trasformazione del responso nel giro di una generazione; Pomponio infatti si sofferma su due giuristi tardo-repubblicani di grandissima importanza l'uno più anziano dell'altro di circa 25 anni (appunto una generazione):

- Quinto Mucio Scevola * (il più anziano)
- Servio Sulpicio Rufo (il più giovane, contemporaneo di Cicerone)

**** La figura di Q. Mucio Scevola (vedi capitolo 7 per S. Sulpicio Rufo)***
- Visse tra il II-I secolo a.C.
- Era un personaggio carismatico.
- Da un lato fortemente collegato alla tradizione pontificale.
- Dall'altro lato, il suo ruolo fu importantissimo dal punto di vista dell'innovazione, la sua opera, infatti, diede un contributo enorme; Sarà nei suoi 18 libri di diritto civile che introdurrà un metodo di organizzazione logica del discorso, attinto dalla dialettica ellenistica, che rappresenta un momento fondamentale per la nascita della scienza giuridica europea: la *diairesis. (Approfondita nel par.6 c.6)*

(Testo pag.168)

> *"Servio Sulpicio era ritenuto il primo, o secondo solo a Cicerone, nel patrocinare le cause. A quanto si tramanda, egli andò a consultare Quinto Mucio per un affare di un suo amico, ma non riuscì a capire quel che Mucio gli rispose sul problema giuridico; perciò lo interrogò una seconda volta, ma, benché Mucio gli rispondesse di nuovo, non riuscì ancora a comprendere; allora Quinto Mucio lo rimproverò aspramente, sostenendo che era vergognoso per un patrizio, un nobile, un oratore, ignorare il diritto di cui si occupava"*

- Questa è una scena che possiamo figurarci:
- Essendo Scevola morto nell'82 a.C., quando Rufo aveva all'incirca 25 anni, dobbiamo immaginare al momento dei fatti narrati un Servio Sulpicio Rufo più o meno ventenne, di fronte ad un Quinto Mucio Scevola ormai giurista anziano (80 anni circa) e autorevolissimo (sappiamo che la senectus era fonte di auctoritas, poiché tanto più si era anziani, tanto più si era un patrimonio da cui attingere).

- Vediamo Servio Sulpicio Rufo che si reca da Quinto Mucio Scevola per esporgli un problema giuridico, ma per ben due volte non riesce a comprendere la risposta di Quinto Mucio Scevola cha dunque lo rimprovera aspramente affermando che fosse assurdo, addirittura vergognoso e incredibile che un patrizio nobile e oratore ignorasse il diritto di cui si stava occupando.

- Servio Sulpicio Rufo (giurista del I secolo a.C.) aveva avuto una formazione parallela a quella ciceroniana (poi ognuno si era specializzato nel proprio ramo), era tra l'altro amico di Cicerone che gli riconosce grandi meriti in qualità di ultimo rappresentante di quella sapienza di cui lui era estimatore, infatti Servio Sulpicio Rufo essendo giurista in senso stretto non si era formato solo in materia di diritto, ma il suo sapere era enciclopedico, toccava, ad esempio anche l'oratoria, tant'è che si dice fosse quasi sullo stesso piano di Cicerone nel padroneggiare le cause, quindi eccelleva sia in ambito giuridico sia in ambito oratorio.
- Ed è proprio per questi motivi, perché le caratteristiche di Rufo rispecchiano quelle dell'ideale di giureconsulto repubblicano laico, che che dobbiamo cogliere l'asprezza del rimprovero di Scevola.

- Data questa premessa, dobbiamo inoltre immaginare che il bagaglio di conoscenze di Rufo fosse già maturo nel momento in cui si recò da Quinto Mucio Scevola, il che è verosimile poiché molti oratori erano già attivi attorno ai 19 anni, ma a prescindere dalla veridicità dell'episodio, ciò che dobbiamo cogliere è, appunto, il significato simbolico dell'aneddoto:
Capiamo bene che Servio Sulpicio Rufo avesse tutti gli strumenti necessari per comprendere le parole di Quinto Mucio Scevola, e non si può dire, d'altro canto, che fosse incapace di comprendere per limitatezza mentale.

Il motivo per cui un Servio Sulpicio Rufo così dotato non comprendeva il responso di Quinto Mucio Scevola è che: la modalità attraverso la quale Quinto Mucio Scevola esprimeva il suo responso era nettamente diversa da quella con cui era abituato e proiettato Servio Sulpicio Rufo.

- Quinto Mucio Scevola era infatti stato pontefice massimo, e pur trattandosi di un giurista laico della tarda repubblica, periodo in cui si era ormai completamente laicizzato il diritto, ciò non escludeva né che si potessero comunque rivestire delle cariche sacerdotali di particolare importanza, né chi è il cambiamento fosse stato repentino: Dobbiamo considerare che nulla cambia all'improvviso, ed evidentemente Quinto Mucio Scevola recava in sé dei retaggi tipici del responso pontificale, e quindi un atteggiamento oracolare nella pronuncia del suo responso.
- Il suo responso era laconico, veniva fuori l'esito ultimo dell'interpretazione, ma tutto il percorso interpretativo non veniva esplicato: l'interlocutore doveva quindi cogliere in sé per sé il responso senza ascoltare tutte le motivazioni che avevano portato a quell'esito finale.

- Servio Sulpicio Rufo d'altro canto, essendo una generazione successiva rispetto a Quinto Mucio Scevola, aveva ormai superato questo legame con la tradizione pontificale, tant'è che il responso serviano si muoveva già in una direzione molto diversa rispetto a quella di Quinto Mucio Scevola la cui mentalità era rimasta ferma in quella realtà della civitas ristretta a discapito di quella più aperta e dinamica che aveva già preso dimestichezza con il diritto commerciale, con i traffici marittimi che possiamo rivedere in Servio Sulpicio Rufo.
Era bastata una sola generazione per cambiare lo scenario, tant'è che Servio scrisse anche un'opera intitolata "reverenza scevolicana" all'interno della quale si pone in polemica nei confronti di Quinto Mucio Scevola, coglie le criticità del suo pensiero in un dialogo costruttivo che permette proprio di far capire la diversità di punto di vista di prospettive dovuta alla differenza generazionale.

4. Custodia e invenzione di formule

5. La diffidenza verso la legge

6. La tradizione civilistica

Anche solo l'espressione “tradizione civilistica” è significativa:

- “Tradizione” ci dà già l'idea di qualcosa che si tramanda, di un passato che fluisce il presente.
- “Civilistica” perché ha a che fare con lo *ius civile* nel senso stretto del termine.

Le ***accezioni di “ius civile”*** sono infatti due:

1- *Ius civile* in senso ampio:
Che si riferisce all'ordinamento giuridico della città nella sua dimensione privatistica, si parla di ius *civitatis*, proprio il diritto della città che disciplina appunto rapporti tra privati.

2- *Ius civile* in senso stretto:
Che Pomponio definisce “in senso proprio”, e si riferisce all’*interpretatio prudentium* (interpretazione dei giuristi), cioè quel corpo di opinioni dottrine e regole che andò accumulandosi e svolgendosi nel tempo, con l’affinarsi sempre maggiore delle tecniche razionali.
Con *interpretatio prudentium* intende proprio quel sapere che si era andato a costituire attorno al diritto privato grazie all'apporto intellettuale dei giuristi che nel corso del tempo costruirono un avere propria *scientia iuris* con metodi e tecniche razionali.

Ed è proprio questa attività interpretativa che poi prodotto una letteratura formata proprio dalle opere in cui si è riversata tutta questa produzione intellettuale dei giuristi: ecco perché si parla anche di tradizione letteraria-civilistica :
Definizione: corpo di opinioni e dottrine elaborate e vagliate attraverso l'impiego di tecniche razionali, soprattutto in ambito privatistico. Tale attività interpretativa dei giuristi costruitasi intorno al *ius civile* si autorappresenta in una letteratura.

I *momenti salienti di questa tradizione civilistica*, scanditi attraverso la letteratura che contiene l'interpretazione dei giuristi in ambito privatistico, sono:

1- III-II a.C.
È possibile risalire sino a Sesto Elio Peto Cato
Autore dei *Tripertita*, l'opera, appunto tripartita, divisa in tre parti che conteneva:

- Il testo delle 12 tavole
Già, quindi, gli si deve attribuire l’importante merito di averne messo per iscritto il testo, in quanto erano state distrutte in un incendio, oramai venivano trasmesse solo oralmente. È principalmente grazie a lui se oggi siamo in grado di leggere integralmente le 12 tavole (seppur con le annesse possibili variazioni dovute dal tempo e dalla trasmissione orale).
- Ad accompagnare i precetti decemvirali c’era poi, nella seconda parte, l’interpretazione dei giuristi.

A tal proposito, non bisogna confondersi, in quanto siamo nel periodo della media Repubblica, e *interpretatio* va ancora intesa in senso statico, per cui si attinge ancora alla materia del formalismo interpretativo, e cioè all'opera dei primi tecnici del diritto (i pontefici) la cui interpretazione consisteva nell’elaborare congegni e formule che non andassero mai a tradire i precetti decemvirali.

- E nella terza parte i moduli procedurali delle *legis actiones*.

Non sappiamo, in realtà, se quest'opera si presentasse in tre blocchi giustapposti, o intrecciati tra loro, per cui c’è sia la possibilità che fossero tre parti distinte, prima le 12 tavole, poi le interpretazioni e poi i moduli procedurali, sia la possibilità che ad ogni precetto decemvirale seguisse la relativa interpretazione e il modulo procedurale adeguato a far valere quella specifica pretesa decemvirale.

2- II a.C

Il passaggio immediatamente successivo c'è dato da Pomponio e che nell'Enchiridion ("manualetto", opera di storia del diritto, della città e delle magistrature) individua una triade di giuristi, a detta sua, "qui fundaverunt ius civile":

- Manio Manilio
- Giunio Bruto
- Publio Mucio Scevola (antenato di Quinto Mucio Scevola)

Autori rispettivamente di:

- *Monumenta, Actiones* (Manilio)
- *De iure civili* (Bruto)
- *De iure civili* (Publio Scevola)

Quando Pomponio afferma che costoro "*fundaverunt ius civile*" , quel *fundaverunt* è da intendere proprio come dare assetto\ fondamento al *ius civile* nella sua seconda accezione, cioè al diritto che si venne componendo come *interpretatio*, autonomo dal dato legislativo: cioè diedero corpo ad un diritto giurisprudenziale che ha carattere scientifico, che sta guadagnando le proprie tecniche razionali.

Il dato innovativo è proprio questo: sono questi tre giuristi che diedero fondamento alla interpretatio prudentium in un senso diverso rispetto a quella che si ritrova ancora in Sesto Elio, poiché si spezza il legame con il dato legislativo.

Ecco perché si è detto che con questi primi tre giuristi si comincia a dotare di autonomia il diritto giurisprudenziale.

> Addirittura in Manio Manilio abbiamo una traccia, considerata molto significativa, di un impiego primordiale di quella tecnica che poi, Tito Livio porterò a livelli più elevati: la diairesis.

La ***diairesis*** (o divisio)non è altro che un mezzo per giungere alla definizione di un concetto partendo, nel caso della diairesis ascendente, da un concetto più vasto che prende il nome di *genus* e procedendo per mezzo di una concatenazione di divisioni ciascuna caratterizzata da differenti proprietà, che prendono il nome di *species*, o viceversa, nel caso della diairesis ascendente, si parte dalle *species* e si risale al *genus*.

In Manio Manilio infatti, si trova traccia della definizione del Nexum, quell'atto di autonomia privata d'età arcaica che prevedeva l'assoggettamento fisico del creditore al debitore; Manio Manilio lo fa rientrare nella categoria più ampia dei negozi per aes et libram, cioè quelli che richiedevano l'impiego del bronzo della bilancia (un'altro è ad esempio la mancipatio).

In sintesi quindi abbiamo l'impiego di uno strumento attinto dalla dialettica, appunto la diairesis.

3- II-I a.C.

Un ulteriore passo significativo si ebbe con Quinto Mucio Scevola, fu proprio lui che portò "a compimento" l'ingresso della tecnica diairetica nelle opere dei giureconsulti.

Con Quinto Mucio Scevola, autore di *18 libri iuris civilis* (18 libri di diritto civile), si inizia anche a parlare di una svolta dell'organizzazione sistematica del diritto.

In realtà anche l'opera di Sesto Elio, i *Tripertita*, può essere intesa come sistematica, tuttavia possiamo intendere quest'aggettivo **sia** come una mera organizzazione di dati esteriori, **sia**, più appropriatamente, come organizzazione dei suoi nessi logici interni.

Per cui non è un semplice riordino, ma si suppone un'organizzazione razionale, con dei nessi logici interni, che Quinto Mucio Scevola stipula proprio sulla base della diairesis, e l'adozione di questo particolare procedimento dialettico conferisce un respiro diverso alla tradizione civilistica.

Naturalmente Quinto Mucio Scevola, non applica la diairesis all'impianto complessivo dell'opera, ma solo per alcuni argomenti, solo successivamente, sul suo modello, hanno iniziato ad utilizzare lo stesso procedimento anche altri.

Questo è un aspetto su cui si sofferma anche Pomponio, nell'Enchiridion, su Quinto Mucio dice proprio *"primus generatim ius civile constituit"*, con "*generatim*" fa proprio riferimento a "generare" nel senso che utilizza per primo questo metodo di divisione logica in genere e specie.

> Dobbiamo pensare ad un avere propria ramificazione o costruzione piramidale in cui abbiamo la categoria più ampia del genus che si ramifica, punto, in varie species.

Es. Le obbligazioni si contraddistinguono nel "genus-obbligatio" (cioè quel vincolo che lega il debitore al creditore in funzione del compimento di una determinata prestazione), questo genus si può suddividere in base alle fonti, agli atti o ai fatti da cui scaturisce l'obbligazione (ad esempio, appunto, le obbligazioni nate da contratto, quelle nate da delitto).

> A loro volta le *species* possono diventare *genera*, cioè dalle specie possono nascere ulteriori ramificazioni\ specificazioni:

Ad esempio, sempre nel caso delle obbligazioni:
- Nella *species* di quelle nate da contratto è possibile distinguere quelle che si perfezionano con la consegna della cosa, con la pronuncia di certe parole, con la scrittura o con il mero consenso
- Nella *species* di quelle nate da delitto, abbiamo quelle nate da furto, danno, dall'ingiuria eccetera.

> Sarebbe sbagliato pensare che questa impostazione sistematica\ diairetica del discorso nell'opera, escluda l'impostazione storica del discorso: l'evoluzione storica degli istituti del diritto privato non viene mai meno.
- A tal proposito, è esemplare il discorso sulla *societas*, affrontato sia da Quinto Mucio Scevola, la cui opinione ci arriva grazie a Pomponio che ne fa riferimento nel suo commentario all'opera muciana, sia da Gaio nelle *Institutiones*.
E abbiamo la possibilità di vedere la combinazione dell'impostazione storica e di quella sistematica:

(Testi pag.186)

Primo frammento - Pomponio
- Nei *commentarii ad Quintum Mucium*, Pomponio riprese quindi il pensiero di Quinto Mucio, si parla proprio di ***commento flemmatico***, cioè si alterna la voce del giurista anziano è quella del giurista che sta commentando.

> *"Se nel contrarre qualunque negozio, sia esso o no di buona fede, interviene un errore, sicché una cosa intende (per esempio) la parte che compra o riceve in locazione, e un'altra cosa l'altra parte contraente, il negozio è nullo. Negli stessi termini bisogna pronunciarsi anche riguardo a un contratto di società; sicché se le parti dissentono intendendo cose diverse, non ha nessuna efficacia quella società che si fonda sul consenso"*

- Pomponio si sta occupando dell'ipotesi del vizio della volontà: cioè dice che se in un contratto, ad esempio di locazione o compravendita, il venditore e il compratore intendono cose diverse, e quindi ad esempio non c'è sintonia rispetto all'oggetto, allora si manifesta il vizio dell'errore e quindi negozio è nullo.

- E ed è così che bisogna comportarsi anche rispetto ad un contratto di società (ecco che individua il *genus* ampio della *societas*), e quindi dice che se i soci, o presunti soci che stanno costituendo una società cadono equivoco, allora quella società che si fonda sul consenso non sortisce nessun effetto giuridico.

- Vediamo quindi un ragionamento diairetico ascendente, cioè sta parlando di una specie rispetto ad un *genus* più ampio, ovvero la società basata sul consenso (*species*), poiché quando dice "quella società che si fonda sul consenso" lascia intendere che ce ne siano altre, rispetto al genus della società che chiaramente include altre ipotesi.

Secondo frammento - Gaio

Ma appunto la società di cui parliamo, cioè quella che si contrae col nudo consenso, appartiene al «diritto dei popoli», e dunque ha valore presso tutti gli uomini per un principio di ragione naturale. È proprio dei cittadini romani, invece, un altro genere di società. Un tempo infatti, alla morte del padre, si costituiva fra gli eredi suoi discendenti immediati, e a lui sottoposti, una società (per così dire) legittima e naturale, che era chiamata ercto non cito, ossia *"senza divisione del dominio"... anche gli estranei che volevano costituire una società come questa, potevano farlo impiegando dinanzi al pretore un apposito procedimento formale.*

- Gaio, si rifà alla tradizione civilistica, conosceva bene Quinto Mucio Scevola e ne fa riferimento quando agli studenti descrive la figura della societas, infatti, per una ragione didattica, Gaio, spesso e volentieri ripercorrendo la storia degli istituti e attinge alla tradizione Muciana; Ed è qui che compare proprio l'inclinazione storica.

- Gaio infatti parte con l'individuare una prima species di società:La societas ius gentium, che è quella specifica di cui sta parlando, e che vale per un principio di ragione naturale, cioè ha alla base la razionalità.

- Dopodichè ne individua l'archetipo, parla infatti di un altra species di società propria dei cittadini romani, cioè il consorzio dei fratelli coeredi:

> Accadeva spesso che alla morte del padre, i figli subentrassero tutti insieme come eredi necessari del patrimonio indiviso del padre deceduto: quindi il patrimonio diventava comproprietà indivisa dei fratelli coeredi alla la morte del padre.

Ed è individuabile come archetipo in quanto essa è il primo tipo di società che ha a che fare con l'ambito del diritto reale, e Gaio la considera come la prima figura su cui i giuristi hanno lavorato per elaborare i diversi species del *genus* "*societas",* in quanto proprio sul modello di questa (che prevedeva una condivisione del patrimonio indiviso del padre in virtù della fraternitas), poi, i giuristi, applicarono questo schema anche a degli estranei, a soggetti che non sono fratelli, ma che vogliono perseguire questo compito di cogestione del patrimonio.
Per cui si ha un'evoluzione: dalla *societas* del consorzio dei fratelli coeredi a quella *iuris civilis* degli estranei che mettono insieme i propri beni per creare un patrimonio che è cogestito, e l'altra, la *societas ius gentium* ne è un ulteriore evoluzione dovuta alle necessità commerciali.

Societas ius gentium, societas iuris civilis e consorzio dei fratelli coeredi sono quindi tre *species* dello stesso *genus* "*societas"*.

In Gaio quindi è lampante sia il discorso diairetico nel momento in cui distingue le varie *species* a fronte dello stesso *genus*, ma anche il discorso storico in cui vediamo il susseguirsi delle varie specie di società.
> Il diritto si sta facendo scienza.

4- I d.C.

La tradizione civilistica vede un altro passaggio importante con:
- Masurio Sabino
- Cassio Longino
> Che saranno i due capiscuola della scuola sabiniano-cassiana del principato.

Anche loro si rifanno direttamente all'opera muciana, naturalmente conoscendo anche il pregresso, e scrivono dei libri di *iuris civilis*.
- Sabino scriverà i L*ibri Tres Iuris Civilis*, che ebbero fortuna notevole in quanto molti giuristi di età successiva scriveranno dei commentari "*ad Sabinum*" e quest'opera sarà molto apprezzata e commentata.
- Cassio scrive appunti, i libri iuris civilis, i quali si misurano perfettamente con queste tematiche, e vedremo che anche il tipo di interesse letterario/tipologia letteraria in cui si versarono saranno specchio di un'impostazione di insegnamento.

5- II d.C.

Un ulteriore esito nella tradizione civilistica si ebbe con Gaio, autore delle I*nstitutiones*.

Gaio, addirittura, si dice espressamente un sabiniano, per cui si riconduce direttamente alla letteratura sabiniana che a sua volta si rifà a quella muciana.

- E le *Institutiones* di Gaio hanno un'impostazione sistematica molto evidente e ci permettono di capire come esito la *diairesis*.

7. L'editto, un testo fragile e persistente

Editto fragile ma persistente (da integrare con par.4 del capitolo quinto)

Così com'è il periodo in carica del pretore, anche la durata dell'editto era annuale: cessata la carica, l'editto perdeva formalmente ogni efficacia e veniva sostituito da quello del pretore successivo, capiamo quindi quanto sia distante dalla "legge", tant'è che al massimo si può parlare di *"lex annua"*.

Tuttavia, seppur l'editto sia in se stesso un testo effimero e precario, poiché sin dal momento in cui viene emanato già prevede la sua prossima fine\ ha una scadenza, nel momento in cui prevede degli istituti che si rivelano dare buona prova di sé, questi potranno essere ripresi dal magistrato successivo.

> Ecco perché la realtà dell'editto si muove fra i poli temporaneità\ intermittenza formale-sostanziale effettività e continuità: l'editto è *dinamico:*

- Da una parte si caratterizza per la sua intrinseca ***fragilità***:
  Ha una sua caducità legata alla durata della carica pretoria.

- Ma dall'altra rimane ***persistente***:
  Tutte quelle norme, quei criteri, quelle formule o rimedi che nell'applicazione pratica davano buona prova di sé e si rivelavano funzionali ed efficaci per regolare determinate situazione, venivano ripresi nell'editto successivo del pretore e successivo e così via, sottoponendosi al vaglio dell'applicazione pratica di anno in anno

Capiamo quindi che la natura intrinseca dell'editto è dinamica, tant'è che questo gioco di conservazione e innovazione, non si ferma neanche con la redazione dell'editto perpetuo: Con l'editto perpetuo, sì, il testo edittale si cristallizza, ma il pretore continua annualmente ad emanarlo.

A maggior ragione, prima della redazione dell'edictum perpetuum, l'editto che avevano di fronte i giuristi dell'ultima Repubblica (metà II-I secolo a.C), ma anche, ancora, i giuristi d'età augustea, era ben diverso da quello che avevano a disposizione ad esempio Pomponio, Gaio, Ulpiano o Paolo (I-II secolo d.C.); seppur i suoi nuclei fondamentali e le sue linee sistematiche fossero ormai ferme, molte norme avevano origine recente se non recentissima, e gli apporti correttivi o innovativi erano più frequenti di quanto si pensa; ecco perché, pur trattenuto entro dei solchi ben definiti, l'editto appariva uno statuto in continua formazione.
(Es. itinerario formativo della bonorum possessio, par.5 cap.5)

>> *Chi stabiliva quando quel determinato contenuto dell'editto fosse abbastanza valido da essere trasferito nell'editto successivo assumendo una sua diversa e durevole giuridicità (sul piano quasi consuetudinario), e chi eventualmente elaborava nuovi strumenti sostitutivi?*

- Cioè, sappiamo che la durata delle norme pretorie dipende dalla rilevanza, dall'autorità che se stesse riuscivano a raggiungere nella loro applicazione pratica, allo stesso modo, vi erano norme che, perchè desuete, podevano totalmente rilevanza e andavano sostituite\ eliminiate; e arbitra di questa rilevanza, non è una generica coscienza sociale, ma ***la giurisprudenza***.

I pretori, salvo casi abbastanza presenti (come ad esempio Labeone), non erano giuristi, per cui, per gestire le attività di elaborazione attorno all'editto, avevano bisogno della consulenza dei giuristi.

Per cui tra la giurisprudenza e l'attività normativa pretoria corre un legame molto stretto (che realtà già si può constatare pensando al contributo dei giuristi nella compilazione delle formule processuali), nell'ambito dell'editto, però, il ruolo della giurisprudenza risulta particolarmente rilevante ed essenziale proprio per suggerire al pretore le formule e le azioni da conservare\ abolire dall'editto precedente a quello successivo, ma non solo, e erano di fatto i giuristi a formulare le nuove soluzioni.

- Ad esempio, nel momento in cui sorgeva una controversia, ci si rivolgeva ad un consulente, appunto, il giurista, per avere un parere tecnico anche su come agire per poter realizzare il proprio diritto in processo; possiamo immaginare quanto questo repertorio di strumenti, formule e mezzi straordinari previsti nell'editto abbiano quindi la necessità di essere vagliate dall'interpretazione dei giuristi che commentano l'editto stesso.

> I loro commentari rappresentano una vera propria fonte di produzione normativa, poiché è attraverso i giuristi che l'editto viene interpretato, commentato e sviscerato:

- I giuristi, quando una norma diviene stabile, esercitano su di essa una riflessione.

- Nel momento in cui più giuristi esprimono il proprio parere, si viene a formare una vera e propria letteratura, e *l'intento* di queste riflessioni era proprio quello di delucidare determinate norme attraverso un'analisi giuridico-linguistica con la quale stabilire se il contenuto individuato fosse da estendere o da restringere nella sua sfera applicativa.

> L'editto, infatti, a differenza della legge non "lega le mani": la sua stessa natura di "statuto in formazione" condanna il testo edittale ad un continuo esame critico che ne verifichi di volta in volta la correttezza logica o la rispondenza ai valori assunti come fondamentali, per cui la stabilità delle norme pretorie è sempre relativa, sono modificabili e perfezionabili nel corso della continua ricerca di una propria stabilità.

(Testo pag. 190)

Un esempio di critica al testo edittale lo possiamo rintracciare nella testimonianza di Ulpiano, che riporta le parole di Labeone, concordando con lui, circa la superfluità di una disposizione specifica relativa all'agire calunnioso o diffamatorio:

- Ulpiano afferma che, secondo Labeone questa specifica disposizione risulta inutile poiché per lo stesso oggetto è possibile agire in base all'editto più generale relativo all'ingiuria, anche se lo stesso Labeone riconosce anche che il pretore, seguendo le modalità del fatto potrebbe essersi pronunciato su quell'oggetto in termini particolari in quanto spesso i comportamenti che nella vita pratica saltano gli occhi, nel momento in cui non ricevono una particolare disciplina, sembrano quasi non presi in considerazione.

> Cogliamo quindi che la critica l'editto è una delle vie attraverso cui la giurisprudenza svolge il suo controllo su una fonte normativa di primaria importanza; questo tipo di critica non è da considerare come un fenomeno esclusivamente tecnico, ma dietro l'impegno tecnico bisogna distinguere interessi e convinzioni di più ampia portata. (si arriva a parlare di politica del diritto)

> I criteri sui quali si regolano i giuristi nelle loro critiche all'editto sono:
- *Utilitas*: e quindi, se volessimo rifarci all'esempio precedente di Ulpiano, la "non superfluità"
- *Aequitas:*
- *Ratio:* che è proprio il principio di fondo, la motivazione che spiega una scelta normativa\ istituto.
> Affinché una norma diventi una misura continuativa dell'agire (affinché perduri nel tempo al di la di ogni causalità storica) bisogna che dimostri la propria utilità, equità e ragione.
Ed è compito dei giuristi rendere chiari questi elementi all'interno delle norme per determinarne l'efficacia.

> Un altro compito della giurisprudenza, era appunto anche quello di definire, ogni volta che fosse necessario, i presupposti di ***applicabilità della normativa*** edittale:
- A tal proposito è esemplificativo il discorso di Ulpiano sull'azione per il dolo che ritroviamo nell'11º libro del suo commento all'editto.

(Testo pag. 191-192)
> L'analisi di Ulpiano comincia ripercorrendo le parole stesse contenute nell'editto, e va poi ad analizzarle riprendendo un filo cronologico che comprende diverse opinioni giurisprudenziali e che risale fino a Servio (I secolo a.C)
- Ulpiano afferma che con l'editto, di cui poi riporta proprio le parole, il pretore predispose un rimedio contro coloro che comportandosi in modo ambiguo e doloso, nuocciono agli altri con una sorta di astuzia;
- Individuando poi la *ratio* (quindi la causa\motivo\le ragioni di questo editto) afferma che da una parte si voleva evitare, ovviamente, che tale astuzia\ malizia fosse vantaggiosa per chi assumeva questo tipo di comportamento, dall'altra "*affinché non sia dannosa a questi una semplice maniera di vedere le cose*".

- Quindi si rifà alle parole dell'editto che stabiliva che *"quanto all'agire negoziale che si dirà tenuto con dolo illecito, se nessun altra azione sarà esperibili è apparirà esservi una ragionevole fondamento, io concederò il procedimento dinanzi al giudice"*

Si concentra prima sulla definizione del dolo:
- Comincia con il parere di Servio che definisce il dolo illecito come *un artificio diretto ad abbindolare gli altri per cui fingendo una cosa se ne fa un altro.*
- Dopodichè considera Labeone, che al contrario afferma che anche senza fingere si può agire in modo da raggirare qualcuno, viceversa senza che vi sia dolo illecito si può fingere una cosa e farne un'altra.
Per cui in una sua definizione di dolo illecito, con cui Ulpiano si trova a concordare, Labeone afferma che *rientra nel dolo illecito ogni astuzia o trucco o artificio impiegato e lo scopo di raggirare, trarre in errore, abbindolare*.

Poi sposta l'attenzione sul l'aggettivo "illecito"
- Afferma che, appunto, il pretore non si era limitato a nominare solo il dolo, ma giunse l'attributo "illecito", e questo perché gli antichi parlavano anche di un *dolo lecito* e davano al termine "dolo" il significato di "*accortezza*" (soprattutto per il caso in cui si agisca contro il nemico o un brigante).

- Un'altra attenzione del pretore era stata quella di concedere l'azione per il dolo solo se nessun altra azione fosse stata esperibile, in quanto l'azione per dolo era un'azione infamante, e nel caso in cui ci fosse stata un'altra azione civile onoraria che fosse, quest'ultima sarebbe stata preferita.

- Ulpiano poi nomina Pedio, che in relazione a quanto scritto nella parte precedente, afferma che si arrivò al punto che questo editto cessa di avere efficacia anche quando c'era un interdetto da esercitare o un'eccezione con cui tutelarsi;

Allo stesso modo la pensa Pomponio che aggiunge che, anche se taluno è garantito da una stipulazione, non potrà ottenere l'azione per il dolo: come accade, per esempio, se si è conclusa una stipulazione concernente appunto il dolo.

- Sempre secondo Pomponio, anche quando è assolutamente da escludere che si dia un'azione contro di me, io non dovrò adoperarmi per ottenere l'azione per il dolo, dal momento che nessun magistrato concederebbe un'azione contro di me.

- Ed è ancora Pomponio che riferisce che, secondo Labeone, anche quando taluno può essere reintegrato nel suo stato giuridico con un'apposita pronuncia magistratuale, non gli compete l'azione per il dolo; e non compete questa azione, anche quando un'altra azione non sia più esperibile per il decorso del tempo, dovendosi imputare a sé stessi il fatto di aver tralasciato di agire: a meno che l'illecita condotta dolosa non abbia avuto proprio il fine di determinare lo scadere del termine.

> Nella clausola edittale con cui il pretore prometteva l'azione per il dolo, ciò che emerge è che il pretore non faceva dipendere la possibilità di usufruire di questo tipo di azione dello stato personale o sociale di chi la richiedesse. Tuttavia Labeone, la cui opinione, ancora una volta, la ritroviamo nella parole di Ulpiano, afferma l'esatto opposto poiché ritiene:

(Testo pag.193)

- Che il pretore debba riservarsi, appunto con una clausola, l'esame sommario della lite;

Cioè quest'azione non bisogna concederla in ogni caso:

- in primo luogo se si tratta di una somma modesta di denaro, poi proprio perché è un'azione infamante, a certe persone non andava mai concessa:

- Come ad esempio ai figli o ai liberti contro i genitori o i padroni

- un uomo di bassa condizione sociale contro chi invece apparteneva ad un ceto elevato e ancora.

- non doveva essere concessa ad un dissoluto o ad un uomo dalla condotta biasimevole contro chi fosse di costumi irreprensibili.

> L'ambito di applicabilità della norma pretoria si definisce quindi secondo un criterio politico-assiologico, addirittura possiamo dire che l'appartenenza ad un ceto sociale è terminato si traduce in un privilegio giuridico, positivo o negativo.

> Infatti l'elemento su cui Ulpiano fa leva e ***l'infamia***, cioè alcune azioni anche quella per il dolo comportavano l'infamia (perdita della dignitas) per il condannato, all'infamia non solo erano ricollegate alcune limitazioni della capacità giuridica, ma era essenziale sotto il profilo politico, la perdita della dignità, del prestigio sociale (quindi l'infamia) costituiva un ostacolo enorme per la carriera politica o eventualmente ne segnano il fallimento.

Capitolo settimo: Il responso

1. La pratica del responso e il processo

È importante l'opinione dei giuristi per stabilire un giudizio processuale?

Come abbiamo visto, il responso non è altro che il parere (del giurista) che risolve tecnicamente un quesito giuridico.

L'attività del *respondere*, che, ricordiamo, si articola nel *cavere* e nell'*agere*, ha una sua evoluzione:
- Nel periodo arcaico vediamo la figura del giurista pontefice:
La sapienza giuridica era appannaggio dei pontefici, un sapere che loro custodivano segretamente negli archivi pontificali; l'unico momento in cui si veicolava la loro sapienza era il *responso* caratterizzato dalla laconicità oracolare, cioè era privo di qualsiasi motivazione, ai profani (a coloro che erano non avevano la minima conoscenza in ambito di diritto, poiché era appannaggio pontificale) che si rivolgevano ai pontefici per avere un parere tecnico ad esempio per una controversia, i pontefici si limitavano a fornire, il congegno\ strumento\ formula più idonea a perseguire la finalità dell'efficacia giuridica.
- L'attività del respondere, con la laicizzazione del diritto, assume un valore pubblico in quanto il giurista diventa laico (e non più necessariamente pontefice massimo).
E con il giureconsulto laico il responso diventa più articolato, include anche l'interpretazione del giurista, che fornisce il consiglio tecnico ad un quesito e non si limita solo ad indicare la mera formula.
(Esemplificativo è il passo di Pomponio su Q. Mucio Scevola e S. Sulpicio Rufo - vedi par.3 c.6)

In generale non fa altro che orientare i comportamenti dei privati, le scelte normative dei magistrati e le sentenze dei giudici.

È particolarmente significativo il rapporto fra il responso e il giudizio (*respondere-iudicare*)

> L'incidenza che le opinioni dei giuristi, e quindi l'*interpretatio prudentium*, aveva sulle decisioni dei tribunali emerge, in particolare, dalle parole che Cicerone rivolge al suo avversario nell'orazione *pro Caecina* (pronunciata in una causa di *ius civile* riguardante il possesso di un fondo)

(Testo pag.195-196)

All'affermazione dell'avversario che non bisogna sottomettersi all'autorità dei giuri consulti, Cicerone, naturalmente in disaccordo, la giudica come inopportuno e contraria.
Allarga poi il discorso a tutti coloro che abitualmente sostengono nei tribunali che i pareri dei giuri consulti non debbano prevalere nelle controversie giudiziarie;
- Nel caso in cui questi ritengano che i giureconsulti abbiano stabilito qualche erroneo principio di decisione, allora, dice Cicerone, dovrebbero arrivare alla conclusione che a loro non bisogna dar ascolto, ma piuttosto che non bisogna dare ascolto a persone irragionevoli.
- Nel caso, invece, in cui ritengano che i giureconsulti hanno dato un responso opportuno, ma sostengono che bisogna giudicare in modo diverso, allora è come se volessero che si pronunci una cattiva sentenza.

Secondo Cicerone infatti non è possibile che in relazione ad un punto di diritto si debba iudicare in un modo e respondere in un altro, viceversa non è possibile che sia considerato un giurisperito chi enuncia un principio giuridico secondo cui non si debba pronunciare la sentenza.

In effetti, è accaduto che si siano pronunciate sentenze in contrasto con il parere dei giureconsulti, ma bisogna capire se si è aggiudicato bene o male:
- se si è aggiudicato bene, allora il diritto si riconosce in ciò che è stato stabilito con il giudizio.
- se sia giudicato male, è chiaro che sia da biasimare il giudice.

Nel caso in cui, però, la sentenza riguardi un punto controverso del diritto, allora non si è deciso in contrasto con i giureconsulti sì sì è considerata l'opinione di uno piuttosto che di un altro.
Lo stesso Crasso non difese la sua causa davanti ai centumviri in modo da condurre un attacco contro i giureconsulti, ma in modo da dimostrare che quanto sosteneva Scevola non era conforme al diritto. Egli non solo portò argomenti a sostegno della sua tesi, ma si servì dei pareri di Quinto Mucio, suo suocero, e di altri autorevolissimi esperti

Cataloghi normativi

> Data l'importanza del respondere, non è un caso che l'interpretazione dei giuristi sia considerata come una fonte di produzione del diritto, e quest'aspetto emerge in maniera evidente attraverso una serie di brani che definiamo "cataloghi normativi", in particolare di Cicerone, Pomponio, Gaio e Papiniano, all'interno dei quali, quelli giuristi vanno a formulare degli elenchi veri e propri delle fonti di produzione normativa. (ricordiamo distinzione norma-legge)

1- Il primo catalogo normativo è quello di **Cicerone**.

> Con Cicerone siamo nel I secolo a.C. (muore nel 43 a.C): periodo tardo repubblicano.

> Innanzitutto proprio perchè di Cicerone, che non è un giurista ma un oratore, è una fonte atecnica:
Definiamo *tecniche* tutte quelle fonti di conoscenza storica del diritto che sono scritte da specialisti del diritto (i giuristi), in ambito di opere giuridiche.

- Cicerone non è un giurista, in quanto oratore è solo un pratico del diritto.
(Tant'è che per le sue arringhe, per saper come strutturare la causa, si rivolgeva al suo amico, giurista, Servio Sulpicio Rufo con cui tra l'altro ci è pervenuto un epistolario)

- Di conseguenza le fonti ciceroniane si possono considerare *letterarie* o *atecniche*, ma non meno importanti al fine di ricostruire il diritto in un determinato momento storico, che in questo caso è quello della tarda repubblica.

> Questo elenco è tratto dai Topica, un'opera di retorica di Cicerone.

La retorica è quell'arte (estremamente importante per l'oratoria) che prevede lo studio dei luoghi dell'argomentazione e quindi dei mezzi per essere più persuasivi nelle argomentazioni.

- Questo suo elenco normativo, infatti, si inserisce come esempio in un discorso più ampio:

(Analisi del testo pag.197)

Cioè Cicerone sta spiegando che quando vogliamo capire meglio un argomento, la definizione può avvenire per enumerazione e per analisi, nel primo caso, la definizione dell'argomento stesso può essere sciolta individuando le parti di cui l'argomento si compone;

- Capiamo allora che sta parlando di un logo della retorica e non di diritto, ma per fare un esempio della definizione ottenuta per enumerazione, cita la definizione di ius civile.

> Questo è un elemento estremamente importante, in quanto ci fa comprendere appieno di cosa è composto il *ius civile* (inteso come ordinamento della città) in età repubblicana, e quindi quali sono le molteplici fonti considerate come fonti di produzione di *ius civile*.

> E quindi il diritto civile non comprende solo le leggi, ma oltre a queste anche:

- Le leggi
- I senatoconulti
  (che sono gli atti del Senato)
- Le decisioni giudiziarie
  (e quindi le sentenze dei processi emanati dai giudici che comunque fanno diritto, creano diritto)
- Autorità dei giuristi
  (e quindi vediamo *l'interpretatio prudentium*, quindi *l'auctoritas*, che è un elemento che caratterizza il giurista repubblicano, come fonte di produzione normativa).
- Gli editti dei magistrati
  (gli editti dei magistrati con giurisdizione: editti dei pretori)
- Il costume
- L'equità

Quindi le caratteristiche di questo catalogo di Cicerone sono:

1- Il richiamo ai *mores.*

Siamo nell'ambito della Repubblica e sappiamo che il fil Rouge della Repubblica è il tradizionalismo, quindi notiamo questi *mores* che vengono richiamati da Cicerone proprio nell'ambito di una mentalità molto tradizionalistica quale quella repubblicana.

2- Il riferimento all'equità:

Qui dobbiamo stare attenti poiché equità non ha accezione etica di equità\ di giusto, ma significa *equità del caso concreto e non nel senso salomonico\ Greco*: ma con equità ci si riferisce alla razionalità che richiede la soluzione di un caso concreto che è quello che viene applicato dei giuristi.

Quindi equità come "elemento giuridico di equità del caso concreto",

2- Il secondo catalogo normativo è quello di **Pomponio**

> Con Pomponio non siamo più in età repubblicana, ma in età classica (circa due secoli dopo Cicerone)

- Vediamo infatti che tra le fonti normative, rispetto a quelle nominate da cicerone, compaiono anche le costituzioni imperiali.

> Pomponio è un giurista d'età Antonina e lo si colloca nella metà del II secolo d.C.

(È un giurista che viene richiamato molto spesso, e non dobbiamo confonderlo quando lo troviamo accanto a Quinto Mucio Scevola, giurista tardo-repubblicano, perchè Pomponio ne fece uno dei più importanti commenti: il commento *ad Quintum Mucium;* Grazie al quale oggi conosciamo l'opera muciana; Oppure, sempre associato a Quinto Mucio Scevola, Pomponio è richiamato in relazione all'episodio dell'atteggiamento oracolare, che si trova nell'Enchiridion, che è una sorta di storia anche della giurisprudenza romana.)

> Il catalogo normativo di Pomponio, siamo quindi nel II secolo d.C., in piena età classica (l'età di fioritura della giurisprudenza) è molto rilevante perché tra tutti è quello che consacra proprio come fonte primaria del *ius civile* l' interpretazione dei giuristi: ed questo è il senso di *ius civile* nella sua seconda accezione (cioè *ius civile* in riferimento al diritto *sine scripto*: che senza essere scritto viene prodotto dall'*interpretatio prudentium*).

(Analisi del testo pag.197-198)

Nel suo elenco normativo distingue:

- Il diritto "legittimo: quello prodotto dalle leggi o dagli atti assimilabili alla legge, di cui fa un elenco: (plebiscito, senatoconsulto, *ius honorarium* e quindi l'editto pretorio e poi, in più, le costituzioni imperiali)
- Il diritto civile in senso proprio\ stretto, nel testo latino dice proprio *"porprium ius civile"*: che consiste nella sola interpretazione dei giuristi senza tradursi in norme scritte.

> Vediamo, quindi, come liberamente sta dando molta rilevanza alla produzione normativa che viene attraverso l'interpretazione dei giuristi.

- Dopodiché fa riferimento alle legis actiones

Cioè afferma che il diritto si produce anche attraverso il processo, e inoltre, dal fatto che cita questo tipo di processo, che ormai a suo tempo da secoli non si svolgeva più (era stato infatti abolito da Augusto nel 17 a.C.) riconosciamo anche qui una forma di tradizionalismo.

La caratteristica di questo catalogo normativo:

Sta nella distinzione tra diritto legittimo e diritto civile in senso proprio (che consiste nell'interpretazione dei giuristi, di cui Pomponio vuole esaltare la funzione normativa in quanto proprio attraverso l'interpretazione i giuristi creano norme senza che si traducano in scrittura come previsto per le leggi)

3- Il terzo catalogo normativo è quello di **Gaio**

> Gaio è un altro giurista di età Antonina, ma successivo, di poco, rispetto a Pomponio, (vive nella seconda parte del II secolo d.C.) ed è celebre per l'opera istituzionale isagogica dedicata ai primi anni e ai primi elementi del diritto che sono le *Institutiones*.

> Anche Gaio è autore di un commento all'editto però all'editto provinciale, poiché era un giurista provinciale, e fu anche uno dei pochi autori a commentare le 12 tavole. (prima di lui Labeone)

(Analisi del testo pag. 198)

Gaio parla di sfere normative del popolo romano, dice proprio "iura populi romani":
Per cui capiamo che, al contrario di quanto avviene a partire dallo sviluppo della mentalità legalistica, non c'è solo la legge, ma ci sono delle vere proprie sfere normative che lui elenca, e riconosce:

> Leggi - Plebisciti - Senatoconsulti - Costituzioni imperiali - Editti di coloro che hanno la facoltà di comunicare al popolo ordinanze e direttive (editti dei magistrati) - Responsi dei giuristi

Quindi, anche Gaio fa riferimento all'interpretazione dei giuristi come sfera normativa, ma giungere all'evento importante; Quando dice:
"Se i pareri di tutti costoro sono univoci, il principio giuridico così affermato tiene il luogo di una legge. Se invece divergono, il giudice è libero di orientarsi fra le soluzioni proposte. Questo fu sancito dal riscritto del divino Adriano."

Le caratteristiche di questo catalogo stanno proprio qui:

1- questo è l'unico a catalogo normativa in cui si fa riferimento allo ius edicendi, in particolare, dice proprio "coloro che furono autorizzati a produrre diritto", e cioè fa riferimento allo *ius publicae respondendi* (ovvero allo *ius edicendi ex autoritate principis*)

> Questo è un altro elemento importante per comprendere quanto cambi la figura del giurista con l'avvento del il principato:

- Non conta più *l'auctoritas* come cifra della persona del giurista di età repubblicana.
- Ma *l'auctoritas* del giurista è mediata dall'*auctoritas* del principe che, astutamente, è consapevole di quanto la figura del giurista sia importante per la produzione del diritto, e quindi da un lato vuole controllare la loro produzione, dall'altro lato vuole giovarsi della loro sapienza tecnica.

  Per cui individua i giuristi migliori e, in qualche modo, adulandoli anche con cariche pubbliche come i consolati, cerca di farseli amici.

  A coloro i quali si avvicinano al principe, che successivamente faranno parte del *consilium principis*, viene fornito dall'imperatore il diritto di emanare *responsi ex autoritate principis*, e quindi consacrati dall'autorità del principe che recano proprio il sigillo imperiale.

  (è chiaro che comunque tutti i giuristi emanavano responsi, ma nell'ambito di un processo, il giudice tendeva a propendere per il parere espresso dal giurista che in qualche modo aveva il placet del principe)

2- un altro elemento importante in questo catalogo e riferimento allo ius controversum
Ovvero, quando più giuristi interpretano lo stesso oggetto, possono avere delle opinioni contrastanti, E quindi possono proporre delle soluzioni pratiche differenti l'una dall'altra, pur essendo ugualmente plausibili. (non che si sfociasse in una lite, ma semplicemente nella produzione del diritto, attraverso l'interpretazione dei giuristi, non sempre ci sono gli spazi concordi: e questo è lo ius controversum)
Con Adriano, però, che è uno degli imperatori più importanti, sia l'elaborazione dell'editto perpetuo; da quel momento in poi, cessò di esistere lo ius controversum

Infatti Gaio dice:

- nel momento in cui le opinioni dei giuristi su un determinato caso sono tutte convergenti, tengono il ruolo della legge (hanno forza di legge\ il giudice deve tenerne conto come se fosse una legge)
- tuttavia, se invece capita che vi sia un responso discordante dall'altro, è il magistrato che ha la facoltà di scegliere l'uno all'altro.

4- Il quarto catalogo normativo è quello di **Papiniano**
Emilio Papiniano È un giurista tardo-classico
Papiniano è considerato tra i "maestri" (fu maestro di Paolo e Ulpiano), fu anche il prefetto del pretorio sotto Caracalla, e pare che fu proprio lui a redigere la costituzione antoniniana, che estendeva la cittadinanza romana a tutto l'impero (nel 212 d.C.).
Fu proprio per mano di Caracalla che morì, infatti, non essendo d'accordo con la sua politica, Caracalla lo fece uccidere. In ogni caso è considerato tra i più grandi giuristi.

Con questo catalogo normativo siamo alla fine dell'età classica, sotto la dinastia dei severi, e dobbiamo considerare che ormai non si parla più di editti dei magistrati, ma si parla di un vero e proprio corpo normativo (l'editto perpetuo redatto sotto Adriano) che bisogna distinguere dagli ius civile:

(Analisi del testo pag.198)
Papiniano distingue:
- Il diritto civile: che è quello che nasce dalle leggi, dei plebisciti, dai Senato consulti, dai decreti degli imperatori, dall'autorità dei giuristi.
- Il diritto pretorio (*ius praetorium\ honorarium*) che definisce come il diritto che i pretori introdussero nell'interesse pubblico per rafforzare il diritto civile, oppure per completarlo o correggerlo.

È proprio questa la caratteristica del catalogo di Pomponio:
1- La distinzione tra ius civile e ius honorarium, con una vera e propria definizione di diritto pretorio:
Cioè afferma che l'editto pretorio, che ormai è un corpo normativo distinto dallo *ius civile*, nasce proprio per rafforzare, aiutare il diritto civile, in un certo senso per completarlo (nel momento in cui va ad aggiungere gli istituti che mancano al diritto civile), o addirittura per correggerlo: cioè il pretore crea anche istituti (ad esempio la *bonorum possessio*) che apportano delle correzioni allo *ius civile* in ambito processuale.

2. Oralità e forma letteraria

La dimensione del responso era l'oralità

Al giorno d'oggi, noi siamo abituati a pensare al diritto nella sua forma scritta, codificata, racchiuso nel raccolte legislative.
Sarebbe sbagliato pensare che nel mondo classico, in particolare nel mondo romano della Repubblica, la realtà testuale del diritto venga ignorata (pensiamo ad esempio alle leggi e al programma del pretore, che pur non nascendo come testi, lo diventavano nel proprio processo formativo; Ma anche i testi giuridici che via via si raccoglievano nelle biblioteche trasmettendosi attraversando vicende alterne e secolari — in una similitudine pseudo-plutarchea, addirittura, si afferma che quei libri hanno lo stesso valore che gli attrezzi agricoli hanno per il contadino, vanno tenuti insieme allo stesso modo, e per loro mezzo attingiamo il sapere alla sua fonte);

> Sicuramente il mondo repubblicano non ignora una realtà scritta, documentale, ma sfrutta lo scritto in maniera minore, perché il diritto sfugge ad una iniziativa codificatore\ ad un allestimento di testi normativi.
- La giurisprudenza si esprime per lo più in consigli per lo più oralmente formulati; quindi, abbiamo una trasmissione ai discepoli anche nel senso dell'insegnamento, un corpo di dottrine che non sono irrigidite dalla pagina scritta, ma sono frutto di conversazione, dialogo, confronto talvolta competitivo, agonistico.

Il responso, quindi, è un atto fondamentalmente orale (così come anche il responso religioso, tant'è che gli auguri, per esempio, affidavano i loro responsi, più che ai libri, alla memoria dei concittadini), ma la redazione di un documento, poteva rivelarsi indispensabile nel momento in cui vi era una controversia giudiziaria e c'era la necessità di comunicare con il giudice:
- O lo stesso giurista scriveva al giudice.
- Oppure il privato interrogante si assicurava, per mezzo di testimoni, la possibilità di dimostrarne il carattere autentico.
> solo in epoca imperiale, quando il responso fu subordinato all'autorizzazione del principe, i giuristi diedero i *responsa signata* (garantiti dal sigillo)

Quando veniva pronunciato, il responso non aveva alcun bisogno di essere motivato, tuttavia argomentazioni e motivazioni si rendevano subito necessarie qualora il caso ed il responso stesso venivano tecnicamente discussi: per cui la *consultatio* poteva dar luogo ad una *disputatio*

Cioè si tratta di un pensiero in movimento, dinamico, anche che parte dalla sollecitazione di una situazione giuridica concreta che può dare adito, nel momento del responso, alla ricerca di una soluzione più adeguata, e poi può anche dare adito al docēre, al momento della controversialità anche.
E tutto ciò sfugge da piramidi concettuali, da concettualizzazioni eccessive.

- Spesso la curiosità\ perplessità di un ascoltatore, o l'esigenza di controbattere un avversario reale o ipotetico, o ancora quando il giureconsulto si trovava a svolgere il ruolo del consigliere, si creava un vero e proprio dibattito che spesso comportava anche una ricerca di casi analoghi e di precedenti giurisprudenziali: e qui la memoria* assume, per la tecnica giuridica, una grande importanza.

* Vedremo come l'antologia di Alfeno Varo, la raccolta dei Digesta, di responsi del duo maestro, sarà proprio il frutto di una memorizzazione quotidiana del rapporto con i discepoli.
Quindi la memoria del giureconsulto è simbolica\ significativa non solo di una dimensione dell'oralità, ma anche proprio di una qualità intrinseca che veniva coltivata affinché il giurista fosse in grado di ritrovarsi a fare da guida alla società perché veniva interpellato in qualunque ambito e doveva fornire le soluzioni immediatamente scavando nel proprio sapere che quanto più era enciclopedico (es. Servio Sulpicio Rufo) tanto più si prestava a consigli di tipo prudenziale, di saggezza e quanto più era specialistico tanto più imponeva rispiate alto tecniche e precise.

> Possiamo vedere il responso, oltre che come un atto pratico, come una ***forma letteraria***: dalla pratica consultiva nasce, infatti, una letteratura, ma il passaggio non è immediato:
- I responsi di *Tiberio Coruncanio* erano "memorabili" ancora nell'età di Adriano, ma egli non scrisse libri.
- *Caio Aquilio Gallo* non affidò alla scrittura le sue decisioni di giurista consulente, ma esse non si persero.

> Inoltre il responso anche nella sua versione scritta può conservare qualche segno dell'origine orale:
- I *libri giuridici* di *Catone* e di *M. Giunio Bruto* non avevano eliminato del tutto i nomi degli interroganti.

Questo dettaglio, fece sorgere un dibattito:

- Cicerone, nel De Oratore, attraverso personaggio di Antonio, sostiene che il motivo per cui si mantengono i nomi è di *farci credere che il punto essenziale della consultazione e del dubbio risieda nelle persone e non nei fatti* , in modo da abbandonare ogni volontà di apprendere e padroneggiare il diritto, perché il numero delle persone è infinito, e solo i fatti sono riducibili alle loro caratteristiche generali. Ma questa è solo un'arguta insinuazione, diretta ad alimentare la polemica contro i giuristi.

- La vera ragione, se una ragione c'era, stava piuttosto nella volontà di riprodurre fedelmente il caso accaduto per non avere una visione falsa della *quaestio* e dei suoi motivi.

Letteratura casistico-problematica: I Digesta (di Alfeno Varo)

> Quando si parla di letteratura che deriva dal responso, in cui il responso trova una sua compiuta decantazione scientifica, si parla di letteratura *casistico-problematica.*

È in questa letteratura che defluiscono i responsi dei giuristi, e "casistico-problematica" sta proprio significare che c'è il caso, e c'è il problema, in quanto dal caso concreto si arriva all'individuazione del problema più ampio (il problema giuridico) che poi porta al quesito e poi naturalmente all'interpretazione giurisprudenziale e infine alla soluzione del caso proposto.
Troviamo le prime tracce di questa letteratura proprio presso la scuola Serviana.

(Vedremo come l'antologia di Alfeno Varo, la raccolta dei Digesta, di responsi del duo maestro, sarà proprio il frutto di una memorizzazione quotidiana del rapporto con i discepoli.
Quindi la *memoria del giureconsulto* è simbolica\ significativa non solo di una dimensione dell'oralità, ma anche proprio di una qualità intrinseca che veniva coltivata affinché il giurista fosse in grado di ritrovarsi a fare da guida alla società perché veniva interpellato in qualunque ambito e doveva fornire le soluzioni immediatamente scavando nel proprio sapere che quanto più era enciclopedico (es. Servio Sulpicio Rufo) tanto più si prestava a consigli di tipo prudenziale, di saggezza e quanto più era specialistico tanto più imponeva rispiate alto tecniche e precise.)

Servio Sulpicio Rufo

Servio Sulpicio Rufo si cala appieno nello scenario ormai sviluppato del diritto laico (vedi ad esempio "atteggiamento oracolare" con Scevola).
- Per quanto riguarda la sua formazione, secondo Cicerone, questa rientrava ancora in quel sapere totalitario o enciclopedico che Cicerone stesso aveva intrapreso, per cui riteneva che Servio fosse davvero un grande giurista di cui, peraltro, aveva conoscenza e che, inoltre, era bravo anche nell'arte dell'oratoria, secondo solo dopo Cicerone.
- Presso Servio, però, la pratica del responso era molto importante:
Abbiamo attestazione che Servio raccogliesse attorno a se una cerchia di auditores (coloro che ascoltavano\ apprendevano attraverso l'ascolto), quindi degli allievi, che dialogavano con il maestro.
Era un insegnamento proprio "sul campo": di continua dialettica tra maestro e allievi.
Con questi auditores naturalmente si discuteva di casi concreti e venivano date una molteplicità di risoluzioni;
Quindi già l'impostazione ci fa capire che il responso non era più quello che si richiedeva recandosi presso il seggio del pontefice, del giurista, solennemente, ma qui era un responso dovuto ad un dialogo, ad una dialettica.

È pur vero che nel momento della sua emanazione il responso non aveva bisogno di essere motivato, ma nel momento della sua discussione nascevano argomentazioni ulteriori che arricchivano di sfaccettature la discussione del caso pratico e una realtà vivace si rifletteva proprio nella descrizione minuta dei particolari che potevano costituire degli elementi rilevanti per altre possibilità di risoluzione.
- Quindi l'arricchimento del quadro, la descrizione minuta dei particolari, il rilievo rispetto a profili particolari, era tutto funzionale a fornire degli elementi utili al ragionamento, alla ricerca delle soluzioni che non sempre sono univoche, ma ce ne possono essere molteplici.
Di fatto, le prime tracce di questa letteratura che si qualifica come casistico-problematica le si trovano, appunto presso la scuola serviana, in cui gli allievi\ auditori di Servio raccolgono i responsi del maestro racchiudendoli in una letteratura che prende il nome di *Digesta* (da digērere significa proprio ordinare\ raccogliere in modo ordinato).
Tra gli allievi risaltano i nomi di Alfeno Varo, Aufidio Namusa e Aulo Ofilio.
(Precisiamo che quindi questi digesta non sono di Servio; Di una letteratura di Servio in effetti non abbiamo tracce, pero troviamo molto di suo grazie alla letteratura prodotta dai suoi allievi\ auditores)
> In particolare i digesta di Alfeno Varo sono i più importanti.
La scrittura alfeniana è ben riconoscibile:
Nell'evidenza descrittiva, nella vigorosa plasticità, nella icastica ricchezza dei particolari.
Il discorso tecnico rigoroso, con le categorie e le ipotesi, si sviluppa da una rappresentazione dettagliatissima del fatto concreto, in cui ricorrono elementi arcaici e anche una reminiscenza del parlare quotidiano. È uno stile unico, che non verrà più incontrato nella letteratura più tarda.

3. Profili metodici

La struttura dell'esposizione è triadica: sono distinguibili tre parti:
1 - Descrizione del caso
2 - Quesito giuridico
3- Responso

> Sono questi profili metallici che si ritrovano in tutta la letteratura che racchiude responsi dati da Servio Sulpicio Rufo presso la sua scuole, e raccolti dai suoi auditores all'interno della letteratura dei Digesta.

(Testo pag. 202) - primo responso serviano

1- In un vicolo, di notte, un tavernaio mise una lucerna su una pietra; un tale, passando, la tolse via; il tavernaio, inseguitolo, reclamava la lucerna e cercava di trattenerlo nella fuga; l'altro, con uno staffile che aveva in mano, cominciò a percuoterlo perché lo lasciasse andare; la lite crebbe, e il tavernaio cavò un occhio all'uomo che aveva preso la lucerna.

2- Il quesito era se non si dovesse escludere la responsabilità del tavernaio, poiché lui per primo era stato percosso con lo staffile.

3- Risposi che il danno non gli era imputabile, posto che egli non avesse cavato l'occhio con un'azione preordinata a questo fine: la colpa dell'accaduto stava dalla parte di colui che per primo aveva colpito con lo staffile. Ma se il tavernaio non le avesse prima buscate, ma avesse iniziato la colluttazione, volendo strappare all'altro la lucerna, la colpa si sarebbe dovuto attribuirla a lui.

1- Descrizione del caso

Quasi con il realismo proprio del romanzo o della commedia, Alfeno, nella prima parte descrive il caso permettendoci di immaginare la scena presentata:

- La vicenda si svolge di notte, quando, un tavernaio mise una lucerna su una pietra affinché illuminasse la zona innanzi alla sua taverna.
- Ad un certo punto, improvvisamente, un tale passando gliela rubò e scappò.
- Nel tentativo di riprendersela, il tavernaio iniziò a rincorrere il ladro, reclamando la lucerna e trattenendolo nella fuga.
- Ebbe inizio una colluttazione: il ladro, infatti, cercando di divincolarsi, iniziò a percuotere il tavernaio con uno staffile (un bastone), affinché quest'ultimo lo lasciasse andare, ma la lite crebbe a tal punto che il tavernaio cavò un occhio al ladro.

2- Quesito Giuridico

Il tabernacolo, preoccupato, andò a consultare il giurista domandandogli se avrebbe potuto incorrere in una responsabilità, cioè se ci fosse stata la possibilità che ladro intentasse un'azione contro di lui per il danno procuratogli (l'occhio cavato), considerando, comunque, il fatto che da una parte si era semplicemente difeso dal furto, e dall'altra era stato lui il primo ad essere stato percosso.

3- Responso

Servio dunque dice che a suo parere, il danno non era imputabile a tavernai, ma solo se si erano verificate delle condizioni specifiche: cioè era necessario che il tavernaio non avesse cavato l'occhio per intenzione preordinata (cioè che non era sua intenzione precisa che avere l'occhi al ladro) e quindi che quest'azione fosse stata solo una degenerazione della lite.
Solo stando a queste condizioni la responsabilità per ciò che era accaduto stava dalla parte di chi per primo aveva iniziato la colluttazione.
Ragionando ancora sul caso, emergono altre ipotesi:
Se il tavernaio non fosse stato percosso per prima, ma fosse stato lui ad aver iniziato la lite volendo riprendersi la lucerna, in questo caso sarebbe incorso in delle responsabilità.

- Notiamo che il responso è argomentato, il ragionamento che porta la soluzione viene a galla, quindi ci sono le due ipotesi, la ricerca della colpa, e quindi è proprio il caso che diviene problema, e la discussione di questo problema spinge a moltiplicarne le varianti.

> In particolare, approfondendo questo caso, possiamo sottintendere che il danno qui descritto rientrerebbe nell'ambito dei casi disciplinati della ***Lex Aquilia de damno.***
> Riconducibile al III secolo a.C., questa legge riguardava il ferimento e l'uccisione di schiavi o animali o la distruzione e il danneggiamento di cose inanimate.

- Tuttavia per poter applicare questa legge Aquilia in questo caso, e quindi regolare la responsabilità del danno sulla base di un'*actio legis Aquiliae*, si dovrebbe supporre che il ladro fosse uno schiavo; Solo in tal caso, se fosse stato in torto il tavernaio, la sua responsabilità per l'occhio cavato sarebbe stata considerata in base alla *lex Aquilia*.
- Ma dal testo non si evince che fosse uno schiavo, per cui si apre l'ipotesi (meno accreditata) del delitto di ***iniuria***: che è un atto di illecito privato, che è un tipo di illecito che si rivolge non agli schiavi (considerati *res*) o agli animali, ma rivolto genericamente alle persone con *damnum corpore corpori datum*, cioè un danno materialmente inferto attraverso un colpo dato, un danno provocato materialmente.

> Per cui, nel caso del furto della lanterna, dato che ovviamente siamo nell'ambito della disciplina privatistica, dobbiamo pensare che il tavernaio si preoccupasse di incorre o nella responsabilità della *lex aquilia* (posto che il danno sia stato inferto ad uno schiavo, elemento che qui non è stato precisato) o al delitto di *iniuria*, e quindi al danno inferto alla persona nella fisicità propria dello scontro.

(Testo pag. 204) - secondo responso serviano

1- Su per la salita del Campidoglio, delle mule trainavano due carri a pieno carico; i mulattieri si sforzavano di sostenere da dietro il primo carro, affinché le mule lo trainassero più agevolmente; questo cominciò a retrocedere; i mulattieri che erano fra i due carri si tolsero di mezzo, e il secondo carro, urtato da quello che lo precedeva, arretrò e travolse uno schiavo.

2- Il proprietario dello schiavo pose il quesito, contro chi dovesse agire in giudizio.

3- Risposi che la soluzione giuridica dipendeva dalle modalità del caso concreto.

1ª ipotesi

Se i mulattieri che sostenevano il primo carro si sono volontariamente allontanati, e perciò è accaduto che le mule non riuscissero più a trattenerlo, e anzi fossero trascinate indietro dal peso, non c'è a mio parere nessuna azione contro il proprietario delle mule, ma è invece possibile agire in base alla legge Aquilia contro i mulattieri che avrebbero dovuto sostenere il carro: non diversamente è responsabile per il danno chi abbandona con atto volontario ciò che trattiene, in modo da provocare un ferimento: si può fare l'esempio di colui che non tenga più a freno l'asino dopo averlo spinto a correre, o di colui che lanci un dardo o altro.

2ª ipotesi

Se invece le mule adombrandosi <sono indietreggiate >, e i mulattieri hanno lasciato il carro per il timore di esserne schiacciati, l'azione non è esperibile contro di loro, bensì contro il proprietario delle mule.

3ª ipotesi

Sè poi né le mule né gli uomini sono in questione, ma quelle non hanno potuto trattenere il carico, o nello sforzo sono sdrucciolate e cadute, e perciò il carro è retrocesso e i mulattieri, sotto la sua spinta, non hanno più potuto reggerne il peso, non c'è azione né contro il proprietario delle mule né contro i mulattieri.
Quel che è certo, comunque siano andate le cose, è che non si può agire contro il proprietario delle mule del secondo carro, perché queste non retrocessero spontaneamente, ma per l'urto subito.

> Vediamo un esempio un po' più articolato:
- Notiamo innanzitutto la struttura descrizione del caso-quesito-responso.
- Ma qui vediamo che il responso acquista uno spazio più importante perché si articola in tutta una serie di ipotesi di risoluzioni del caso, che variano in relazione ad una serie di elementi presi in considerazione.
Capiamo bene, allora, che Servio fosse proiettato in una modalità del *respondere* che non è affatto laconica o oracolare, ma dialettica, sciolta: tutta l'argomentazione viene a galla ed il ragionamento è assolutamente limpido e trasparente. "Lo si tocca con mano".

> *Descrizione del caso:*
- Dobbiamo immaginare la salita del campidoglio che viene attraversata da due carri a pieno carico;
- Dietro il primo carro ci sono dei mulattieri che aiutano il carro nella salita per far in modo che le mule possano salire più facilmente;
- Dietro il secondo carro c'è uno schiavo.
- A un certo punto succede che il primo carro comincia ad andare indietro, i mulattieri che stavano in mezzo (dietro al primo carro e davanti al secondo) si sfilano.
- Quindi il primo carro urta il secondo carro, e questo travolge lo schiavo che ne stava dietro.
- Lo schiavo quindi viene ferito.

> *Quesito giuridico:*

Lo schiavo è una *res*, è un bene, per cui il danno inquadrato è subito dal proprietario dello schiavo, che è infatti colui che pone il quesito a Servio chiedendo contro chi dovesse agire in giudizio.
(Essendo stato inferto un danno ad uno schiavo, ovviamente, interviene la legge Aquilia)

> *Poi c'è subito il responso:*

Servio afferma che la soluzione dipendeva dalle modalità del caso concreto:

1- La *prima ipotesi* pone il caso che i mulattieri che si siano volontariamente allontanati dal carro che stavano sostenendo, e a seguito di questo allontanamento le mule non siano più riuscite a trattenere il carro, per cui abbiano iniziato ad indietreggiare.
- E in tal caso il proprietario *deve agire nei confronti dei mulattieri* a cui è imputabile la responsabilità, e che dovrebbero quindi risarcire il danno.

> In relazione al modo in cui si articola questa prima ipotesi possiamo evidenziare l'uso di alcuni ***espedienti espositivi***\ strumenti argomentativi (ricordiamo anche l'abilità e le conoscenze di Servio Sulpicio Rufo in campo dialettico e retorico), in questo caso riconosciamo:
- La comparazione\ ***l'analogia*** (che serve a rendere più efficace l'argomentazione): infatti dice *"non diversamente…"* e poi fa un ***esempio***, e dice che " lo stesso varrebbe per colui che non tiene più a freno l'asino dopo averlo spinto a correre oppure di colui che lanci un dardo o altro".

- Quindi il comportamento dei mulattieri che si sottraggono volontariamente al proprio compito, è analogo\ paragonabile <u>*sia*</u> a quello di colui che ad esempio lancia un dardo e non si preoccupa di dove questo dardo vado a finire, non curante, quindi anche degli effetti che questo possa provocare (ad esempio ferire qualcuno), <u>*sia*</u> a quello di colui che libera un asino lasciandolo correre, non curante del fatto che l'asino possa comunque travolgere qualcuno o provocare danni.

> E quindi per spiegare questa prima ipotesi si fa un'analogia, e si portano degli esempi per spiegare una situazione di voluta sottrazione dei mulattieri al proprio compito senza preoccuparsi delle conseguenze.

2- Una *seconda ipotesi* pone il caso che siano state le mule ad adombrarsi e allontanarsi, per cui i mulattieri si siano allontanati per paura di essere schiacciati, di conseguenza le mule non sono più riuscite a trattenere il carico, e dallo sforzo sono cadute provocando la retrocessione del carro che ha poi travolto lo schiavo.
> In tal caso la responsabilità cade sul proprietario delle Mule, e quindi l'azione è intentabile contro il proprietario delle mule.

3- Una *terza ipotesi* vede invece la possibilità che né le mule né gli uomini siano riusciti semplicemente a trattenere il carico; quindi per cause di forza maggiore, data la troppa pesantezza del carro, le mule non siano riuscite a reggere il peso e siano cadute, e così facendo neanche i mulattieri siano riusciti a svolgere correttamente il loro compito.
> E il proprietario dello schiavo non può agire né contro il proprietario delle mule, né contro i mulattieri.

> In <u>*conclusione*</u> specifica che comunque siano andate le cose non si può agire contro il proprietario delle mule del secondo carro, poiché se hanno retrocesso è stato per l'urto subito.

> Questo passo ci da proprio l'idea di come si articoli il responso serviano, considerando le modalità del caso concreto, e notiamo anche come si avvalga di strumenti espositivi, come ad esempio l'analogia, per spiegare ulteriormente alcune ipotesi.

(Testo pag. 206) - terzo responso serviano (non spiegato dalla prof.ssa)

1- Più commercianti avevano caricato il grano nella nave di Saufeio, stivandolo alla rinfusa. Saufeio aveva restituito, dal catico comune, il grano a uno dei commercianti caricatori; poi la nave è affondata.

2- Si pone il quesito, se gli altri commercianti caricatori possano agire nei confronti dell'armatore, per la loro parte di grano, con l'«azione per la sottrazione di carico».

3- Il responso fu in questi termini.
Due sono i generi degli assetti locativi, in quanto o ci si obbliga a restituire la stessa cosa ricevuta in consegna (come quando siano locati dei vestiti a un lavandaio perché ne prenda cura), o ci si obbliga a restituire una cosa dello stesso tipo (come quando si dia dell'argento fuso a un artigiano, perché ne faccia dei vasi, o dell'oro, perché ne faccia degli anelli).
Nella prima ipotesi, la cosa rimane in proprietà dell'affidante;
nella seconda ipotesi, sorge in capo all'alienante un diritto di credito.
Lo stesso quadro giuridico si ha nel deposito: se si deposita del danaro contante, senza consegnarlo chiuso e sigillato, ma semplicemente contandolo, il depositario a nient'altro è tenuto che alla restituzione di una somma eguale. Secondo quanto si è detto, nel caso nostro, il grano è stato acquistato in proprietà da Saufeio, ed è stato validamente trasferito.
Se invece il grano fosse rimasto in proprietà di ognuno dei commercianti caricatori - diviso in scomparti, chiuso per mezzo di tavole o in ceste o in barili in modo da poter distinguere ogni singolo carico - allora noi non avremmo potuto «permutare» un carico con l'altro; e quanto al commerciante caricatore, proprietario del grano che l'armatore ha restituito, egli sarebbe legittimato a esperire l'azione di revindica.
Perciò, secondo Servio, non è possibile ammettere l'esercizio dell'«azione per la sottrazione di carico»: perché delle due l'una: o le merci consegnate all'armatore sono tali, che egli ne divenga immediatamente proprietario, e al commerciante caricatore spetti solo un diritto di credito verso di lui, e allora non c'è sottrazione di carico, appartenendo quest'ultimo all'armatore;
o deve essere restituita la medesima cosa che è stata consegnata, e allora il locatore (ossia, il commerciante caricatore) può esercitare l'azione per il furto, ed è quindi superflua l'«azione per la sottrazione di carico». Ma, posto che la dazione della cosa si configuri in modo tale, che sia possibile restituire una cosa dello stesso tipo, il conduttore (Ossia, l'armatore) è responsabile solo per colpa (infatti, in un rapporto che si costituisce contrattualmente nell'interesse di entrambe le parti, si ha solo responsabilità per colpa);
né nel nostro caso, vi è colpa, per il fatto che il conduttore ha restituito a uno dei commercianti caricatori la sua parte del frumento comune. E la ragione è questa: era pure necessario che il conduttore, nel compiere la restituzione, cominciasse da uno qualunque di loro; sebbene egli, così facendo, non è né se migliora la condizione giuridica rispetto agli altri.

> In questo responso non siamo più nell'ambito di una casistica “cittadina”, ma lo scenario del caso in questione è commerciale, relativo a traffici marittimi, e compaiono le figure negoziali dello *ius gentium*.
- lo scenario che qui fa da sfondo al responso, rappresenta appieno ciò in cui ormai il diritto si è trasformato, è una dimensione più aperta, ormai si tratta di diritto commerciale a tutti gli effetti.

> Notiamo immediatamente, oltre all’intento pratico, quello didascalico, in quanto nell'argomentare questo caso fa riferimento, anzi compara, la locazione-conduzione ed il deposito; per cui immaginando la dimensione in cui veniva espresso il responso (e quindi dobbiamo immaginare Servio circondato dai suoi allievi che ne ascoltavano le parole) l'ispirazione didattica si giustifica completamente.

(Testo pag. 208) - quarto responso serviano

1- Si proponeva questa ipotesi: alcuni dei giudici, nominati per la stessa «cosa», dopo aver udita la causa erano stati esonerati dall'ufficio, e altri avevano preso il loro posto.
2- Si domandava: il mutamento di singoli giudici mantiene identica la «cosa» o rende altro il collegio giudicante?
3- Risposi: non solo se l'uno o l’altro dei giudici, ma anche se tutti i giudici fossero cambiati, nondimeno la «cosa» e il collegio giudicante rimarrebbero tali quali erano prima.
Né accade solo in questo caso, ma anche in molti altri, che, mutate le parti, si continui a considerare la cosa come la medesima. Così si ha sempre la medesima legione, benché molti soldati di essa siano morti e altri li abbiano sostituiti; così, il popolo di ora è considerato lo stesso di quel che era cento anni fa, benché nessuno di quel tempo ora sia vivo; così una nave, che è stata spesso riparata, al punto che non c'è in essa più nessuna tavola che non sia nuova, continua ad apparire sempre la stessa nave.
Che se poi si pensasse che, mutando le parti, anche la cosa diventi un'altra, se ne dovrebbe arguire, seguendo il filo del ragionamento, che anche noi non siamo più gli stessi che eravamo un anno prima, perché, come dicono i filosofi, siamo costituiti di particelle estremamente piccole, e queste, giorno dopo giorno, abbandonano il nostro corpo, mentre altre prendono all'esterno il loro posto.
In conclusione, si deve riconoscere che, sino a quando rimane identica la forma di una cosa, anche la cosa continua ad essere la medesima

> Questo è un passo interessante in cui troviamo traccia quasi della formazione di Servio Sulpicio Rufo, in quanto troviamo l’analogia combinata alla “riduzione all’assurdo”, che sono due strumenti tipici dell’oratoria, ma anche, nel finale, abbiamo testimonianza della formazione enciclopedica di questo giurista in quanto è esplicito il riferimento alla teoria atomistica.

> *Descrizione del caso:*
Qui vediamo l’ipotesi in cui all’interno di un collegio giudicante che viene nominato per dare una sentenza rispetto ad un determinato affare, alcuni dei giudici nominati, dopo aver saputo della causa e ascoltato gli sviluppi, vengono estromessi dal loro ufficio e sostituiti con altri giudici.

> *Quesito giuridico:*
Il quesito posto era se a seguito del cambiamento dei membri del collegio giudicante ci fossero effettive variazioni, e quindi se fosse da considerare come lo stesso collegio, o come un altro.

> *Responso di Servio:*
Per spiegare ed avvalorare la sua posizione rispetto alla quale il collegio giudicante rimane lo stesso e la causa rimane la stessa pur essendo cambiati i suoi membri, espone una serie di argomentazioni estendendo il ragionamento:
- Fa una serie di analogie:

Così come la legione, una volta morti e sostituiti i soldati che la componevano, non cambia, lo stesso valeva per il collegio giudicante.

Così come il popolo romano contemporaneo non era composto dalle medesime persone del secolo presedete ma rimaneva sempre “il popolo romano”, lo stesso valeva per il collegio giudicante.

Così come una nave a cui, per essere riparata, venivano sostituite tutte le tavole che la componevano, e nonostante ciò rimaneva sempre la stessa nave, allora lo stesso valeva per il collegio giudicante.

- Dopodichè non solo fa riferimento alla teoria di intonazione epicurea (atomistica*), ma spinge il suo ragionamento di analogia ad una forma di "assurdo":
* Secondo la teoria atomistica le particelle che ci compongono tendono meccanicamente ad aggregarsi e disgregarsi, sostituendosi costantemente.
E Servio dice che, seguendo lo stesso ragionamento delle analogie precedenti, anche noi quando cresciamo saremo altri in quanto dato che le particelle che ci compongono si sostituiscono ripetutamente, potremmo affermare, ***ragionando per assurdo,*** che noi non siamo noi da quando abbiamo cinque anni rispetto a quando ne abbiamo 10.

> Ecco allora come Servio spieghi tutti i passaggi del proprio ragionamento usando anche strumenti come l'***analogia***, la ***riduzione all'assurdo***, e anche elementi che richiamino una cultura filosofica.
- Il che è, capiamo bene, è molto diverso rispetto al responso laconico e oracolare di Mucio Scevola, ecco perché in senso simbolico nell'aneddoto di Pomponio, Servio non riesce ad intendere.

Capitolo ottavo: Il giurista e il principe

1. La diplomazia del potere

L'età del principato: età classica

I secolo a.C. - Metà III secolo d.C.

Il periodo dell'età classica abbraccia tre secoli: a partire dal principato augusteo (27 a.C.) sino alla prima metà del III secolo d.C., col termine della dinastia severiana.

- Una prima valutazione da compiere è in relazione all'***aggettivo "Classica"*** dobbiamo coglierne un giudizio di valore: e questo perché nell'età classica (ed è parere comune) si raggiunse l'acme della raffinatezza culturale, ma non solo, è il periodo in cui Roma raggiunse la sua espansione massima.

Si venne a realizzare un universalizzazione della società romana, la quale fu capace di assoggettare un numero immenso di popoli sui quali impose in un certo senso il proprio "marchio" imprimendo i propri valori, ma allo stesso tempo rispettò, non soffocandolo, l'assetto culturale e tradizionale di ciascuna delle popolazioni conquistate.

> Anche dal punto di vista giuridico, il discorso è analogo, tant'è che il giurista tedesco Savigny, arrivò a sostenere che con Papiniano, Paolo ed Ulpiano la scienza giuridica raggiunse il suo punto più alto.

Ottaviano Augusto

L'instaurazione del principato, si deve al, così definito, "genio politico" di Ottaviano.

Ottaviano, (pro)nipote di Cesare, fu adottato da Cesare come suo successore.

A partire dalla morte di quest'ultimo nel 44 a.C., passando attraverso le vicende delle guerre civili e del triumvirato (stipulato assieme a Lepido e Marco Antonio: Lepido fu sconfitto in Sicilia, Marco Antonio si fece travolgere dalla passione amorosa nei confronti della regina egiziana Cleopatra e rifiutò i principi romani per abbracciare quelli orientali), si arrivò alla battaglia di Azio nel 31 a.C., dopo la quale l'impero passò sotto il potere di Ottaviano.

Con la sua personalità carismatica e la sua attività politica, riuscì a porre fine alla lunga crisi della Repubblica, e grazie a suo intuito politico, Ottaviano, si trovò a godere di un prestigio notevolissimo che combinato con un impeccabile strategia gli permise di accentrare il potere solo nelle sue mani.

> La sua ascesa, oltre che con i "fatti", dimostrò le sue qualità strategiche e la sua prontezza nelle questioni militari, si ebbe attraverso l'attribuzione progressiva dei poteri ordinari e straordinari (tipici delle magistrature repubblicane), e culminò con la seduta in Senato del 27 a.C. quando si fece nominare ***Princeps Senatus***, e poco dopo assunse anche l'***imperium proconsolare maius et infinitum*.***

* forma di *potestas* che spetta al *princeps* ed è il comando su tutte le forze armate romane, in tutte le province, importante soprattutto in quelle strategiche.

Attraverso anche un abile azione di propaganda, nascose l'affermazione del suo potere assoluto, strategicamente, dietro un abile disegno di restaurazione e mantenimento (che poi sarà solo formale) delle istituzioni repubblicane romane, ormai danneggiate dalle guerre civili.

- Nel 28 a.C. infatti, Ottaviano, già console e *Princeps Senatus,* annuncio l'opera di restaurazione della Repubblica.

Tutte le gesta di Ottaviano si ritrovano nelle cosiddette ***res gestae:***

- Un' opera che racchiude la memorie ufficiali e il bilancio del suo governo, voluta dallo stesso principe e diffusa in tutto l'impero, chiaramente a scopo propagandistico; (che ci è pervenuta attraverso vari esemplari in latino e in traduzione greca)

> Quest'opera racconta l'ascesa del *princeps* e poi la sua attività di governo, come perseguimento tenace dell'opera politica fatta di uomini, di opere e di idee e a volte anche manipolazioni.

> In quanto figlio adottivo di Cesare, Ottaviano si portava dietro il nome di:
- ***Imperator*** (*prenomen*): rappresentava il fondamento del potere militare evocato dallo stesso *prenomen*.
- Venne consacrato ***Augustus***: richiama l'idea della *inauguratio*, dell'investitura religiosa.
- Ottenne il titolo onorifico di ***Pater Patriae***: il padre della patria, salvatore e benefattore della società.

> Dopo il principato augusteo (27 a.C. fino al 14 d.C.) abbiamo:
- l'età dei *Giulio-Claudii* che si concluse nel 68 d.C. (con Tiberio Caligola, Claudio e Nerone);
- la Dinastia dei *Flavi* (con Vespasiano, Tito e Domiziano) che si concluse nel 96 d.C.
- l'età degli *Antonini* (Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio)
- l'età dei *Severi*, che inquadra il momento conclusivo del principato che si concluse nel 235 d.C. dove abbiamo Settimio Severo, Caracalla (colui che estese cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero), Alessandro Severo.

Forme del potere

In effetti nelle mani di Ottaviano Augusto ritroviamo gli stessi poteri che caratterizzavano le magistrature repubblicane; Si nota proprio il passaggio dalle cariche repubblicane, giudici e magistrati e popolo, al solo potere assoluto del Princeps.
Ottaviano è infatti rivestito della ***potestas*** che non ha nessun legame sostanziale con le antiche magistrature, e seppur si presenta nella realtà delle cose come assoluta, è ancora definita secondo la logica del vecchio ordinamento e quindi distinta in poteri singoli (fra cui emergono quello tribunicio e quello proconsolare).
Ottaviano assume infatti:
> ***Tribunicia Potestas*** (il *princeps* assume in sé le prerogative dei tribuni plebis); che comportava la ***Sacrosantitas*** (inviolabilità della sua persona) e anche lo ***Ius auxilii*** (vietare qualunque sopruso di altre magistrature); la *potestas* attinta dalla *tribunicia potestas* è slegata dalle antiche magistrature.

> L'altra faccia della *potestas* è l'***auctoritas:*** nella repubblica individuava il prestigio sociale del giurista nell'esercizio delle sue virtù, ora connota il potere del principe ed esprime la preminenza assoluta del principe su ogni carica pubblica.
> Si arroga puoi anche l'***imperium maius et infinitum***.
L'*imperium* che risiedeva nel *princeps* non aveva limiti né nel tempo e né nello spazio, era al di sopra di tutto e tutti (Plinio lo definisce *omnium rerum potestas*).

> Augusto quindi è il ***princeps universorum.***
È il principe il nuovo centro di potere in una rete che si affianca agli organi repubblicani.
- Ha il comando dell'esercito
- Governa o controlla le province
- Mantiene rapporti con i regni vassalli e le città straniere
- Dispone delle risorse finanziarie
- Conta sulla "fedeltà emozionale e devozione religiosa" dei suoi sudditi
- Si pone nel pieno rispetto delle situazioni passate presentandosi come cittadino tradizionalistia
- Ed è appunto *pater patriae,* il benefattore della società, in questo ravvisiamo l'immagine-guida della monarchia patriarcale e della regalità omerica.

L'obiettivo primario della politica augustea era quello di un risanamento sociale (discostare gli uomini dai loro vizi), politico e di coesione con la repubblica per garantire un periodo di tranquillità e di serenità per i cittadini; si proponeva infatti di ricostruire il *mos maiorum attraverso una* riforma dei costumi che erano stati perduti durante le brutalità delle guerre: vi era stata una vera e propria risolutezza dilagante.
E in virtù della necessità di riformare i valori della vecchia repubblica, con l'obiettivo di ritornare ad una situazione stabile e pacifica, ci furono delle novità:
- Legislazione sul matrimonio
- Repressione dei *crimina* (profilo criminale)
- Limitazione degli sperperi

> Dopo aver rimesso i suoi poteri al popolo e al senato, essendo ormai salva la repubblica, Ottaviano assume in se i poteri che spettavano alle magistrature repubblicane realizzando un accentramento capillare, che riguardava quindi tutte le zone dell'impero, in merito alla pace e la guerra, ai trattati internazionali, agli aspetti amministrativi, ma anche alle pronunce giudiziarie (la giurisdizione infatti ormai appartiene al principe e cambiò anche la procedura del processo legata alla figura del principe)

La giurisprudenza in età classica

Naturalmente, al cambiare dell'assetto socio-politico, cambia anche l'impostazione del giurista e della giurisprudenza; in realtà il principato ricopre comunque tre secoli, e non possiamo pensare che in un così vasto lasso di tempo rimanga tutto invariato, bisogna infatti, col passare del tempo, dei mutamenti, in quanto non tutto rimane con l'impostazione data da Augusto, ragion per cui possono essere fatte sia riflessioni di carattere generale, si riflessioni, precisazioni, di carattere specifico.

L'instaurarsi di un nuovo regime non determinò una trasformazione improvvisa della giurisprudenza, seppur con qualche lieve differenza col passare del tempo, i giuristi continuano a rappresentare il cuore della produzione giuridica con la loro attività interpretativa (tant'è che lo si vede anche con i cataloghi normativi, sia nell'età repubblicana, sia nell'età del principato, la produzione giurisprudenziale rimaneva una fonte essenziale di produzione normativa) > questo è un dato in continuità.

> Ottaviano Augusto, ovviamente riteneva necessario confermare e mantenere il filo continuo con le cariche repubblicane, per cui, così come nella Repubblica il giurista era aristocratico, conservò i privilegi dell'èlite nobiliare senatoria, e in particolar modo fece leva su coloro che non avevano ricevuto la confisca dei beni nel periodo delle guerre civili o che non erano stati colpiti dalle liste di proscrizione, e gli offrì ricchezze ed onori per accaparrarsi il loro appoggio.

>Il ruolo del giurista nel quadro istituzionale nuovo, si va a trasformando:

Il contesto non è più quello cittadino, a seguito dell'espansionismo si amplia e diventa mondiale, per cui scompare via via la figura del giureconsulto aristocratico (quel sapiente che godeva di un prestigio sociale che gli era corrisposto dalle cariche pubbliche relazione alle sue virtù), e cede il posto al giurista funzionario e consigliere del principe.

- Cioè, con l'aumentare dei territori imperiali, si espande anche l'amministrazione per controllarli, per cui è sempre più facile vedere giuristi che abbiano un ruolo all'interno dell'amministrazione imperiale, tuttavia scompare quella stretta connessione tra carica pubblica e giurisprudenza, in quanto, se alcuni giuristi fanno parte di quell'amministrazione, altri se ne tengono nettamente lontani, svolgendo l'attività di insegnanti o ritirandosi a vita privata per studiare, o che fanno semplicemente da "consiglieri" del principe.

Il connubio tra carica pubblica e giurisprudenza risulta completamente scisso.

- Ma l'idea che il giurista possa essere funzionario, non ci deve portare a pensare che siccome c'è un potere assoluto, ovvero quello del principe, i giuristi perdono la loro libertà ed importanza, al contrario, quella *libertas* repubblicana mantiene il suo fascino, ed è molto presente come modello di comportamento:

> *Una personalità significativa del passaggio tra repubblica e principato* ***Marco Antistio Labeone:***

Labeone si dice giurista augusteo, in quanto la maggior parte della sua vita la svolta sotto il principato augusteo, tuttavia ha vissuto anche l'ultimo periodo repubblicano, ha vissuto la trasformazionie;
> Per cui manifesta il suo essere nostalgico dei confronti della *libertas* repubblicana.

Si pone infatti in polemica antigovernativa, condotta sul filo di un esasperato tradizionalismo, addirittura rifiuta di diventare console sotto proposta di Augusto stesso; non si rassegnava al potere assoluto del principe, era estremamente legato alle modalità di svolgimento dell'attività giurisprudenziale repubblicana.

Un suo contemporaneo, Ateio Capitone (che tra l'altro, al contrario, era sostenitore del principe) dice di lui che fosse *invaso dall'idea folle e smisurata della libertà*.

È possibile riconoscere in Labeone anche degli *aspetti innovativi*:

1- Pomponio nel suo *Enchiridion, (*opera che ripercorre la storia della giurisprudenza) oltre che di Mucio Scevola (atteggiamento oracolare), si occupò anche di Labeone, e ne rimarcò il rifiuto del consolato, e disse che aveva organizzato la sua attività durante l'anno in due parti:
- Per 6 mesi si dedicava all'insegnamento presso Roma (e quindi l'attività del respondere quindi rapporto più diretto con chi chiedesse il responso); e
- Gli altri 6 mesi si ritirava in campagna per studiare e scrivere libri (infatti abbiamo circa una quarantina di libri di Labeone).

Seppur il rifiuto del consolato sia una manifestazione del suo essere conservature con riguardo alla repubblica (resistendo alla proposta di Augusto, lui tende a preservare in se il modello di giurista repubblicano), è proprio in quanto atteggiamento che ne cogliamo un primo aspetto innovativo:

> Da ciò deduciamo proprio come il giurista del principato non è detto che aderisca e affianchi il principe: L'innovazione che sta nel comportamento di Labeone è che, allo stesso tempo, è sia conservatore del modello aristocratico del giurista repubblicano ma d'altro canto, proprio perché distaccato dall'impegno pubblico, era estremamente innovativo.

> Questo lavoro intellettuale stava quindi iniziando a manifestare la sua autonomia, specialistica, vissuta spesso in alternativa l'impiego politico:

2- È ancora in Labeone che vediamo l'aspetto della dedizione agli studi, venne intrapresa proprio come atteggiamento di discostamento\ rifiuto politico come occasione di rifondare la giurisprudenza come *scientia*, in grado di creare nuovi contenuti normativi che permettano al *ius* (al diritto), di crescere, anche al di fuori del sistema politico: e questa é un'affermazione innovativa dell'autonomia della giurisprudenza rispetto al potere politico.

- Vi sono una serie di giuristi che non vi si uniscono alla figura del principe, ma che comunque continuano la propria attività senza alcuna censura da parte del principe. E quindi hanno libertà di espressione (e di pensiero ovviamente. (Altrimenti, senza libertà di espressione non si spiegherebbe l'enorme sviluppo culturale dell'età classica).

3- Pomponio, su Labeone, dice proprio "*Plurima innovare instituit"*: e cioè fu l'autore di un grandissimo rinnovamento; il che non ci deve sorprendere alla luce del suo essere conservatore, in quanto ci stiamo proiettando in una dimensione in cui il sapere giuridico è più autonomo.

> E l'impulso dato in questo periodo dato dalla tipologia letteraria del *commento all'editto* è significativo, in quanto il quesito giuridico cercava di riappropriarsi del suo primato nell'interpretazione del diritto e nel suo controllo della sua applicazione pratica, studiando le molteplici possibilità date dalla *lex annua* pretoria.

- Quindi con Labeone si inaugura il commento all'editto (forse anche prima con con Servio, anche se non abbiamo prove certe di nessun suo commento all'editto).

Di Labeone ci è pervenuto un commentario all'editto, e l'impulso dato da quest'opera è proprio la volontà di riaffermazione di quel ruolo importante che la giurisprudenza rivestiva nella funzione normativa dell'editto, che stava nella verifica degli strumenti in esso contenuti o nel suggerimento di nuovi da inserire a fronte della formazione alluvionale dell'editto stesso…

(Nel commento all'editto si riafferma simbolicamente quel ruolo della giurisprudenza.)

4- E anche poi un innovatore sotto il profilo delle dottrine contrattualistiche, il suo apporto dato al ragionamento nell'ambito del diritto privato fu significativo in quanto defin' proprio il contraere, siamo ali albori del contratto;

Con il ius gentium erano affiorati i nova negotia, questa nuova tipologia di contratto, su cui la giurisprudenza inizia ragionare, e Labeone definisce il ***contraere*** distinguendolo dall'*agere* e dal *gerere*.

- *Agere*: *actum, agere* allude all'attività che si realizza tramite fatti ho parole

- *Gerere*: *gestum, gerere* fa riferimento ad un comportamento diverso e concludente, che non ho bisogno di particolari attività espressive

- *Contraere*: il *contactum* invece è caratterizzato dalla "*ultro citroque obligatio*" che individua una reciprocità delle prestazioni, da cui si produce proprio il *vinculum*\ le obbligazioni, che nasce nel momento genetico\costitutivo del contratto: le due parti si obbligano specularmente, reciprocamente.

Primo aspetto che lega giurista e principe

Ius Respondendi ex auctoritate principis (responsa signata)

Si tratta dell'aspetto più significativo per comprendere il rapporto che si viene a creare tra giurista e principe nell'epoca del principato, ed è il punto di incontro tra l'autorità del principe è quella del giurista.

> È una sorta di autorizzazione che il principe attribuiva ad alcuni giuristi (quelli a lui più vicini e che avevano una visione politica in linea con la sua) in base alla quale questi determinati giuristi avevano la facoltà di emanare i responsi "con valore pubblico", come se provenissero direttamente dall'*auctoritas* del principe stesso. Si parla infatti di ***responsa signata***, cioè dotati di una sorta di sigillo imperiale.

- Pomponio, nell'*Enchiridion,* a riguardo, dice proprio che per primo l'imperatore Augusto, affinché vi fosse una maggiore autorità del diritto, stabilì che (alcuni giuristi) rispondessero in base alla sua autorità.

- Cioè i responsi dei giuristi dotati di *ius rispondendi ex auctoritate principis* era come se fossero emanati dal principe: avevano molta importanza ed autorità.

> Possiamo vedere in questo fenomeno un vero e proprio espediente con il quale il principe riesce ad avere e ad esercitare una certa forma di controllo sull'interpretazione giurisprudenziale:

- E questo perchè dobbiamo considerare che il momento in cui il diritto si afferma\ si applica, è il processo, è il momento della controversia, quando si contrappongono opinioni contrastanti;

E in base a queste opinioni contrastanti, il giudice è chiamato ad emanare una sentenza: compie una scelta, che nel momento in cui vengono introdotti i *resposa signata*, diventa quasi una forma di scelta politica, e questo perché è chiaro che il giudice fosse portato a protendere per l'opinione supportata da un responso emanato da un giurista dotato di *ius rispondendi*.

> Per cui capiamo che, così facendo, il principe riesce ad avere un controllo sull'applicazione del diritto il quale poi è finalizzato ad orientare una determinata politica sociale generale.

> Non dobbiamo pensare che agli altri giuristi, non dotati di questa prerogativa, fu impedito di esprimere opinioni o di scrivere libri giuridici, non si viene a formare una sorta di dittatura di pensiero, tuttavia, appunto nel processo, erano chiaramente privilegiati i pareri dei giuristi dotati del sigillo imperiale.

- Quindi vediamo che l'autorità del principe (che va intesa come preminenza assoluta) va a sovrastare quella del giurista (in ambito repubblicano, ciò che caratterizzava la figura del giurista era proprio quell'autorità che derivava ad esempio dal talento del giurista stesso);

- E il principe riesce ad insediarsi e a controllare anche la realtà del processo, influenza le sentenze imprimendo l'orientamento politico che gli stesso sosteneva.

> In generale Augusto fu portato a concedere questo sigillo ai giuristi appartenenti al ramo senatorio, un po' in virtù della nostalgia repubblicana, espressione del monopolio della giurisprudenza, un po' per il prestigio dell'ordine senatorio e il dovere di difendere gli interessi pubblici, scelse tra i senatori quei giuristi a cui attribuire lo ius respondendi.

> Tuttavia, ci troviamo nel periodo dell'ascesa della classe equestre (quella classe più legata alle nuove realtà economiche, composta ad esempio da commercianti, che si stava pian piano arricchendo).

Inizialmente gli appartenenti a questo ceto non furono prese in considerazione da Augusto, poiché era parere comune che potessero essere poco abili ad interpretare il volere imperiale, in un secondo momento, però, i giuristi appartenenti al rango equestre iniziarono ad aumentare e ad inserirsi gradualmente nelle maglie dell'amministrazione imperiale, ed ecco che anche gli *equites* furono investiti dello *ius respondendi*.

- Quindi da un lato si fece strada la convinzione che il giurista potesse essere un funzionario imperiale e rivestire compiti amministrativi, e se arrivo a partire dal II secolo a contare un elevatissimo numero di giuristi provenienti dal ceto equestre (anche prima ancora, in età severiana), tant'è che i maggiori giuristi tra cui Paolo, Ulpiano o Papiniano, riuscirono a raggiungere ruoli importanti come ad esempio la carica di prefetto del pretorio.

Secondo aspetto che lega giurista e principe

2. Discussioni nel consiglio imperiale

Il ruolo emblematico del giurista è quello di consigliere, lo si vede in queste vesti in quasi tutte le epoche, a partire da quell'arcaica con il giurista pontefice, ma anche durante la Repubblica in cui si ritrova a consigliare, ad esempio, al pretore, o in generale a magistrati, giudici o oratori.

Anche il giurista dell'età del principato conserva questa prerogativa: diventa consigliere del principe.
I giuristi diventano quindi funzionali al principe, collaborano con lui per aiutarlo a risolvere problemi di fondamentale importanza, laddove il principe, non essendo un esperto, necessitava di consiglieri (*consiliarii*)\ aveva bisogno di circondarsi di consiglieri: si viene a creare il ***Conslium Principis.***

Consilium Principis: non era altro che insieme di giuristi, nel quale il principe richiamava i suoi "amici", persone a lui fidate (non bisogna fraintendere il significato di questo legame, non è da intendere in maniera volgare ma bisogna guardarlo come un rapporto che alla base un alto livello di affidabilità e vicinanza).
- I soggetti che ne fanno parte, sono coloro che hanno compiti e ruoli importanti all'interno dell'amministrazione imperiale: sono funzionari.
- Questi assumono un ruolo di collaborazione che acquista sempre più importanza col passare del tempo, tant'è che dall'essere occasionale, diventa sempre più costante, fino a che, in età post-classica, andarono a costituire dei posti retribuiti e fissi.

> Vediamo quindi che c'è una un rapporto di collaborazione tra giuristi e principi, che segnando anche degli orientamenti di politica legislativa imperiale, portano delle discussioni e conducono a determinate soluzioni sui casi specifici.

(Testo pag. 215)

> Questo è un passo tratto dalle Institutiones giustinianee (sviluppate seguendo la falsa riga dell'impostazione delle institutiones gaiane; In quanto, ovviamente ci sono tutte le novità del secolo di Giustiniao); lo scopo è comunque didascalico, quindi didattico-pedagogico, e quindi ho gli istituti vengono presi in considerazione dall'origine, si fa riferimento all'oro momento originario.

- In questo frammento, ritroviamo la particolare vicenda che porta all'origine\ creazione dei ***fedecommessi***.

È noto che, prima dell'età augustea, l'istituto giuridico del codicillo non esisteva; fu Lucio Lentulo per primo a introdurlo, e da lui presero inizio anche i fedecommessi.

Egli infatti, in Africa dove morì, redasse un codicillo confermato nel testamento; e con questo pregò Augusto, per mezzo di un fedecommesso, di compiere un qualche atto. Poiché Augusto eseguì la sua volontà, gli altri via via, sull'esempio del principe, adempirono a loro volta i fedecommessi, e la stessa figlia di Lentulo adempì i legati a cui giuridicamente non era tenuta.

Si racconta che Augusto abbia convocato i giuristi, - fra i quali Trebazio, che godeva allora di un grandissimo prestigio, - e abbia loro posto il quesito, se quella pratica fosse ammissibile e l'impiego dei codicilli non dissonante con l'interna coerenza dell'ordinamento giuridico.

Trebazio, si dice, persuase il principe su questo punto: era utilissimo per i cittadini,- e rispondeva a una necessità, dati lunghi e continui soggiorni in paesi stranieri (assai frequenti presso gli antichi) ,- il poter fare dei codicilli, se non era possibile fare un testamento…

> Innanzitutto precisiamo:

Codicilli:

- Sono un documento scritto, privo delle formalità testamentarie*, che poteva contenere tutte le disposizioni testamentarie, di ultima volontà, ad eccezione dell'istituzione dell'erede, tra le quali rientrano anche i fedecommessi.

* Nel testamento, infatti, affinché sia valido, devono essere presenti tutta una serie di prerogative formali, come l'*istitutio eredis*, che non era ammessa nei codicilli.

Fedecommessi:

- I fedecommessi, sono quindi delle disposizioni di ultima volontà espresse in termini di preghiera; sono infatti introdotti da verbi come "*prego*" o "*rogo*" che inquadrano subito questa peculiarità del fedecommesso: cioè questa formulazione sotto forma di richiesta posta con cortesia, di preghiera di porre in essere una volontà del testatore, ad esempio, una prestazione il nome di qualcun altro.
  E ovviamente era rivolta ad un onerato (un soggetto viene gravato di questa richiesta di porre in essere alcuna volontà del testatore).
- Potevano, quindi, essere contenuti all'interno dei codicilli
- E, inizialmente, proprio perché concepiti come preghiere, l'attuazione di quanto veniva espresso era affidata alla lealtà dell'onerato: cioè se l'onerato era onesto, allora dava seguito alla volontà contenuta nel fedecommesso, in caso contrario, non c'erano vincoli ufficiali\ giuridici che facessero valere quella richiesta a seguito della mancata esecuzione. (la vincolatività giuridica per i fedecommessi nascerà in un secondo momento)

Legati

- Erano altro tipo di disposizioni di ultime volontà già vincolativi sotto il profilo giuridico: per cui l'onerato, a differenza di quanto accadeva per i fedecommessi, era obbligato giuridicamente a portare a termine il suo compito.
- Fedecommessi e legati sono due figure che pian piano si assimileranno.**

> Nel brano *si racconta,* infatti, che prima dell'età augustea codicilli e fedcommessi non esistevano, e fu Lucio Lentulo ad introdurli, in quanto, prima di morire (in Africa), scrisse un codicillo (confermato nel testamento) pregando Augusto, attraverso un fedecommesso, di compiere una sua ultima volontà.
- Quindi l'onerato di dar seguito alla preghiera di Lucio Lentulo e Augusto.

> Augusto diede seguito a questa preghiera, ed essendo *princeps*, questo suo comportamento risultò esemplare e paradigmatico, di conseguenza, seguendo il suo esempio, tutti iniziarono ad adempire i fedecommessi (si precisa, infatti, che anche la stessa figlia di Lucio Lentulo adempì a quanto scritto nei codicilli, pur non essendo tenuta a farlo dal punto di vista giuridico)

> Notiamo quindi che proprio attraverso il comportamento esemplare del principe, si manifesta, e acquista rilievo, la volontà normativa del principe stesso;
- Tant'è che se questo problema della obbligatorietà di codicilli e fedecommessi fosse sorto durante la Repubblica, molto probabilmente sarebbe stato risolto con un'*actio in factum* composta da qualche giureconsulto e approvata dal pretore che dopo un periodo di prova l'avrebbe inserita nel suo editto.
- Ma qui vediamo che uno sviluppo edittale viene consapevolmente eluso: Ha valore normativo il comportamento esemplare del principe.

> Nel testo emerge anche un'immagine del *consilium principis*;
> Si racconta infatti che Augusto convocò i giuristi, tra cui Trebazio Testa, giurista di grande autorevolezza, e chiede se quella prassi (messa in atto in primis da lui stesso e poi da altre persone che avevano adempito i fedecommessi seguendo il suo modello), non fosse in contrasto con l'ordinamento giuridico:
- Cioè: aveva fatto qualcosa conforme o dissonante rispetto allo '*ius*'? (dato che queste erano comunque figure nuove)

> Vediamo poi Trebazio, nelle vesti di consigliere, che rispose ragionando in termini di utilità sui codicilli:
- Non ravvisò alcuna contrarierà rispetto ai principi dell'ordinamento giuridico, anzi, ritenne che questi codicilli rappresentassero una grande novità\ un passo in avanti, considerando le difficoltà di redigere un testamento in maniera formalmente corretta, specie per chi si allontanava per lungo tempo in paesi stranieri.
(I codicilli quindi sono molti utili, non contrari all'ordinamento giuridico e Trebazio consiglia il principe relativamente alla domanda che gli è stata posta).

** Ovviamente il comportamento di Augusto inaugura una nuova pratica:
non solo rafforzò l'uso dei codicilli, ma il suo dare seguito alla preghiera contenuta nei fedecommessi, via via portò una loro vincolatività giuridica.

Pian piano si ha un'azione da parte dell'*onerato* (colui che è gravato della richiesta espressa dal *fedecommissario*) perché ponga in essere dei comportamenti a favore di un *onorato* (il *fedecommissario**)

* come legatArio, con questa desinenza si specifica colui che sì avvantaggia di qualcosa, che riceve effetti.

Che verrà dotato di un'azione, cioè avrà la possibilità di agire, nei confronti di un onerato inadempiente: ecco in cosa consisteva la vincolatività giuridica, sta proprio nell'avere un'azione a presidio, in questo caso, del fedecommesso.

Nascerà tra l'altro una competenza apposita, ci sarà un *Praetor fidecommissarius*, competente per le cause nascenti da fedecommesso, e quindi con una conoscenza specifica della materia.

Quindi i fedecommessi dall'essere mere preghiere legate alla lealtà dell'onerato e quindi non azionabili, diventeranno vincolative analogamente ai legati che già nascono così.

Tutto questo è molto significativo:
- Trebazio che dà il consiglio
- Il comportamento di Augusto che fa nascere la vincolatività arrivando fino all'instaurazione della nuova figura del '*praetor fidecommisarius*'.
- Augusto che convoca i giuristi ci già dà idea che lui ha bisogno di questo consilium dai giuristi che avranno dei ruoli sempre più importanti:
Traniano, Marco Aurelio, Salvo Giuliano, Prisco, Celso, Marcello, Meciano, sono alcuni nomi importanti di consiglieri e collaboratori del principe.
> Dal II sec in poi la figura del consigliere diventerà fissa e stabile, poi dalla dinastia dei Severi ci sarà più burocrazia e i giuristi vengono proprio inseriti nei ruoli amministrativi dello Stato.

(Testo pag. 217)

"Poiché Valerio Nepote, mutando la sua volontà, ha dissuggellato il testamento e cancellato i nomi degli eredi, ritengo che la sua eredità, secondo la costituzione del divino padre mio, non spetti a coloro che sono stati nominati".

Agli avvocati del fisco Antonino Cesare disse: "Voi avete i vostri giudici".

Vibio Zenone disse: "Ti prego, sovrano imperatore, ascoltami con pazienza: riguardo ai legati che cosa stabilirai?"

Antonino Cesare disse: "Ti sembra che colui che cancellò i nomi degli eredi volesse che il testamento fosse valido?"

Cornelio Prisciano, avvocato di Leone, disse: "Ha cancellato solo il nome degli eredi".

Calpurnio Longino, avvocato del fisco, disse: "Non può essere valido un testamento che non abbia un erede".

Prisciano disse: "Ha manomesso alcuni schiavi e ha disposto dei legati".

Antonino Cesare fece uscire tutti; dopo aver deliberato, li fece entrare di nuovo e disse: "La causa presente ammette un'interpretazione più umana; seguendola, stimo che Nepote abbia voluto rendere inefficace solo ciò che ha cancellato".

> Questo brano è relativo alla materia testamentaria\ereditaria, che senz'altro la materia che comporta più problemi e che fa nascere più incertezze, in quanto è complicato comprendere le volontà reali di una persona, specialmente dopo che questa è morta e ci sono interessi in campo contrapposti.
Tant'è che proprio per questi motivi, è uno degli ambiti su cui i giuristi ragionano di più e forniscono più interpretazioni.

> Il passo è tratto dai Digesta, l'autore è Ulpio Marcello, che ci riporta un'udienza in sede giurisdizionale (un processo) tenutasi dinanzi a Marco Aurelio.

> L'oggetto in questione è il testamento di un tale Valerio Nepote, il quale, essendo il testamento rivedibile fino alla propria morte, prima di morire, Valerio Nepote aveva tolto i sigilli dal suo testamento e cancellato i nomi degli eredi, ma non quello dei legatari.

- Il primo elemento certo è che, essendo stati cancellati i nomi degli eredi, era chiaro che l'intenzione del testatore fosse quella di non lasciare a questi l'eredità. (Si richiama una costituzione di Antonino Pio)

- Il problema si poneva in relazione ai legati:

Intervengono le diverse voci delle parti coinvolte: abbiamo gli avvocati del fisco, gli avvocati dei legatari e Antonino Cesare (cioè Marco Aurelio, richiamato con dei nomi alla dinastia, Cesare rimanda proprio il concetto di imperatore).

(Caso concreto) Si viene a sviluppare una contrapposizione tra gli avvocati dei legatari che vogliono conservare la validità dei legati, e poi gli avvocati del fisco che invece vogliono invalidare tutto il testamento affinché l'eredità venga consegnato allo stato.

Dunque si discuteva su cosa comportasse il dissuggellamento del testamento, se la cancellazione dell'*institutio aeredis* invalidasse tutte le disposizioni presenti nel testamento, e quindi anche i legati .

- I legatari, infatti, rivendicavano una loro posizione\ vantaggio in quanto i nomi non erano stati cancellati i loro nomi.

- Secondo Marco Aurelio, dato che il testatore aveva eliminato gli eredi, l'intenzione del testatore era quella di invalidare tutto il testamento

- Prisciano, avvocato di un legatario, specifica, però, che erano stati cancellati solo i nomi degli eredi.

- Calpurnio , avvocato del fisco, afferma che un testamento non può essere valido se non c'è il nome di un erede, di conseguenza essendo il testamento invalidato dalla cancellazione dei nomi degli eredi, tutto il patrimonio che non poteva essere assegnato nessuno andava consegnato al fisco.

> In base ad un ragionamento rigoroso, bisognava dare credito alle parole di Calpurnio e Marco Aurelio, in quanto un testamento privo di eredi è invalido nella sua interezza, di conseguenza l'eredità spettava allo stato, e tutto ciò che in esso era contenuto, dai legati ad eventuali eventuali manomissioni di schiavi era da ritenersi invalido

> Tuttavia in questo caso, sia un tentativo di fornire un'interpretazione diversa da quella rigorosa, specialmente gli avvocati delega Tari, spingono affinché ci sia un risultato diverso, e Marta nel fatto che il testatore abbia cancellato solo i nomi degli eredi, e non delle altre disposizioni, per cui la volontà del testatore era andare ad invalidare soltanto l'institutio aeredis, e non tutto il resto.

> Alla fine Marco Aurelio, dopo aver sentito tutte le parti, si pronuncia, facendo valere il principio dell'***Humanitas:***

- Cioè porta ad attenuare un'interpretazione tecnica e troppo rigorosa parlando di una interpretazione "***humanior***" (più umana) .

Bisogna riflettere su quale fosse veramente la volontà del testatore, e si arriva a ritenere che Nepote attraverso la cancellazione di quei determinati nomi abbia voluto rendere inefficace solo ciò che ha cancellato.

> Questa non è una novità indifferente perché se ci si ferma allo *ius scriptum* (quindi ad un'interpretazione rigorosa), allora l'esito sarebbe stato differente, ma facendo valere il principio dell'Humanitas, che porta a salvare le disposizioni non cancellate, in virtù dell'interpretazione della volontà testamentaria, si rende valido quanto del testamento non era stato cancellato.

> Vedamo quindi il principe manifesta i suoi dubbi, questi vengono posti a discussioni e a consigli, e infine arriva ad una sua conclusione.

(Testo pag. 219)

Sappiamo che si è talvolta dubitato da parte degli esperti, se il nipote del patrono possa chiedere il «possesso dei beni ereditari» contro il testamento del liberto, nel caso che l'avo-patrono, compiuti i venticinque anni, abbia accusato quel liberto di un delitto capitale.

Ci è noto che Proculo, un giurista di non lieve autorità, fu di questa opinione, che al nipote non si dovesse attribuire il «possesso dei beni ereditari». Anche noi seguimmo il suo parere, quando demmo la nostra risposta scritta al «libello» di Cesidia Longina; ma anche il senatore Volusio Meciano amico nostro, interprete attento e scrupoloso del diritto civile oltre il limite di un'antica e salda esperienza, spinto dalla puntuale esattezza del nostro rescritto affermò dinanzi a noi che, secondo il suo avviso, non si doveva rispondere diversamente. Ma trattando la questione in modo più approfondito, con lo stesso Meciano e con l'intervento di altri giuristi nostri amici, ci è parso piuttosto che né la lettera né l'intenzione della legge o dell'editto pretorio escludessero il nipote dai beni del liberto «avito»; e che questa fosse l'opinione di parecchi autori, e anche di Salvio Giuliano, amico nostro e uomo di rango senatorio.

> Tracce della collaborazione dei giuristi trovano riscontro anche i documenti ufficiali; questo testo riportato da Ulpiano (*ad legem Iuliam et Papiam*) è infatti un *rescritto* (una delle costituzioni che emana il *princeps)* di Marco Aurelio e Lucio Vero, in particolare è una risposta che proviene dalla 'cancelleria imperiale' relativa a degli interrogativi di privati.

- Dato che ci troviamo sempre in campo tecnico, c'è il principe che scrive il rescritto, ma avvalendosi sempre dell'aiuto dei giuristi.

> Tratta di questioni testamentarie (diritto successorio).

> In questo caso si tratta di un patrono che ha dato la libertà al suo schiavo, ormai diventato liberto.

- Però, dopo averlo liberato, il patrono aveva accusato il liberto di un delitto capitale, quindi il rapporto tra i due era stato fortemente compromesso.
- In genere, il patrono ha la possibilità di entrare nella successione dei beni del liberto (quindi di chiedere la *Bonorum Possessio* dei beni del liberto), però se qualche patrono, come in questo caso, accusa il liberto di delitto capitale, non ci può entrare nella successione dei beni: questa ipotesi gli è preclusa.
- Subentra allora il nipote del patrono a cui è stata preclusa questa possibilità, che si domanda se avessi potuto chiedere lui la *Bonorum Possessio contra testamentum* dei beni dello schiavo liberato, in quanto non c'entrava nulla con l'accusa di delitto.

> Ulpiano (che è un giurista severiano), rimanda a quanto espresso da Proculo un giurista di non lieve autorità del I sec d.C. (c'è un dialogo senza tempo tra giuristi, una tavola rotonda senza tempo) secondo cui, nemmeno il nipote, come il patrono, può aspirare a nulla, quindi non può chiedere la *Bonorum Possessio*.

- A partire da quanto affermato da Proculo, si sviluppa un dibattito, la questione va oltre al caso stesso, in quanto vediamo che i giuristi aprono una nuova strada ad interpretazioni pure non trascurando la dottrina più antica:

> Il caso in questione era infatti oggetto di un '*libello*', cioè una richiesta scritta, da una tale *Cesinia Longina* alla cancelleria imperiale di Marco Aurelio che gli risponde in questo modo: cioè il nipote non può chiedere la *bonorum possessi*o del liberto.

- Il primo di cui si menzione il parere è Meciano (di epoca successiva a Proculo) che era un giurista molto importante e di notevole fama, che in accorso con Proculo, ne rimarca la puntualità della risposta.

- Poi però una cerchia di giuristi inizia a discutere in maniera più approfondita: e si dice che non era scritto da nessuna parte (né nella lettera né nell'intenzione della legge o dell'editto pretorio) che il nipote non potesse entrare nella *bonorum possessio* del liberto.

Viene citato Salvio Giuliano, che al contrario di quanto afferma Mescino, dice di non escludere il nipote(lo si nomina per dare maggiore autorevolezza al pensiero).

(Testo pag. 220-221)

Fabio Antonino lascia un figlio impubere, Antonino, e una figlia, Onorata. Diseredatili, istituisce erede la loro madre, Giunia Valeriana; pone a carico di quest'ultima un lascito di trecento(mila) e di varie cose a favore della figlia Onorata; esprime, infine, volontà che tutto il restante patrimonio ereditario sia trasferito al figlio Antonino, se e quando giungerà al ventesimo anno: per il caso che egli muoia prima dei vent'anni, dispone che quel patrimonio ereditario sia trasferito a Onorata. La madre muore senza testamento, lasciando i due figli, Antonino e Onorata, eredi legittimi. Muore poi il figlio Antonino che ha compiuto diciannove anni ed è entrato nei venti senza compierli, lasciando sua erede la figlia, Fabia Valeriana. Da quest'ultima, la zia paterna Onorata pretende l'adempimento del fedecommesso e la restituzione parziale dell'eredità, secondo il testamento del padre suo Fabio Antonino. Presso il tribunale del governatore della provincia, essa vince la causa. I tutori di Valeriana, la figlia di Antonino, invocano la sua indigenza, e «recitano» una costituzione di Adriano: in essa l'imperatore aveva stabilito che, quanto all'adempimento degli oneri municipali, l'anno di età, una volta iniziato, è da considerare come compiuto. L'imperatore, mosso da ragioni equitative e dalle parole del testamento «se (giungerà) al ventesimo anno», pronuncia la sentenza contro la parte attrice. E questo nonostante egli dicesse di sapere che Marco Aurelio non aveva esonerato dall'ufficio della tutela chi era solo entrato nel settantesimo anno di età. Da parte mia avanzai argomenti tratti dalla legge Elia Senzia e altri ancora.

> Questo brano è tratto dal secondo libro dei *'Libri decretorum'* di Paolo.
- Questo è uno di quei rari libri che racchiudono le costituzioni imperiali, e non si sa se sia un riassunto di un'opera più vasta di Paolo cioè '*Libri imperialium sententiarum'*.
Anche un certo 'Papiro Giusto' (giurista-funzionario) scrisse un'opera in cui sono racchiusi i rescritti di Marco Aurelio e di Lucio Vero, o del solo Marco Aurelio.

> Si tratta sempre di materia ereditaria-successoria, vi si discute di un testamento, che è al centro di una vicenda giuridica alquanto complicata:
- in un primo momento la vicenda era stata oggetto di una controversia giudiziaria presso il tribunale del governatore della provincia.
- Dopo la sentenza, la parte soccombente aveva deciso di interporre appello al principe contro la sentenza del governatore. (Ci sarà, infatti, una terza forma di processo detto cognitorio, che si rifà proprio a quella che è l'ascesa del principe e prevede la possibilità dell'appello, cioè di rivedere la sentenza di primo grado)
- La sentenza con cui si chiude il processo di seconda e ultima istanza, modifica la prima decisione in favore dell'appellante (soccombente del primo processo)

> Vediamo dunque un tale Antonino, padre di due figli: un maschio impubere Antonino e la sorella Onorata, e marito di una certa Giunia Valeriana.
> Dopo aver diseredato i figli (per questioni di validità testamentaria) pone erede la madre dei due ragazzi, Giunia, però gli attribuisce un lascito (somma di trecentomila e varie cose) a favore della figlia Onorata (fedecommesso), mentre il restante patrimonio pone che sia lasciato al figlio Antonino se e quando arriverà al ventesimo anno, qualora dovesse morire prima di arrivare al ventesimo anno, Antonino dispone che quanto gli sarebbe spettato dovesse andare alla sorella. (Quindi per quanto riguarda ciò che la madre deve fare nei confronti nel figlio è condizionato dal raggiungimento di questo del ventesimo anno di vita.)
> Però succede che la madre muore senza testamento, di conseguenza, come previsto dalla legge, subentrano come eredi i figli *ex lege* (legittimi), quindi entrambi Onorata e Antonino.
> Poi muore anche il figlio Antonino all'età di 19 anni (quindi è entrato naturalmente nei 20 senza compierli) e designa come sua erede la figlia Fabia Valeriana;
> Da quest'ultima, la zia paterna Onorata pretende l'adempimento del fedecommesso (del testamento di suo padre, nonno di Fabia) e la restituzione parziale dell'eredità, in quanto, essendo il fratello morto prima del compimento effettivo dei vent'anni, allora l'eredità spettava a lei.

- Da una parte (rappresentata da dei tutori in quanto si trovava in età impubere) abbiamo Fabia Valeriana (la figlia di Antonino, nipote di Onorata) essendo madre e fratello morti, vuole l'eredità che spettava al padre.
- Dall'altra, la zia Onorata dice che in esecuzione del testamento del nonno, le deve dare quello che le spettava

> Allora si impianta la causa, poiché ci troviamo di fronte ad una contrapposizione tra la zia e la nipote.

- Il primo processo è vinto dalla zia, che nel tribunale dei governatori della provincia, fa valere la disposizione del padre
- Successivamente 'altra parte i tutori di Valeriana 'invocano la sua indigenza' (è povera, ha bisogno); e vediamo come i tutori della bambina citino una costituzione (cioè un provvedimento normativo) di Adriano per quanto concerne la questione dell'età:
<u>*Come si interpreta la questione dei 20 anni del padre Antonino?*</u> Si dice, nella costituzione di Adriano, che l'anno di età, una volta iniziato, è da considerare come compiuto.
- Per cui l'imperatore (ci troviamo sotto Settimio Severo), mosso da ragioni equitative e dalle parole del testamento (SE giungerà al ventesimo anno), pronuncia la sentenza contro la parte attrice.

Quindi rispetto alla prima sentenza che vedeva vincitrice la zia Onorata, qui in questa seconda sede di appello, rivede quella sentenza e in virtù dell'indigenza e in virtù della interpretazione di quel limite di 20 anni (cioè andava considerata l'interpretazione 'SE giungerà al 20esimo anno'), decreta a favore della figlia Fabia Valeriana.

> Poi c'è un richiamo a tutte quelle costituzioni o quelle legge che riportano in sé il modo di interpretare i termini, e vediamo come in seduta di appello, Settimio Severo. cambia visione e si pronuncia a favore della figlia Fabia Valeriana (c'è una linea interpretativa molto diversa da quella riportata nella sentenza del tribunale dei governatori provinciali, quindi ancora una volta vediamo come l'imperatore e i giuristi si consiglino su questi argomenti).
È curioso come c'è l'intervento in prima persona di Paolo nella questione (non sappiamo se quell'intervento sia stato favorevole alla sentenza o meno), ed è curioso come i giuristi intervenissero ad aiuto di Settimo Severo, poiché da lì a poco *'essi sarebbero divenuti solo un docile strumento della volontà imperiale'*.

3. Il principe legislatore, gli editti e i senatoconsulti

Fonti di produzione normativa del periodo classico

Anche in età classica, come in età repubblicana, le fonti di produzione normativa, pur variando, rimangono molteplici.

La peculiarità di questo periodo, sta nel ruolo del principe, che non si limita ad esercitare un controllo sui modi di formazione del diritto, ma agisce come un legislatore: il sistema giuridico romano si arricchisce quindi di una nuova fonte di produzione del diritto che sono le ***costituzioni imperiali***.

> Altri organi capaci di produrre nuove norme:

- L'***interpretazione giurisprudenziale*** pur continuando a rivestire un ruolo fondamentale, va sbiadendosi.
- L'attività normativa che può essere ricondotta al ***pretore*** e ai suoi editti si arresta subito dopo la Repubblica
- Le ***assemblee popolari***, soprattutto in età augustea, continuano svolgere un'intensa attività legislativa: molti settori ricevono una minuta regolamentazione, ricordiamo ad esempio la riforma dei costumi e degli istituti familiari, ma anche l'ambito del processo pubblico o privato (es. si stabilirono limiti alle manomissioni degli schiavi, alla libertà di associarsi, si impone una tassa sull'eredità, si colpiscono il lusso, la violenza pubblica e privata, o anche la corruzione elettorale e venne inoltre disciplinata l'offesa alla maestà del popolo romano.
- Il ***senato***, quel consiglio permanente di ex magistrati nel quale si raccoglieva tutte le esperienza del ceto dirigente romano, che in età repubblicana aveva in sé tutta la politica del paese (e per questo è simbolo della *res publica* come un'istituzione che trascende i singoli governanti), attraversò fasi alterne, subendo un lento declino nel corso di tutto il regno di Augusto (fino a 238).
  E nonostante ciò, il suo ruolo rimase a lungo importante in campo religioso, diplomatico, legislativo e giudiziario; le deliberazioni del Senato si presentavano sottoforma di ***senatusconsulta***, cioè dei consigli che di fatto contenevano linee generali della politica.
  Dopo Augusto vediamo, però, l'accrescersi dei *senatoconsulti* che mutano il proprio ruolo, il che testimonia la perdita dell'autonomia del Senato:
  = Queste deliberazioni, infatti, divengono un vero e proprio condensato delle decisioni del principe, si ispirano alla sua politica, oppure risultano essere una semplice sintesi della proposta del principe stesso. Presto i *senatusconsulta* acquistarono il valore di "legge", e vede (il senatoconsulto) nella figura del magistrato la sua applicazione, il quale fornisce gli strumenti attraverso cui il principe fa ratificare il suo volere, manifestato in una ***Oratio principis;*** tant'è che l'*oratio principis* arriva a rappresentare la sostanza del senato consulto, che si accompagna ad essa come un atto formale (in effetti i due termini possono anche scambiarsi, è il caso, ad esempio, il "*Senatus consultum Orfitianum"*, indicato come "*oratio sacratissimi principis"*.
- Le ***leges***, di matrice repubblicana *(lex rogata)*, erano *"deliberazioni votate dai cittadini riuniti in assemblee popolari su proposta dei magistrati"* che avevano la facoltà di convocare e dirigere queste assemblee (*ius agendi cum populo*), in particolare i *comitia centuriata* (svolgevano attività legislativa), e poi con la *lex Hortensia* (287 a.C.) si sancirono come vincolanti per tutti i cittadini, anche le deliberazioni della plebe che venivano votate nei concilia plebis. (Quindi anche i plebisciti si ritrovano nei cataloghi normativi): A parte dall'emanazione della *Lex Hortensia* sono infatti equiparati alle *leges,* quindi tutte le deliberazioni dei *concilia plebis* su sollecitazione dei tribuni furono estesi a tutti i cittadini.

  > In generale, però, è possibile registrare uno scarso ricorso allo strumento della "legge" nell'arco cronologico tra le 12 tavole fino alla fine della Repubblica.
  Cioè lo strumento della *leges* era piuttosto sporadico perché dietro questo ricorso alla legge vi è una sorta di diffidenza verso la legge stessa, una certa parsimonia dovuta anche alla difficoltà di pubblicarle e quindi proprio era difficoltosa la loro conoscibilità per tutti.

> Una concentrazione di leggi invece, la ritroviamo in età augustea (principato) lì dove Augusto deve imporre dall'alto una guida che educhi i cittadini, soprattutto perché doveva riformare dei settori della vita privata, però, è molto raro vi è sempre una certa ritrosia; infatti, non vi sono processi codificatori del diritto poiché era ancora lontano dalla mentalità romana quello di voler circoscrivere il diritto in delle raccolte in quanto esso mutava di volta in volta.

La Legislazione imperiale: Le constitutiones

In questo quadro le costituzioni imperiali del principe, in maniera discreta efficace, iniziano ad insediarsi prendendo piede in varie forme e tipologie rifacendosi più o meno in maniera simile al modello della creazione magistratuale del diritto, differenziandosi, però, profondamente:

- Nella durata: una costituzione imperiale dura fin quando non viene abrogata espressamente, potremmo definirla e eterna.
- Nell'estensione: vale per tutti.

> Le costituzioni imperiali non rappresentano un fenomeno eversivo, ma anzi, anche la terminologia e strategica: lo scopo di Augusto era quello di porsi in continuità rispetto all'età repubblicana, e anche in questi atti vedremo chi rispetta questa volontà, almeno formale, di restaurazione.

Le ***constitutiones*** comprendono:

- *Edicta*
- *Decreta*
- *Rescripta*
- *Mandata*

> Terminologia:

Notiamo come la terminologia rievochi, rispetto all'età repubblicana, gli "*edicta*" ed "*decreta*", due atti che richiamano l'attività pretoria (i decreta erano infatti gli atti con cui il pretore poteva intervenire anche ad integrare l'editto durante l'anno in carica).
Ovviamente, però, cambiano di significato.

> Efficacia:

Si rievoca qui l'efficacia generale e particolare dell'attività normativa.
Il termine "efficacia" ci riporta subito agli "effetti", su chi ricade l' effetto di queste costituzioni:

- Efficacia generale: si intende che il loro effetto ricade su una generalità di casi, situazioni e persone.
- Efficacia particolare: si fa riferimento al caso di specie, ovvero quando gli effetti si dispiegano soltanto in relazione al caso specifico che ha sollevato l'intervento normativo del principe.

- ***Edicta***

Tra queste forme costituzionali quella che più si avvicina al modello magistratuale è l'editto, proprio in virtù delle sue prerogative che sono la *tribunicia potestas, imperium proconsulare*.

- Avevano durata eterna (fin quando non veniva espressamente abrogata)
- Si occupavano delle materie più varie; per esempio il principe con l'editto indirizza situazioni di diverso genere, dal diritto privato, al diritto penale, ordinamento giudiziario…
- Erano indirizzati a tutto l'impero comprese anche le province.
- Con riguardo agli editti imperiali si parla di efficacia generale.

(Differenza con l'editto del pretore:
Quanto al contenuto, il magistrato repubblicano regola con l'editto la sua funzione giurisdizionale, rivolgendosi in primo luogo a se stesso; il principe interviene nei campi più diversi, e indirizza direttamente ai governatori le sue norme); Inoltre la durata (ufficiale) era annuale.)

> Il discorso normativo, talvolta, si va ad intrecciare con il messaggio politico, appare quasi difficile leggere gli editti come un mero catalogo di norme, all'interno, infatti, è possibile notare che il principe non adoperava sempre lo stesso tono, ma il suo linguaggio poteva assumere toni e imperativi e persuasivi.

- Un esempio ne sono i ***Cinque editti ai Cirenei***

  Furono emanati tra il 7 ed il 4 a.C.

  E in ognuno di essi è possibile cogliere un tono diverso di Augusto.

  > La Cirenaica era una regine dell'impero (Libia orientale) che presentava delle condizioni particolari tali per cui, i sudditi iniziarono a sollecitare il principe lamentandosi per le vessazioni subite in relazione al processo, dal momento che le giurie erano presiedute da romani che evidentemente abusavano del loro potere; Per cui i sudditi cirenaici si rivolsero al principe, il quale intervenne attraverso nuove disposizioni in materia di giudizi capitali, rispetto ai quali stabilì nuovi criteri, lo stesso fece in materia di età e di censo, ed anche introdusse nuove misure procedurali per la costituzione di giurie miste.

  Altri interventi riguardano invece le prestazioni pubbliche (in questo caso vedremo l'alternarsi del tono persuasivo a quello imperativo).

  (Al governatore, il principe si rivolge nella forma del consiglio, secondo una prassi seguita nei rapporti fra Senato e i magistrati provinciali)

(Testo pag. 225) - Terzo editto

Se qualcuno nella provincia di Cirenaica ha conseguito la cittadinanza romana, io ordino (κελεύω) che non, sia meno tenuto ad adempire, per la sua parte, le prestazioni pubbliche verso la comunità dei greci. Ne sono esclusi solo coloro i quali con una legge o con un senatoconsulto (κατά δόγμα συνκλήτου), con un decreto (ἐπικρίματι) di mio padre o mio, è stata concessa l'immunità insieme con la cittadinanza; e appunto costoro, ai quali è stata concessa l'immunità ritengo opportuno (ἀρέσκει μοι) che siano immuni rispetto ai beni che avevano allora, ma che adempiano le prestazioni pubbliche riguardo a tutti i beni acquistati dopo.

- Questo è il terzo editto
- Riguarda la partecipazione dei nuovi cittadini (nuovi perché hanno avuto da poco la cittadinanza romana) alle prestazioni pubbliche (versamenti che bisogna pagare).
- Si stabiliscono quindi le modalità in base alle quali devono partecipare a queste, e Augusto decise che per il pregresso si conservava l'immunità, ma per il nuovo, quindi per quanto riguarda quello che hanno acquistato dopo l'intervento di Augusto, allora devono partecipare anche loro alle prestazioni pubbliche.
- Qui notiamo toni imperativi come *'io ordino'* e toni più persuasivi come *'è opportuno'*.

(Testo pag. 226) - Quarto editto

Qualunque controversia sorgerà nella provincia di Cirenaica fra Greci, - salvo che si tratti di cause capitali, che il governatore in carica deve esaminare e decidere personalmente o per cui deve dare un collegio di giudici, - per qualunque altra causa, dunque, sembra opportuno (ἀρέσκει) che si diano giudici greci, a meno che il convenuto o l'accusato non voglia avere come giudici dei cittadini romani. Quando saranno dati, in forza di questo mio editto, giudici greci, non sembra opportuno (οὐχ ἀρέσκει) che venga dato un giudice della stessa città da cui proviene l'attore o l'accusatore o dalla quale proviene il convenuto o l'accusato.

- Riguarda i processi, in particolare quelli civili e penali (ad eccezion dei giudizi capitali in quanto erano già stati disciplinati)
- Da qui emerge che l'atto normativo del principe deve confrontarsi con il senatoconsulto e con la legge.
- Il tono è perlopiù persuasivo ("sembra opportuno\non sembra opportuno"), anche se comunque, risponde in modo decisivo alla richiesta dei sudditi.

(Testo pag. 226) - Quinto editto

Affinché sia noto, a tutti coloro dei quali ci prendiamo cura, il senatoconsulto (δόγμα συνκλήτου) sulla sicurezza degli alleati del popolo romano, emanato alla mia presenza e con la mia partecipazione durante il consolato di Gaio Calvisio e di Lucio Passieno, ho stabilito di inviarlo nelle province e di porlo in calce al mio editto (των ἐμωοι προγράμματι), il quale renderà chiaro a tutti gli abitanti delle province quanta sollecitudine abbiamo, io e il senato, che nessuno dei nostri sudditi sopporti un'irregolarità o subisca un'ingiusta pretesa

- Qui si nota ancora meglio il rapporto tra principe e Senato, vediamo infatti un unico indirizzo politico tra i due, in quanto a seguito di reato di concussione da parte dei governatori delle province, si richiama nell'editto un senatoconsulto: Il senatoconsulto Calvisiano (che prende il nome da Gaio Calvisio).
- Atraverso l'editto, quindi, l'imperatore dimostra di abbracciare il senato consulto emanato per il reato di concussione. L'imperatore si fa portatore di un messaggio di equità, di giustizia che il senatoconsulto aveva già decretato, non stabilendo nessuna gerarchia fra l'uno all'altro.

(Per cui capiamo che il messaggio politico il discorso normativo non si separano l'uno dall'altro)

(Testo pag. 227)

> Un altro esempio di questo intreccio messaggio politico-discorso normativo, che dimostra anche che il senato e il principe andranno, almeno inizialmente, di pari passo, è il testo del senatoconsulto in onore dell'ormai defunto Germanico, figlio adottivo di Tiberio, in cui si esprime proprio la lealtà verso la dinastia.
- Risale a 25 ani più tardi rispetto agli editti ai Cirenei, e fu visibile a tutti nel 19 d.C. in Spagna.

Egualmente il senato chiede e considera giusto, perché si mostri nel modo più chiaro la gratitudine di tutti gli ordini verso la famiglia imperiale e il consenso unanime dei cittadini nell'onorare la memoria di Germanico, che i consoli rendano pubblico questo senatoconsulto accompagnandolo con un loro editto, e ordinino ai magistrati e ai legati dei municipii e delle colonie di farne delle copie e di inviarle ai municipii e alle colonie d'Italia, e alle colonie nelle province; anche quelli che governano le province agiranno correttamente e in modo opportuno, se avranno cura di far affiggere questo senatoconsulto nel luogo più frequentato .

(Testo pag. 228)

> Negli editti il discorso normativo e il messaggio politico non si separano l'uno dall'altro.
Anche il lungo editto che Marco Aurelio indirizzò agli Ateniesi era un messaggio politico.
- Qui si affrontano diverse questioni pubbliche e private, tra le quali due istituzioni locali importanti, l'areopago (antico consiglio di Atene) e il panellenio (assemblea rappresentativa delle città e degli stati greci istituita da Adriano) ricevono una nuova disciplina.
- In un punto di questo editto il sovrano manifesta, inoltre, con abile eloquenza, il suo interesse per il mondo ellenico:

Credo di aver dimostrato quanto mi prenda cura di Atene quando cercai di ricondurre il suo consiglio più eminente all'antica consuetudine, secondo la quale venivano ammessi all'areopago solo coloro che avevano superato la prova delle tre generazioni. Ma bisogna da un lato avere indulgenza e senso di umanità per quanto riguarda il passato, dall'altro gettare solide basi per il futuro. Perciò, entro questi limiti mi trovo d'accordo con gli Ateniesi e farò loro concessioni: per il passato si guarderà solo se uno ha il padre libero di nascita, e qualora risulti che uno è stato espulso dall'areopago per la norma delle 3 generazioni, sarà reintegrato nella sua carica; in seguito, sarà condizione sufficiente per l'ammissione quella di avere entrambi i genitori liberi di nascita .

- ***Mandata***

Sono istruzioni "interne" di carattere amministrativo che l'imperatore invia ai funzionari e governatori delle province, anche quelle senatorie (ecco perchè "interne"), affinché poi loro stessi ne curino l'obbedienza presso i sudditi: Notiamo il rapporto indiretto fra sudditi e principe.

- Anche i *mandata*, come gli *edicta*, hanno efficacia generale.

4. Riscritti e decreti

La passività: rescritti e decreti

È possibile rilevare come minimo comune denominatore degli atti imperiali, quindi come caratteristica del governo imperiale, la ***passività***:
Cioè il principe non interveniva normativamente per sua iniziativa, ma sempre su sollecitazione esterna; o su istanza dei sudditi o per rispondere alle domande provenienti da istituzioni imperiali (magistrati e funzionari). Il *princeps* ha, infatti, dovere regale di prestare ascolto: *"l'aver tempo e il concedere la parola sono il modo di manifestarsi del βασιλεύειν (del regnare)"*.

- Possiamo considerare radici della passività, da una parte nella tradizione aristocratico-repubblicana del patronato, e dall'altra nel modello del sovrano macedonico-ellenistico.

> Questa caratterista la si può riscontrare in maniera evidente nei *rescripta* nei *decreta*.

- ***Rescripta***

I rescritti sono dei pareri, delle risposte, che la cancelleria imperiale da a delle sollecitazioni e richieste provenenti da istanze esterne. (notiamo una certa affinità con i responsi giurisprudenziali, tanto che al tramontare della giurisprudenza classica, ne prenderanno il posto)
- Sudditi, governatori o altri funzionari avevano infatti la possibilità di rivolgere al principe dei quesiti i quali venivano raccolti da degli uffici appositi, e ai quali, appunto, il *princeps* rispondeva.
(Non dobbiamo mai dimenticare che c'è sempre una cerchia di giuristi che aiuta il principe nelle decisioni e poi controlla l'efficacia dei rimedi).

I **rescripta** si suddividono in **subscriptiones** ed **epistulae**.

1- Le ***subscriptiones***
- Sono risposte a quesiti di privati cittadini (talvolta anche di una comunità).
- Redatte dall'*ufficio a libellis* della cancelleria imperiale (perché la richiesta del cittadino avveniva su un *libello\ preces*, un piccolo scritto).
- Naturalmente, in base alla richiesta era fornita una risposta, che poteva essere o esposta al pubblico (con o senza *libellus*) o comunicata in modo privato, quindi personalmente, alla persona che l'aveva richiesta, o, in alcuni casi, l'una e l'altra cosa insieme.

2- Le ***epistulae***
- Sono risposte ad un quesito giuridico di un funzionario, di un magistrato, di una comunità o un'associazione di interlocutori qualificati (es. assemblea provinciale).
- Erano redatte dall'*ufficio ab epistulis* in forma di lettera.
- Si sollecitavano da una *relatio*, una *consultatio* o una *suggestio.*

> Un esempio di epistola ci è tramandato da Ulpiano, che riporta il rescritto di Adriano il quale risponde ad una consultazione rivoltagli dal proconsole della Betica

« Ho appreso, ottimo imperatore, nella mia inchiesta sul caso intercorso fra Claudio ed Evaristo, quanto segue. Claudio, figlio di Lupo, mentre i compagni riuniti per un banchetto si divertivano a lanciarlo in alto da una coperta tesa, fu raccolto così malamente per colpa di Mario Evaristo, che morì nello spazio di cinque giorni. Apparve chiaro che non c'era nessuna inimicizia tra Evaristo e lui. Tuttavia, io ho creduto che l'autore di un comportamento così sfrenato andasse egualmente punito, per correggere altri giovani suoi coetanei. Ho bandito, dunque, Mario Evaristo per cinque anni da Roma, dall'Italia e dalla Betica, e ho ordinato che pagasse la somma di duemila al padre di Claudio, poiché la sua povertà era manifesta ». « Giustamente, Taurino, hai commisurato la punizione di Mario Evaristo alla sua colpa: anche nei delitti più gravi, ha rilievo se l'atto è stato compiuto con intenzione o per caso ».

> Sui due uffici (*a libellis* e *ab epistulis*) ricadeva un lavoro enorme, su quello *a libellis*, Seneca, rivolgendosi al ministro Claudio affermava che *bisognasse ascoltare migliaia di uomini*, o ancora, il liberto

Polibio, affermava che *si registrasse un gran numero di domande* in quanto *gli affari provenivano da tutto il mondo e ognuno secondo il suo ordine doveva essere sottoposto all'attenzione del principe.*

> La produzione di rescritti, infatti, superato un primo secolo in cui si rivelò essere molto limitata e poco ricorrente, a partire dall'età adrianea ebbe un notevole sviluppo, e questo ramo della produzione normativa *non conobbe soste* fino all'età dioclezianea e oltre.

> Il rescritto di per sé ha una ***efficacia*** particolare perché si tratta di una questione sollevata dal singolo rispetto ad un caso di specie, di conseguenza la risposta imperativa del principe è in riferimento a quel caso particolare; Tuttavia il grado della sua efficacia può variare.
Il giurista tedesco Dieter Nörr , conducendo studi a riguardo arrivò a sostenere che per i rescritti *"il pendolo oscilla tra la lex e exemplum"*, e ciò vuol dire che:

- Come la *lex* la cui efficacia reclama, come comando statuale, una stretta obbedienza, così il rescritto ha valore imperativo con riguardo al caso specifico. (Denota un modo intensivo di esprimere la normativa)
- E ha però un'attitudine a valere come *exemplum*, ovvero ha una sua possibilità applicativa oltre il caso specifico denotando un indirizzo (quindi come esempio per situazioni analoghe) per casi simili.

> Capiamo allora che raramente i rescritti hanno una portata generale, piuttosto tendono ad acquistarla nel corso del tempo; anche se è da considerare che il valore tendenzialmente generale dei rescritti non è in armonia con il loro sistema di pubblicazione, il quale era particolarmente inadatto ad assicurarne la piena conoscibilità in tutte le zone dell'impero.

- Questo in realtà, era un problema relativo all'intera esperienza giuridica romana, il che porta ad interrogarsi anche sull'efficienza di un ordinamento giuridico, di un'amministrazione, dei meccanismi compensatori all'interno dell'ordinamento sociale che risulta essere privo della certezza del diritto. Tant'è che Nörr arriva ad affermare addirittura che il processo fosse *un gioco incerto con esito spesso minaccioso per l'esistenza*. (Questo a causa della confusione e dell'incertezza normativa, che poi si pone alla base, vedremo, della movimento codificatori)

- ***Decreta***

Nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, il *princeps* emana i *decreta*, ovvero le sentenze (del principe)

> Dobbiamo infatti tener conto che il principe e anche il *giudice supremo*, in prima ed unica istanza o in grado d'appello, in materia sia civile sia penale.

> Ed anche in questo caso interviene su sollecitazione di istanze esterne, vi si rivolgono magistrati, funzionari o anche privati.

> Capiamo quindi che i *decreta* si collocano nell'ambito di un processo vero e proprio;
> Ma bisogna precisare che il sistema processuale cambia, si afferma una nuova procedura detta *cognitoria:* si parla infatti di *cognitio straordinaria,* cioè che va oltre l'ordinario, perché c'è comunque una procedura ordinaria che sussiste, e poi interviene questa nuova procedura.

<u>*In ambito penale:*</u>

> La *giurisdizione ordinaria* era data dalle cosidette ***quaestiones perpetuae***
Che si vennero a formare nella metà del II secolo a.C. e sopravvissero fino all'età dei severi, ed erano delle corti giurate (tribunali) permanenti che si occupavano dei *crimina* penali pubblici; Ognuna di esse competeva per un singolo reato o per un gruppo di reati.

> Si affiancò, poi, accanto alle *questiones perpetuae*, la *giurisdizione straordinaria* presieduta dal principe o dai suoi funzionari più alti di grado (come il *prefetto del pretorio* che ricopre una carica amministrativo-giudiziaria molto importante in questo contesto, e anche il *prefetto urbano* e il *prefetto dei vigili*, che prendono il posto dei triumviri capitali, ed oltre ad esercitare un potere di polizia, diventarono importanti in campo giudiziario. Precisiamo che il prefetto nelle decisioni, fa sempre riferimento all'esperto: il giurista).

- Le regole di procedura cambiano, e mutano d'altra parte i criteri valutativi dei delitti e delle pene.

Durante la procedura non si fa ricorso ai giurati, come per le *quaestiones*, ma a decidere è il ***prefetto*** (con l'aiuto eventualmente del suo consiglio), aumenta infatti la discrezionalità, c'è una possibilità di modulare la pena in relazione all'accertamento dei *crimina* commessi.
- Le pene e i reati si svincolano in qualche misura dagli schemi delle leggi repubblicane, e si determinano secondo le direttive del governo centrale o lo stesso apprezzamento del giudice.
- Inoltre questa giurisdizione straordinaria, può essere vista come una giurisdizione delegata perché il principe prepone a questo compito i suoi funzionari.

> Anche il ***principe***, muovendosi *fuori dalla procedura ordinaria*, esercita in prima persona il potere giurisdizionale, accanto all'assemblea senatoria, titolare di un potere analogo nei primi anni dell'Impero. (Di solito non decide direttamente una controversia, ma lo fa incaricando un giudice, quando interviene lui, ascolta le parti o i loro avvocati, i testimoni e, prima di pronunciare la sentenza, esamina la causa con i suoi consiglieri).

In ambito civile
> La procedura formulare continua la sua strada nella sfera del diritto privato almeno fino alla prima metà del III secolo; Parallelamente, però, si sviluppano nuove regole che pian piano vanno a sostituire quelle precedenti, a cui si riconosce un carattere straordinario, ma che vanno a costituire un avere propria nuova forma procedurale: si sviluppa il ***processo cognitorio***

- Non vi è più la struttura bifasica: tutto il processo avviene dinanzi ad un solo organo giudicante
- Viene introdotta la novità dell'appello, ovverola possibilità di rivedere la sentenza di primo grado;
- Viene introdotta la possibilità della contumacia , ovvero la possibilità di procedere il processo anche in assenza di una delle parti, cioè c'è la possibilità di accertare la pretesa dell'attore anche in assenza del convenuto (per cui vediamo come la litis contestatio vada a perdere il suo valore) (a differenza del processo formulare il quale prevedeva la perdita del processo in caso dell'assenza).
- La procedura cognitoria nasce con riguardo a singole materie:
  per esempio, in relazione ai fedecommessi che trovano vincolatività processuale, prima attraverso i consoli, e poi con l'istituzione nell'età di Claudio di due *pretor fidecommissarius, (*uno dei due fu abolito pochi decenni dopo) che presiedeva una *cognitio straordinaria*; ovvero quando il fedecommesso viene riconosciuto nella sua vincolatività significa che chi onorato non dia seguito invece il beneficiario può agire presso un tribunale apposito attraverso una procedura straordinaria.
  Oppure, successivamente, ancora, vediamo come fra Marco Aurelio e i Severi, viene nominato un pretore per le controversie in materia tutelare e un altro per le cause di libertà.
  Oppure, si viene a definire la competenza dei consoli nel settore del diritto agli alimenti.

  Ciò sta proprio ad indicare come per singole materie nasce questa nuova procedura straordinaria dinanzi a delle autorità preposte.
- Possiamo riconoscere a questa procedura cognito Oria una coloritura pubblicistica, che vede, ad esempio, di fronte i privati e il fisco (come avviene per la vindicatio dei beni caduchi O vacanti che è un delatore può esperire nell'interesse del fisco o dell'erario, in base alla legislazione matrimoniale augustea.
- Sono giudici in questo campo oltre ai prefetti dell'erario, il procuratore imperiali e il pretore fiscale istituito da Nerva.

Questa parentesi al processo serve a mettere in evidenza che il *decretum* è la sentenza del principe, è la decisione che accerta una situazione della controversia sottoposta all'autorità giudicante, quindi ha un'efficacia particolare, però le sentenze possono essere esplicative di un indirizzo normativo e quindi per situazioni analoghe bisogna attendere la stessa risoluzione (acquistando così, in un qual senso, efficacia "generale").

5. Un potere nuovo?

Gli atti normativi del principe erano connotatati da passività, nel senso che questi atti derivavano sempre da una sollecitazione delle istanze esterne che appunto sono raggruppabili in relazione all'efficacia che è generale per quanto riguarda editti e mandati, ed è particolare per quanto concerne rescritti e decreti (perché disciplinano imperativamente il caso di specie, concreto e particolare che viene sottoposto all'attenzione del principe) anche se per rescritti e decreti dobbiamo considerare che allo stesso tempo manifestano una sorta di attitudine di essere estesi oltre al caso particolare, perché nelle situazioni analoghe ci si può aspettare un medesimo indirizzo da parte del principe).

> Tutti questi atti avevano la particolarità di conservare l'argomentazione\ nomenclatura repubblicana, non c'è nulla di nuovo nella terminologia:

- Gli ***editti*** ed i ***decreti*** rientravano nell'attività amministrativa del magistrato.
- In età repubblicana si ha notizia di qualche ***epistola*** attraverso cui i consoli si rivolgevano alla città.
- Lo stesso vale per i ***mandati***, seppur per una via più incerta, potremmo ricercare un precedente terminologico nelle istruzioni impartite dall'organo senatorio.

> Tuttavia l'identità dei nomi non poteva nascondere un profondo divario.

- Decreti ed epistole magistratuali, rispetto agli atti imperiali, hanno un'altra funzione, ed una portata relativa.
- I mandati sono forse quelli che più denotano l'elemento innovativo, poiché sono quanto di più adatto a rispondere all'indirizzo burocratico del nuovo ordinamento, aspetto molto lontano dalla tradizione.
Tant'è che forse è proprio per questo che la letteratura giuridica fra il II e il III secolo, in uno spirito tradizionalistico, preferisca non menzionarli accanto ad altri atti normativi del principe.
- Un discorso più ampio riguarda l'editto:
Con la magistratura pretoria l'editto assunse enorme rilievo, ma non possiamo pensare di vedere l'editto dell'imperatore come una copia di quello pretorio.
Si differenziano infatti per:
  - Durata: L'editto pretorio aveva durata annuale (ricordiamo però il discorso dell'annualità), mentre quello del *princeps* durava oltre la carica, veniva meno solo a seguito di un'abrogazione esplicita.
  - Abito applicativo: L'editto pretorio veniva applicato soltanto a Roma e sul suolo italico (dopo le riforme Sillane), mentre l'editto del *princeps* aveva validità per ogni regione dell'impero.
  - L'efficacia: L'efficacia dell'editto del *princeps* può essere universale e perpetua (eterna).
  - Contenuto: Il pretore, con l'editto regola la sua funzione giurisdizionale, rivolgendosi in primo luogo a se stesso, mentre il principe interviene in campi diversi indirizzando direttamente governati le sue norme.

Su quale fondamento costituzionale il principe agisce come legislatore?

Abbiamo visto che questo "potere nuovo" del princeps che si affianca ai poteri preesistenti.
> La giustificazione\ la legittimazione, fondamento costituzionale del potere di legiferare su cosa si basa?
- Da un lato, quando il princeps, nel suo modo di dettare la norma, "consiglia" si può revocare la figura dell'*auctoritas* nel suo significato di preminenza assoluta (che si affianca all'*auctoritas* giurisprudenziale che ha come funzione quella di condizionare le sentenze dei giudici).
In effetti questa è una caratteristica che il principe si fa attribuire e che ha una funzione similare alla funzione del senato di emanare norme;
- Tuttavia non sarebbe corretto pensare che quando il principe si esprime sottoforma di legge, nel senso imperativo (rivolgendosi ad esempio a legati, procuratori o ai sudditi attraverso un editto) si ravvisa una ***potestà*** nuova e straordinaria rispetto alle qualificazioni repubblicane (qualificazioni che erano state strumentalizzate dallo stesso principe proprio per non far apparire questo suo potere come nuovo e straordinario).
> Questa potestà nuova non è sempre riconducibile all'*auctoritas*, ma va ricondotta al concetto di *imperium* inteso in senso unitario, svincolato dalle qualifiche magistratuali.

> Un documento significativo a riguardo è la ***Lex de imperio Vespasiani***.
Una tavola di bronzo che ne riportava inciso il testo fu ritrovata nel 1347 da Cola di Rienzo ed ora esposta nella chiesa di S. Giovanni in Laterano.

- La *Lex de imperio* nel contesto del principato, si configura come la legge di investitura con cui senato e popolo conferivano potere al principe

- Con il ritrovamento della Lex de imperio Vespasiani, che non è importante perché riguarda Vespasiano, ma anche (e soprattutto) per il pregresso, ci consente, infatti, di desumere i meccanismi che sottostanno a questa attribuzione dei poteri.
È quindi una "legge di investitura" (che peraltro rievoca ciò che accadeva nei *comitia curiata* quando si faceva l'investitura della *res,* e da qui ravvisiamo che nessun concetto, parola o gesto sono del tutto nuovi ma vengono richiamati e innovati con accezioni differenti).
- Nella *lex de imperio* si legge una ratifica "a posteriori" dell'operato del principe (scritta da parte del senato e del popolo), cioè, tutto ciò che il principe aveva fatto, decretato ordinato prima dell'investitura, veniva ratificato come se il principe avesse compiuto ogni atto in nome del senato e del popolo.
- Vi si aggiunge inoltre la cosiddetta "clausola discrezionale": che è una clausola nella quale si attribuisce al principe la facoltà di intervenire normativamente come meglio creda nell'interesse e per la maestà dello stato, ovvero per il bene pubblico.

> Risulta chiaro come una formulazione di questo tipo che non solo ratifica l'operato del principe già compiuto in precedenza, ma si aggiunge questa clausola in cui si riconosce questo potere al principe che ha agito, agisce e agirà per il bene comune.

> Questo è un aspetto importante per capire ***in che misura il principe, investito di un potere normativo, risulta essere sottoposto alla legge***, e proprio dalla clausola discrezionale emerge un'interpretazione autocratica, si sta infatti affermando che il principe è legibus solutus, cioè "sciolto dalle leggi", perché proprio nell'ottica in cui deve agire nel bene collettivo, egli stesso è sciolto dal vincolo del rispetto delle leggi che egli stesso pone: Lui è al di sopra delle leggi che emana.
Il fatto che sia sciolto dalla legge consente al principe di trasgredire legittimamente alle sue leggi, che per altro poteva rivedere in ogni momento, in quanto ogni sua decisione e azione era giustificata per essere fatta nel rispetto dell'interesse della popolazione.

6. Normativa imperiale e giurisprudenza

Attraverso l'attività normativa imperiale si da un nuovo impulso alla formazione del diritto.

Il principe alla luce non solo della discrezionalità, ma anche della sua libertà negli interventi normativi, spesso si ispira criteri direttivi vari; dei valori come, ad esempio: *benignitas, benevolentia, humanitas, philantropia, clementia, pietas, eusebeia, favor, aequitas, iustitia, lenita, diligentia...*

Questi criteri\ valori venivano richiamati in modi differenti chiaramente *a volte* anche con un effetto di grande innovazione rispetto a delle discipline preesistenti (che erano rigorose), *a volte* in maniera propagandistica ed opportunistica.

> Con l'impiego tecnico di questi principi si superano delle regole tradizionali e l'ordinamento si evolve.

Esempi:

- *Età degli Antonini è particolarmente segnata dall'utilizzo di questi valori:*
  > Marco Aurelio (imperatore-filosofo, ultimo degli antonini), infatti, coltivò ed incarnò determinati ideali che diventano particolarmente rilevanti.

  (Testo pag. 238)

  Quella stessa relazione che vi è, in organismi individuali, tra le membra del corpo sussiste, in essere tra loro separati, tra le intelligenze razionali, fatte per cooperare a un'unica azione comune.
  Potrai cogliere meglio questo concetto, se ripeterai sovente a te stesso: "sono un membro (μελος) dell'insieme formato dalle intelligenze razionali". Ma se dirai semplicemente con la lettera ρ, di esserne una parte (μερος), allora vorrà dire che non ami ancora gli uomini dal profondo del cuore, che il fare del bene non ti da una gioia di cui comprendi la vera natura; tu lo fai come un semplice dovere, non ancora con la convinzione che, in tal modo, fai del bene anche a te stesso.

  - Questo è un passo tratto dai "*Pensieri*" (7,13), scritto da lui stesso, in cui riflette riguardo all' amore verso il prossimo che si fa espressione di una convinzione profonda\ teoria che vede ognuno essere parte di un "*tutto*" che collabora ad un'azione comune.

  Questi ideali venivano applicati dunque in modo tecnico, e si traducevano in interventi normativi (oppure diventavano oggetto dei discorsi giurisprudenziali).

  Il pensiero di Marco Aurelio sull'amore verso il prossimo, ad esempio, può essere riconosciuto nella sua legislazione nel momento in cui si occupa della violenza:

  (Testo pag. 239)

  (Dal *de cognitionibus* di Callistrato:)

  Esiste un decreto del divino Marco, nel quale si leggono queste parole: «È cosa ottima che tu, se pensi di avere delle pretese, esperisca le azioni giudiziarie». Poiché Marciano osservò: «Non ho fatto alcuna violenza», Cesare disse: «Credi che la violenza stia solo nel ferire degli uomini? Violenza si ha ogni volta che qualcuno cerchi di ottenere, senza ricorrere al giudice, ciò che afferma gli sia dovuto. Pertanto, chiunque possiede in modo temerario o ha ricevuto qualche cosa del debitore, o qualche somma di danaro che gli era dovuta, senza che il debitore gliela abbia consegnata spontaneamente e senza essere ricorso a un giudice, non sarà più titolare del diritto di credito;quando,beninteso,mi sarà data la prova che,per ottenere tutto questo, egli si è tatto giustizia da sé»

Quindi vediamo come sia possibile rintracciare il motivo dell'amore verso il prossimo in ciò che Marco Aurelio stabilì sulla violenza, che inizia ad essere combattuta anche nella forma dell'autodifesa privata: in quanto stabilì che nel momento in cui, ad esempio, un creditore si ritrovi a possedere qualcosa che gli era dovuta dal debitore, ma né il debitore l'aveva consegnata spontaneamente, né era stata ottenuta ricorrendo ad un'azione processuale, allora il creditore che "si è fatto giustizia da sé" non era più ritenuto titolare del diritto di credito.

• *Anche prima dell'età degli Antonini, si travisano degli interventi simili, da parte di altri principi che richiamano determinati criteri:*

> Di Augusto vengono infatti sottolineate la sua *lenitas* (mitezza) e *diligentia* nelle decisioni, si dice di lui che *"Egli sapeva essere generoso nel momento opportuno"*.

> Di Claudio si dice che facesse prevalere il *bonum et aequum* sul rigore o l'indulgenza eccessiva delle leggi.

> Traiano: viene invece definito *optimus princeps* che facendosi ispirare da questi ideali, contrassegnò la sua età di un senso estremo di giustizia.
- Lo si vede, ad esempio, nel fatto che non vuole mandare un vantaggioso provvedimento in materia finanziaria, suggerito da Plinio, che sarebbe andato a danneggiare i decurioni della Bitinia.
- Oppure, è possibile cogliere una sua certa *clementia* nel momento in cui decise l'abolizione della confisca dei beni, che, secondo un'antica prassi accompagnava la condanna alla relegazione.

> Adriano, in linea con il pensiero di Marco Aurelio sull'amore per il prossimo (*philanropia*), pone questo principio a giustificare una norma relativa ai figli dei soldati, che, dato il divieto (per i soldati) di contrarre matrimonio (vigente al suo tempo), e quindi necessariamente figli illegittimi, stabilì che sarebbero potuti succedere come *bonorum possessores* (possessori dei beni ereditari).

Talvolta, però, il richiamo a questi valori non è riflesso di una filosofia o comunque non è sorretto da un'autentica convinzione, motivo per cui si incorre da una parte nel rischio di scambiare la retorica governativa con la realtà dei comportamenti pratici, dall'altra il rischio di attribuire alle parole un significato diverso da quello che esse realmente hanno.

Sono molti, infatti, gli esempi in cui il moralismo che emerge nell'utilizzo di questi valori si traduce in opportunismo imperiale:

> Un esempio ne è Traiano
Questo imperatore assunse un atteggiamento particolarmente strano ed incoerente nei confronti dei cristiani (visti come eretici) da un lato ordinò di punirli ove manifestamente colpevoli di eresia, d'altro lato, però, non si preoccupò più di tanto di andare a ricercarli o di accogliere le denunce di altri contro i cristiani.

> Un altro esempio è l'utilizzo del principio dell'***humanitas***
L'*humanitas* viene richiamata sotto varie sfaccettature:

- Possiamo citare ad esempio un rescritto di Marco Aurelio sulla libertà fedecommissaria concessa al servo-amministratore in quanto riteneva che fosse più equo liberarlo subito, e *non umano* indugiare per attendere il controllo patrimoniale sulla sua gestione;
  Quindi vediamo come venga richiamata l'*humanitas* per favorire un trattamento più benevolo nei confronti delle manomissioni di schiavi, tant'è che vi è tutto un orientamento che ravvisa da un certo momento in avanti una maturazione del *favor libertatis,* ovvero di un favore maggiore nella concessione della libertà degli schiavi in determinate situazioni. (e questo è un altro esempio di come questi principi entrino nel discorso tecnico-giuridico innovando l'ordinamento)

- Nel richiamo all'*humanitas* è anche possibile cogliere un esempio di come, a volte, vi fosse un'ambivalenza tra convinzione e moralismo:
  (Testo pag. 240)
  Saggiamente e con grande senso di umanità, dilettissimo Sassa, condannasti alla tortura lo schiavo Primitivo, che era sospettato di fingersi colpevole di omicidio solo per il terrore di ritornare dal suo padrone, e che perseverava nel dichiarare il falso. Il tuo scopo era di indagare sui complici che egli, sempre falsamente. aveva detto di avere, e raggiungere così una confessione più credibile su di lui. La tua saggia decisione non è stata vana, perché nella tortura è stato accertato che egli non ebbe quei complici e che mentì sconsideratamente sul proprio conto. Puoi quindi condonargli la pena che gli è stata inflitta con la sentenza precedente e ordinare che sia venduto per mezzo dei pubblici ufficiali, con la clausola che non torni mai più nel potere del suo padrone; il quale, ne siamo certi, si priverà volentieri di uno schiavo simile ricevendone il prezzo

Dalle parole della lettera di Marco Aurelio diretta al proconsole (dell'Africa) Vocino Sassa, abbiamo l'opportunità di notare un modo insolito di richiamare il principio di umanità in relazione alla tortura, in quanto, anziché scalfirlo come ci si aspetterebbe, viene invocata paradossalmente per giustificarlo.

La tortura, in generale, veniva utilizzata come strumento probatorio per estorcere delle confessioni a schiavi che si pensava fossero stati testimoni di certi *crimina*.

E qui, vediamo che la tortura viene adoperata per disvelare non una colpevolezza ma la finzione della colpevolezza: lo schiavo viene torturato per riuscire ad estorcergli la verità rispetto al fatto che lui si autoproclamasse colpevole al fine di sfuggire ad un padrone da cui era terrorizzato.

A seguito della tortura, in effetti, si ottenne la verità, e lo schiavo non solo viene scagionato e liberato dalla pena a cui era stato condannato per essersi dichiarato colpevole, ma vi si aggiunge una clausola che prevedeva che lo schiavo non tornasse più nel potere del suo (ex)padrone.

La contraddizione sta proprio in questo:

Il senso di umanità stava nell'aver condannato alla tortura lo schiavo per estorcergli una verità che lo scagionasse dal padrone.

> *Aequitas*

> Riguardo al principio dell'*aequitas*, è significativo un intervento di Antonino Pio, su cui ci informa Marcello nei suoi Digesta, con riguardo all'assenza in un processo di una delle parti.

(Testo pag. 241)

Sebbene delle cose che hanno una loro solennità, non si debba mai mutare nulla in modo facile, tuttavia, là dove lo reclami un'equità evidente, è doveroso che si ponga rimedio.

Così, quando in un procedimento giurisdizionale, chi è stato chiamato dal pretore non ha risposto, la norma è che si abbia una pronuncia contro di lui; ma se il chiamato compare poi subito davanti al tribunale, dove tu siedi, si può presumere che egli non si sia presentato prima non per colpa sua, ma perché non ha udito la voce dell'araldo.È possibile, quindi,reintegrarlo nella situazione giuridica primitiva.

- Vediamo come il richiamo all'*aequitas* viene utilizzato per giustificare il mutamento di alcuni schemi rigorosi e solenni che fino ad allora venivano utilizzati.

Infatti, nell'ambito del processo formulare, il fatto che il convenuto non si presentasse in sede processuale nonostante una regolare convocazione, comportata la sconfitta.

Si interviene proprio su questo, si racconta un caso in cui il convenuto, non avendo ricevuto correttamente la comunicazione dell'araldo (l'annuncio dell'araldo era un modo per convocare le parti in processo), si era diretto dinanzi al tribunale "all'ultimo minuto" solo subito dopo esserne venuto a conoscenza.

Antonino Pio dunque intervenne invitando il pretore a concedere una *in integrum restitutio, ovvero la reintegra del convenuto* nella situazione giuridica in cui quale era stato convocato.

Ciò è una novità assoluta rispetto al pregresso.

- Qui vediamo che l'aequitas imperiale andava ad affermarsi aggirando quasi la disciplina esistente.

> Alcune, il principio nuovo viene drasticamente affermato nonostante le voci contrarie.

Un esempio è riportato da Ulpiano, e riguarda il settore dei rapporti familiari:

(Testo pag. 242)

Il proconsole non dovrà avere alcun dubbio sul punto, se anche il figlio possa essere nominato curatore del proprio padre. In Celso , e in molti altri, si registra un'opposizione, quasi sia disonorevole che il padre abbia una guida nel figlio; ma il divino Antonino Pio in un rescritto a Insteio Celere, e i divini imperatori fratelli, stabilirono che il figlio, se vive sobriamente, e non un estraneo, deve essere dato al padre come curatore.

- Qui vediamo come la voce dell'imperatore, sovrasti l'opinione dei giuristi.

> Ovviamente, non sempre le città imperiale era in contrasto con la coerenza dell'ordinamento, poteva infatti anche contribuire a ristabilirla.
- Ad esempio, Gaio, nota che, in una costituzione di Adriano, l'imperatore mosso non solo dalla *iniquitas rei* ma anche dalla *inelegantia iuris*, *"richiamò in vigore la regola del diritto dei popoli, secondo cui una donna, finché rimane libera, genera uomini liberi"*.

Rapporto tra attività normativa imperiale e giruisprudenza

(Testo pag. 246)

Un mezzo protettivo di questo genere non opera solo in un caso come questo. È necessario tutelare coloro che, senza loro colpa, sono tratti in inganno, soprattutto se l'avversario ha agito con frode, e anche quando spetti normalmente l'azione per il dolo. È caratteristico di un pretore avveduto ristabilire di nuovo la controversia, così come suggeriscono la «ragione» e l'«equità», piuttosto che dar luogo a un'azione giudiziaria infamante, alla quale si deve ricorrere solo quando non può esservi altro rimedio

In questo passo, Marcello prosegue sul ragionamento avviato da Antonino Pio che in nome dell'*aequitas* aveva chiesto che il convenuto arrivato in ritardo al processo a causa di una comunicazione arrivata in modo non corretto. Marcello ne amplia la portata su un piano interpretativo, e lo estende ad altre ipotesi.
- Partendo infatti dalla considerazione di *aequitas*, Marcello va oltre, e afferma che ci sono anche altre situazioni che possono andare a giustificare la propria mancata comparsa in tribunale.
Per cui è possibile reintegrare il soggetto convenuto in processo anche quando tratto in inganno, soprattutto se l'altra parte ha appositamente agito con frode per vincere più facilmente la causa.

> Questo ragionamento fatto da Marcello fa anche capire come <u>la giurisprudenza abbia una relazione strettissima con la normativa imperiale</u>.
- Innanzitutto abbiamo visto (in un'ottica pratica) che i giuristi ricoprivano un ruolo estremamente importante all'interno del consiglio, in quanto erano in grado di influire, la maggior parte delle volte, sulle singole decisioni, favorendole o contrastandole.
- Ma questo non era l'unico ruolo, la giurisprudenza e anche, soprattutto, un'impresa scientifica che si esprime in un corpo di dottrine in una letteratura, e principe legislatore i suoi funzionari ed i suoi consiglieri non possono non tenerne conto.

> Niente impedisce però che si percorrano nuove strade, ma, a volte, si tratta solo di ribadire un indirizzo giurisprudenziale già affermato o di scegliere fra indirizzi contrastanti.
È la giurisprudenza che offre alla normativa imperiale un ventaglio di soluzioni possibili.

- Vi sono due testimonianze in materia successoria:

1- (Testo pag. 243)

I giuristi dissentono su questo punto: Sabino e Cassio, e gli altri maestri della scuola sabiniana, pensano che l'oggetto di un legato vindicatorio divenga subito del legatario, dopo che è stata adita l'eredità, anche se egli ignori l'esistenza del legato; ma quando ne abbia avuto notizia, e lo abbia respinto, è come se il legato non fosse mai stato disposto.
Nerva e Proculo, invece, e gli altri esponenti della scuola, pensano che la cosa legata non sia del legatario se non nel momento in cui egli voglia acquistarla.
Ma oggi, dopo una costituzione di Antonino Pio, si applica piuttosto il regime giuridico di cui fu sostenitore Proculo. A una colonia, infatti, era stato legato un Latino, e la disposizione aveva efficacia reale: «i decurioni deliberino», dispose il principe, «se vogliono acquistarlo, come se il legato si indirizzasse a un'unica persona»

- Vediamo l'imperatore emanare una costituzione che propende per una parte piuttosto che per l'altra: fa una scelta.

2- (Testo pag. 243 - 244)

Se il testatore ha legato una cosa sua e poi l'ha trasferita ad altri, Celso è del parere che la cosa sia egualmente dovuta, sempre che la vendita non celi l'intenzione di revocare il legato.
Nello stesso senso si pronunciarono, in un rescritto, Settimio Severo e Antonino.
Essi stabilirono anche che il testatore il quale, dopo aver disposto il testamento, diede in pegno i fondi che erano stati legati, non sembra manifestare così una volontà di revoca; e perciò il legatario può agire contro l'erede, perché i fondi siano liberati dal vincolo.

- Vediamo l'imperatore emanare una costituzione in linea con il parere giurisprudenziale.

> Capiamo quindi che giurisprudenza e legislazione, nel loro legame strettissimo, sono in dialogo permanente, sia perché l'imperatore deve tener conto delle soluzioni offerte dal letteratura giurisprudenziale, ma anche perché le norme imperiali, una volta emanate, sono ancora sottoposte ad un esame critico. (In maniera quasi analoga a quanto era accaduto con l'editto pretorio nell'età della Repubblica o nei primi decenni del principato).

(Testo pag. 244)

- Un primo esempio è costituito da questo frammento di Gaio.

> *Per i fedecommessi, sono dovuti gli interessi e i frutti, sempre che l'onerato sia in mora.*
> *Al contrario, nei legati gli interessi non sono dovuti. Così si esprime un rescritto del divino Adriano.*
> *Ma io so che, secondo Giuliano, lo stesso regime giuridico dei fedecommessi si applica nel legato permissivo; e questa opinione prevale ancora oggi*

(Testo pag. 245)

- Questo non è un caso isolato, anche in ambito criminalistico, in cui l'opera riformatrice è molto più intensa, si nota un andamento simile.

Un ulteriore esempio si ritrova nell'ottavo libro delle *Disputationes* ulpianee, nel momento in cui si commenta la legge Giulia sul processo pubblico.
Ulpiano limita o "corregge" un precetto governativo sulla legittimazione all'accusa (che forse egli steso aveva contribuito a formulare in qualità di alto funzionario di Settimio Severo.

> *Chi è imputato di un reato deve discolparsi, né può accusare prima di essere stato prosciolto: nelle costituzioni, infatti, si precisa che l'imputato si discolpa non col giustificare la propria azione e accusando a sua volta, ma dimostrando la propria innocenza.*
> *Rimane però incerto, se può accusare solo l'imputato che sia stato prosciolto, o anche il reo che abbia subito (e scontato) la pena: la ragione del dubbio è in ciò, che il nostro imperatore Caracalla e il divino padre suo stabilirono che, dopo una condanna, non è possibile dare inizio a un'accusa. Ma io penso che queste parole si riferiscano solo a coloro che abbiano perduto o la cittadinanza o la libertà. E ovvio, d'altra parte, che essi possano completare, anche dopo la condanna, le «delazioni» iniziate prima.*

> Può, inoltre, accadere che l'introduzione di un principio nuovo per mezzo di un atto normativo imperiale vada a cambiare radicalmente il corso delle cose, e ad indurre la giurisprudenza ad abbandonare un punto di vista sostenuto nel passato.
- A tal proposito è esemplificativa la vicenda del fedecommesso di emancipazione; secondo il parere comune dei giuristi, infatti, nessuno poteva imporre il padre di emancipare i figli.
La potestà paterna si sottraeva all'intervento di estranei e non era economicamente valutabile.
Tuttavia in un caso particolare, Settimio Severo riconobbe l'obbligo del padre fedecommissario di eseguire il fedecommesso emancipando i figli, e da allora il fedecommesso di emancipazione ebbe il suo posto fra gli istituti del diritto ereditario romano. Si discusse solo intorno al suo ambito applicativo.

- E abbiamo visto, come accaduto per il rescritto di Antonino Pio, che talvolta la giurisprudenza può intervenire per ampliarne la portata attraverso delle interpretazioni *(vedi testo pag. 246)*

> La normativa imperiale ha la caratterista di essere episodica, quindi è un procedere che è episodico nonostante il suo essere duratura, non è unitario, ma è la giurisprudenza ad avere una funzione unificatrice - Essa ristabilisce di volta in volta l'equilibrio formale dell'ordinamento, sottolineando da una parte la forza innovatrice di atti imperiali che si ispirano a quei valori e dall'altro cogliere le ragioni interne ovvero da cosa sia scaturito quel determinato intervento.
> E la giurisprudenza, in quanto scienza, custodisce una *ratio* più profonda da cui dipende l'unità e la continuità del diritto.

Capitolo nono: L'amministrazione pubblica, l'insegnamento, le scuole

1. Immensum corpus imperii

2. Carriere

3. Maestri e allievi

Durante il periodo del principato i giuristi, oltre a alla produzione letteraria giurisprudenziale, si occuparono in modo particolare anche alla pratica dell'insegnamento, e questo fu possibile perché il giurista in età classica è più svincolato può decidere se affiancare il princeps nella sua politica o anche se discostarsene completamente.
Quindi si sviluppa in modo più ampio la figura del giurista-insegnante, il quale decideva di dedicarsi solamente all'insegnamento, di non accettare nessun incarico politico, tanto che la loro produzione letteraria andò ad orientarsi rispetto a tale scelta: è il caso di Masurio Sabino, Gaio, Fiorentino o Marciano; Scrissero dei manuali istituzionali che furono frutto di una didattica di primo incontro con i giovani studiosi del diritto, e non ricoprirono cariche pubbliche, il loro impegno come consulenti nel *consilium principis* può considerarsi relativo o, eventualmente, mancare del tutto.

> ***Labeone*** è, in quest'ambito, una delle figure principali ed emblematiche.
Seppur non impersoni ancora pienamente la figura del giurista-accademico, si fa testimone di quel cambiamento che il giurista ha nel corso del tempo in relazione alla sua autonomia dal potere politico.
Egli stesso trascorreva ben sei mesi dell'anno dedicandosi all'insegnamento a Roma (gli altri sei si ritirava in campagna per studiare e scrivere libri).
Labeone nell'affrontare l'esame dei singoli casi concreti, si apriva all'indagine dei principi sottostanti; nutriva, infatti, particolari interessi antiquari e grammatici, che nelle sue opere si ravvisano molto spesso, arricchiva così lo studio: continui richiami alla grammatica e all'antiquaria, pur senza perdere il nesso strettissimo fra teoria e pratica (alla maniera dei grandi maestri repubblicani)
- Questa capacità di tener stretto il nesso pratico-teorico affascinò anche giuristi successivi come Nerva, Cassio Longino o Aristone.

> Diversamente dall'<u>insegnamento repubblicano</u> che proponeva una cerchia di *auditores* che ascoltavano solamente il maestro, <u>nel principato</u> ritroviamo una divisione in scuole.

(È Pomponio nell'Enchiridion (storia dei giuristi e della giurisprudenza) a fornircene le notizie principali)

Sappiamo, che si sviluppò, un duplice orientamento scolastico, una sorta di divisione in filoni contrastanti (si parla di *sectae* dal verbo *secare: "*tagliare\ dividere").

E proprio durante il principato, si vengono a formare le *scolae* giuridiche come vere e proprie istituzioni stabili (o che tendono a diventarlo), cioè i vari giuristi si affiliavano ad un filone di orientamento di pensiero, che si identifica con un metodo dato dai capi scuola. Distinguiamo:

- *Sabiniani* (o *sabiniani-cassiani)* (Masurio Sabino e Cassio Longino: capiscuola del filone sabiniano)
- *Proculiani* (Proculo e Cocceio Nerva: capiscuola del filone proculiano)

> Pomponio fa risalire questo duplice orientamento scolastico a degli antenati, ovvero lo aggancia alla contrapposizione fra Antistio Labeone e Ateio Capitone (appartenuti alla generazione appena precedente).
- Capitone viene posto all'origine del filone dei sabiniani.
- Labeone viene riconosciuto come il vero antesignano dei proculiani.

E questo modo di narrare la storia dei giuristi da parte di Pomponio ha dato poi adito ad una chiave di lettura di tipo politica a questa contrapposizione:
Il fatto che Labeone avesse ispirato il filone proculiano e Capitone quello sabiniano, sarebbe dovuto ad un atteggiamento nei confronti del potere:
- Labeone era infatti polemico dei confronti del potere del principe;
- Capitone al contrario, lo appoggiava.
Queste letture sono troppo riduttive e nessuna chiave di lettura ci dà l'idea della complessità di questo fenomeno culturale delle scuole.
(In generale la contrapposizione fra due orientamenti non è proprio così netta, si tratta di centri di discussione che, pure avendo spirito corporativo, in alcuni casi convengono pienamente)

Sabino

Lo abbiamo incontrato nella tradizione civilistica perché autore dei Libri tres iuris civilis (tre libri di diritto civile che si rifanno a Quinto Mucio Scevola).

- Nonostante i ***dati biografici*** poco reperibili, possiamo affermare che sia stato un giurista particolarmente longevo, la sua data di nascita si colloca infatti attorno al 15 a.C e sicuramente visse per 80 anni circa, in quanto arrivò occuparsi del senatoconsulto Neroniano (la cui datazione oscilla fra il 55-65 d.C.) quindi possiamo immaginare che visse almeno fino a quella data.

- Possiamo quindi immaginare, in base al contesto in cui gli storici sono riuscito a collocarlo, quali fossero i suoi ***rapporti culturali***: ebbe modo di conoscere l'anziano Trebazio Testa (uomo che era vissuto i tempi della Repubblica ed era stato amico di Cicerone), così come fu contemporaneo di Seneca (il filosofo), conobbe Labeone, Livio, Ovidio (prima che fosse esiliato da Roma), Seneca (il retore) e Filone di Alessandria. e visse sotto le leggi di Tiberio da cui ebbe lo *ius respondendi*.

- Non fu molto benestante, probabilmente fu proprio di bassi natali, aveva, cioè, origini umili (probabilmente apparteneva ad una famiglia veronese di decurioni, quindi, seppur il suo patrimonio non fosse proprio così limitato, a confronto con gli abitanti della capitale, nettamente più benestanti, doveva sembrarlo), tra l'altro si narra che sul piano economico fosse aiutato dai suoi allievi.
Entrò, poi, nel ceto equestre solo verso i 50anni, il che significa che solo allora poté avere un censo tale da poter accedervi.

- In effetti, Tacito nei suoi Annali, quando parla di uomini e famiglie importanti non ricorda né Sabino, né Proculo (ragion per cui si pensa che anche lui non fosse molto benestante nonostante il suo peso politico) (Cassio Longino che riconosceva in Sabino il suo maestro, invece, apparteneva ad un rango superiore).
- Al contrario di Tacito, Pomponio dà rilevanza sia a Sabino, sia a Proculo nel suo Enchiridion, includendoli proprio fra gli "uomini grandissimi" accanto ai giuristi della Repubblica e ai più eminenti giuristi imperiali.

L***'opera*** più importante a cui si lega maggiormente la fama di Sabino e il suo trattato di diritto civile, appunto i *Libri tres iuris civilis*; scrisse, inoltre, forse, anche una piccola raccolta di libri edittali e poi alcune opere giuridico-antiquarie come *Memoralia*, i *Fasti*, i *Commentarii de indigenis* (che illustrano cerimonie, consuetudini, collegi sacerdotali e trionfi militari). Queste sono tipologie letterarie che si spiegano e si collocano perfettamente in quel contesto di rinascita e restaurazione religiosa che si svolse fra Augusto e Tiberio).

> I libri più importanti sono i ***Libri tres iuris civilis***, detti anche "sistema civilistico" di Sabino.

Per quel che si può ricostruire, si può ravvisare un impianto sistematico (sicuramente la *diaresis* ha avuto il suo sviluppo e l'abbiamo vista espressa per singoli argomenti e nell'impianto complessivo dell'opera).

> Alcuni studiosi hanno cercato di capire quale fosse l'organizzazione interna dell'opera tra cui:

Fritz Schulz

Distinse 4 grandi settori:

1- Diritto ereditario (testamenti e legati)

2- Diritto delle persone

3- Diritto delle obbligazioni

4- Diritto delle cose

> Tuttavia Schulz ravvisandone un impianto sistematico, ne fa una distinzione troppo modernistica.
L'ordine delle materie era infatti molto più libero e si contrapponeva non solo alla dogmatica moderna, ma anche all'organizzazione gaiana delle Institutiones.

> Un’altro studioso, *Burkard Wilhelm Leist* pare abbia seguito la giusta strada:

Leist

Riteneva che vi si potessero ravvisare 6 parti.

1- *de testamentis , de legatis*

2- *tradizione* (o mancipatio)

3- *matrimonio e dote, tutela*

4- *furtum*

5- *condictiones, stipulationes*

6- *rei vindicatio o de iurisdictione*

Arangio-Ruiz

Fu Arangio-Ruiz ad occuparsi del metodo:

“ Partito dalla forma dei testamenti e dall’istituzione di erede, Sabino era passato ai legati, e di qui alla manumissio testamento , cui aveva riattaccato alcuni principii fondamentali sulle persone alieni iuris , ma fermandosi poi a lungo sugli statuliberi . E poiché dopo l’istituzione di erede, i legati, le manumissioni di schiavi, le tavole testamentarie contenevano la menzione della mancipatio familiae necessaria alla celebrazione del testamento civile, era stata questa a fornire a Sabino il chiodo a cui appendere una trattazione generale della mancipatio; essendo poi la mancipatio, come scrive Gaio, una imaginaria venditio , l’autore le ha fatto seguire un excursus relativamente breve, sulla emptio venditio consensuale . Ed è la mancipatio ancora una volta che ha richiamato quell’altro atto solenne di trasferimento delle cose e dei diritti che è l’ in iure cessio : poiché con una speciale applicazione di quest’ultima si costituiva in origine fra estranei il consorzio e rcto non cito , ciò ha attirato nell’orbita della materia dei testamenti perfino la società. Procedimento guidato più da associazioni di idee che da deduzioni logiche, ma singolarmente profittevole ai fini di una relativa completezza .”

- Analizzando il procedimento utilizzato nella composizione e nella sequenza degli argomenti all'interno dell’opera, e ravvisò un procedimento guidato più da associazioni di idee che da deduzione logiche, il quale si presentava profittevole ai fini di una relativa completezza.
(= i nessi logici sono associazioni mnemoniche che portano ad una relativa completezza.)

I *Libri tres iuris civilis*, insieme ad un'altra opera con lo stesso titolo, ma molto più ampia (si sviluppava almeno in 10 libri, redatta da Cassio*, divennero i testi base della scuola sabinana-cassiana

*Si tratta dei libri iuris civilis, i quali, come l'opera di Sabino, iniziavano dai testamenti e delegati, tuttavia non si può dire se e in quale misura si allontanassero punto di vista sistematico

- Questo trattato Sabiniano insieme a quello Cassiano non rappresentavano un’opera di tipo elementare\ di primo approccio, prima di studiarle si presentava l’esigenza di una didattica più semplice e orientativa, che fornisce delle conoscenze basilari, la quale si troverà solo più tardi, nelle *Institutiones* di ***Gaio***

(Gaio - Institutiones)

> Anche Gaio è inserito nella tradizione civilistica perché scrive, appunto, le *Istitutiones*, le quali trattano di diritto civile e fondamento primo del diritto privato.

- Gaio si ritiene un sabiniano-cassiano e lo dice spesso nella sua opera.
- In Gaio si ravvisa molto questo impianto sistematico-diairetico.

(Testo pag. 261-262)

Tutto il diritto di cui ci serviamo, riguarda o le persone o le cose o le azioni.
In primo luogo occupiamoci delle persone.
Per diritto delle persone, la distinzione che si colloca nel punto più alto, è questa: tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi. Degli uomini liberi, poi, gli uni sono «ingenui», gli altri libertini.
Sono ingenui coloro che sono nati liberi; libertini, coloro che sono stati affrancati da una condizione servile giuridicamente riconosciuta. I libertini costituiscono, a loro volta, tre generi: sono cittadini romani o sono Latini o rientrano nel numero dei «deditici». Consideriamo queste categorie una per una.
La distinzione massima delle cose si articola in due gradi: le une sono di diritto divino, le altre di diritto umano. Le prime comprendono le cose sacre e quelle religiose... Le cose che abbiamo qualificate di diritto umano, o sono pubbliche o sono private… Inoltre, vi sono cose corporee e cose incorporee. Sono corporee quelle tangibili, come un fondo o uno schiavo, un abito, un oggetto d'oro o d'argento, e altre cose innumerevoli. Sono incorporee quelle che non possono toccarsi, come le cose che hanno solo un'esistenza giuridica: l'eredità, 'usufrutto, le obbligazioni contratte in qualunque modo. Non importa che dell'eredità facciano parte cose corpore, e che siano corporei i frutti che si colgono in un fondo, e che quanto ci è dovuto in base a un rapporto obbligatorio, anche questo, almeno normalmente, sia corporeo: un fondo, uno schiavo, il danaro. Lo stesso diritto di successione, infatti, è incorporeo, e così il diritto di usare e di fruire e il diritto di obbligazione. Sono incluse nell'elenco le servitù urbane e rustiche.

In questo passo delle *Istitutiones* Gaio mette in luce questo suo impianto diairetico:
Già dai primi righi possiamo notare come la *diaresis* sia collegata ad un discorso elementare.

- Gaio ci dice che il diritto si suddivide in persone, *res et actiones*, e poi si va a ramificare ciascuna di queste *genera*.

(In sintesi)

> Per il diritto delle persone , la distinzione più alta è tutti gli uomini o sono liberi o sono schiavi .
Gli uomini liberi sono ingenui (coloro che sono nati liberi) o libertini (coloro che sono stati affrancati da una condizione servile giuridicamente riconosciuta).
I libertini sono cittadini romani o Latini o deditici .

> La distinzione massima delle cose si articola in cose di diritto divino (cose sacre, religiose) e cose di diritto umano (pubbliche, private). Ci sono cose corporee (tangibili: fondo, schiavo, abito) e cose incorporee (intangibili: eredità, usufrutto, obbligazioni).
Il diritto di successione è corporeo, così come il diritto di usufrutto e il diritto di obbligazione.
Le obbligazioni nascono o dal contratto o dal delitto .
Esistono quattro generi di obbligazione che nascono dal contratto: l'obbligazione si contrae con:

1. La dazione di una cosa;
2. la pronuncia di parole determinate;
3. con la scrittura;
4. con un consenso.

- Oltre alle *Institutiones*, si discute sulla paternità gaiana di un'altra opera elementare: "*res cotidianae*" (o"Aurea") presenta qualche differenza rispetto alle *Institutiones*, soprattutto sull'analisi delle obbligazioni dove Gaio introduce un terzo termine: ovvero nelle Institutiones si limitò di dire che l'obbligazione è data dal binomio contratto-delitto; in quest'opera aggiunge al binomio anche *variis causarum figuris*, cioè da vari tipi di cause al di fuori del delitto o contratto.

(Ritornando a sabino…)

> L'opera sabinaiana (ma anche quella Cassiana) è molto importante anche perché è stata oggetto di *commentarii, epitomi o annotati*, da parte di giuristi successivi come Ulpiano, Giavoleno*, Aristone*, fino ad arrivare a Pomponio*.

* Giavoleno: scrive un'opera di 15 libri relativi a Cassio
* Aristone: fu autore di "note" sia dell'opera di Sabino sia di quella di Cassio, non sappiamo però se avessero una forma letteraria autonoma o erano ricomprese nei suoi Digesta.
* Pomponio: è autore di un esteso documentario a Sabino

<u>Un primo elemento di contrasto si ravvisa negli indirizzi didattici</u>

> <u>*Nell'ambito sabiniano si predilige una letteratura*</u> di tipo civilistico-trattatistica, addirittura si discutevano gli scritti di altri giuristi che facevano parte della scuola stessa, ad esempio Minicio ed Urseio Feroce (entrambi allievi di Sabino), ma non solo, importantissimi erano anche i commenti ad autori passati:

- Pomponio e Gaio si erano dedicati all'opera di Quinto Mucio Scevola (principe della tradizione civilistica di cui anche Sabino e Cassio facevano parte)
- Giavoleno riassume e critica i *Libri posteriores* di Labeone (e tenendo presente che Labeone fosse addirittura l'antesignano della scuole rivale, capiamo che non per questo vengono esclusi, né c si muove sempre in polemica nei loro confronti)
- Di Plauzio, che più che un giurista originale era un raccoglitore di opinioni altrui, non ne viene trascurato l'operato, in particolar modo da Giavoleno e poi più tardi a Pomponio.

> Seppur non trascurati nella scuola sabiniana, i libri di carattere problematico, che pongono al centro il caso e la *quaestio* che ne deriva, sono il <u>genere di letteratura che caratterizzava la scuola proculiana</u>:

- Ciò rispecchierebbe un modo di procedere sia nell'insegnamento sia nell'interpretatio dei casi concreti. Ad esempio, nella scuola proculiana, che vede Labeone (autore di epistole e responsi) come modello letterario, troviamo:

- Le Epistulae di Proculo
- Le Epistulae e i responsa di Nerazio
- Le Epistulae e Digesta di Celso Figlio
- Le Quaestiones e i Digesta di Celsio

> Non troviamo nella scuola proculiana, nessuna opera comparabile con i libri civilistici di Sabino o di Cassio (ad eccezione, forse, delle *Regulae* di Nerazio, e del fatto che si annotassero\ commentassero scritti di Labeone o Plauzio)

- Quindi vediamo che, se nella scuola sabiniana non venivano trascurati gli scritti di quella proculiana, nella scuola proculiana manca un'attenzione specifica per gli scritti dell'altra scuola.

> Da ciò capiamo che l'insegnamento all'interno delle due scuole seguisse modalità e stili differenti, forse i sabiniani erano più sistematici mentre i proculiani erano più inclini ad un agile pragmatismo didattico.

(Sarebbe sbagliato, però, pensare che i sabiniani non discutessero di casi pratici o che i proculiani evitassero ogni discorso giuridico elementare o sistematico.)

(Oltre il contrasto: talvolta erano convergenti)

> È importante ricordare che nonostante queste differenze stilistiche o ideologiche, le due scuole non erano dei blocchi contrapposti. Il giurista emerge sopra tutto il contrasto e ogni giudice manteneva le proprie peculiarità, il giurista ha la sua propria personalità, quindi non persegue in toto quelle che sono le caratteristiche di queste scuole; infatti, poteva accadere che all'interno del medesimo filone ci fossero delle divergenze di vedute, oppure convergenze in alcuni ambiti da parte di giuristi di filoni diversi:

Esempi:

> Un argomento di discussione su cui si ritrovavano a <u>*convergere*</u> erano *usus* e *usufructus*

Questi due sono esempi di diritti reali di godimento:
L'***usus***: ha un contenuto limitato perché comporta l'utilizzo della *res* altrui nei limiti dei propri bisogni.
L'***usufructus***: comporta anche la percezione dei frutti (si ha diritto al *fructus*, al reddito della cosa produttiva, ne percepisce i frutti e n ricava il guadagno consentito dagli usi sociali)

Vi fu una discussione sui in relazione ai limiti dell'*usus* affinché fosse possibile definire meglio la distinzione tra l'uno e l'altro.

Sabino e Cassio intervennero in materia, sostenendo che, se l'oggetto dell'*usus* era un fondo, allora l'usuraio poteva raccogliere fiori, frutta, legumi, ortaggi, legna e utilizzare l'acqua per i suoi bisogni, ma senza percepirne un profitto.
- Quindi si dà un'interpretazione leggermente più ampia dell'*usus* del fondo limitatamente ai bisogni della vita quotidiana.

Rispetto a questa interpretazione sabianiano-cassiana, Labeone si era pronunciato nello stesso modo, e anche Proculo si dimostrano d'accordo.

(Nerva padre si era dimostrato meno d'accordo, e aggiunse all'elenco di Sabino sarmenti e strame, ed escluse dalla sfera dell'usuraio grano, biade e olio.)

> Un argomento su cui si trovavano a convergere nel pensiero riguarda differenza fra *condicio* e *modus*.

Sono figure giuridiche differenti, ma affini che rientrano negli elementi accidentali del negozio:

La ***condicio*** è la condizione, evento incerto rispetto a cui è rimandata l'efficacia del negozio;
Il ***modus*** è una clausola che si appone soltanto ai negozi a titolo gratuito (come la donazione o il legato) e che impone al destinatario della liberalità l'onere di tenere un determinato comportamento, ma non sospende l'efficacia del negozio.

- Il dubbio era relativo al modo con cui sanzionare la clausola modale apposta un legato:

Trebazio Testa, trovando l'appoggio di Labeone, Nerva padre, Atilicinio e anche Proculo, propone una soluzione, una finzione interpretativa: cioè sostenne che il *modus* equivale ad una condizione, e solo se il legatario prometteva di eseguire il comportamento previsto, allora è legato doveva essere adempiuto

(Altri motivi per cui si pensa ad un contrasto\ competizione)

Vediamo una serie di chiavi di lettura talvolta riduttive, comunque poco esaustive rispetto alla lettura tale fenomeno estremamente complesso, però dobbiamo considerarle in qualche misura..

1- Una prima chiave di lettura è quella <u>filosofica</u>:
Sviluppatasi nell'ottocento, possiamo riconoscere in questa considerazione una sorta di carattere speculativo:
> Si tentava infatti di condurre il contrasto tra le due scuole, di volta in volta, all'antitesi fra stoicismo e Accademia, o fra stoicismo da un lato, e aristotelismo o epicureismo dall'altro. Tuttavia, seppur si intreccino in alcuni punti, non è possibile travasare in tal modo la filosofia all'ambito giuridico.
- I proculiani linee aristotelee.
- I sabiniani linee stoiche.

2- Un'altra chiave di lettura vede il contrapporsi:
- Di un <u>atteggiamento tradizionalistico</u> da parte dei Sabiniani
- Di un <u>atteggiamento di innovatività</u> da parte dei proculiani

> Anche questo però è riduttivo; seppur vero che i sabiniani si rifanno particolarmente alla tradizione, a qualcosa che è già permeato, allo stesso tempo si rifanno al nuovo, così come i proculiani si rifanno più all'innovazione, ma con la consapevolezza della tradizione.

3- Un'altra chiave di lettura vede una contrapposizione sul piano <u>logico-grammaticale</u> e sul linguaggio:

Vediamo da una parte:

- Gli analisti: più conservatori e poco inclini ai neologismi
- Gli anomalisti: più inclini ai neologismi

> Ma anche in questo caso, limitarci a questa divisione sarebbe riduttivo.

> Una divergenza di pensiero riguarda la ***compravendita***:
La compravendita è un contratto bilaterale perfetto, quindi nascono delle obbligazioni in capo a tutte due le parti, e si caratterizza per la presenza di un prezzo da pagare che coincide con il denaro, quindi è a titolo oneroso.
- I sabiniani riflettono sulla ***permuta***, cioè lo scambio di una cosa con un'altra, e sostengono che È possibile identificare la permuta come una specie della compravendita, poiché il prezzo può consistere anche in una cosa diversa dal denaro.
Questo ragionamento può essere visto come <u>*anomalistico*</u>, proprio perché identifica la compravendita con la permuta, e dobbiamo considerare che è una figura giuridica si estende sino al suo limite massimo, oltre il quale non c'è alternativa che constatare un'anomalia.

- I proculiani, invece, si concentrano sulla compravendita cioè ritengono che nella permuta, mancando il prezzo in denaro, non è possibile vedere una compravendita in quanto non si potrebbe stabilire quale cosa sia venduta e quale valga come prezzo, e allo stesso modo sarebbe assurdo considerarle entrambe l'una e l'altra cosa (cioè sia oggetto sia prezzo).
Questo orientamento che coglie una differenza tra la compravendita e la permuta, poi neanche la premessa per stabilire un eventuale <u>*analogia*</u> fra due tipi, tanto che Aristone, indipendentemente dalla sua simpatia scolastica, afferma che la permuta e "vicina alla compravendita".

4- Potremmo inserire anche quella chiave di lettura politica della contrapposizione che vede:
- I Sabiniani appoggiavano il principe
- I Proculiani in polemica con il potere del principe
> Tuttavia, questioni ideologiche e politiche riguardavano più la vita dei singoli individui che i gruppi in generale.

- Se Proculo fu un uomo politicamente influente, sembra certo che Sabino, come antiquario, si sia mosso nel solco dell'ideologia imperiale. Gli anni di Caligola e di Claudio sono stati, anche per i giuristi, anni difficili, ma non per tutti allo stesso modo. La *ferocia dei tempi* domizianei fu più grave da sopportare per Celso padre che non per Pegaso (*praefectus urbi*) o Giavoleno (*legatus consularis*). Più tardi, Celso figlio e Giuliano, non amici fra loro, furono entrambi amici di Adriano.

Come dobbiamo immaginare queste scuole?

Le scuole giuridiche erano istituzioni stabili di natura privata, non statale, senza uno statuto determinato.

Non hanno nulla in comune con le università funzionanti nel tardo impero, a Berito o a Costantinopoli.
- I giovani si muovono da ogni parti e arrivano a Roma per sviluppare le loro attitudini, si riuniscono in luoghi pubblici come *stationes* o *auditoria.* Un punto di incontro era forse il tempio di Apollo sul Palatino, dove Augusto aveva istituito una biblioteca per il diritto e le arti liberali.

Su quale modello si costituirono i consolidarono le scuole giuridiche?
Il modello di queste scuole si avvicina a quello delle scuole filosofiche greche.
Tuttavia le differenze di metodo sono evidenti
Entrambe erano centri di discussione, ma fra la discussione giuridica e quella filosofica intercorrevano non poche differenze.

> I filosofi
In Grecia, la scuola filosofica per eccellenza era l'Accademia, che nel corso della sua storia, riprese e abbandonò abbandonato il metodo socratico (in base al quale si confutava l'opinione dell'interlocutore dopo averlo costretto a dichiararla con domande opportune).
Un'altra via consisteva nel porre una questione al maestro\ filosofo, che svolgeva il suo discorso in modo continuo come un'*oratio perpetua,* dopo una volta conclusa, gli allievi potevano interrogarlo su qualunque argomento, e si poteva fondare così una contrapposizione: la *disputatio*.
- Nell'ambito delle scuole filosofiche, inoltre, era abituale nell'insegnamento la lettura e lo studio dei classici, si leggevano non solo le opere rientranti nell'indirizzo della propria scuola ma anche quelle di scuole rivali. (un po' come accadeva nella scuola sabiniana)
> I giuristi
Sul modello delle scuole filosofiche, anche nell'ambito delle scuole giuridiche si arrivava ad una *disputatio*, che doveva avere un andamento suo proprio; è da escludere un dialogo serrato di tipo socratico-accademico, ma possiamo immaginare la forma del discorso continuo.
È, inoltre, verosimile che il tema fosse proposto più spesso dal maestro che dei suoi ascoltatori, i quali ponevano soprattutto domande tecniche nel campo problematico scelto di volta in volta.
- Nell'ambito dell'insegnamento, sicuramente gli autori presi in considerazione non venivano studiati secondo l'insegnamento aristotelico, ma ci si approcciava alle opere degli autori precedenti interpretando il loro pensiero in senso dinamico cercando di cogliere ogni possibilità, spunto, utile per la soluzione di nuovi problemi pratici.

> Con Salvio Giuliano, il dualismo scolastico andò perdendo il suo significato, anche se non vengono meno le divergenze dei singoli giuristi fra loro. (Cioè quando vi fu l'emanazione dell'editto perpetuo che è come uno sparti acque, si consolida l'editto e allo stesso modo un controllo perpetuo da parte dei giuristi).
- Quel dualismo, Gaio cerca ancora di rappresentarlo come vitale, ma con scarsi risultati. Ciò non vuol dire che non siano rintracciabili, dopo il grande magistero giulianeo, simpatie sabiniane o proculiane.

4. Il giurista “filosofo”

La fine del dualismo scolastico non ha a che fare con la fine dell’insegnamento giuridico.

> Si sviluppa infatti una letteratura che a che fare, appunto, con insegnamento: le *Institutiones*
Gaio, infatti, non è l’unico a scrivere un’opera del genere, ma allontanandosi dal suo modello, per un verso per l'altro, molti giuristi decidono di dedicarsi in tal modo all'insegnamento:

- *Fiorentino:* fu autore di un’opera di Institutiones, difficilmente databile, per cui in effetti non si sa se abbia seguito o, addirittura, preceduto, addirittura, Gaio, ma comunque non fu pubblicata prima di Marco Aurelio. Conta ben 12 libri (numero enorme per un testo elementare);
- *Elio Marciano*: anche lui scrisse delle Institutiones, la cui estensione era ancora più ampia di quelle di fiorentino, contava infatti 16 libri (in lui si è voluta vedere una *mostruosità letteraria*).
  Certo, esse non hanno il limpido andamento delle *Institutiones* di Gaio.
  Non è improbabile che Marciano vi abbia raccolto materiali diversi, che poi non ha rielaborato, e che la pubblicazione sia dovuta a un editore più tardo. Ad ogni modo, Marciano era alle prese con le sue *Institutiones* sotto Caracalla o subito dopo;
- *Callistrato* e di *Paolo* , le cui *Institutiones* contano rispettivamente 3 e 2 libri e sono degli stessi anni o poco precedenti (rispetto a quelle di Marciano).

(Institutiones Ulpianee)

> La raccolta più importante di *Institutiones*, composte a partire dal regno di Callistrato, furono le *Institutiones* di Ulpiano (2 libri).
- Ciò che ci è pervenuto lo ricaviamo dai *Digesta* Giustinianei.
All’inizio dei Digesta troviamo proprio un passo di quest’opera Ulpianea, e la collocazione risulta essere significativa per lo sviluppo del Digesto.

(Testo pag. 271)

Colui che intende dedicarsi al ius, al «diritto», è necessario che conosca, in via preliminare, da dove trae origine la parola. Ora il ius è chiamato così da iustitia: infatti, secondo l’appropriata definizione di Celso, il diritto è l'«arte» del buono e dell’equo. Di quest'arte, noi potremmo a ragione essere chiamati sacerdoti: poiché abbiamo cura della giustizia e insegniamo il concetto del buono e dell'equo, separando ciò che è equo da ciò che non lo è, distinguendo il lecito dall'illecito, desiderosi di rendere buoni gli uomini non solo con la minaccia delle pene, ma anche con l'incentivo delle ricompense, cercando, se non mi sbaglio, una filosofia vera, non apparente.

> Vediamo che il discorso si muove in una prospettiva giusnaturalistica, e ci permette di delineare la figura del giureconsulto (per come si sviluppa nell'età severiana) attraverso una nuova enfasi pedagogica e moralistica: Il giurista è visto come colui che insegna l'arte del buono dell'eco, a separare e a distinguere il lecito dall’illecito, addirittura viene assimilata la figura del giurista a quella di sacerdote dell'arte giuridica.

- Non è certo che si ponga in polemica anticristiana, dubbio che si pone poiché l'insegnamento cristiano nel periodo di Ulpiano, ruotava attorno al concetto di filosofia vera o di vera ragione, e Ulpiano d’altro canto parla di *veram non simulatam philosophiam*.

  Un’ altra interpretazione riguarda una sorta di accusa che aveva mosso Cicerone nell'orazione *Pro Murena*, quando aveva bollato l'arte giuridica come *verbosa simulatio prudentiae*, e quindi possiamo pensare che Ulpiano stesse rispondendo a quell’accusa.

- Ulpiano, infatti, nelle ultime righe del frammento, richiama la filosofia come disciplina più vicina a Dio (solo in Dio risiede l’αλεθεια), e Ulpiano vuole assegnare un valore filosofico alla figura del giurista, che nel suo campo deve comportarsi come un filosofo, deve indagare la verità.

> Schulz osserva che è difficile credere che Ulpiano e Paolo, grandi giuristi di alto rango, scrivessero manuali brevi, dal contenuto elementare, e che i loro libri non sostituirono nelle scuole di diritto l'antiquata e lacunosa opera di Gaio (è un dubbio aprioristico, che non trova nessuna dimostrazione analitica).
Se Ulpiano e Paolo hanno scritto opere istituzionali, questo non significa che abbiano anche insegnato a quel primo livello di studi: come insegnante, Ulpiano si esprime molto meglio nelle *Disputationes* che nelle *Institutiones* . Le *Disputationes* si collocano accanto alle *Quaestiones* di Papiniano e di Paolo e riprendono a loro modo l'indirizzo casistico-problematico della giurisprudenza repubblicana e classica.

(Possibile domanda d'esame)
Possiamo tracciare una linea evolutiva dalla repubblica al principato.
Scandire il passaggio del giurista rispetto queste coloriture differenti:
si parte dal giurista aristocratico di cui tutti hanno bisogno e riveste cariche pubblica e porta una saggezza pratica, poi verso la fine della repubblica c'è una crisi di questo modello, e quindi non necessariamente cursus honorum e scientia iuris debbano andare a braccetto, ma è lo specialismo che va coltivato, specialismo che rende autonomo al potere politico/pubblico, poi abbiamo Labeone che si distacca dal presente, rimpiangendo il passato, fino ad Ulpiano dove vediamo il giurista come filosofo.

Capitolo decimo: Le forme letterarie

1. La letteratura problematica

È possibile guardare alla letteratura giuridica in base a due percorsi differenti, che seppur parallele, si intrecciano in più punti:

> O riconducendoci ai singoli autori con le relative opere
- Così facendo potremmo comprendere l'insieme delle circostanze in cui si svolge la produzione letteraria (analizzando gli interrogativi\ i problemi che l'hanno determinata, ed i nessi interni che la caratterizzano)

> Oppure guardando alle forme e generi letterari
- Che non sono un semplice schema classificatorio, ma attraverso la loro analisi, ci permettono di comprendere il modo di organizzazione e di comunicazione del pensiero giuridico.

- Durante la *Repubblica*, è possibile distinguere raccolte di formule, raccolte di leggi e commenti alle raccolte di leggi; alla fine della Repubblica erano ormai saldamente costituite:
  - Da un lato la forma del ***trattato*** civilistico
  - Dall'altro la forma del ***commento*** edittale
  - È possibile poi distinguere la letteratura ***teorico-didattica*** che vede la sua espressione negli *Horoi* (definizioni) di Quinto Mucio Scevola.
  - Ancora, possiamo individuare il filone ***casistico-problematico*** che si afferma nella scuola di Servio Sulpicio Rufo
  - E anche se rare, sono presenti alcune ***monografie***.
  - Ricordiamo, inoltre, il *De usurpationibus,* di Appio Claudio Cieco (rif. anedd. laicizzazione del diritto) all'interno del quale si incontrano lo scritto sulla dote e quello sulla rinunzia ai culti familiari di Servio. (hanno, poi, un posto a sé tutti gli scritti di diritto pubblico e di diritto sacro)

- Durante il *principato*, una letteratura di responsi continua a svolgersi, ma va trasformandosi:

> ***Responsa***:

1- Fra Augusto e Adriano, troviamo dei libri intitolati "*responsa*" di Labeone-Sabino-Nerazio-Celso.

2 - All'inizio dell'età severiana, si collocano altri responsa redatti scritti da Cervidio Scevola, Papiniano, Giulio Paolo, Ulpiano e Modestino.

1- Se il giurista tardo-repubblicano e augusteo si muoveva ancora in uno spazio cittadino (era in rapporto diretto con il pubblico anche quando affrontava questioni che nascevano dal traffico commerciale, o discuteva di istituti operanti in un ambito geograficamente vasto)

2- Dopo il periodo augusteo, lo *scenario* del responso *cambia*:

- Sono significativi a tal proposito i *Libri responsorum* di Cervidio Scevola, ma anche di Papiniano e Modestino, che includono una casistica provinciale e hanno un altro stile.
Gli interroganti, infatti, spesso sono uomini che vivono lontani dalla capitale, in ambienti romanizzati, o che hanno acquisito da poco la cittadinanza romana (talvolta, addirittura, i quesiti sono posti in greco)

> ***Epistulae***:

La comunicazione del parere tecnico, non di rado, avveniva (o si fingeva che avvenisse) attraverso uno scambio epistolare: è così che accanto ai responso nascono le *Epistulae*:

- Uno egli esempi più famosi è un caso esaminato da Giavoleno, ambientato in Britannia, e si caratterizza per essere un testo insolitamente ricco di dettagli (anche perché era raro che un giurista li ricordasse, in quanto lo sguardo si concentrava subito e quasi esclusivamente sul problema e sui caratteri significativi a riguardo); non è, infatti, da trascurare il fatto che nonostante questa ricchezza di particolari, i collaboratori di Giustiniano abbiano deciso di conservarlo nei suoi elementi minimi.
- Ciò di cui si discute è un fedecommesso di eredità, il dubbio che sorge e se vi fosse stato a posto un termine vero e proprio, oppure una condizione.(Giavoleno si orienta verso la prima ipotesi)

In ogni caso, ciò che è più significativo, è la struttura del discorso:
- Nella prima parte parla l'ignoto interlocutore di Giavoleno proveniente da una lontana provincia.
- Dopodiché viene posto il quesito.
- Poi il giureconsulto da, in forma epistolare, il suo responso.

1- « Seio Saturnino, capo pilota della flotta britannica, ha istituito erede fiduciario nel suo testamento il trierarca Valerio Massimo, e gli ha imposto con un fedecommesso l'onere di restituire l'eredità al proprio figlio, Seio Oceano, appena avesse raggiunto sedici anni.
Oceano muore prima. Si fa avanti Mallio Seneca, che afferma di essere zio materno di Seio Oceano, e pretende i beni ereditari sulla base del rapporto di parentela; il trierarca Massimo invece li rivendica per sé, poiché è morto colui al quale avrebbe dovuto restituirli. Questo è il caso.

2- domando sei beni spettano al trierarca Valerio Massimo, erede fiduciario, oppure a Mallio Seneca, che si dichiara zio materno del giovane defunto.

3- Rispondo. L'eredità fiduciaria spetta a colui al quale spettano gli altri beni di Oceano. La ragione è nel fatto che la potenziale attribuzione di fedecommesso è avvenuta durante la vita di Oceano ; sempre che il testatore, prorogando il momento dell'esecuzione, abbia voluto permettere all'erede fiduciario la custodia dei beni, piuttosto che fissare per il fedecommesso un termine incerto ».

> Non è da escludere che nomi siano fittizi, quel che è certo è che, coloro che si rivolgevano ai giureconsulti appartenevano alle categorie più svariate: privati, uomini, donne, magistrati in dubbio su una decisione da adottare…
> Come i *Responsa*, anche le *Epistulae* non si limitano sempre alla soluzione del caso singolo, ma possono assumere un andamento didattico-teoretico.

> Dobbiamo però precisare che il Epistulae e Responsa fanno parte di quella letteratura problematica nella quale rientrano anche opere con titoli diversi:
- ***Quaestiones*** (ricordiamo quelli di Celso, Fufidio, Cecilio Africano, Cervidio Scevola, Callistrato, Papiniano, Tertulliano e Paolo;
- ***Digesta*** (ricordiamo quelli di Tizio Aristone, Celso, Ulpio Marcello, Salvio Giuliano, che li produssero sull'esempio del vecchio Alfeno Varo)
- ***Disputationes*** (ricordiamo quelle di Ulpiano e Trifonino)
- ***Ambiguitates***

2. Commentari e altri scritti

Oltre alle opere problematiche , la tipologia letteraria classica comprende anche altri generi:

- Commentari civilistici ed edittali
- Libri che riassumono o annotano scritti gli autori più antichi
- Libri sulle singole leggi
- Libri che raccolgono o interpretano il senatoconsulti e costituzioni imperiali
- E monografie
- Raccolte di definizioni e regole
- Florilegi
- Manuali e compendi
- Trattati di diritto processuale\ tributario\ costituzionale\ amministrativo

Questa tipologia letteraria non è assolutamente un rigido disegno geometrico, non è uno schema, e le forme presentano tra loro affinità e similitudini.
Talvolta è possibile che si intrecci con questi generi il discorso casistico-problematici, ad esempio nelle raccolte di regole o nei commentari è possibile trovare traccia di alcuni responsi, viceversa, è possibile trovare, ad esempio, discorsi regolativi-definitori nei responsi o nelle epistole.

> *Libri regularum*
I più famosi sono quelli di Nerazioo, ma non fu l'unico a produrre questo genere;
Ne scrissero anche Pomponio, Gaio, Cervidio Scevola e quasi tutti i giuristi dell'età dei Severi.

> ***Definitiones***
Papiniano scrisse un'opera intitolata "Definitiones" (riprendendo in latino il nome greco degli Horoi di Quinto Mucio)

> Nei ***libri sulle singole leggi***, i giuristi prendono in esame non solo le 12 tavole, ma anche:
- *Lex Cincia* sulle donazioni, della fine III secolo a.C. (su cui si ha un breve commento da parte di Paolo.
- Lex Falcidia sui legati, del 40 a.C. (si hanno scritti autonomi di Paolo e Rutilio Massimo);
- Legislazione matrimoniale augustea fu attentamente studiata dalla giurisprudenza .
- *Lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *Lex Papia Poppaea nuptialis* che costituirono una sorta di testo unico su cui si soffermarono Gaio, Giunio Mauriciano, Ulpio Marcello , Terenzio Clemente, Paolo e Ulpiano , in opere di diversa ampiezza;

> Anche i ***senatoconsulti*** (in particolare il *Tertulliano* e l'*Orfiziano*) ebbero i loro interpreti in Gaio, Pomponio, Paolo, Elio Marciano.

> Alle ***costituzioni imperiali*** furono dedicate poche raccolte (Decreta frontiana, Libri decretorum, Libri imperialum sententiam…)

> Al contrario, furono molti gli scritti privatistici di carattere ***monografico***:
- Fedecommesso → si occupano dei *fideicommissa* Aburnio Valente, Pomponio , Gaio , Ulpiano , Paolo , Campano, Meciano e Modestino in un *Liber singularis de legatis et fideicommissis*.
- Stipulazione → Pedio, Pomponio (8 libri), Venuleio (19 libri).
- Diritto ipotecario → Gaio (di cui conosciamo tre libri singulares a riguardo), Marciano, Paolo
- Matrimonio → Nerazio (libro sulle *nuptiae*), Modestino (libro sul *ritus nuptiarum*)
- Dote → Gaio (*Dotalicion liber singularis*), Paolo (scritto sulla *dotis repetitio*)

> Vediamo poi i Digesta, da quelli di Celso, poi di Giuliano.

> Pomponio che pubblicò un commento in 39 libri ***ad Quintum Mucium (***relativi ad un testo letterario civilistico) lo stesso fecero anche Gaio e Lelio Felice nei primi anni del principato di Antonino Pio.
- E tra l'altro questa fu anche una produzione degna di rilevanza, in quanto nessuno prima di allora si era spinto così dietro nel commentare, o anche solo nell'annotare, i testi giuridici antichi.
- Questo si inquadra perfettamente con il gusto aneddotico e antiquario dell'epoca, già Pomponio aveva delineato nell'Enchiridion, una vera e propria storia del diritto, delle magistrature e della giurisprudenza.
- Le 12 tavole , nonostante ogni razionalismo o modernismo, mantenevano intatto il loro valore, e gli stessi Gaio e Sesto Cecilio Africano continuarono a scriverne o discorrerne.
- Inoltre ci fu un massiccio recupero della tradizione, perseguito in modo più consapevole, da un gruppo di giuristi che si muovono fuori dagli apparati del potere, in un ambito scolastico-accademico dove si compie ormai l'educazione giuridica.

> Furono commentati, poi, anche altri giuristi come ad esempio Masurio Sabino, a cui Pomponio, Ulpiano e Paolo dedicano scritti molto estesi (36, 51, 16 libri) servendosi nel loro commento non solo dei *Libri III iuris civilis* , ma anche di altri materiali sabiniani.

> I grandi commentari hanno un carattere lemmatico e seguono così un modulo largamente diffuso nella letteratura scolastica greca e latina, che ha per oggetto testi retorici, filosofici, poetici, tuttavia la letteratura giuridica ha esigenze proprie:
- Si richiamavano, o si ripetevano, incorporandoli nell'opera, frasi o brani o ancora parole singole appartenenti ad un'altra opera, e su questi veniva intessuto il commento.
Spesso, però, l'autore commentato appariva solo in un discorso indiretto, tanto che siamo capaci di renderci conto raramente (talvolta in modo visivo) di tale struttura composita, poiché nel corso della tradizione letteraria, la distinzione fra commento e dilemma è andata quasi sempre perduta.

> Talvolta, ancora, i commenti ad autori antichi potevano anche procedere in modo selettivo, è il caso:
- Dei commenti di Giavoleno ai *Posteriores* di Labeone
- Di Paolo ai *Pithana* di Labeone e ai *Digesta* di Alfeno
Andarono a costituire delle vere proprie epitomi, cioè riducono l'opera esaminata, mentre la discutono; MA anche quando non veniva ridotta l'opera-base, il commento arriva mutarne i contorni.
- E questo perché i testi vengono letti in un periodo in cui la mentalità è variata rispetto al momento della loro produzione, per cui cambiano volto, e vengono sfruttati a scopi interpretativi, magari anche molto diversi da quanto l'autore potesse concepire.

> La scienza del diritto è tradizione vivente, che elabora e rinnova, in un dialogo continuo, i suoi dati. Naturalmente nel pensiero giuridico può insinuarsi il ricordo storico-antiquario o l'annotazione filologica, o si può sottolineare la distanza o la continuità del presente dal passato, ma mentre la coscienza della propria storicità rimane spesso solo nel fondo, l'attitudine razionalistica deve spesso cedere di fronte a valutazioni pratiche piuttosto *ragionevoli* che razionali.

> In modo parallelo ai commentari civilistici si svolgono, sui modelli tardo-repubblicani e augustei, i ***commentari edittali***:
Dopo Labeone, e forse Fabio Mela, tocca a Masurio Sabino.
L'editto si era venuto consolidando, ma la codificazione giulianea è lontana;
- Gaio sembra commentarne solo un certo numero di titoli, non l'intero testo normativo;
- Pomponio costituisce, invece, un'opera completa e gigantesca.
- A Pomponio si rifanno spesso i *Libri ad edictum* di Ulpiano e di Paolo;
L'attenzione si sposta anche:
- Sull'editto edilizio, su cui si ricava un commento autonomo di Celio Sabino.
- Sull'editto provinciale di cui si occupa per primo Gaio, e probabilmente anche Callistrato nei suoi l*ibri edicti monitorii,* e poi ancora Furio Anziano (di cui però scarseggiano le notizie biografiche, tanto che non si è riusciti a collocarlo temporalmente in modo preciso)

3. Interessi nuovi

I commentari severiani dimostrano il ***rapporto ancora saldo*** della giurisprudenza tardo-classica ***con il passato***.
Ma, allo stesso tempo, giurisprudenza tardo-classica (Paolo, UIpiano, Papiniano, Marciano, Callistrato, Arrio Menandro, Macro, Modestino) ***coltiva anche nuovi interessi*** e\o approfondisce temi già presenti da qualche generazione alla coscienza degli interpreti.

> La letteratura giuspubblicistica sugli *officia* di magistrati cittadini, prefetti, governatori provinciali, aveva qualche precedente fra Antonino Pio e Marco Aurelio:

- Appartengono a Marcello e a Venuleio due opere, l'una sulla carica di console, l'altra su quella proconsolare;
- E cinquant'anni dopo, il ***De officio procunsulis,*** <u>*Ulpiano*</u> persegue l'intento di ricavare, dai rescritti e dai mandati che riguardano questa o quella provincia, i *principii applicabili a tutte le province senatorie* , costruendo così un *sistema comune di diritto amministrativo provinciale* . In questo libro si rivela l'arte di governo del grande funzionario che ne è l'autore, e il profondo moralismo che la ispira.

> Un altro gruppo di libri ha uno spiccato *carattere programmatico* :
Riguardano il *pretore tutelare,* istituito da Marco Aurelio, e furono scritti da:

- <u>Paolo</u> (*Liber singularis de excusationibus tutelarum* , *Liber singularis de officio praetoris tutelaris* , *De iurisdictione tutelaris*),
- <u>Ulpiano</u> (*Liber singularis de officio praetoris tutelaris* , *Liber singularis de excusationibus*),
- <u>Modestino</u> (*De excusationibus* , in greco).

> Nascono poi opere autonome sul fisco, le imposte, il processo cognitorio e l'appello, i crimini e le pene, che pian piano acquistano un più deciso rilievo all'interno dei consueti generi letterari;
(Ma anche qui, almeno per quanto riguarda il diritto penale, non si tratta di una totale novità; il cammino era già stato indicato da alcuni decenni.)
Sono significativi gli scritti di_

- <u>Callistrato</u> (*De cognitionibus* , *De iure fisci (et populi)*), di
- <u>Macro</u> (*De appellationibus*),di
- <u>Ulpiano</u> (*Deappellationibus*)ediModestino(*Depoenis*) sono scritti significativi.

> Ancora, Marciano e Macro scrivono su *giudizi pubblici* , ma, anche in questo caso lo avevano già fatto, prima di loro, Venuleio e Meicano.

> Si pone attenzione anche sul diritto militare: Paolo, Macro, Arrio Menandro, e anche qui è possibile trovare un precedente in Tarrunteno Paterno.

A quale pubblico si indirizzavano queste opere?
Coloro che erano impegnati nell'amministrazione dello stato.
- Anche i giuristi molto spesso lo erano; ma, ricordiamo, a loro era dato di coniugare, ancora una volta, l'esperienza pratica con la vocazione precettistica e letteraria.

Capitolo undicesimo: I modi di una tecnica

1. L'opera collettiva e i singoli attori

2. Strade vecchie e nuove

3. Il “caso” e il problema

4. Come si forma una regola

5. Dialoghi fuori del tempo

6. La cura per le parole

Capitolo tredicesimo: Il diritto codificato tardo-antico

1. Assolutismo e legislazione

Anarchia militare (50 anni)

Nel 235 d.C. con la fine del regno di Severo Alessandro termina la dinastia severiana, e con essa l'età del principato.

È in questo momento che si colloca un cinquantennio di anarchia militare: dal 235 d.C. al 284 d.C.

- Questo fu uno dei periodi di maggiore crisi nella storia dell'impero romano, sia per la lunghezza della crisi istituzionale (l'instabilità politica durò appunto cinquant'anni), sia per la concomitanza di altri grandi difficoltà (es. carestie, epidemie di peste, tensioni religiose, ma soprattutto le invasioni barbariche).
- Questo periodo si caratterizza, infatti, sia per una disgregazione delle strutture portanti dell'organizzazione imperiale, sia per una frammentazione del territorio provocata proprio dalla dilagazione delle popolazioni barbariche, estremamente diverse dalla civiltà romana e con altre metodologie in vari campi, che riuscirono anche a penetrare nelle file degli eserciti romani.

> Dunque si ha un passaggio da un governo unitario ed armonico —> alla frammentazione.
Ciò si traduce in tutta una serie di problematiche socio-economiche e politiche, ecco perché inizia ad essere data sempre più importanza alla componente militare, e cioè si accenta il potere dell'esercito, in quanto è quella componente che ha il compito di difendere i territori dell'impero.

- Tutti gli imperatori incaricati di governare in questo periodo furono tutti comandanti militari, condottieri, o in generale importanti esponenti dell'esercito: la cui base del potere era proprio l'esercito.

Si venne dunque a determinare una nuova *aristocrazia militare*, di estrazione provinciale, sempre meno romanizzata, e sempre più contaminata da elementi esterni (alcuni imperatori furono addirittura barbari).

- Termina così l'età della tradizione, delle classi dirigenti rappresentate dal Senato o dalla classe equestre le quali furono esautorati da una nuova aristocrazia militare che diventa via via sempre più importante.

Anche perché venne meno tutta quella cultura sotto il profilo economico che era stata assicurata dal buon governo dell'età classica, per cui l'esercito diventa l'unica forza reale dell'impero.

Le spese militari iniziarono a diventare ingentissime, ciò ebbe come conseguenza l'aumento dei tributi, che si tradusse in vere proprie vessazioni sulla popolazione che aveva difficoltà a sostenere il peso delle tasse in un tale periodo di crisi, che, appunto, registrò anche carestie ed epidemie.

- Per garantire allora le entrate nelle casse dello stato, e quindi il pagamento di tributi pretesi, lo stato introdusse il sistema del ***colonato***, cioè il vincolo dei contadini alla terra: Si legano dunque le famiglie (quindi i contadini e i loro discendenti) alla propria terra, cioè ciascuno doveva procedere l'attività del proprio ascendente mantenendosi come proprietario della terra d'origine e coltivandola.

Ciò ebbe come conseguenza un immobilismo sociale in quanto ciascuno doveva conservare il mestiere del proprio padre, non si ha la possibilità di migliorare la propria condizione sociale, inoltre la vecchia aristocrazia delle locali comunità cittadine e la borghesia principale anch'esse sempre più vessate, perdono la loro antica superiorità.

Età del dominato

Il periodo tardo antico, o età del dominato, che culmina con la compilazione giustinianea, è quel periodo che si caratterizza da una parte per lo sviluppo di una forma di potere assoluto più accentuato rispetto al principato, ma soprattutto per l'affermazione della realtà del codice.

- L'idea di codice, che attecchisce e si afferma proprio in età tardo antica, è un'idea concepita precedentemente, addirittura nell'età di Cesare, quando si tentò di introdurre un codice che tuttavia non ebbe modo di attecchire, tant'è che nel periodo successivo la realtà del codice non riuscì a svilupparsi in alcun modo: Una caratteristica peculiare del diritto romano è proprio questa, per molti secoli non si parlerà di un diritto codificato, ma bisognerà attendere il periodo tardo antico, in particolare dal regno di Diocleziano in poi.

Contesto storico e socio-politico

È nel contesto dei rivolgimenti a livello sociale e politico tipici del periodo dell'anarchia militare che iniziano ad emergere delle aspirazioni ad una pacificazione\ alla stabilità: il desiderio di una situazione migliore.
È proprio per questo motivo che il periodo dell'anarchia militare durò relativamente poco, terminò infatti con l'ascesa di Diocleziano nel 284 a.C.
Diocleziano prima (governo: 284-305 d.C.) e Costantino dopo (governo: 306-336 d.C.), sono due imperatori che, seppur ognuno con le proprie peculiarità, possono essere messi in continuità tra loro.
Furono proprio Diocleziano e Costantino che fra III e IV secolo, riuscirono a risaldare in misura considerevole l'organizzazione unitaria dell'impero, sulla scia, però, di una monarchia militare teocratica e dinastica che in realtà aveva già avuto qualche manifestazione nella tarda età classica (quindi nell'età dei severi: ciò testimonia che nulla accade improvvisamente, c'è sempre una continuità di fondo).

> Con Diocleziano dunque si inaugura l'età del dominato:
Questo periodo è caratterizzato da una forma accentuatissima di assolutismo, più del principato:
L'autorità imperiale durante il principato ha infatti dei limiti che riguardano proprio la sostanza del potere, addirittura si arriva a parlare di *diarchia* nel senso di un governo diviso fra Senato e il principe (lo dice Mommsen, uno storico e giurista tedesco dell'ottocento).

Con Diocleziano e Costatino la situazione cambia:

- L'unica autorità effettiva, in ogni senso, è quella dell'*imperatore.*

  - Nella concezione pagana è un vero e proprio Dio, mentre in quella cristiana riceve da Dio il suo potere; compare in pubblico con un diadema, vestito con una veste intessuta d'oro e di pietre preziose, ogni cosa che gli appartiene o che lo riguarda è considerata sacra e chiunque all'obbligo di prostrarsi dinanzi a lui come innanzi ad un re persiano; Questo è solo uno dei tratti orientali della monarchia, un'altro, ad esempio, è il fatto che nell'ambito dell'amministrazione centrale, i funzionari si trovavano mescolati con coloro che prestavano uffici domestici al principe, ad esempio il *praepositus sacri cubiculi*, che era una sorta di ciambellano, il quale stava accanto al *magister officiorum* e al questore palatino.

- Il *popolo* come organo costituzionale non esiste più.

- Il *senato* ha un ruolo ancor più marginale, quasi come se fosse un consiglio cittadino: Accanto a quello di Roma ne sorge un altro a Costantinopoli (la nuova capitale), ma il suo non è più un ruolo incisivo, alcune volte funzionò come alta corte di giustizia, agiva inoltre come organo di pubblicazione (Se non di formazione) delle leggi imperiali. Ma di fatto il Senato è solo un'ombra, e al ceto senatorio, oltre ad onori e privilegi spettano anche oneri finanziari.

- I *magistrati*, anch'essi solo un'ombra, non furono aboliti, ma ciò che un tempo erano le magistrature ormai spettava all'imperatore, e ai magistrati restava un ruolo puramente onorario, esistono solo di nome:
  - I consoli ordinari sono nominati dall'imperatore e continuano a designare l'anno entrando in carica con una solenne cerimonia.
  - I pretori ed i questori svolgono una funzione locale che in realtà è un *munus* e implica spese non lievi.
  - I tribuni e gli edili conservano un mero titolo.

Struttura governativa dell'impero: Tetrarchia Dioclezianea

L'impero, che durante il periodo dell'anarchia militare aveva ormai assunto una struttura piuttosto frammentaria, si presentava con una struttura dualistica sul piano costituzionale: Impero d'Oriente (capitale: Costantinopoli) e Impero d'Occidente (capitale: Roma) sono parti distinte o comunque tendevano ad esserlo.
Diocleziano decise allora di dare al governo una struttura di tipo tetrarchico: si parla infatti di *governo tetrarchico* o ***Tetrarchia Dioclezianea.***
- Poiché i territori imperiali erano estremamente estesi, e ciascun area aveva caratteristiche proprie, nacque l'esigenza di un'amministrazione più efficace e capillare che potesse essere anche più verticistica per far si che il controllo dell'imperatore su tutte le zone dell'impero fosse facilitato:

Dunque Diocleziano optò per un'amministrazione distinta tra le due parti ma con legislazione unica, cioè:
> Ognuna delle due parti la propria amministrazione (sul piano governativo\finanziario\militare)
> L'attività legislativa era comune (anche se l'Augusto d'Oriente prevaleva rispetto a quello d'Occidente)
L'impero era dunque governato da 2 Augusti e 2 Cesari:
- Augusto d'Oriente:
  Diocleziano (ricordiamo che la parte orientale aveva sempre una prevalenza rispetto a quella occidentale)
- Augusto d'Occidente:
  Massimiano (Fedele generale di Diocleziano)
- A ciascuno dei quali era affiancato un Cesare, adottato dall'Augusto; Aveva poteri minori, ma era il vero e proprio successore scelto dell'Augusto in carica.

Vantaggi:
- Questo tipo di organizzazione era un sistema verticistico molto chiaro che garantiva anche una più diretta vigilanza e tempestività di intervento dove e quando fosse necessario.
- Assicurava, soprattutto, la continuità del potere:
Si dovevano infatti evitare quei momenti di vuoto di potere che avrebbero potuto dar luogo a delle crisi, per cui alla morte di un Augusto, automaticamente, subentrava il Cesare.
Per altro, era frequente che I figli degli augusti si sposassero con quelli dei cesari stipulando un vero e proprio legame familiare.
- La garanzia di successione era inoltre importante poiché dava luogo ad una certa continuità anche, ad esempio nell'introduzione delle varie riforme, cioè avrebbe portato ad una politica più ordinata nel tempo.

Amministrazione:
Diocleziano si dedicò molto all'amministrazione centrale e periferica, civile e militare ponendo molta attenzione anche all'apparato burocratico che divenne molto articolato e ovviamente con struttura gerarchica. Tutte le funzioni conferite dall'imperatore sono stipendiate.
> Moltiplicò le *province* dell'impero, governate da alcuni tipi di magistrati (come consoli e proconsoli; Diocleziano tra l'altro escluse i senatori dai governatorati provinciali) e le racchiuse in 12 (o 13) *diocesi* a capo delle quali stanno i *vicari.*
> Le diocesi, a loro volta, erano subordinate alle 4 *prefetture* (Italia - Gallie - Illirico - Oriente), che erano delle grandi circoscrizioni territoriali a capo delle quali stanno i *prefetti del pretorio*.

(Cariche singole)

> Grazie alla "*Notitia Dignitatum"*, che è un documento ufficiale redatto tra IV e V secolo, ad oggi abbiamo una lista completa delle cariche civili e militari del tardo impero con le rispettive aree di competenza, in base anche alla divisione territoriale (il documento si divide infatti in due parti: la prima per le cariche dell'impero d'Oriente, l'altra per le cariche dell'impero d'Occidente).

- *Prefetto del pretorio:*

  - In origine erano funzionari legati alla persona del principe, ma nel tardo impero diventano una delle cariche-vertice dell'amministrazione territoriale (assieme ai prefetti urbani delle due capitali Roma e Costantinopoli, e ai proconsoli delle province di Acaia, Asia e Africa).
  - Il numero di prefetti del pretorio varia nel tempo finché non ne diventarono stabilmente quattro: 2 per ogni parte dell'impero
  - Svolgono solo funzioni civili (es. amministrazione delle finanze o controllo dei governatori provinciali)
  - Solo i prefetti d'Italia e di Oriente continuarono a risiedere presso le rispettive corte imperiale dove ebbero un ruolo politico di primo piano.

- Le cariche più elevate dell'amministrazione centrale (ovviamente stipendiate) dell'impero erano le quattro, cosiddette, *Dignitates Palatinae:*

  1 - *Quaestor sacri palatii*

  > Venne introdotto da Costantino ed era un "ministro della giustizia" che aveva il compito di preparare sia il testo delle leggi o delle sentenze pronunciate dall'imperatore, sia le risposte dell'imperatore alle istanze che gli venivano rivolte di volta in volta.

  2 - *Comes sacrarum largitionum*

  > Era una sorta di "ministro finanziario" che si occupava da una parte di donativi e stipendi da concedere alle truppe militari, per cui aveva una funzione importante per assicurare al principe la fedeltà delle truppe, dall'altra parte si occupava anche del controllo delle miniere e delle zecche dello stato per gestire le casse dello stato ed emanare le tasse.

  3 - *Comes rei privatae*

  > Anche questo era un ministro finanziario, propriamente l'amministratore a capo dei dominii imperiali, cioè stiva le proprietà private dell'imperatore.

  4- *Magister officiorum*

  Può essere tradotto letteralmente come "direttore degli uffici".

  > Sovrintendeva a diversi uffici detti "*scrinia*":

  I tre scrinia più importanti erano:

  - *scrinium\ officium memoriae:*

  Ufficio che gestiva le decisioni imperiali chiamate "annotazioni" (erano note fatte dall'imperatore su documenti presentati a lui) e anche le risposte alle petizioni per l'imperatore.

  - *scrinium\ officium epistularum*

  Ufficio che gestiva la corrispondenza trattata con i potentati stranieri e con l'amministrazione provinciale e le città.

  - *scrinium\ officium libellorum*

  Ufficio che gestiva i ricorsi dei tribunali inferiori e le petizioni da coloro che vi erano coinvolti.

  - A questi, in seguito, si aggiunse a cui si aggiunse in seguito lo *scrinium dispositionum* su cui però non si hanno numerose informazioni.

  > Era inoltre ministro di polizia

  > Da lui dipendevano i corrieri imperiali e gli *agentes in rebus* (funzionari che non avevano un compito specifico, ma gliene veniva assegnato uno diverso di volta in volta, ovviamente, dall'imperatore)

- *Tribuni* e *Notarii* operavano nella cancelleria sotto la guida del *Primicerius notariorum* a cui era affidato l'elenco aggiornato degli ufficiali dei funzionari più elevati (detto *laterculum maius*).

(Consigli e gruppi)

- *Consistorium*

Era "il Consiglio di Stato dell'imperatore" di cui facevano parte i capi dei dicasteri principali.
Deriva dal *consilium* dell'età del principato, ed era l'organo consultivo dell'imperatore.
- I consiglieri si pronunciavano su questioni politiche amministrative.
- Il consistorium interveniva anche nella formazione delle leggi, e talvolta come suprema corte di giustizia.
Quando si riuniva in assenza dell'imperatore le sue decisioni devono essere ratificate.

- *Comitatus*

Di cui facevano parte tutte quelle persone che formavano la casa privata, le guardie, gli impiegati civili, ma comprendeva anche ministri e uno dei prefetti del pretorio.
Era un'organismo migrante *E seguiva l'imperatore nei suoi spostamenti da un luogo all'altro.*

Società:
Una prima distinzione più ampia è quella tra *honestiores,* cioè gli appartenenti alle classi più elevate (senatori, cavalieri, veterani, decurioni),e *humiliores* (o *tenuiores*, o *plebeii*).

- I Senatori hanno una propria gerarchia interna (*illustres, spectabiles, clarissimi*) e nel corso del IV secolo, il ceto senatorio, arriva a comprendere gli alti funzionari
- I Cavalieri hanno ormai perso il loro rilievo e non esistono più come ceto autonomo in quanto i più eminenti tra loro rientrano nell'ordine senatorio.

Siamo in una società in cui la ricchezza dipende ancora fondamentalmente dal possesso fondiario, sulla base del quale si distinguono ricchi e poveri; Ma questa non è l'unica divisione che frammenta la società: si distinguono senatori e plebei, militari e dignitari ecclesiastici, e cambia anche il divario fra ieri e schiavi in quanto ormai vige il sistema del colonato.
Oltre al colonato, che riguarda i contadini, in un'ottica più generale, si può notare che tutte le professioni ricevono una forte impronta corporativa e tendono a divenire ereditarie (artigiani, commercianti, armatori o fornai che sono riuniti proprio in collegi).

Una situazione complicata era quella relativa alle tasse:
Queste gravavano soprattutto sugli strati più deboli, e per il particolare meccanismo di riscossione e di garanzia la responsabilità era concentrata nelle mani di decurioni o curiali, i membri dei consigli cittadini, i quali formavano, nelle diverse città, la parte più elevata della popolazione, e che lo Stato lega, anche in questo caso ereditariamente, ai suoi compiti.
È sbagliato pensare che lo Stato impersoni ancora gli interessi dei grandi proprietari terrieri, ma anzi, agli occhi di gruppi sempre più vasti appare come un "nemico" verso il quale, spesso, non si riconosce altra scelta che la disobbedienza o la fuga (Era frequente, ad esempio, il fenomeno del brigantaggio).

Il Diritto

In un contesto in cui l'organizzazione è centralizzata e burocratica si esige una rigorosa applicazione ed esecuzione del diritto in quanto il diritto è una leva del potere e va controllato sia nelle sue forme di produzione sia nella sua applicazione.
Possiamo quindi affermare che il diritto dell'età tardo antica vede i suoi momenti fondamentali nella legge e nel codice.

> Dunque se è vero che lo scenario del periodo tardo antico appare in disfacimento, e anche vero che l'età tardo antica ha fecondato la novità del codice consegnando al futuro delle istituzioni irremovibili.

> Un passo importante è infatti la questione della scrittura:
Sino ad allora la dimensione della scrittura non aveva rappresentato l'unica dimensione del diritto, tutt'altro, era stata trascurata e considerata residuale. Nell'epoca tardo antica questo cambia, e l'unica forma di promulgazione autorizzata del diritto diventa quella scritta.

È proprio nei codici che si racchiuderà il diritto che l'imperatore pone:
Codificare il diritto significa proprio racchiuderlo entro dei testi normativi che sono autorizzati dall'autorità imperiale in quanto l'imperatore si pone come legge vivente: la sua autorità feconda la legge.
Quindi il diritto si identifica con la legge scritta che promana dall'autorità imperiale.
I codici andranno a racchiudere questo diritto imposto dall'imperatore e anche gli atti normativi dell'imperatore, cioè le ***costituzioni***.

> *Costituzioni imperiali e Lex generalis*

Le costituzioni imperiali sono leggi che potevano avere effetti diversi a seconda della loro efficacia:

- *Generale*
  Quando si parla di costituzione ad efficacia generale, si fa riferimento a quelle costituzioni che perseguivano i propri effetti con riguardo ad una generalità di casi o soggetti.
- *Particolare*
  Quando si parla di costituzione ad efficacia particolare, si fa riferimento ad una legge che si rivolge ad un caso specifico.

Queste vengono riprese dall'epoca del principato in cui rappresentavano ciò che l'imperatore stabiliva attraverso gli atti normativi: *mandata, edicta, rescripta* e *decreta*. (costituzioni di efficacia particolare)
Queste singole forme di atti normativi, però, mutano, o comunque non conservano sempre lo stesso rilievo che avevano durante il principato, ad esempio:
- I *mandata* in quanto istruzione di carattere generale impartito ai funzionari sì c'erano sotto altro nome o scompaiono del tutto.
- I *rescripta* iniziano a confondersi con i decreti a seguito dello sviluppo della procedura *per rescriptum** ed inoltre la loro potenziale efficace oltre il particolare (del caso singolo e della singola controversia) inizia ad essere sempre più limitata.

  * Procedura *per rescriptum*: cioè chi dava inizio alla lite si rivolgeva all'imperatore esponendone l'oggetto con un *libellus*, una *supplicatio* o delle *preces,* e la risposta dell'imperatore era il *rescriptum*, che nel momento in cui non aveva un effetto immediatamente decisorio, in sostanza come se fosse un *decreto*, andava comunque a vincolare il giudice qualora i fatti fossero stati veritieri e la norma imperiale non in contrasto con il diritto vigente.)

Vengono introdotte poi:
- L'*adnotatio*
C'è una risposta alle istanze presentate all'imperatore scritta al margine della richiesta, quasi come un rescritto
- La *sanctio pragmatica*
Che si sviluppa a partire dal V secolo, ed è una via di mezzo tra il rescritto e la *Lex generalis.*

- *Lex generalis (o nomos ghenikos)*

È Costantino a dar vita alle *leges genarales,* che sono delle costituzioni di efficacia generale con le quali vengono definitivamente accantonati i rescritti; la sfiducia nei confronti dei rescritti, nacque infatti a causa della forte corruzione all'interno dei tribunali, che portò gli imperatori ad affidare al giudice il compito di accertare prima la verità dei fatti, e poi procedere all'emissione della sentenza.

> Da Costantino in poi gli imperatori si registra che gli imperatori svolgessero la loro attività normativa principalmente attraverso editti e “leggi generali”.

2. Una mentalità legalistica

Se a partire dall'età tardo antica il diritto romano si era sempre caratterizzato per essere composito, in quanto si rifaceva ad una molteplicità di fonti, e l'interpretazione dei giuristi rappresentava il cuore pulsante dell'attività normativa, nell'età tardo antica cambia tutto.

C'è una riduzione: l'unica fonte di produzione del diritto e la legge dell'imperatore.
Si radica dunque nella sensibilità dell'epoca tardo antica la cosiddetta "mentalità legalistica" che è proprio quella mentalità che identifica il diritto con la legge scritta prodotta dall'autorità imperiale.

(Testo pag. 360)
A questo proposito è significativo un estratto del secondo dialogo delle *Erotapokriseis*.
Le *Erotapokriseis* che può essere tradotto con *"domande risposte"* sono un'opera dalla paternità incerta:
- Molti la attribuiscono ad un certo Cesario Dinazianzo (si dice appunto che è un testo Pseudo-Cesario), medico e funzionario presso la corte di Costanzo II e poi Gioviano e Valente (in sintesi ricoprì queste funzioni tra 317 e 328 d.C.);
- Anche la datazione di quest'opera è incerta, la critica ha oscillato tra la fine del IV secolo, gli inizi del V secolo e la metà del VI secolo, ma convenzionalmente si è portati a farla risalire, appunto, a VI secolo, fu probabilmente composta durante il regno di Giustiniano (527-548 , e quindi seconda metà del VI secolo).
A prescindere dalla datazione specifica, è certo e sicuro che risalga al periodo tardo antico, e ciò che emerge, e che è di estrema importanza è proprio questa mentalità legalistica tardo antica.

- In quest'opera è possibile trovare tutta una serie di dialoghi, appunto, domande e risposte, relativi a problemi teologici o astrologici, tuttavia, proprio nel secondo dialogo, ritroviamo una riflessione che può avere valore anche per cogliere il mutare della sensibilità giuridica nell'età tardo antica.

> Questo testo, che posiamo classificare come fonte atecnica, si apre con il punto di vista dell'autore che, in qualità di portatore di una sensibilità complessiva dell'epoca, riconosce una dualità tra leggi scritte e non scritte, che vede com due poli opposti.
In particolare distingue il testo scritto dalle consuetudini: cioè, identifica le "usanze ancestrali" cioè le consuetudini come leggi orali, non scritte, che sono proprio quelle regole orali che normano e governano una determinata civiltà.
> Dopodiché fa una sorta di valutazione affermando che "leggi nel senso stretto della parola" sono solo quelle scritte, per cui sta dando una connotazione negativa alle leggi non scritte (e quindi alle consuetudini); tant'è che nel testo, quando parla di *"coloro che considerano leggi le usanze ancestrali"*, utilizza il termine *ἀνομόι* che tradotto letteralmente significa proprio "senza leggi".

E la mentalità legalistica è evidente.

> Procede menzionando a titolo esemplificativo ciò che accade nel popolo dei Seri (che sarebbero i cinesi):
- In primis dobbiamo evidenziare quanto sia significativo che quest'autore tardo del V-VI secolo che si trova nell'impero romano, per fare un esempio di popoli guidati da leggi orali richiami proprio i Seri, che sono un popolo così distante, lontano non solo geograficamente (*"abitano sull'estremo confine della terra"*), ma proprio sentito come estremamente distante e diverso; È quasi come se questo autore romano abbia dimenticato del tutto la cultura giuridica romana classica che aveva come matrice istitutiva quella di essere prevalentemente orale.
Non bisogna infatti dimenticare che si inizia a dare maggior valore al diritto scritto proprio in questo periodo, nel periodo tardo antico, e sino ad allora il diritto romano si era mosso in una direzione prevalentemente (anche se non completamente) orale, in quanto era importantissima proprio l'interpretazione dei giuristi che portava continue evoluzioni, ma, appunto, sempre in forma orale.
Quindi è singolare il fatto che ci sia questa lontananza rispetto alla tradizione da parte dei giuristi di epoca classica verso, appunto, i predecessori che non molto tempo addietro avevano prodotto una civiltà giuridica elevatissima quasi interamente orale.

- L’autore dunque afferma che presso il popolo dei Seri vengono osservati i costumi antichi come “leggi” (che ad esempio proibiscono azioni come furto o l’adulterio) e questi sono considerati più importanti addirittura del movimento degli astri; Quindi l'autore vuole mettere in evidenza il fatto che presso questo popolo, cita poi anche gli abitanti della Battriana ed i bramani, la forza vincolante delle consuetudini è maggiore di quella che assicura il movimento degli astri, che dobbiamo immaginare avesse molta importanza per l’autore.

- Ciò che dobbiamo cogliere da questo testo, e che, nell'ambito di una mentalità tardo antica, le leggi per eccellenza sono quelle che esprimono in un testo scritto una volontà precettiva.

(Testo pag. 362)

Sempre nella stessa ottica, è importante uno scritto anonimo d'ispirazione pagana: il *De rebus bellicis* che risale probabilmente al IV secolo d.C.
In base alle informazioni che si possono ricavare dal contenuto di quest'opera, possiamo immaginare che l'autore sia un suddito, un semplice privato, non un militare o un impiegato pubblico, probabilmente appartenente al ceto dei curiali o comunque al ceto medio benestante.
Dunque questo suddito si sta rivolgendo all'imperatore Costantino per polemizzare rispetto alla sua politica monetaria\ tributaria a causa dell'accanimento nei confronti dei problemi militari, infatti bisogna considerare che tanto più la componente militare viene considerata importante, tanto più ne risente la politica tributaria finanziaria, in quanto si cercano sostentamenti per l'esercito e per le campagne militari che tendono a gravare sulla popolazione.

Durante l'impero di Costantino, nacquero delle problematiche del genere nelle varie province dell'impero, in particolar modo, in questo caso, questo suddito appartiene ad una provincia dell’Oriente, E sta manifestando la sua polemica all'imperatore per chiedere un intervento.

> L'autore (il suddito), si rivolge direttamente all'imperatore, e, facendo emergere il binomio *arma* - *leges*, afferma che:
- Così com’è dovere dell'autorità imperiale garantire al popolo una sicurezza militare attraverso presidii presidii militari interni ed esterni (e quindi sia per la protezione dei confini, sia all’interno, per assicurare una vita civile e pacifica alla popolazione)

- Allo stesso modo è necessaria una sicurezza legislativa; Ed è compito dell’imperatore in quanto “autorità altissima”, l’unica autorità da cui può scaturire il diritto (= mentalità legalistica) trovare un *rimedio* rispetto a quelle determinate problematiche e inquietudini che affliggono la popolazione civile relative proprio alla contraddittorietà e confusione delle norme le quali rendono impossibile amministrare la giustizia correttamente, andando a creare un malessere generale che porta poi a delle degenerazioni.
Dunque il suddito sta chiedendo all’imperatore di trovare un *rimedio,* è significativo l’utilizzo proprio questo termine che rimanda alla medicina, e quindi fa riferimento proprio alla necessità di trovare una “soluzione” ad un determinato malessere, dato dalle speculazioni, vessazioni e problematiche della popolazione civile a causa della mancanza di una certezza del diritto.

—> Dunque se nel testo dell’*Erotapokriseis* abbiamo visto come caratteristica fondamentale della della mentalità tardo antica la scrittura delle leggi, ora bisogna cogliere l'idea che la legge deve essere, sì, scritta in quanto c’è la necessità di dare certezza al diritto, ma non solo, emerge propri che questa legge può derivare solo dall'autorità imperiale.

> È possibile inquadrare l'affermarsi della mentalità legalistica come la premessa necessaria allo sviluppo del movimento codificatorio, il quale si sviluppa proprio a partire da questo mutamento profondo del panorama delle fonti di produzione del diritto che vede in concomitanza con l'emersione del potere assoluto del dominato l'identificazione del diritto con le leggi scritte emanati dall'autorità imperiale (la mentalità legalistica)

> In conclusione possiamo, infatti, affermare che in base a questa nuova mentalità legalistica l'imperatore e l'ordinamento non appaiono più come due entità separate, e le leggi che possono essere emanate solo dall'imperatore necessitano di essere scritte, e devono assicurare la protezione in modo eguale a tutti gli uomini: addirittura *l'immunità* veniva giustificata solo nel momento in cui colui che cercava asilo era sfuggito alla prigionia di cittadini potenti, negli altri casi la richiesta di asilo e tutela straordinaria veniva vista come qualcosa fatta per danneggiare gli altri e non per difendere se stessi.

Binomio Leges et Iura

Accanto alla legge, intesa nel suo senso più ampio comprensivo di ogni grado della sua evoluzione nel significato, nell'ambito del diritto romano c'è sempre stata, almeno sin dal periodo della laicizzazione del diritto, l'elemento della produzione giurisprudenziale.

In età tardo antica, questo rapporto lo si racchiude nel binomio Leges et Iura.
Bisogna però fare una precisazione:

Dato che le parole, così come i testi, sono soggette nel tempo a vicende alterne e spesso il loro significato cambia e si evolve, è importante tenere a mente che il binomio Leges et Iura ha una duplice accezione in base al contesto a cui si fa riferimento:

- *In età republicana:*
  Leges = si intendono le norme poste dagli organi costituzionali della città.
  Iura = si intendono le norme consuetudinarie.

- *In età tardo antica:*
  Leges = Costituzioni imperiali
  Iura = Interpretatio prudentium

Questo è un elemento essenziale nel momento in cui si va ad analizzare il movimento codificatorio, in quanto è possibile individuare due patrimoni normativi giuridici oggetto di codificazione: non si tengono in considerazione soltanto le Leges, ma anche gli Iura nell'accezione di produzione giurisprudenziale.

(Si hanno codificazione tanto di Leges quanto di Iura)

> Infatti, così come emerse la volontà di riordinare e fare chiarezza rispetto alla confusione legislativa che rendeva sempre più arduo il compito di amministrare la giustizia, emerse anche la volontà di riordinare e racchiudere nei codici l'enorme patrimonio della produzione intellettuale giurisprudenziale del passato, per far si che non fosse disperso nel tempo, in quanto si riconobbe a questo patrimonio un'utilità nell'applicazione pratica, che era, però, complicata a causa dalla numerosità delle opere e degli autori tra cui districarsi: c'erano proprio difficoltà di consultazione e di orientamento.

<u>E dunque nel periodo tardo antico, con lo sviluppo del movimento codificatorio si avranno:</u>

- Raccolte di Leges
- Raccolte di Iura

Ma anche:

- Raccolte miste di lege et iura

> All'interno delle quali le une si affiancano agli altri per integrarne la conoscenza, cioè da un lato le costituzioni potevano integrare la letteratura giurisprudenziale con nuovi regolamenti più moderni, dall'altro potevano derogare o infrangere i regolamenti per casi specifici o per determinate categorie di persone a titolo eccezionale e per scopi precisi come *ius singulare.*

(*Ius singulare*: si fa riferimento a qualcosa di eccezionale, una deroga che riguarda la situazione specifica, il singolo caso: cioè con lo ius singulare era possibile derogare ad una regolamentazione generale già applicata.)

3. Le vicende della letteratura

Raccolte di iura

Nell'età tardo antica si assiste ad un vero e proprio tramonto della giurisprudenza classica e preclassica, anche questo dipendente da quelle profonde trasformazioni politiche e culturali che coinvolsero l'impero dopo la metà del III secolo.
Nulla accade improvvisamente, infatti già dalla metà del II secolo, e volendo, si può risalire anche al periodo precedente della dinastia dei severi (quindi dall'età tardo-classica), iniziarono a comparire quei primi sintomi che avrebbero poi portato alla conclusione dell'attività giurisprudenziale.
È a partire dall'età dei severi che si avvertì fortemente il sopravanzare dell'autorità del principe anche sotto il profilo dell'attività normativa: iniziò, infatti, da parte del *princeps* un utilizzo sempre più massiccio delle costituzioni come mezzo di creazione del diritto, e di conseguenza le altre fonti di creazione del diritto d'età classica, pur rimanendo in vita, vennero via via sostituite (proprio dalle costituzioni).

Tra l'altro è nello stesso periodo che si va articolando sempre di più l'amministrazione imperiale, e di fatto gli stessi giuristi l'età classica sono proprio impiegati nelle maglie dell'amministrazione imperiale (burocrati, funzionari…), dunque si impegnano e talvolta rivestono cariche anche molto elevate.
Queste sono le basi\ le premesse di ciò che si consoliderà nell'età post classica e nel periodo tardo antico.
E possiamo affermare che con la crisi del principato termina anche il periodo creativo della giurisprudenza proprio perché in concomitanza con l'emergere del dominato, che vede lo sviluppo di questa posizione verticistica, di questa mentalità legalistica che concepisce l'imperatore come "legge vivente" in quanto unica fonte di produzione del diritto, l'attività creativa della giurisprudenza non ha più ragion d'essere, e di fatto si spegne. Si registra una sorta di involuzione dello spirito giuridico.

Il giurista d'età post classica

Raramente lo si vede impegnato nell'analisi minuta delle fattispecie (carattere tipico del giurista repubblicano), è un giurista che ha una formazione libresca, sottile ma priva di realismo, non è un giurista pratico, ma spesso raggiunge soluzioni incerte e approssimative, talvolta astrattizzanti.
Non c'è più traccia del giurista tecnico, specialista che opera nell'età repubblicana e classica.
Inoltre, mentre prima c'erano i nomi dei giuristi sulla scena con le loro proprie fisionomie ben distinte, con i giuristi d'età tardo antica si perde anche quest'aspetto: non troviamo più neanche i nomi a ricordarli.

> Gli ultimi sprazzi di originalità nella produzione giurisprudenziale sono:

- Erennio Modestino (appartenente all'ultima età severiana)
- Ermogeniano (si colloca tra III e IV secolo)
  Autore di una raccolta di 6 libri "*Epitomae Iuris*" e probabilmente anche del *Codex Hermogenianus*.
- Aurelio Arcadio Carisio (anche lui si colloca tra III e IV secolo)
  Fu segretario di stato, autore di diverse monografie relative ad esempio ai *munera civilia* (prestazioni pubbliche), o anche sull'importante carica del prefetto del pretorio.

Dopo di loro si arriva a parlare addirittura di *giuristi epigoni* (epigono= Discepolo o successore, di solito inferiore e decadente, senza personalità né capacità creativa), in generale, la letteratura che viene formandosi in questo periodo, che nella massima parte annoi nota è di origine occidentale, ha carattere anonimo, o l'autore si cela dietro il nome di alcuni grandi giuristi del passato (tarda età classica).
- Dunque non siamo più in grado di ricollegare le opere ad un'immagine della personalità del giurista autore, e dobbiamo anche considerare che nel momento in cui si cela dietro a nomi di giuristi precedenti, è perchè al passato\ al pensiero antico si riconosceva grande autorevolezza e profonda attualità\ vigenza, infatti intervenivano sulle opere dei giuristi del passato con ritagli e selezioni di quanto si riteneva fosse utile al presente e adattabile poi nella concreta applicazione.

Alcuni esempi emblematici di questo genere di letteratura sono:

1- *Epitomae Ulpiani*

"Epitomare" vuol dire proprio "ritagliare"

- Quest'opera sembra coincidere, se non interamente almeno in parte, con il *Liber singularis regularum*, che è uno scritto Pseudo-Ulpianeo, cioè di un'autore del III-IV d.C. falsamente attribuito ad Ulpiano.
- L'Epitomae Ulpiani è una vera e propria silloge con finalità didattiche, cioè racchiude un insieme di scritti di vari autori classici, ad esempio di Gaio (autore del II secolo d.C.) o Ulpiano, non proprio come un manuale, ma con valore prevalentemente didattico.
- La testimonianza di quest'opera ci è pervenuta in maniera frammentaria al di fuori della compilazione Giustinianea, in un rifacimento abbreviato attraverso un manoscritto riscoperto nella biblioteca vaticana.

2- *Pauli Sententiae*

- Cioè le "sentenze di Paolo"; con sententiae si a riferimento alle pronunce\ opinioni consolidate di Giulio Paolo, importante giurista d'età severiana.
- Quest'opera risale probabilmente al III-IV secolo d.C. , si diffuse estesamente sia in Oriente sia in Occidente, ed è anche questa, come l'Epitomae Ulpiani, un'opera elementare (cioè che introduce gli elementi primi del diritto) con funzione prevalentemente didattica.
- Contrariamente a quanto si può immaginare, quest'opera si compone di materiali appartenenti non solo a Giulio Paolo, ma anche tratti da opere di altri giuristi tardo classici; Tanto'è che probabilmente il suo nucleo sei andato costituendo verso la fine del II secolo d.C., prima ancora della vita di Paolo, e non è da escludere che lo stesso testo sia stato alterato nel corso del tempo.

> Le *Pauli Sententiae* venivano spesso impiegate nella pratica giudiziaria citando ed estrapolando le opinioni dei giuristi che vi erano riportati, tant'è che l'imperatore Costantino intervenne e ne disciplinò l'impiego dissipando ogni dubbio rispetto alla loro validità.

(Di Paolo si può inoltre dire che fu probabilmente autore di un'opera che prende il titolo di "*Manualia*", anche questa aveva scopo didattico, e subì una rielaborazione profonda nel corso del tempo perita di essere utilizzata per i *Fragmenta Vaticana*)

3- *Epitomae Gaii*

- Fu scoperta ad Autun, in Francia, ed è una vera e propria sintesi delle *Institutiones* gaiane, che erano un manuale elementare del diritto privato romano redatto da Gaio (giurista del II secolo), in particolare si tratta di una sintesi\ riduzione dei primi 3 libri delle *Institutiones*.
- L'Epitome Gaii non ebbe fortuna nell'immediato, ma solo dopo il periodo in cui fu scritto, sia per i contenuti sia per le modalità di esposizione.

Tutti questi sono testi di facile utilizzo in situazioni pratiche, ed il loro studio approfondito permette di far emergere l'originario contenuto classico su cui poi si sono stratificati i vari interventi dei giuristi, e questo ci consente di osservare come il diritto romano abbia attraversato i secoli, trasformandosi e procedendo verso la sua riduzione volgaristica: Nel senso che c'era stata una vera e propria riduzione di tutte quelle grandi costruzioni intellettuali che erano state frutto dell'elaborazione dei giuristi (ad esempio la scomparsa della dimensione processualistica oppure la scomparsa di alcune distinzioni tra proprietà e possesso), la quale (elaborazione dei giuristi) va semplificandosi all'interno di una cultura che va meno apprezzata in ambito occidentale.

Raccolte miste di leges et iura

I frammenti di queste opere, in realtà, ci sono pervenuti grazie a delle raccolte miste di *leges et iura* (oltre che attraverso le leggi romano-barbariche); queste raccolte sono importanti proprio perché denunciano un'esigenza che a partire da questo periodo durerà per una lunga serie di anni: cioè la volontà di stabilire un legame fra testi legislativi (costituzioni imperiali) e testi giurisprudenziali (scritti classici).

- All'interno di queste raccolte, che sono frutto di un lavoro esegetico (lettura e annotazione\ esplicazione) di raccolta durato oltre un secolo, i brani estratti dalla produzione giurisprudenziale vengono organizzati non secondo il discorso ordinario, ma in maniera frammentata: ci sono cioè delle citazioni tratte da autori diversi adunate intorno a temi di fondo, ma ciascun pensiero era attentamente ricollegato al suo autore di provenienza.

1- <u>*Fragmenta vaticana*</u>

- Tra queste raccolte miste di leges et iura abbiamo i *Fragmenta Vaticana* che sono un'estesa antologia di testi giurisprudenziali e costituzioni imperiali di dimensioni notevoli (ma comunque inferiori rispetto ai digesta giustinianei) risalente prima alla metà del IV secolo d.C., ad un periodo appena posteriore all'età costantinea (La sua composizione deve essere avvenuta subito dopo il 318 d.C. in ambiente occidentale)

- Autore e titolo di quest'opera ci sono ignoti, si chiamano così poiché furono scoperti nel 1821 leggendo un palinsesto nella biblioteca vaticana, appunto, sotto una scrittura del VII secolo d.C. ne emerse un'altra risalente al IV-V secolo d.C. ma hai cancellata.
- Portando avanti il lavoro di decifrazione, tra l'altro, emersero lavori anche di Papiniano, (un giurista d'età severiana) Ulpiano e Paolo.
- Allo stesso modo, sono emerse altre costituzioni di Diocleziano, di Costantino e di altri imperatori come Valentiniano I, Valente…

> Ciò che è chiaro è che agli scritti dei giuri consulti ci si rivolgeva se non con intento critico e capacità creativa, con la preoccupazione di conservarne l'insegnamento

- Questa raccolta ha carattere teoretico, era probabilmente destinata all'insegnamento, e avrebbe dovuto rimpiazzare tutti i materiali circolanti in quanto era anche un compendio utile, maneggevole e più accessibile per chiunque volesse accostarsi all'apprendimento della scienza giuridica.

2- <u>*Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*</u>

- Questa è un'opera molto particolare, quasi un'opera di diritto comparato tra la legge dei mosaici (popolo di Mosè, quindi legge ebraica) e quella dei romani; Riporta, infatti, prima di ogni titolo un passo della legge mosaica.
- In questa raccolta ritroviamo una concatenazione di testi redatta in Occidente senza particolare ordine e metodo, ma con lo scopo di comprare i principi giuridici romani con quelli mosaici (che corrispondono alle prescrizioni della Bibbia) affermando in linea di principio la conformità dei principi romani a quelli mosaici ricavati dalla Bibbia, e infine la superiorità di questi ultimi.

> Vediamo che accanto agli scritti giurisprudenziali, compaiono anche delle costituzioni;

- I nomi più ricorrenti per quanto riguarda la produzione giurisprudenziale sono: Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino: "I grandi della giurisprudenza" , che sono gli autori dell'ultima età classica che ebbero maggiore circolazione, poiché forse nello spirito nella sensibilità erano più vicini a quelli dell'età tardo antica.
- Le costituzioni che compaiono sono in particolare quelle dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, e non compare il codice Teodosiano.

> Il fatto che non compaia il codice Teodosiano che ci aiuta anche nella datazione, poiché dobbiamo intuire che fosse sconosciuto, per cui è possibile far risalire questa *Collatio legumi Mosaicarum et Romanarum* ad un periodo precedente a Teodosio stesso, in particolare la oscilla tra l'inizio e la fine del IV secolo.

3- *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti*

- È un'altro opuscolo anonimo, pubblicato poco prima della metà del V secolo.
- Si tratta raccolta mista di valore modesto, ma ugualmente significativa, in quanto costituisce una collezione di pareri tecnici, cioè di giuriconsulenze su vari argomenti.
- Quasi come se fossero delle esercitazioni giuridico-retoriche, l'autore produce un proprio parere allegando le sue argomentazioni con le costituzioni di riferimento tra quelle contenute nei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, ma sopratutto attinge alle *Pauli Sententiae*, che secondo l'autore riassumono maggiormente, e in modo migliore, i vari pareri giurisprudenziali.

> Alla luce di queste informazioni abbiamo la conferma del fatto che i giuristi poste-classici si presentano in modo estremamente diverso dai loro predecessori.
È chiaro che ci fosse una conoscenza classica che, per quanto pallida, ci permette di avvertire un fortissimo legame con la cultura giuridica passata che si esprimeva in modo vario.
La *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* è una palese testimonianza del fatto che i giuristi post-classici non sembrano essere in grado di esprimere e creare un proprio pensiero originale, o di rinnovare e costruire un discorso giuridico proprio e adeguato i loro tempi, ma si concentrano per lo più a parafrasare o ridurre i testi legislativi e giurisprudenziali di comune impiego cercando, in tal modo, di trarne utilità.

La concezione della produzione giurisprudenziale cambia: La legge delle citazioni

> Capiamo quindi che la letteratura classica continua a circolare, sebbene alterata, riassunta o frantumata in parti diverse nel suo trasmettersi di edizione in edizione, ma cambia il modo in cui vi si attinge, i quanto bisogna adeguarsi ad una nuova mentalità in cui la società è abituata a vedere nel diritto la sola norma imposta da un potere legiferante, e la letteratura giurisprudenziale costituiva un semplice repertorio da cui attingere per la pratica giudiziaria:
- Se prima la produzione giurisprudenziale veniva concepita come manifestazione classica di un pensiero continuo mi pento, simbolo di un dinamismo estremo legato alle esigenze della pratica, e veniva adoperata e studiata come pensiero in continua evoluzione.
- Ora non più: viene ritenuta un utile repertorio di soluzioni possibili a cui fare riferimento, ma che è chiuso in se, "cristallizzato", in quanto non c'è più un'attività creativa da parte dei giuristi.

> Tant'è che proprio in questo periodo iniziò a diffondersi una pratica giudiziaria secondo la quale erano le parti o i loro avvocati a dover indicare al giudice, che ricordiamo, era spesso tecnicamente impreparato, le norme su cui avrebbe dovuto fondarsi nella pronuncia della sentenza.
Tuttavia non ci si limitava solo a leggere in giudizio le costituzioni imperiali (unici testi normativi), ma si menzionavano, secondo la pratica della *recitatio* (menzione\ citazione), di volta in volta, in base alla propria cultura personale, le varie opinioni dei giuristi antichi (e quindi si attingeva alla produzione giurisprudenziale in qualità di "repertorio di soluzioni a casi concreti") come se fossero vere e proprie norme.

Ma spesso i pareri dei giuristi antichi venivano invocati in modo abusivo, se ne faceva uso improprio, in quanto vi era l'incertezza dei testi consultati.
Non sempre, infatti, erano autentici: capitava che ci fossero opere attribuite a determinati giuristi la cui autenticità non era comprovata (spesso si avevano molte difficoltà proprio nella consultazione di queste opere che erano alterate o troppo numerose nelle loro edizioni), e quindi citare in giudizio qualcosa di non autentico per avvalorare le proprie tesi, risultava fuorviante, infatti ci poteva essere un avvocato accorto che adduceva in qualsiasi momento citazioni pratiche tratte dalla produzione giurisprudenziale della tradizione imperiale, e pretendeva che il giudice ne tenesse conto, e allo stesso tempo ci poteva essere un avvocato meno accorto, non in grado di fornire i giusti testi, e alla fine il giudice si trovava in serie difficoltà nel dover comprendere quale tra i due testi potesse essere ritenuto più importante nella decisione finale.

> Dunque, non avendo i giudici abbastanza regole su cui orientarsi, nacque l'esigenza di una legge che andasse a fissare un limite ed un criterio da seguire per la *recitatio* nella pratica giudiziaria.

> Fu Valentiniano III, nel 426 d.C., nella parte occidentale dell'impero, presso la cancelleria imperiale della Galla Placidia, a concepire questa costituzione\ testo normativo che determinava le regole per l'impiego, da parte di avvocati e giudici, della letteratura giurisprudenziale classica nella pratica giudiziaria.

> Questa costituzione, a cui facciamo riferimento con il nome di ***Legge delle citazioni***, fu accolta poi nel Codice Teodosiano: dunque vediamo inclusi, proprio nel primo libro della redazione conclusiva del codice Teodosiano, i criteri in base ai quali i giudici, i privati ed i giuristi dovevano procedere alla consultazione e utilizzo delle opere dei giuristi di età precedente nella pratica giudiziaria.

(Testo pag.368)
La legge delle citazioni comincia con quel "confermiamo" che de nota proprio l'autorevolezza della voce imperiale, che in questo caso sta dando validità e autorevolezza agli scritti di Papinano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, che tra l'altro sono proprio quei cinque giuristi le cui opere erano presenti in maggioranza in quelle che abbiamo visto essere le compilazioni miste di leges et iura.

- Notiamo che sono tutti i giuristi appartenenti alla tarda età classica (età severiana) ad eccezione di gaio, che appartiene ad un periodo immediatamente precedente (II d.C. - età antonina).
Gaio riceve infatti una fortuna postuma, e nella stessa costituzione, viene fatta una precisazione, si esplicita proprio che a gaio deve essere riconosciuta la stessa autorità degli altri quattro (come sì gli si volesse restituire un'autorevolezza postuma rispetto la sfortuna che lo aveva accompagnato in vita).
- Per cui capiamo che tutti e cinque questi giuristi devono essere considerati sullo stesso piano e che così come sono valide le opinioni dei quattro giuristi d'età classica, allo stesso modo si possono attingere da tutto ciò che è stato prodotto da Gaio "dall'intera sua opera" le opinioni da recitare nel processo come argomenti che avvalorano determinate tesi di pensiero.

- Dopodiché, il raggio dei giuristi citabili e delle opere che si possono considerare valide per trarre le opinioni da citare in giudizio, si espande, in quanto si dà validità anche alle opere citate dai 5 giuristi nominati in precedenza: cioè, Papinano, Gaio, Paolo, Ulpiano e Modestino nelle loro opere citavano altri giuristi del passato (proprio interloquendo e confrontandosi con loro come se fossero ancora vivi) e ne richiamavano i pareri (vengono menzionati ad esempio Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello).
Quindi, creando una sorta di catena che allarga indietro nel tempo la rosa delle opinioni citabili, si dà validità allo stesso modo anche alle parole di questi altri giuristi.
- Per cui è possibile menzionarli nei processi, ma ad una condizione: viene infatti precisato che, essendo le opere di questi giuristi molto antiche, bisognava che ne fosse garantita l'autenticità, ciò accadeva attraverso la collazione (= confronto) dei manoscritti circolanti.

Affronta poi il problema dei <u>criteri con cui il giudice può orientarsi</u> nel nel caso in cui si ritrovi di fronte a citazioni di diversi giuristi ugualmente valide, e notiamo che sono dei veri e propri criteri numerici:

- Nel caso in cui ci si ritrovi innanzi a due opinioni diverse, sostenute l'una e l'altra da più autori tra quelli citabili, si stabilisce un criterio di maggioranza:
Cioè vale l'opinione sostenuta in maggioranza (es. Se Gaio e Modestino sostengono un determinato argomento, e Paolo ne sostiene un altro, prevale l'opinione di Gaio e Modestino che costituiscono la maggioranza = due al fronte di uno).
- Però, nel caso in cui ci si ritrovi innanzi a due opinioni diverse sostenute da due soli di questi cinque giuristi, di cui una è sostenuta da Papiniano, quella di Papiniano prevarrà sempre, in quanto gli si riconosce una maggiore autorevolezza. Tuttavia "egli deve cedere rispetto a due" cioè la sua opinione soccombe ugualmente al criterio di maggioranza qualora l'altra opinione sia sostenuta dalla maggioranza degli altri giuristi citabili.
- Inoltre, e qui capiamo quanto Papiniano fosse considerato d'ingegno straordinario, si stabiliva che fossero considerate invalide le annotazioni al suo pensiero; anche se erano annotazioni di giuristi importanti come Paolo o Ulpiano non potevano essere prese in considerazione.

- Si pone poi il caso che due opinioni contrastanti siano sostenute l'una e l'altra dallo stesso numero di giuristi citabili, in questo caso si stabiliva che dovesse essere l'equità del giudice, le sue capacità, il suo buon senso, a scegliere per quale delle due opinioni propendere.
- Ed infine conclude confermando la validità delle *Pauli Senetentiae.*

> Appare chiaramente che i giuristi sono ormai divenuti "le semplici cifre di un calcolo giuridico".
È quasi come se i giuristi fossero stati appiattiti e privati della loro fisionomia, in quanto non vengono messi in evidenza per tutto il ragionamento che hanno condotto attorno ai casi concreti, ma viene estrapolato il loro semplice parere per il caso specifico e a questo parere viene assegnato un valore numerico espresso nel criterio di maggioranza, minoranza, uguaglianza.
Anche nel caso di Papiniano: la sua fama viene piegata ad un fine prettamente pratico, diventa un valore numerico.

> Vediamo inoltre che i giuristi del passato recuperano la loro voce attraverso l'autorità imperiale, poiché è l'imperatore che ne autorizza l'impiego e ne regolamenta i criteri di selezione, e lo fa attraverso una costituzione che promana egli stesso in quanto unica autorità legiferante (In pieno rispetto della mentalità legalistica: vene conferita autorità delle opere e al pensiero dei giuristi del passato in virtù della volontà imperiale), E di fatto non è altro che è un primo intervento di riordino degli iura che avviene dall'alto del potere ufficiale il quale vuole porre rimedio alle difficoltà della pratica giudiziaria.

—> Quindi, a distanza di tempo, l'imperatore riprende i contenuti della produzione giurisprudenziale e, tramite delle sue disposizioni, li fa rivivere attribuendogli valore normativo.

> Questa posizione (= la legge delle citazioni) resta in vigore per un secolo finché non si arriverà la compilazione Giustinianea

4. Il codice come libro e come testo legislativo: raccolte non ufficiali e codificazione teodosiana

Raccolte di Leges

Il movimento codificatorio

Abbiamo visto, dunque, che il movimento codificatorio nasce dalla necessità di porre un rimedio alla confusione legislativa che rendeva ancora più arduo il compito di amministrare la giustizia e questo perché vi erano tutta una serie di problematiche:

1- La conoscenza delle leggi imperiali era frammentaria ed insicura: il loro metodo di pubblicazione e diffusione era inadeguato, ed era proprio difficile accedere alla conoscenza delle norme stesse.
2- Vi si riscontravano anche numerose difficoltà relative al variare dell'efficacia delle costituzioni (che poteva essere generale o particolare)
3- Anche la divisione amministrativa dell'impero in due parti distinte era motivo di confusione.
4- E anche (per quanto riguarda le raccolte di Iura) bisogna considerare che le opinioni dei giuristi antichi erano disperse in un numero in mensa di libri.

> Quindi nacque il bisogno di riordinare e riorganizzare tutte le norme da applicare ai fini di una *claritas* che rischiarasse *l'obscuritas* dell'apparato normativo confusionario che si era venuto formando fino ad ora.

> Il codice, allora, risultò essere lo strumento adatto a questo scopo.
- È un modo diverso di trasmissione del sapere che si adatta perfettamente al diritto che, in questo periodo, va alla ricerca di una manifestazione solenne; Il che vale anche per le opere dei giuristi classici, in quanto quasi in maniera utilitaristica, non diventano altro che lo strumento o il veicolo della volontà del principe.
- Per cui si instaura un legame intrinseco fra codice e autorità.

> Il codice, però, prima di essere un testo giuridico, è una vera propria forma libraria che si discosta dall'idea moderna di "libro": il *codex* antico è infatti composto da quaderni pergamenacei o papiracei rilegati insieme.
- L'introduzione e la diffusione del codex ha inizio verso la fine del I secolo d.C. e si conclude nel IV secolo d.C., periodo in cui, gradualmente, andò a rimpiazzare l'uso del rotolo di papiro.
- Il codex infatti quanto a funzionalità e resistenza era preferibile al papiro fragile e scomodo (poiché per essere letto necessitava di essere srotolato), ma non solo, il papiro era anche significativo di una cultura elitaria in quanto non tutti potevano accedervi al contrario del codice che, data anche la sua relativa economicità, si faceva strumento di comunicazione e di formazione culturale adatto anche alle classi meno abbienti (tant'è che divenne il principale veicolo della letteratura cristiana, soprattutto biblica).

> Dobbiamo inquadrare il passaggio al codice come segno di un mutamento non solo tecnico ma anche psicologico; Ciò che ha portato al passaggio dalla tradizione orale (che aveva caratterizzato il diritto romano fino a questo momento) a quella scritta del codice sono stati quei profondi cambiamenti psicologico-sociali che hanno caratterizzato il modo romano nel periodo tardo antico:
> E quindi la diffusione della mentalità legalistica che portava con se:
- La riduzione all'unità delle fonti di produzione del diritto, in quanto vi è il predominio dell'imperatore che incarna su di sé la legge vivente a dispetto della molteplicità di fonti dell'età classica,

- E allo stesso modo, se <u>in età classica</u> (ma anche nella prima età repubblicana), si attribuiva un enorme valore all'interpretazione dei giuristi, che erano il cuore pulsante della produzione del diritto poiché interagendo con tutte le altre fonti di produzione del diritto riusciva a far evolvere il diritto stresso,

nel <u>periodo tardo antico</u> la giurisprudenza si spegne in virtù dell'assolutismo e dell'autorità imperiale, e rivive soltanto attraverso di essa (attraverso l'autorità imperiale) e attraverso le sue stesse costituzioni, in quanto, considerando ad esempio la legge delle citazioni, è l'autorità imperiale che ne autorizza l'impiego regolamentandone i criteri di selezione: quindi è l'imperatore che restituisce valore al pensiero dei vari giuristi attraverso costituzioni scritte, nel pieno rispetto della mentalità legalistica (attraverso la sua autorità rende normativo un diritto che si è prodotto nel passato ed è stato tramandato oralmente).

Le prime raccolte non ufficiali

> Verso la fine del III secolo d.C., l'idea di codice come raccolta normativa autoritativa si era ormai fatta strada, ed è in questo momento che compaiono i primi tentativi di soddisfare l'esigenza di racchiudere entro un testo le norme perché si abbia un riferimento quantomeno univoco delle norme applicabili.

Emergono, infatti, delle iniziative di privati che in autonomia producono due codici:

- *Codex Gregorianus*
- *Codex Hermogenianus*

(Ci sono pervenuti entrambi indirettamente; li conosciamo attraverso due epitomi incluse nella *Lex romana Visigothorum* e da alcuni frammenti della *Lex romana Burgundionum* e della letteratura giuridica tarda.)

> Alcuni ritengono che questi due codici siano il risultato di un lavoro scolastico sulle fonti del diritto imperiale, tuttavia siamo più inclini a credere che i due autori Gregorio ed Ermogeniano fossero due privati, sudditi dell'impero, molto probabilmente dei funzionari che avevano rivestito qualche incarico importante nell'ambito dell'amministrazione pubblica\ della burocrazia imperiale, e che quindi fossero autorizzati ad avere accesso agli archivi imperiali e a tutta la documentazione necessaria per allestire questi due codici.

> Il codice Gregoriano ed il codice Ermogeniano sono infatti due raccolte di costituzioni pubbliche che, naturalmente, non hanno valore ufficiale anche se sono in linea con la politica dominante:

- Ciò che è certo, è che i due autori avessero colto in pieno lo spirito dell'epoca e sentivano come propria la sfida di trovare ordine nella confusione normativa.

> Questi due codici si pongono quasi in maniera complementare l'uno con l'altro:

- Il *Codex Gregorianus*

  Raccoglie le costituzioni (per lo più rescritti indirizzati a privati) a partire dall'età Adrianea Sino al 291.

  Si compone di almeno 13 (forse 15) libri, divisi in titoli e, che seguono l'ordine edittale per quanto riguarda il diritto privato, ma contiene anche delle costituzioni in ambito diritto penale pubblico (i reati).

- Il *Codex Hermogenianus*

  Completa il Codice Gregoriano raccogliendo le costituzioni Dioclezianee del 293 e 294 d.C.
  Conteneva un numero elevatissimo di costituzioni prive di revisioni proprio per dar vita ad una raccolta il più possibile completa, che era facile da consultare grazie alla divisione interna in titoli (ma non in libri)

  Molti studi convengono nell'identificare l'Ermogeniano autore di questo codice con l'Ermogeniano autore dell'*Epitomae iuris*, il che sarebbe un dato significativo, in quanto si sa per certo che l'Ermogeniano autore dell'*Epitomae iuris* avesse rivestito un incarico importante nella cancelleria di Diocleziano, e qualora si tratti dello stesso autore, ciò conferirebbe al *codex Hermogenianus* carattere di semi ufficialità. La provenienza dell'autore, infatti, poteva conferire questo carattere che avrebbe restituito all'opera uno scopo importante, simbolico nell'istituzione della tetrarchia, in quanto rispondeva all'esigenza\ necessità di avere un diritto per iscritto.

> La lacuna temporale dell'anno 292 ha lasciato spazio a dei dubbi rispetto ai quali sono state formulate delle ipotesi:

- Si pensa o che Ermogeniano avesse rivestito un incarico nella cancelleria di Giustiniano solo a partire dal 293, e quindi non abbia avuto accesso agli archivi di quell'anno.
- Oppure semplicemente il 292 è stato un anno privo di costituzioni ed interventi normativi imperiali

> Questi due codici, seppur creati per iniziativa di privati, hanno una rilevanza non indifferente in quanto segni inaugurali di quella nuova sensibilità, necessità, urgenza di fare ordine nella produzione legislativa.

(Un’altra raccolta che si può citare, ma di minore importanza, è una raccolta privata composta da 16 costituzioni imperiali risalenti ad un periodo tra il 333 e il 425 d.C., fu allestita in Occidente, e la si ricorda con il nome del suo primo editore: è denominata la “*sirmondiana*”)

Codificazione Teodosiana

La prima iniziativa che edificatoria di carattere ufficiale fu quella teodosiana.
Teodosio II, Augusto d'oriente, nel Marzo del 429 d.C. ordinò ad una commissione (formata perlopiù da burocrati) di portare avanti un progetto molto ambizioso che prevedeva la compilazione di due codici che dovevano avere funzione e caratteristiche differenti, ma che di fatto non fu portata a termine.

1- ***Il primo codice***

Nel Primo codice dovevano essere raccolte tutte le costituzioni di efficacia generale, vigenti e non vigenti, emanate da Costantino (dal 306 d.C. in avanti).
> Lo ***scopo*** di includere sia le costituzioni vigenti, sia quelle cadute in desuetudine, era quello di far conoscere quelle regole giuridiche che seppur ormai valide solo per i bisogni pratici del proprio tempo, mantenevano un valore storico importante.
- Capiamo allora che si voleva dare a questo codice una sorta di *intentio scholastica*: un valore pedagogico. Si voleva costituire un repertorio di contenuti giuridici fondamentali utili per l'insegnamento e per lo studio, ma anche funzionali nella pratica, proprio perché si aveva la possibilità di comprendere come un preciso momento storico-politico avesse prodotto un determinato tipo di risposta del potere attraverso un determinato tipo di normativa, indipendentemente dal fatto che fosse stata soppiantata da altre norme dopo essere caduta in desuetudine, in quanto era qualcosa di estremamente importante sul piano pedagogico.
- I testi normativi potevano essere divisi in titoli diversi, veniva data alle parole un'importanza essenziale: queste si conservavano solo se portatrici di un contenuto giuridico, non c'era spazio per “una vuota copiosità”, non si conservavano le parole aggiunte “senza una necessità intrinseca”.
- Le costituzioni desuete, erano ben distinte da quelle indigenza, ma questa compresenza tra ciò che vige e ciò che non vige costituiva un anello simbolico dato dalla presenza di un intreccio tra vecchio e nuovo.

Ciò lascia emergere un'idea di fondo di continuità che rimane sempre in vita, e che rispetta appieno la mentalità tradizionalistica secondo cui ciò che è antico e durevole è estremamente importante, non è qualcosa che può essere abbandonato: Per cui, la legislazione nel suo accumularsi nel tempo arriva a costituire qualcosa di durevole e continuativo al punto che anche ciò che ormai era stato superato, non avrebbe mai perso un valore storico intrinseco.
- Dunque con questo codice sarebbero addirittura stati conservati i due codici precedenti (Gregoriano ed Ermogeniano) per quello che riguarda le costituzioni comprese tra l’età adrianea e dioclezianea. Il loro modello compilatori e venne conservato e considerato un modello da seguire.
Così facendo, se il progetto fosse andato a buon fine, sarebbe stata costituita una rassegna completa delle costituzioni imperiali da Adriano fino a Teodosio II

2- ***Il secondo codice***

Nel secondo codice dovevano essere raccolte solo le costituzioni in vigore già ricomprese nel primo, insieme a quelle che si ricavavano dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, ma includendo anche a quanto di utile si poteva ricavare, titolo per titolo, dai trattati e dei responsi giurisprudenziali.
> Lo ***scopo*** era infatti quello di assolvere alla funzione di magisterium vitae, ovvero di direzione della vita pratica: era destinato principalmente alla vita pratica giudiziaria, doveva infatti indicare tutte le norme da seguire e di comportamenti da evitare avvalendosi anche del contributo della giurisprudenza del passato per integrare meglio quanto espresso dalle norme imperiali.
In questo modo si sarebbe arrivati ad allestire un codice organico e chiaro, privo di contraddizioni, ripetizioni o incongruenze, integrato anche con una selezione di commenti della giurisprudenza.
- La presenza della produzione giurisprudenziale (a cui evidentemente si attribuiva un valore tale da avere la necessità che quel patrimonio non dovesse essere disperse) indica che l'intento era anche quello di riunire

“tutto il diritto”, anche quello prodotto in passato dai giuristi, in quanto i loro responsi, inseriti all'interno di questo codice, avrebbero assunto lo stesso valore autoritativo delle costituzioni imperiali.

(Se fosse stato portato a termine il progetto, con questo secondo codice, la legge delle citazioni avrebbe perso il suo valore, così come in effetti accadrà con la compilazione dei Digesta giustinianei)

> Questo progetto fallì

- Forse per l'impreparazione dei commissari imperiali.
- Anche se molti, non riscontrando segni di impreparazione nell'elaborazione di quel codice Teodosiano di cui abbiamo contezza, in quanto è un codice ordinato e chiaro (per cui è improbabile che poco prima fossero impreparati), ritengono che il motivo per cui questo ambizioso progetto sia fallito, è che non era stata data ai commissari abbastanza libertà di intervento sui materiali, cosa che invece fu fatta nei riguardi della seconda commissione:

> Infatti, Teodosio II, nel 435 investì una ***nuova commissione*** del compito di redigere un unico codice diviso in 16 libri che doveva raccogliere tutte le costituzioni imperiali di carattere generale da Costantino in avanti, con la possibilità di introdurre modifiche, tagli e aggiunte.

> All’interno dei libri il contenuto era diviso in titoli per materia, in ciascun titolo, poi, le norme erano organizzate cronologicamente:

- Si ritrovava una *inscriptio* (lett. “ciò che è scritto prima”) che precedeva ogni costituzione, che conteneva il nome dell'imperatore emanante e del destinatario della costituzione (che poteva essere il popolo, il Senato, i consoli…)
- E alla fine una *subscriptio* (lett. “ciò che hai scritto sotto”) che indicava l'anno di emanazione.

> Si abbandonò il progetto di inserire anche i commenti della giurisprudenza, ma di fatto verrà compresa la “legge delle citazioni” cioè quella costituzione che regolava i criteri per l'impiego delle citazioni dei giuristi durante le azioni processuali.

> Il 15 febbraio del 438, nella parte orientale dell’impero, dopo all'incirca un decennio di lavoro, fu emanato il codice Teodosiano la cui efficacia durò un secolo, fino alla compilazione giustinianea.

(Le norme del codice Teodosiano furono anche trasferite o abbreviate e nella legislazione romano-visigotica e romano-Burgundica fino ad arrivare ad essere applicate ancora dopo l'età carolingia nel sud della Francia, ma anche in Spagna durante e oltre la dominazione araba).

Grazie, allora, alla compilazione Teodosiana, che entrò in vigore il primo giorno dell'anno successivo rispetto alla sua emanazione (quindi nel 439), finalmente nei tribunali si iniziò ad avere una certezza effettiva del diritto applicabile: L’autorità imperiale, infatti, promuoveva questo codice come unica fonte di diritto applicabile, tanto che sembrava non esserci più bisogno degli esperti.

Dobbiamo però considerare che, nonostante non si potesse applicare un diritto diverso da quello che conteneva, almeno per il periodo a cui si riferiva, il codice Teodosiano non comprendeva tutto il diritto, anche perché nuove costituzioni continuavano ad essere emanate, E, una volta trasmesse nelle forme necessarie, avrebbero avuto efficacia in entrambe le parti dell’impero (eventualmente andando a soppiantare costituzioni precedenti anche contenute nel codice).

Inoltre bisogna anche considerare che i due codici precedenti (Gregoriano ed Ermogeniano) continuarono a circolare, e le norme giurisprudenziali continuano ad essere applicate secondo criteri dettati dalla legislazione.

> il codice Teodosiano si distingue dai due precedenti, non solo per il suo carattere ufficiale e per la cronologia delle costituzioni raccolte, ma anche per la sua struttura: comprende infatti solo costituzioni generali (Sebbene il grado di generalità possa variare), e ciò fece assumere un'assoluta prevalenza al diritto pubblico.

(Es. Il diritto privato nel Gregoriano occupa 13 libri, nel Teodosiano 4 + un gruppo di titoli nel libro 8)

5. La "sapienza giuridica" dei re barbari

Il movimento codificatorio, ovviamente, non si chiude con la raccolta di Teodosio II, ma trascorsa poco più di una generazione dall'emanazione del codice Teodosiano, l'impero d'Occidente cadde (nel 476 d.C.) proprio a causa della frammentazione in una moltitudine di regni barbarici.

Edward Gibbon, storico inglese del '700 nella sua opera *"Decline and Fall"* ("Storia della decadenza e caduta") che si occupa proprio di questo momento di crisi e frammentazione dell'impero, ce ne offre una descrizione molto efficace:

- Nella descrizione di Gibbon viene estrapolata un'immagine che rappresenta l'impero romano d'Occidente al momento della caduta, da cui se ne avverte l'estensione ma anche la frammentazione, in quanto l'impero si ritrovava ad essere suddiviso in una miriade di regni e spartito tra i vari barbari: Sassoni, Britanni, Franchi, Visigoti, Svevi, Burgundi, Mauri, Vandali, Ostrogoti…

> Questo passaggio dei barbari in ogni caso trovò un terreno fortemente impregnato di cultura giuridica romana, di fronte alla quale persino le popolazioni barbariche, in qualche maniera, ne riconobbero la superiorità.

> Ciascun popolo, inoltre, anche quando riconosceva formalmente la sovranità dell'imperatore d'oriente, comunque governava in base ad un potere autonomo sia sulle proprie genti, sia sulle popolazioni romane o romanizzate su cui avevano imposto la loro presenza.
Quindi in generale ciascuna stirpe (sassone, sveva etc.) viveva secondo la propria legge e il proprio dritto.

> Tutto ciò comportò delle difficolta per la popolazione romana, che naturalmente subiva questo declino culturale ed economico dei barbari che avevo reciso ogni legame con il resto dell'impero, quindi si sentì l'esigenza di una sintesi breve e chiara del diritto romano.

> Le maggiori testimonianze sono delle modeste compilazioni di scritti giurisprudenziali e leggi imperiali, editate dai re barbari sullo scorcio del V sec. d.C., e stiamo parlando delle ***"leggi romano-barbariche".***

- Quando si parla di *"Sapienza giuridica di re Barbari"* è perché naturalmente questi sovrani diedero vita a delle compilazioni di leggi che tenevano conto del diritto romano preesistente che era presente nel territorio e a cui la stessa popolazione era abituata.

> Lo ***scopo*** di queste compilazioni era vario:
1- Alcune furono redatte per ricreare quelle regole del diritto romano che i re barbari volevano si applicassero anche alle loro popolazioni (e qui leggiamo una sorta di riconoscimento della superiorità della cultura giuridica romana)
2- Altre invece furono messe insieme per sintetizzare i principi di diritto applicabili solo ai sudditi di nazionalità romana (quindi qualcosa di utile alle popolazioni barbariche anche solo nei rapporti con la popolazione romana, ma in generale comunque avvertivano questa importanza e questa rilevanza della cultura giuridica romana).
3- Altre invece furono volte a rendere più facile la gestione delle popolazioni assoggettate di nazionalità romana.

> Le compilazioni romano-barbariche sono inoltre estremamente importanti, in quanto racchiudevano la cultura giuridica romana e spesso, lo si vede dalle fonti a cui si rifanno, sono state il veicolo della conoscenza\ della trasmissione del sapere di costituzioni romane del passato e anche di contenuti giurisprudenziali (= quindi di opere della giurisprudenza)

> Ecco che capiamo che queste leggi romano-barbariche hanno una doppia valenza:
1) Sia proprio come attestazione di una risposta dei barbari (nella parte occidentale dell'impero) nel rapporto con le popolazioni romane e con la cultura romanizzata,
2) E poi anche come veicolo della conoscenza per il futuro, e quindi nella trasmissione della conoscenza delle costituzioni del passato e anche del recente passato.

Tra queste compilazioni ricordiamo:

1. *L'Edictum Theoderici*

- Riferibile o a *Teodorico il Grande l'Ostrogoto* , oppure *Teodorico II* re dei Visigoti.
- Risale all'870 d.C. ed ebbe, si pensa, efficacia territoriale.
- Fu concepito in un contesto sociale in cui l'arbitrio dei potenti non faceva che calpestare le leggi, e vi era anche una particolare violenza di bande armate nelle campagne: Quindi era una situazione particolarmente complicata che esigeva un minimo di imposizione \ regolamentazione dall'alto, ed ecco perché intervenne, ecco quindi lo scopo.

> Il testo dell'editto, oltre ad un prologo, contiene un epilogo particolarmente interessante in cui si dice:

"come il legislatore ha inteso provvedere alla sicurezza di tutti i sudditi, così l'intera comunità deve rispettare il suo ordinamento."

- E questo è una sorta di ammonimento: avendo fatto sentire la priorità legislativa dall'alto, si cercava di garantire l'ossequio delle norme dicendo "io autorità imperiale (Teodorico) ho provveduto a fornirvi una sicurezza\ certezza attraverso un corpo normativo, a questo punto è doveroso da parte vostra l'ossequio alle stesse".

> L'editto di Teodorico contiene 154 capitoli le cui *fonti* sono:

- Il codice Gregoriano,
- Il codice Ermogeniano
- Il codice Teodosiano
- Delle Novelle post-Teodosiane (di cui si ebbero varie raccolte private tra V e VI secolo)
- E in più le *Pauli sententiae* (opera giurisprudenziale tarda).

2. *Lex Romana Visigothorum*

- Questa è un'altra compilazione, un'altra legge romano barbarica detta anche *Breviario Alariciano,* poiché riferita ad Alarìco II, che nel 506 d.C.

Quest'intervento legislativo si rese necessario in quanto i Franchi cattolici stavano affermando il loro predominio anche sul territorio su cui si erano stanziati, per cui, cercando in extremis di rafforzare l'intesa con la chiesa cattolica (in quanto i Visigoti erano eretici), emanò questa legge, appunto con l'intenzione di raggiungere una condizione più favorevole al conflitto che ormai era alle porte con i franchi cattolici. Quindi cercò di agire su un piano meno conflittuale.

- Con un lavoro affrettato e approssimativo, la commissione di esperti incaricata da Alarico, ordinò contenuti più familiari alle scuole e ai tribunali della Gallia meridionale allo ***scopo*** di eliminare l'oscurità delle leggi romane, del diritto antico, in modo che si applicasse soltanto quanto in essa era racchiuso.

> E questa *Lex Romana Visigothorum* è importante perché si fa veicolo di fonti essenziali per la ricostruzione della storia; All'interno infatti compaiono:

- Costituzioni del Codie Teodosiano
- Novelle post-Teodosiane
- Costituzioni estratte dai codice Gregoriano ed Ermogeniano,
- Ma anche altri stralci di opere giurisprudenziali (*Institutiones* di Gaio, in particolare l'*Epitomae Gai*, le *Pauli Sententiae* e anche un responso di Papiniano)

> Ognuno di questi testi era inoltre accompagnato da una *interpretatio,* nel caso questa mancasse si avvertiva esplicitamente che non ve n'era bisogno.

> Sembra che la *Lex romana Visigothorum* avesse efficacia solo per i sudditi romani della Tracia meridionale e della Spagna, e rimase in vigore all'incirca per centocinquant'anni.

- Per i Goti, alla fine del V secolo venne composto un altro codice, grazie al re Eurico, primo dei monarchi Goti che mise per iscritto gli usi e costumi del suo popolo

> Nonostante la rozzezza e l'inadeguatezza come opera legislativa compiuta attraverso un lavoro approssimativo e sintetico nei contenuti, la *Lex Romana Visigothorum* fu di notevole importante per la storia del diritto dell'Europa sud-occidentale.

3. *Lex romana Burgundionum (o Papianus)*
- Accanto ad una raccolta di norme germaniche, la legge romana dei Burgundi, che erano un'altra popolazione barbarica, aveva efficacia solo o principalmente per la popolazione romana.
- Risale ad un periodo compreso tra V e VI secolo, si ipotizza che il re Gundobado ne sia stato autore, probabilmente, in base alla datazione, poco prima di morire, ormai alla fine del suo regno.

- La base di questo codice è quasi analoga alla *Lex Romana Visigothorum* (Codice Teodosiano, Ermogeniano e Gregoriano…)

- Tutto questo materiale è diviso in 47 titoli ed è per molti aspetti basato su *interpretationes* molto vicine a quelle che accompagnano la *Lex Romana Visigothorum*.

- Essendo più fortemente impregnato di diritto volgare, questo codice ha avuto meno fortuna rispetto alla *Lex romana Visigothorum* in quanto conteneva meno materiale di conoscenza ad un diritto anteriore al contrario della *Lex Romana Visigothorum*.

La Codificazione Giustinianea: Il Corpus Iuris Civilis

6. La codificazione giustinianea

Tutto ciò che oggi conosciamo del diritto romano si trova condensato in una straordinaria raccolta di testi che durante il Rinascimento assunse il titolo di *Corpus Iuris Civilis.*

La raccolta a cui oggi ci riferiamo con *"Corpus Iuris Civilis"*, non nasce con questo nome.
Fu Giustiniano I, nel corso del VI secolo, nella parte orientale dell'impero, ad assumersi il compito di dare vita ad una monumentale raccolta che ad oggi costituisce un enorme patrimonio giuridico normativo, ma non fu lui ad intitolarla *"Corpus Iuris Civilis"*: Questa denominazione fu adoperata da Dionisio Gotofredo sul finire del '500, in riferimento proprio ad una raccolta riunitiva di tutte le parti costitutive dell'opera compilatoria e legislativa di Giustiniano.

> Il Corpus Iuris Civilis si compone infatti di quattro parti:

- Il *Novus Codex* (o semplicemente *Codex* - o Codice giustinianeo)
- I *Digesta*
- Le *Institutiones*
- Le *Novellae*

E nel suo insieme rappresenta un punto di connessione tra il passato e il futuro degli studi giuridici, in quanto fa da spartiacque tra:
- Il punto di partenza della tradizione giuridica europea\ o romanistica (e cioè degli studi del diritto romano che hanno fondato la cultura giuridica dell'Europa sino ad arrivare alle codificazioni moderne dell'ottocento e del novecento),
- E allo stesso tempo il punto di arrivo\ la conclusione dell'esperienza giuridica romana in senso storico.
(E quindi anche dei nostri studi del diritto romano che comprendono lo svolgersi dell'esperienza giuridica dalle origini sino, appunto, alla compilazione giustinianea).

Dove e quando viene realizzata

La compilazione Giustinianinea viene dunque realizzata nella parte orientale dell'impero romano che vive una vita molto diversa rispetto alla parte occidentale, segnata a partire dal 476 d.C. dalle invasioni barbariche che avevano portato con se una cultura, in particolar modo giuridica, più rudimentale: il diritto nell'architettura del sapere, non conservava un posto in primo piano, tant'è che, ad esempio, nel regno ostrogoto o visigoto, gli uomini dell'aristocrazia senatoria romana o della gerarchia ecclesiastica più elevata (che erano l'elite culturale dell'impero romano d'occidente) avevano una formazione essenzialmente letteraria, retorica o filosofica (ricordiamo, ad esempio, Cassiodoro, Boezio o il vescovo Cesario di Arles)

> Nell'Impero Romano d'Oriente, al contrario, il pragmatismo di una burocrazia illuminata ed il classicismo accademico raccolsero a loro modo la preziosa eredità della giurisprudenza romana: ed è proprio questa la realtà in cui fioriscono le università (in particolare quelle di Brito e di Costantinopoli), grazie alle quali la cultura avrebbe poi avuto la possibilità di fiorire in maniera più incisiva.

> La codificazione Giustinianea non nacque d'un colpo, il suo stesso progetto si venne delineando poco a poco nel corso di 6 anni, che è comunque un periodo brevissimo rispetto alla maestosità dell'opera di raccolta e di riordino del materiale giuridico accumulato nei secoli svolta dai compilatori, appunto tra:

- Febbraio 528 = Data dell'emanazione della *Constitutio Haec quae necessario*, che introduce il progetto della realizzazione del primo *Codex* con la nomina della commissione.
- Novembre 534 = Data dell'emanazione della *Constitutio Cordi*, e quindi della pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis*)
- Poi, dal 535 al 565 seguì tutta la produzione legislativa corrente, e quindi la produzione delle nuove *constitutiones* da Giustiniano in poi, che verrà racchiusa nelle *Novellae*.

Le tappe della compilazione Giustinianea

È possibile distinguere le tappe dell'opera compilatoria e legislativa di Giustiniano in base alle costituzioni emanate a riguardo: possiamo, infatti, notare che c'è sempre:

- Una *Constitutio* che pone i criteri\ individua le linee programmatiche ed investe una commissione del compito di redigere una determinata compilazione.
- Seguita da una *Constitutio* che, quasi come a chiudere un cerchio, a consultivo di quanto svolto, pubblica quella parte della compilazione riprendendone i motivi del progetto facendo emergere l'esito di quanto fatto, che cos'è accaduto rispetto al progetto originale espresso nella precedente *Constitutio*.

(* Le varie *Constitutiones* prendono il nome dalle primissime parole che contengono, a prescindere che abbiano o meno un senso compiuto, spesso infatti hanno un significato poiché ci può essere, ad esempio, un ablativo assoluto, spesso però ne sono prive, poiché manca il verbo della frase.)

(1 - Il Novus Codex)

1. **Febbraio 528** — *Constitutio Haec quae necessario (de novo codice componendo)*

La prima tappa è individuata dalla *Constitutio Haec quae necessario*, nella quale Giustiniano nomina una commissione a cui affida il compito di redigere un Codice Nuovo di *leges* che racchiudesse la totalità del corpo di norme e costituzioni imperiali utilizzabili nella pratica del processo.

- L'intenzione espressa era quella di raccogliere e sistemare le costituzioni imperiali con lo scopo di porre fine alla *prolixitas litium* (la lungaggine \ prolissità delle liti delle controverse del processo), e cioè, in relazione alla pratica giudiziaria, queste erano lungaggini dovute alla difficoltà di districarsi tra la normativa elefantiaca con cui avvocati e giudici avevano a che fare.

(C'era bisogno di un testo unico e chiaro)

> La *commissione:*
Giustiniano affidò la redazione del Novus Codex ad una commissione, per la prima volta, mista\ composita in cui confluivano le varie anime del diritto:

- Se consideriamo Teodosio II, la commissione che aveva redatto il codice Teodosiano era composta da soli funzionari, i quali avevano, inevitabilmente una visione burocratica\ amministrativa del diritto.

- Con Giustiniano, invece, aumenta l'ampiezza delle vedute, poiché la commissione arriva a comprendere importanti professori del diritto e avvocati, alcuni anche con dei ruoli nella burocrazia imperiale.

> Quindi erano presenti:

- Un'anima accademica: Data dalla presenza di professori universitari
- Un'anima burocratica: data dalla presenza di funzionari
- Un'anima pratica: data dalla presenza degli avvocati

> Anche se, in realtà prevalse la componente burocratica sulle altre due, in quanto il numero di funzionari (6) era maggiore rispetto a quello di professori e avvocati

> Alcuni nomi di rilievo in questa commissione sono:

- *Giovanni di Capadocia*, che fu il presidente\ colui che ebbe l'incarico di dirigere la commissione per la compilazione del Codex
- *Triboniano*, che era un funzionario di spicco, in particolare allora aveva il titolo e la dignità di soprintendente alle cancellerie imperiali (ma non le funzioni effettive).
- Teofilo, che era un professore nella scuola giuridica di Costantinopoli, e anche membro del *consistorium*.

> Questa commissione riuscì a concludere il lavoro di raccolta in pochissimo tempo, e da questo dato capiamo proprio quanto fosse raffinata ed elevata la cultura giuridica che si sviluppa in questo periodo.

> Il *contenuto:*

Il *Novus Codex* doveva comprendere tutte le costituzioni imperiali in vigore (quindi non quelle cadute in desuetudine come accadde per il codice Teodosiano) emanate dall'età Adrianea (dal 120 d.C) in avanti, organizzate seguendo un ordine cronologico, e con la possibilità di apportarvi le modifiche necessarie sulla base, anche, di quanto fosse desumibile dai tre codici precedenti (Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano) che, in effetti, il *Novus Codex* quando proprio a rimpiazzare.

> Da qui emergono degli *scopi utilitaristici* di questa nuova compilazione:
Vediamo infatti che alla commissione viene dato un grande potere di manipolazione\ grande libertà di intervento sui materiali del passato per renderli il più possibile adeguati all'attualità.

Quindi, oltre ad eliminare le costituzioni ormai cade in desuetudine, laddove lo ritenessero necessario, potevano modificare e ritoccare le costituzioni, ad esempio:

- Eliminando alcune *inscriptiones* * qualora fossero risultate inutili allo scopo normativo.
- Eliminando, attraverso operazioni di semplificazione, costituzioni simili o affini (le cosiddette "ripetizioni")
- Aggiungendo, introducendo o mutando il valore delle *leges*.
- Ed avevano addirittura la possibilità di dividere o fondere in un testo unico determinate costituzioni e norme distribuite in maniera disordinata.

* Ricordiamo che le Constitutiones erano precedute dalla *inscriptio* che riportava imperatore emanante e destinatari della costituzione, e seguite dalla *subscriptio* contenente l'anno di emanazione. (Vediamo quindi la componente storica: attraverso questi dati il tempo diventa parte integrante della compilazione)

> In effetti, dobbiamo considerare che uno dei motivi per cui la commissione riuscita a svolgere questo enorme lavoro di raccolta in un tempo brevissimo, è proprio perché fu utilizzato il lavoro svolto in precedenza: C'erano infatti già state delle importanti raccolte di costituzioni (appunto i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano), grazie alle quali la commissione eletta da Giustiniano, elevatissima dal punto di vista intellettuale, ebbe la possibilità di agire con maggiore scorrevolezza potendo attenere ad un materiale già ordinato.

> Le costituzioni comprese nel *Novus Codex* avevano solo efficacia generale.
- Anche quelle che in origine avevano efficacia particolare, E che quindi erano state emanate in occasione della soluzione di un caso specifico nel passato, estendono la propria efficacia e diventano generalizzate a tutte le situazioni.

> In *conclusione* :

Possiamo affermare che il codice Giustinianeo nel suo essere più organico e completo rispetto ai precedenti, segna un progresso dal punto di vista tecnico in quanto non lascia fuori di sé nessuna raccolta legislativa:

- Infatti l'introduzione del codice Teodosiano non aveva escluso\ rimpiazzato i codici Gregoriano ed Ermogeniano, che pur non avendo carattere ufficiale, rappresentavano dei punti di riferimento per attingere ad una serie di dati normativi.
- Con il Novus Codex, il discorso cambia, tutto ciò che non era contenuto all'interno della raccolta non aveva valore normativo, tanto che Giustiniano aveva proprio stabilito un divieto di fare il corso ai vecchi codici, ma non solo, anche le costituzioni successive, se non contemplate dal codice, erano prive di validità (fatta eccezione, ovviamente, per le decisioni dei tribunali supremi, che erano importanti edifici amministrativi, ma anche per alcune costituzioni che concedevano privilegi speciali, cioè quelle ad efficacia singolare, purché rientrassero nei limiti dell'interesse pubblico e non fossero a contrasto con le direttive e di fondo del codice).

> Per quanto riguarda, invece, i *pareri dei giuristi*.

- Qualora questi fossero in armonia con le costituzioni del codice, era concesso, nei tribunali farvi ricorso menzionando i libri dei giuristi antichi e allegandone l'opinione.

- Risulta però chiaro che la raccolta del *Novus Codex* doveva raccogliere solo *leges:* a conferma di ciò possiamo considerare il fatto che ritroviamo compresa all'interno del *Codex* anche la legge delle citazioni del 426 contenuta nella redazione finale del codice Teodosiano.

2. **Aprile 529** — *Constitutio Summa rei publicae (de Iustiniano confirmando)*

> Terminato i lavori di redazione, nel 529, con la constitutio *Summa rei publicae*, Giustiniano pubblicò e diede validità al *Novus Codex*.

- All'interno di questa seconda *constitutio*, Giustiniano fa emergere e sottolinea questa quotidiana cura del bene comune nell'apprestare una formulazione generale ed oggettiva della pura norma, quindi nel dar vita ad un tentativo razionale di sistemazione dei materiali giuridici che puntava ad agevolare la pratica forense. (che quindi era considerata un'esigenza da soddisfare primariamente).

- Inoltre, quasi richiamando quanto affermato nel *De Rebus Bellicis*, emerge un riferimento al motivo *arma-leges.* Mette sullo stesso piano la certezza del diritto e la protezione concreta dello Stato:
Cioè come se la difesa dello Stato fosse affidata tanto all'esercito, che garantiva la sicurezza concreta dello Stato, tanto alle leggi, che garantivano la certezza dei rapporti, dell'equilibrio e della pace interna.
Giustiniano dice proprio di aver realizzato quella chiarezza, di aver superato la *fuligo* (la fuliggine), il grigiore delle leggi precedenti e di aver raggiunto una semplificazione del materiale normativo utile sottoscrivendo il divieto di adoperare tutto ciò che esula dalla raccolta del Codex.

> Notiamo inoltre che questo Codex, per la prima volta fa emergere una caratteristica nuova, importante, tipica del codice moderno: la tendenza all'esaustività e ad una sufficienza interna della codificazione.

(2 - I Digesta)

3. **Dicembre 530** — *Constitutio 'Deo Auctore' (de conceptione digestorum)*

Che annunciava l'avvio del lavoro di raccolta del diritto giurisprudenziale per la redazione dei Digesta.

> Con la pubblicazione del *Novus Codex*, che era una raccolta di *leges*, ed oltretutto contemplava anche la legge delle citazioni, sembrava ben lontana l'idea di una raccolta di *iura*.

> Tra il 529 ed il 530, la situazione cambiò, e soprattutto grazie a Triboniano, iniziò ad insinuarsi l'idea di una raccolta di opinioni giurisprudenziali, forse anche perché la legge delle citazioni aveva, via via, cominciato a mostrare le sue problematiche in quanto spesso produceva controversie processuali dottrinali.

> Su questa vicenda, in realtà non si conosce molto, si sa che i maggiori problemi relativi alla risoluzione di alcune controversie presenti nelle opere giurisprudenziali classiche erano state risolte dalle *Quinquaginta decisiones*:
- Un gruppo di costituzioni, di cui non si conosce bene né l'origine né il tipo di trattazione, ma che sembravano volte a risolvere, appunto, queste controversie riferibili ad alcuni frammenti della giurisprudenza classica.
- Alcuni ritengono addirittura che fosse una sorta di lavoro preparatorio del digesto, altri invece pensano che fosse una "coda" del primo progetto Teodosiano.

- Ciò che è significativo, è che manifestano un disagio dell'epoca per lo stato degli iura, per cui capiamo che si stesse facendo strada l'esigenza del riordino degli *iura*, anche a fronte di quanto accaduto per le *leges*.

> Ecco che dinanzi a questa esigenza, Giustiniano nominò una nuova commissione a cui affidare il compito di raccogliere, selezionare e sistemare tutto il materiale giurisprudenziale al fine di redigere un secondo nuovo codice con il nome di Digesta (o Pandectae) che si affiancasse in quanto raccolta di *iura* al *Novus Codex*, raccolta di *leges*.

> La commissione:

Anche stavolta, come per il *Codex*, si tratta di una commissione mista in cui si ritrova una componente burocratica, un importante presenza accademica ed una presenza forense (in particolare 11 avvocati del tribunale supremo della prefettura d'Oriente).

- Il compito di dirigere i lavori di redazione, stavolta, spetta allo stesso Triboniano, ormai ministro della giustizia, che aveva partecipato alla composizione del *Codex,* rivestendo però un ruolo secondario.

Ricordiamo poi

- Costantino, sovrintendente alle cancellerie imperiali e tesoriere.
- Quattro professori: due della scuola giuridica di Berito (Doroteo e Anatolio), e due della scuola giuridica di Costantinopoli (Teofilo che aveva partecipato anche alla redazione del Novus Codex, e Cratino).

> Il *contenuto*:

La commissione aveva il compito di raccogliere sistemare e manipolare tutti i frammenti della letteratura giurisprudenziale dell'età preclassica (repubblicana) e classica (naturalmente, i compilatori potevano utilizzare le opere dei maestri antichi nello stato e nella forma in cui erano giunte sino a loro, e quindi complete delle alterazioni volontarie o involontarie che avevano subito nella corso della storia testuale).

- I testi dovevano essere ordinati secondo una *ratio* precisa all'interno di un unico codice, organizzandoli in (50) libri, titoli e paragrafi.

- Così com'era accaduto in precedenza per le costituzioni, era possibile modificarli qualora fosse necessario, per evitare ripetizioni, contraddizioni, o anche laddove sorgesse la necessità di attualizzare, rispetto ai tempi correnti, il dettato originale.

> Questo lavoro si concretizza in un'enorme antologia che prende il nome di ***Digesta***:

> "*Digesta"* deriva da "digerere" che vuol dire proprio raccogliere\ ordinare, e non è un titolo nuovo:

- Erano una vera e propria tipologia letteraria che ha origini molto risalenti (periodo tardo repubblicano, ricordiamo ad esempio i *Digesta* di Alfeno Varo risalenti al I a.C.) per cui i *Digesta* Giustinianei rientrano nel filo di questa tradizione letteraria.

- I Digesta costituivano un grande patrimonio di soluzioni interpretative, e di fatto sono la raccolta da cui traiamo gran parte delle informazioni di conoscenza storica del diritto romano, tant'è che sono anche detti *Pandectae* "Pandette" : dal greco πανδέκται, "onnicomprensivi, riguardanti qualsiasi materia", per indicarne proprio la completezza; Attraverso quest'opera rivive "la schiera innumerevole" della giurisprudenza classica.

(Testo pag. 382)

Dal testo della *Constitutio Deo Auctore*, che inaugurava il lavoro mastodontico della compilazione dei Digesta, emergono le linee programmatiche del progetto che ci fanno comprendere la portata di quanto Giustiniano avesse intenzione di realizzare.

- Il primo aspetto che salta all'occhio è il nome, e quindi le prime parole di questa costituzione *"Deo Auctore"* che è un ablativo assoluto: "Con l'ispirazione di dio": Si vuole dare proprio l'idea dell'*auctoritas* divina, e quindi abbiamo la rappresentazione dell'imperatore visto come vincolo della volontà divina; L'imperatore è colui che realizza e si investe di questo compito maestoso (e chiaramente questo è anche un forte messaggio politico).
- E quindi con questa grande enfasi che denota il potere imperiale,Giustiniano ordina perentoriamente "di esaminare ed emendare le opere che, sul diritto romano scrissero i giuristi antichi" e quindi il lavoro che doveva essere compiuto non era semplicemente un lavoro di analisi, ma anche di emenda\ miglioramento delle opere dei giuristi antichi, capiamo quindi quanto fosse grande la libertà di intervento che i commissari avevano sulle opere, e precisa poi che avrebbero potuto eliminare ripetizioni o discordanze

con il fine, importantissimo, di raccogliere tutto quanto fosse considerato necessario entro un unico libro così che si potesse fare affidamento, nella pratica, solo a questo.

- Ma specifica che si potesse agire solo sulle opere di determinati giusti, limitandone il numero a coloro ai quali "i sacri imperatori concessero la facoltà di redigere ed interpretare le regole giuridiche": Cioè i giuristi a cui era stato concesso lo *ius rispondendi ex autoritate principis* (Quella prerogativa che i principi potevano concedere ad alcuni giuristi dandogli la possibilità di emanare responsi con il "sigillo imperiale" cioè la cui valenza era maggiore in quanto era come se quei pareri tecnici provenissero dal principe stesso).
  - Giustiniano, in realtà, ne sta facendo *questione ideologica*:
    Nel momento in cui dice di esaminare solo i casi dei giuristi che avevano il sigillo imperale, vuole fare una selezione in base alla maggior autorevolezza, addirittura afferma perentoriamente che sarebbe sconveniente che le opere di altri autori andassero ad alterare quel disegno legislativo; Ma di fatto le cose andarono diversamente, nel Digesto, infatti, non ci sono i frammenti solo di questi giuristi, ma di gran parte dei giuristi anche non dotati di questa prerogativa, quindi è solo un fatto ideologico inserito nella costituzione, quasi come se volesse sottolineare l'importanza della grande autorevolezza, ma soprattutto del controllo imperiale rispetto all'emanazione dei vari responsi.
- Dunque Giustiniano vuole che prima vengano raccolti tutti i materiali, di fatto furono presi in considerazione ben 2000 libri di opere giurisprudenziali, a cui doveva seguire un enorme lavoro di analisi e riordino che durò, tra l'altro solo tre anni.
- Lo scopo di questo lavoro era quello di "innalzare alla giustizia un duraturo e venerabile tempio", e qui Giustiniano esprime proprio l'idea della durata nel tempo, l'idea di poter redigere un monumento alla giustizia, qualcosa di solido che non può essere intaccato: Giustiniano era consapevole di consegnare ai posteri un monumento della cultura giuridica.
- Segue poi l'idea dell'esaustività, doveva essere racchiuso "tutto" il diritto
- Ed introduce le vere e proprie linee guida, quindi questa raccolta di "tutto il diritto" doveva essere suddivisa in 50 libri e titoli al suo interno prendendo come modelli di impostazione e sistemazione:
  - Il *Novus Codex*, che era stato pubblicato da poco
  - L'Editto Perpetuo: L'editto è un'altra realtà normativa importantissima, prodotta dall'attività dei pretori nel corso del tempo e che aveva visto in età Adrianea una sua redazione finale.
  - In questa *Constitutio* emerge ancora una volta il binomio arma-leges nel momento in cui dice, in riferimento al diritto, che sarà "difeso come un baluardo", e quindi richiama la difesa dell'esercito per puntualizzare la solidità, la certezza del diritto.
  - Ed emerge anche il senso della qualità, della quantità del materiale, della sistemazione, del riordino, dell'autorevolezza e dell'esaustività di questo compito.

> Il passaggio si conclude con:
"tutti i giuristi hanno un eguale dignità, e a nessuno deve essere riconosciuto è un qualche privilegio: perché nessuno è sempre superiore o sempre inferiore agli altri, ma ciascuno lo è, di volta in volta, in determinati profili."

- Questa puntualizzazione è un riferimento allusivo, ma piuttosto chiaro alla legge delle citazioni, in quanto ci fa intendere era ormai superata; Per quanto inclusa nel Novus Codex, e quindi ancora vigente, viene anticipato che grazie a questa nuova, futura, raccolta così ampia e sistematica, non sarà più necessario ricorrere alla legge delle citazioni che era ormai una regolamentazione da considerare "rudimentale",
- Anche perchè limitava molto il cerchio dei giuristi da poter menzionare, mentre con i Digesta, ogni giurista viene riportato in auge nella sua propria fisionomia nella sua personale, in quanto a ciascun frammento doveva essere preposta una *inscriptio* con il nome del giurista, l'opera da cui era stato estrapolato (con il numero del libro ovviamente), per cui sarebbe stato possibile contestualizzare ogni frammento, e ridare le proprie sfumature a ciascun giurista e a ciascun pensiero.

> Quindi i giuristi non saranno più appiattiti e gestiti solo nella misura delle *recitationes,* della pratica processuale ed in base ad un criterio di maggioranza.

5. **Dicembre 533** — *Constitutio Tanta-Dedōken (de confirmatione digestorum)*

Dopo soli 3 anni, il lavoro di costituzione della grande antologia di *iura* che sono i Digesta, terminò.

> A fronte dell'enorme numero di opere spogliate per la realizzazione di questo codice (circa 2000), risulta quasi incredibile pensare che tale lavoro sia stato svolto in così pochi anni; Certamente vi fu un alacre lavoro dei commissari particolarmente qualificati, ma, studiando l'organigramma dei Digesta, si è giunti alla conclusione che vi furono delle *sottocommissioni* che lavorarono parallelamente :

- Cioè la commissione nominata da Giustiniano, a sua volta si organizzò suddividendosi in quattro sottocommissioni che si spartirono le opere da studiare e da analizzare per il Digesto.

> Dopo approfonditi studi, il giurista tedesco Bluhme formulò una teoria che prende il nome di ***teoria delle masse Bluhmiane***, secondo la quale ciascuna sottocommissione ebbe tra le mani da spogliare una massa di opere ben determinata: una detta Sabiniana, una Papinianea, una Edittale ed una *Appendix*.
Cioè erano state divise:
- Tutte le opere che potevano afferire a Sabino o al commentario alla sua opera (massa detta Sabiniana).
- Tutto ciò che poteva afferire alla tipologia di opere di Papiniano (rientrava in quella papinianea),
- Tutto ciò che riguarda i commentari edittali (rientrava nella massa edittale)
- Tutto ciò che non rientrava nelle altre tre rientrava nell'*Appendix*.

> Una volta terminata la redazione, i *Digesta* entrarono in vigore in tutte le parti dell'impero, con la *Constitutio Tanta-Dedoken,* detta anche "*constitutio* bilingue" perché le prime parole sono in latino ed in greco, ed era indirizzata al senato e a tutti i popoli.

> Ciò che era stato annunciato nella *constitutio Deo Auctore,* si era ormai realizzato e compiuto; e questa *constitutio Tanta-Dedoken* va proprio a chiudere l'opera renendola valida.

- All'interno della *costitutio Tanta-Dedoken* è possibile comprendere le linee tematiche riprese ed i motivi enfatici propagandistici e apologetici di Giustiniano.

(Testo pag. 384)
• Giustiniano mostra, innanzitutto, un atteggiamento di *reverentia antiquitatis*, dice proprio:

"Così Grande è la referenza che abbiamo verso l'antico da non volere in nessun modo abbandonare il silenzio i nomi dei giuristi"

- Esplicita quindi il suo rispetto profondo verso il passato e verso l'antichità splendida dell'età classica che si era concretizzato (poiché ormai il Digesto era stato pubblicato) nella conservazione dei nomi dei giuristi: cioè ciascun passo verrà restituito al suo autore riportandone il nome nella *inscriptio*.

• Precisa poi i modi d'intervento che erano stati apportati ai testi (era stato eliminato ciò che era apparso superfluo, inesatto o inopportuno, le contraddizioni erano state eliminate spesso riformulando anche il testo originale affinché esprimesse regole irreprensibili) ma ciò che è importante e che dobbiamo cogliere è la presenza di una legittimazione della norma giurisprudenziale sulla base della volontà imperiale:

- Cioè afferma che: *"a tutte quelle accolte è stata riconosciuta la stessa autorità, sicché quanto vi espresso deve considerarsi nostro, costituito dal nostro volere."* : Sta dicendo proprio che ai frammenti contenuti nel Digesto, che erano stati attribuiti ai vari giuristi con i loro nomi e le loro opere, erano stati apportati determinati interventi di modifica affinché si potesse giungere ad un risultato: il riconoscimento a quei giuristi dell'autorità che passa attraverso la volontà imperiale.

> Quindi capiamo che il Digesto è un testo autoritativo da cui si possono attingere i pareri dei vari giuristi che sono validi in quanto è stato l'imperatore a legittimarne il valore normativo: è l'autorità imperiale che fa sì che il Digesto sia utilizzato regolarmente nella pratica.

- Va poi a rimarcare che valeva solo ciò era stato pubblicato\ incluso nel Digesto, in quanto all'interno di quella redazione, nell'ottica di un miglioramento, erano state attuate tutte le manovre ritenute opportune e addirittura erano stati ammessi interventi, laddove necessario, alle costituzioni (cioè quando i giuristi richiamavano delle costituzioni imperiali, se questo richiamo non era adeguato al diritto Giustinianeo, si era intervenuti anche su quelle): E queste modifiche avevano appunto portato ad un miglioramento: l'obiettivo era raggiungere una *claritas* totale:
  - si puntava ad una *veritas* dei testi, ad una purezza che eliminasse qualsiasi incertezza nel diritto.

> Ecco lo scopo dell'adattamento dei testi, ed ecco perchè aveva validità solo quanto integrato nei Digesta.

> Un altro elemento importante è l'atteggiamento rispetto al passato a cui ci si riferisce con ***"classicismo giustinianeo"***, secondo il quale, il passato viene visto come un blocco unitario che fornisce tanti valori ed idee guida che vanno tesaurizzati e conservati: non è la voce del singolo che conta, ma il mondo giuridico classico nella sua unità: ha una sua unità rappresentativa e simbolica anche al di la dei momenti storici che hanno rappresentato la storia passata.

(Testi pag. 399 - 400)

(oltre al passaggio di pag. 382, il riferimento al divieto dei commentari e alla legge delle citazioni compera anche dopo)

- In un altro passaggio della *constitutio Deo Auctore*, è addirittura più chiaro il superamento della legge delle citazioni: Giustiniano, infatti, interviene a definire un esplicito divieto di produrre dei commentari al Digesto, con l'obiettivo ambizioso di non offuscare la cl*aritas* questa raccolta attraverso una serie di verbosi commentari che la possano inficiare (la chiarezza).
- Quindi emerge il timore che l'attività interpretativa successiva, com'era accaduto in passato, potesse intaccare la perfezione e la chiarezza di questa antologia prodotta dall'autorità imperiale.
- Dunque i commentari vengono esplicitamente vietati, ed eventualmente, come unica guida per accostarsi a questo testo, c'era la possibilità di dar vita a dei sommari o delle parafrasi solo per mezzo di indici e spiegazioni dei titoli, in modo che aiutassero ad avere accesso ai contenuti del Digesto, ma evitassero di produrre i danni dell'attività interpretativa.
- Per rafforzare e far emergere meglio la volontà di Giustiniano che nessuno abbia la dacia di unire dei commentari al testo delle leggi, precisa che fosse consentito solo tradurle in greco e renderle intelligibili in un'altra lingua, oppure chiarirne il senso attraverso delle annotazioni simili a quelle che usano fare i greci (fa riferimento al metodo κατὰ πόδα).

> Questo è proprio il concetto di *reverentia antiquitas* nell'ottica che l'autorità imperiale ha usato per far rivivere quella classicità e realizzando il suo monumento.

> In effetti notiamo quasi una contraddizione tra classicismo giustinianeo e la volontà di restituire ogni opera al suo autore:

- Sicuramente un ritorno al passato è presente più nella ripresa dello stile quanto in quella dei contenuti, poiché la commissione aveva ampia discrezionalità nell'intervento sui testi in funzione dell'attualizzazione.
- E questo ritorno al passato è accompagnato da un'ammirazione (appunto una "reverenza") nei confronti del passato stesso, sebbene non manchino anche punte critiche e polemiche rispetto ad esso (al passato), a cui spesso Giustiniano rimproverava la subtilitas (eccessiva sottigliezza) e il "gretto formalismo".
- Tuttavia non si può dire che il classicismo sia un'inerte registrazione antiquaria, ma c'era una forma di riconoscimento rispetto della grandezza di quel patrimonio con cui ci si voleva porre in continuità, ma sempre affermando e legittimando la propria posizione assolutistica: cioè giustificando tutti gli interventi di taglio e aggiustamenti.

> Ma non bisogna confondersi: questo recupero del passato e questa evocazione classica non significano per nulla una restituzione alla scienza giuridica del suo antico ruolo propulsore\ dinamico di produzione del diritto: La norma imperiale resta l'unica fonte di produzione del diritto.
- La valorizzazione di quel patrimonio classico ha una funzione più di affinamento\perfezionamento della conoscenza teoretica * (che tra l'altro sono molto utili all'insegnamento) e l'attività dell'interpretazione ha il solo compito di spiegare tecnicamente i contenuti giuridici e di renderli accessibili.
- E qui si ritorna a quel divieto limitativo di Giustiziano, a scrivere i commentari, non è un caso che già nella prima constitutio relativa ai *Digesta* (la *constitutio Deo Auctore*) il riferimento a questo divieto sia anche abbastanza ripetitivo.

* A tal proposito è anche opportuno precisare che viene posto un freno, quasi in contraddizione con il rimprovero della subtilitas, a quelle tendenze vulgaris tique, diffuse nella legislazione del IV e V secolo (Che, ad esempio, avevano portato a fare confusione tra alcuni termini\ istituti come *dominium* e *possessio*, o anche usufrutto e dominio), per cui, con un certo limite, si ebbe quasi una rinascita della dogmatica giuridica classica che era crollata a partire dall'epoca di Costantino.

> Dieter Simon, giurista tedesco, affermò che l'interpretazione *"non tende a fornire uno strumento ben congegnato e praticamente adoperabile di regole giuridiche, con il cui aiuto il giurista pratico possa ordinare e dominare i rapporti della vita"*, cioè non fornisce uno strumentario di regole giuridiche che possano essere utili al giurista pratico, ma ora, con Giustiniano l'interpretazione serve solo a spiegare tecnicamente il materiale tramandato e renderlo accessibile\ farlo capire tramite l'insegnamento.
(Questo spiega anche quel divieto di commentari che possono intaccare la *veritas*, la *claritas*, la purezza raggiunta da questa compilazione giustinianea.)

(3 - Le Institutiones)

6. **Novembre 533** — *Constitutio "Imperatoriam"* (indirizzata alla *cupidam legum iuventus*)

Un mese prima rispetto all'emanazione della costituzione che avrebbe pubblicato e dato validità ai Digesta, con la Constitutio "*Imperatoriam*" furono pubblicate le *Institutiones*.
In parallelo con la gestazione del digesto avvenne la concezione di un vero e proprio manuale istituzionale che contenesse i pilastri\ fondamenti del diritto: le *Institutiones*, destinate proprio alla *"cupidam legum iuventus"* e cioè alla "gioventù desiderosa di conoscere le leggi", appunto, a coloro che erano alle prime armi con il diritto.

> La <u>*commissione*</u>

- Era costituita da 3 soli commissari: Triboniano, Teofilo e Doroteo

> <u>*Contenuto*</u>

- Le *Institutiones*, così come i Digesta, non sono un genere nuovo, ma hanno le proprie remote origine:
  • Il manuale istituzionale più importante è quello Gaio del II secolo d.C.
  - Gaio è il maestro per eccellenza, colui che si dedica all'insegnamento, e il suo manuale delle institutiones è tra l'altro una rara fonte di conoscenza diretta.
  • Dunque fu Gaio ad inaugurare la fortuna di questa tipologia letteraria, e dopo di lui anche altri autori produssero delle "*institutiones*" come ad esempio Marciano ed Ulpiano (nel III secolo d.C).
- Utilizzando proprio questi manuali degli antichi, in primis quello di Gaio, i tre commissari incaricati svolsero un lavoro antologico di raccolta e selezione che diede vita a quattro libri di carattere elementare e pedagogico che contengono gli elementi primi, introduttivi del sapere giuridico.
- La peculiarità delle Institutiones è che le nozioni contenute all'interno è come se fossero enunciate dalla "voce del principe"

6. **Dicembre 533** — *Constitutio 'Omnem'*

- Con la pubblicazione delle *Institutiones* si inaugura la ***riforma didattica*** (che Giustiniano stava maturando di pari passo con quella codificatoria) che trova sbocco contemporaneamente nei Digesta.

- Il Digesto, infatti, oltre ad essere un testo autoritativo, era anche un testo formativo che rientra perfettamente in questo nuovo piano didattico di Giustiniano, in particolar modo, se le Institutiones erano perfette per la parte elementare della formazione, i *Digesta* vertevano sulla parte di studio un po più avanzato e specialistico, proprio perché offrivano tanti casi concreti su cui i giuristi potevano esercitarsi a proferire le loro consulenze.

- A scopo didattico, inoltre, furono divisi i 50 libi del Digesto in 7 parti:

1- Prima parte denominata *"Prōta"* comprende i libri 1-4

2- Seconda parte denominata *"de iudiciis"* comprende i libri 5-11

3- Terza parte denominata *"de rebus"* comprende i libri 12-19

4- Quarta parte era la parte centrale dell'opera e comprende i libri 20-27

   <u>*Dei quali*</u>: il 20° libro relativo a pegno e ipoteca; 21° relativo ad editto edilizio, azione redibitoria, evizione e *stipulatio duplae*; 22° relativo ad interessi, prestito marittimo, documento, testimoni, prove e presunzioni; 23°-25° relativi agli sponsali, al matrimonio e la dote; 26°-27° relativi a tutela e cura.

5- Quinta parte comprende i libri 28-36 relativi al testamento e ai legati.

6- Sesta parte comprende i libri 37-44

<u>Dei quali</u>: 37°- 38° relativi a *Bonorum possessio* e successione intestata; 39° relativo alla denuncia di nuova opera, danno temuto, *actio aquae pluviae arcendae*, pubblicani e donazioni; 40° relativo a manomissioni e processo di libertà; 41° relativo all'acquisto della proprietà e del possesso; 42° relativo alla cosa giudicata e l'esecuzione; 43° relativo agli interdetti; 44° relativo alle eccezioni.

7- Settima parte comprende i libri 45-50

<u>Dei quali</u>: 45° relativo alle obbligazioni verbali; 46° relativo a fideiussione, mandato di credito, estinzione delle obbligazioni, novazioni e stipulazioni pretorie; 47°-48° detti anche *"terribiles libri"* racchiudevano il diritto penale; 49° relativo all'appello; Ed infine il 50° relativo all'amministrazione delle città, opere pubbliche e mercati, *pollicitationes*, varie forme di cognizione, tributi, ed il significato delle parole e delle regole del diritto antico.

> Le linee guida di questo nuovo, grandioso progetto didattico che Giustiniano stava portando avanti, furono pubblicate attraverso la *Costitutio 'Omnem'*.

- Era, infatti, essenziale che i nuovi giuristi si formassero sui testi che Giustiniano stava concependo in un disegno ampio, e che quindi questi testi dominassero il diritto così come Giustiniano lo aveva concepito.

> Giustiniano stesso affermò che la scienza del diritto potesse essere appresa dall'inizio alla fine, poiché ormai essa sola, fra tutte le arti, aveva un confine segnato. (dato dalle tre parti *Institutiones-Digesta-Codex*)

> Si stabilì che:

- L'insegnamento giuridico avesse la durata di 5 anni:

1° : Studio delle *Institutiones* e dei *Prōta* (primi 4 libri dei Digesta)

2° : Studio della seconda o terza parte dei *Digesta* + i libri 23, 26, 28, 30.

3° : Studio di quella tra la seconda e terza parte che era stata tralasciata nel secondo anno + i libri 20 e 22

4° : Durante il quarto anno le lezioni vere proprie cessavano, e per ricavarne "tesoro di sapienza", si prendevano in esame i 10 libri non ancora studiati della quarta e della quinta parte.

5° : Il quinto anno era dedicato alla lettura approfondimento del Codice

- Lo studio della sesta e della settima parte dei Digesta era rinviato ad un momento successivo.

> La formazione dunque abbracciava tutto il diritto nella sua completezza ed interezza

Il giovane durante il suo percorso formativo affrontava tutti gli argomenti necessari partendo dalle dall'inizio con la conoscenza dei fondamenti primi (*Institutiones*), per poi procedere con la conoscenza dei *Digesta*, e quindi della casistica vera e propria attraverso la produzione dei giuristi che permetteva di formarsi anche in relazione al ragionamento giuridico, fino ad arrivare, al quinto anno di formazione, allo studio del *Codex*, che permetteva di acquisire consapevolezza delle costituzioni imperiali, quindi della normativa imperiale di riferimento.

(Revisione del Novus Codex)

7. **Novembre 534** — *Constitutio 'Cordi'*

> Che prevedeva la pubblicazione del ***Codex repetiate praelectionis.***

Il digesto ed il materiale legislativo che si era venuto via via accumulando, fecero apparire il primo codice Giustinianeo come un testo antiquato già dopo soli pochi anni dalla sua promulgazione.

La necessità di una revisione del Codex emerge:

> Da una parte se consideriamo i tre gruppi di costituzioni successive e quindi escluse dal primo codice:

- Furono infatti raccolte (prima della produzione del Digesto) le *Quinquaginta decisiones* con le quali Giustiniano aveva eliminato alcune controversie sorte fra i giuristi classici o tardi.
- Proprio questo lavoro compilatore rese necessario il secondo gruppo di costituzione: le *ad commodum propositi operis pertinente*, che risolvevano le incertezze nate durante lo spoglio della letteratura giuridica.
- Un terzo gruppo di costituzioni comprende quelle emanate per alcune esigenze particolari dell'amministrazione dell'impero.

> D'altra parte, a testimoniare l'inadeguatezza del Novus Codex c'è anche fatto che con la realizzazione del Digesto era stata soppiantata completamente la legge delle citazioni al contrario di quanto contenuto e ammesso all'interno del Codex.

> Nel novembre del 534 fu pubblicato, tramite la Constitutio Cordi, il *Codex repetitae praelectionis,* che era una nuova edizione del Novus Codex ottenuta dalla sua revisione e correzione (Fu, ad esempio, superata completamente la legge delle citazioni, e furono anche integrati quei gruppi di costituzioni che erano state escluse dal primo codice).

> Con la pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis,* il *Novus Codex* viene completamente superato, e a partire da quel momento ebbero validità solo le costituzioni compresa all'interno di esso, e viceversa persero validità quelle che, pur presenti nel primo Codice, erano state escluse da questa seconda redazione. (Fatta eccezione per alcune costituzioni che non potevano essere comprese poiché emanate in corso d'opera, e che andavano a disciplinare delle situazioni particolari)

> La *commissione* era più ristretta rispetto alla precedente, mi facevano parte Doroteo, Triboniano e tre avvocati del supremo tribunale Costantinopolitano.

> Il loro compito fu, appunto quello di raccogliere le nuove costituzioni organizzandole secondo i vari titoli attraverso un lavoro di eliminazione delle costituzioni superflue presenti nel primo codice, di superamento delle costituzioni contrastanti tra loro, di completamento delle costituzioni lacunose e infine di chiarimento delle costituzioni oscure.

- Il contenuto del *Codex repetitae praelectionis* si organizza in 12 libri, a loro volta divisi in titoli, ognuno con un apposita rubrica che ne individua la materia. (Anche in questo codice ogni costituzione è preceduta da una *inscriptio* che individua il nome dell'imperatore emanante e del destinatario, ed una *subscriptio* con luogo e anno di emanazione.)

- 1° libro si occupa di rapporti chiesa-governo, fonti di produzione del diritto e cariche pubbliche.
- 2°-8° riguardano dritto privato e procedura civile
- 9° si occupa di diritto e procedura penale
- 10°-12° si occupano di diritto amministrativo e finanziario.

> Da una parte vediamo che coesistono sia profili pubblicistici che privatistica, ma non solo, un altro elemento da notare è che vediamo concretamente quanta importanza stesse acquistando il cristianesimo in età giustinianea (tanto da arrivare ad occupare alcune costituzioni, quelle dei rapporti tra stato e chiesa).

7. Le novelle e il rapporto con il mondo classico

Con la pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis* l'opera codificatore di Giustiniano era giunta al termine.

8. **535 - 565** — *Legislazione corrente: Le Novellae constitutiones*

Bisogna però considerare che il principe legislatore continuò a dettare le sue norme, in greco e in latino, per tutti i popoli che rientravano nell'immenso territorio dell'impero romano.

- Di fatti l'ultima tappa della compilazione Giustinianea si colloca nel periodo compreso fra 535-565 (anno della morte di Giustiniano, e quindi della fine del suo regno), che è il lasso di tempo in cui viene prodotta la legislazione corrente:

> Tutte queste nuove costituzioni che Giustiniano emanò dopo la stesura del Codex (che naturalmente non le conteneva poiché posteriori) confluirono nelle *Novellae constitutiones (νεαραι διάταξεις in greco),* di cui manca una raccolta ufficiale (fu pensata dal governo bizantino, ma mai realizzata), tanto'è che ci sono infatti pervenute attraverso alcune raccolte private:

- La collezione è più ampia delle *Novellae constitutiones* (ma non la più antica) fu redatta fra il 578 e 582, durante il regno di Tiberio II. Questa comprendeva, almeno in origine, tutte le novelle del testo originale, sia in greco sia in latino* per un totale di 168 Novelle per la maggior parte appartenenti a Giustiniano, ma non solo, 4 sono di Giustino II e 3 di Tiberio II, inoltre due costituzioni sono duplicate (di una ricorre sia il testo greco che un richiamo al testo latino), ed infine le ultime 3 non sono leggi imperiali ma editti emanati dai prefetti del pretorio.

  * I manoscritti che arrivarono in Italia, dopo la caduta dell'impero d'Oriente, riportavano solo alcune delle costituzioni pubblicate, in greco, mentre quelle latine erano state tralasciate o direttamente sostituite da riassunti in greco
  - Questa collezione si conserva, inoltre, i due manoscritti:
    - Uno si trova nella biblioteca Marciana (Venezia) e contiene un'appendice con 13 editti giustinianei.
    - Uno si trova nella biblioteca Laurenziana (Firenze)

- Una seconda collezione detta "*Authenticum*" era nota la scuola giuridica bolognese fra XI e il XII secolo, il cui nome deriva proprio dalla convinzione che essa fornisce il testo originale delle novelle; ne comprende 134 (risalenti al periodo compreso tra il 535 e 563) alcune delle quali erano state emanate in lingua latina mentre le altre compaiono in traduzione latina da originali testi greci.

- Una terza raccolta fu introdotta in Italia poco dopo la riconquista bizantina: L'*Epitomae Iuliani*
  - Prende il nome da Giuliano, probabilmente professore della scuola giuridica di Costantinopoli, e conserva in un riassunto latino 124 novelle (la più antica risale al 535, la più recente alla 555; due delle quali si ripetono)

> Le "Nuove Costituzioni" che (lo dice Giustiniano) assieme alle norme contenute nei codici andarono a costituire un ordinamento unitario, alieno da una graduatoria fra le sue parti, furono particolarmente importanti poiché spesso andarono a riformare interi settori, come quello amministrativo, giudiziario, o anche del diritto privato (soprattutto nella disciplina dei rapporti familiari e successorii)

> I caratteri formali e *contenutistici* (quindi il testo in se e per se delle *Novellae*) rivelano un mondo molto diverso da quello emerso dal resto delle compilazioni:

- In questo periodo, infatti l'etica cristiana andò sviluppandosi, e trova largo spazio anche nelle *Novellae* (ad esempio in una di queste costituzioni si ritrova il codice coniugale cristiano).
- Vediamo inoltre un'incisiva dell'etica cristiana nel sistema di regolamentazione della famiglia e nel sistema ereditario che viene scisso nei suoi punti essenziali.
- Assume maggiore rilevanza la volontà nei negozi giuridici.

- Assume un peso differente anche la scrittura, il documento (in armonia dunque con i tempo)

- In generale, sul piano dei contenuti in questa legislazione, emerge il problema dello stato, delle sue strutture amministrative e burocratiche e quindi c'è una tematica pubblicistica che emerge in maniera più evidente rispetto alle tematiche privatistiche, presenti in minor parte, ma di cui sono impregnate sia le *Institutiones* che il Digesto, nei confronti delle quali (tematiche giuridico-privatistiche) viene svolta una tendenza semplificatrice ed unificatrice, tant'è che la distinzione fra diritto civile e diritto onorario aveva perso il suo valore pratico così come quella tra processo formulare e processo cognitorio.
(Ricordiamo che la *subtilitas* era considerata un ostacolo da superare)

> Nella maggior parte dei casi, le novelle ci trasmettono oltre alla norma ed al principio giuridico anche l'iter attraverso cui la cancelleria è pervenuta a quella soluzione, proprio come dei lavori preparatori.

Digressione: La tradizione manoscritta del Digesto.

I Digesta sono la parte del corpus iuris civilis che ha avuto più fortuna risputò alle altre, è infatti la parte che ha destato maggior interesse, e sulla quale è stata sviluppata una lunga tradizione manoscritta:

‣ *Littera Florentina*

> Una prima redazione scritta particolarmente autorevole del Digesto giustinianeo è databile a poco dopo la fine del regno di Giustiniano (VI secolo), ed è la cosiddetta *Littera Florentina* nella quale è stato riprodotto il contenuto del testo dei Digesta.

- Questo manoscritto si compone di ben 905 fogli suddivisi in due tomi
- (Ogni foglio misura 36,6 cm in altezza e 32 in larghezza, la scrittura che dal ventesimo foglio in poi corre su due colonne è onciale (scrittura arrotondata apparsa nel IV secolo) con elementi di semionciale)

‣ *La Littera Bononiensis (o Vulgata)*

> Al contrario di quanto avvenne per le *Institutiones*, il *Codice* e le *Novellae*, la cui conoscenza almeno in una forma riassuntiva non andò mai perduta, il digesto fu dimenticato per tutto l'alto medioevo fino a Rinascimento bolognese.

> Per un certo periodo di tempo, infatti, non si ebbe più traccia della *Littera Fiorentina* almeno sino all'ultimo quarto dell'XI secolo, quando a Bologna a seguito di una vera e propria rinascita degli studi giuridici, si ha notizia di maestri bolognesi, chiamati Glossatori, che stavano lavorando ad un altro manoscritto dei Digesta: la cosiddetta *Littera Bononiensis (o Vulgata)*.

- Tra XI e XII secolo, a Bologna, fiorì infatti la scuola dei Glossatori:
  "***Glossatori***" poiché annotavano i testi con numerose glosse, e cioè con l'interpretazione delle parole più oscure (perchè ormai cadute in disuso), e le sostituivano con termini del linguaggio corrente: Il loro era un metodo strettamente esegetico (interpretativo), di analisi minuta parola per parola.

> Il loro studio si basava sui testi giuridici del diritto romano (in quanto primo comune denominatore di tutto ciò che c'è stato in futuro), e questi glossatori (la cui maggior parte dei nomi ci è sconosciuta, ma ricordiamo ad esempio Irnerio) partirono proprio dal *Corpus Iuris Civilis* con particolare attenzione per i *Digesta* da cui faranno partire lo studio giuridico.

> Il loro lavoro, tuttavia, soffre di scarsa sensibilità storicistica, non vi è una eccessiva preoccupazione per la comprensione dei testi alla luce della realtà in cui furono prodotti, ma c'è un tentativo di rivelare la ricchezza dei contenuti e dei significati di un patrimonio di fonti fino a quel momento trascurato.
- Il tutto quasi con una subordinazione formale ai testi: veniva svolta un'analisi pedissequa, che ossequiava il testo senza modificarlo, ma semplicemente analizzandolo.

‣ *La Magna Glossa Accursio*

> Nel 1250 circa, il giurista toscano Accursio racchiuse in un'unica opera l'intero lavoro dei glossatori bolognesi raccogliendo tutte le 96 000 glosse realizzate del *Corpus Iuris Civilis*.

—> Capiamo dunque che i testi del Corpus Iuris Civilis sono considerati allo stesso tempo principio e fine della conoscenza giuridica: c'è proprio la necessita che il giurista debba spingere oltre le sue conoscenze come se fosse un testo inesauribile da cui si possono reperire tutte le soluzioni e le spiegazioni.

- Emerge in questo senso una concezione *teocratica* del diritto, nel senso che tale Corpus Iuris Civilis arriva ad essere considerato una sorta di rivelazione chiusa in se con fondamenti teologici espliciti.

- Tant'è che laddove i glossatori spingessero per cercare la ragione intrinseca (la *ratio iuris*) di determinate soluzioni, la trovavano attraverso una lettura degli stessi testi, e quindi si spiegava tutto alla luce di se stesso, <u>non vi era prospettiva storica</u>.

I Consilia

> Nel secolo successivo, tra XIII e IV secolo, si ebbe una sorta di evoluzione all'approccio dei testi giuridici giustinianei con la scuola dei *Commentatori* (o *Post-Glossatori*), tra i quali spicca il nome di Bartolo da Sassoferrato.

> Quest'evoluzione è data dal fatto che iniziò ad essere abbracciato il diritto canonico anche sotto il punto di vista normativo, per cui emerse il bisogno di coordinare il materiale giuridico con le esigenze concrete della realtà: Nasce una sensibilità nuova verso le esigenze dei propri tempi che portò i commentatori ad utilizzare un po' più liberamente il patrimonio che avevano nelle mani;

- Il loro sforzo era volto ad introdurre nuove forme articolate di trattazione utilizzando sul piano pratico la miniera di insegnamenti presenti nel *corpus iuris*.
- Non si limitarono più ad un'analisi minuta del testo ma iniziarono a scomporre il testo in modo tale da costruire nuovi concetti ("come mattoni per le costruzioni adeguate del tempo").
—> Ecco che ritroviamo dunque un senso di maggiore storicità.

> I *Post-Glossatori* vita ad una nuova letteratura con commenti molto più corposi ed articolati, detta di *Consilia* che era più autonoma rispetto al testo originale.

Il periodo dell'Umanesimo Giuridico

> Tra il XV e XVI secolo si colloca il periodo dell'Umanesimo giuridico:
- Questo periodo si caratterizza per un incremento degli studi filologici e l'emergere di una volontà di conoscenza più approfondita del mondo classico greco e romano anche in ambito giuridico, andando alla ricerca del suo linguaggio più puro e delle sue espressioni originali.

> In questo periodo:
- Da una parte fu estremamente valorizzato il testo della *Littera Florentina*, che era quella più vicina alla realtà giustinianea.
- D'altra parte fu contestata la *Littera Bononiensis* che, sulla base della nuova visione purista degli umanisti, era considerata piena di errori, rozza ed inattendibile così come, di conseguenza, gli studi che su di essa avevano svolto i glossatori ed i commentatori.
- Quelle visioni (di glossatori e commentatori) vennero messe in discussione, tanto'è che si arrivò a parlare di *Bartolismo*, prendendo Bartolo da Sassoferrato come commentatore rappresentativo, in quanto aveva studiato ed elaborato dei concetti proprio sulla base dei materiali che utilizzava e aveva sviluppato una critica piuttosto feroce.

> Gli umanisti coltivarono una scienza filologica sui testi greci e latini, approcciandosi in modo più consapevole alle fonti insistendo anche sul profilo dei singoli giuristi:
—> Assistiamo quindi ad un recupero della storia: si sviluppa un senso storicistico molto forte.

> Il loro intento era quello della classicità più pura:
> Il concetto era che l'uso di una parola rivelava gli echi di tutta la sua storia precedente perché la temporalità era intrinseca ad ogni atto linguistico e ad ogni forma semantica.
- Tanto che si misero persino in discussione le stesse correzioni, manipolazioni apportate dai giustinianei nel momento in cui avevano questa grande opera.

> Quindi addirittura si cercò di superare il testo per capire quali stratificazioni avesse subito il testo originale classico che aveva potuto subire anche manipolazioni giustinianee.

> Vediamo quindi un superamento della visione dei glossatori e commentatori che concepivano il corpus iuris civilis come una "recinzione chiusa", e si passa a concepire che tale recinzione debba essere scavalcata e che si debba dialogare con altri ambiti culturali per poter apprendere a pieno il discorso giuridico (e cioè la *scientia iuris* doveva cercare legami con altre discipline, la filologia prima di tutto).

> Fu proprio durante l'Umanesimo giuridico che furono ricostruiti testi antichissimi come le XII tavole.

> Il compito della *scientia iuris* in quel periodo era quello di intendere la coerenza naturale intrinseca dei dati normativi ed eventualmente smantellare gli impianti della compilazione per costruire nuovi edifici sistematici con un proprio equilibrio che li renda utili al diritto attuale.

> In questo periodo, inoltre, si formula il ***diritto soggettivo*** con tutta la sua pienezza, ad opera di un grande autore: Ugo Donello, che diede vita a questa impresa grandiosa di rinnovare la radice del diritto:
- A partire dalle fonti giuridiche romane si avvertiva l'esigenza dell'organizzazione degli istituti e tale costruzione razionale di norme è fatta proprio di istituti e relazioni tra istituti;
- In primo piano, per Donello, dovevano venire i principi e i precetti legati tra loro in un corpo unitario.

‣ *Idee Giusnaturaliste, universalistiche e giusrazionalistiche*

> Questa spinta umanistica aveva portato gli uomini a guardare più dentro se stessi che al di fuori.

—> Ciò portò allo sviluppo di diverse visioni filosofiche che eclissano la coscienza della storicità e si rivolgono ad una visione di *ratio naturale,* giusnaturalista.
- Il concetto che le soluzioni vadano cercate in una sorta di equilibrio tra metafisica e storia, vi sono principi universali metafisici che risponde ad una naturalità del diritto:
L'uomo viene visto come un essere naturale che vive secondo determinati principi universali, e tutti i comportamenti degli uomini sono dettati da principi identici secondo una *ratio naturalis (*come il vivere onestamente e dare a ciascuno il suo, principi di giustizia universale): Tutto questo accomuna gli uomini.
> All'origine del diritto naturale c'è sempre la ragione e gli uomini, pur essendo in presenza di leggi dello stato, gli uomini restano comunque titolari di alcuni diritti inalienabili, come il diritto alla vita, alla proprietà che sono razionalmente giusti.

—> In simbiosi con questa idea del diritto naturale vanno queste *idee universalistiche* che il pensiero umano ama generare e cioè vediamo una forte aspirazione ai principi assoluti universalistici: una ricerca della storia e del costante.
> Il *Corpus Iuris Civilis* continua ad essere considerato il punto di riferimento del diritto e dei principi.

> E si sviluppa l'idea che il valore del diritto romano consista soprattutto nel suo contenuto razionale, quindi la riflessione dei giuristi si sposta dalle norme ai principi ed è sulla base di questi che si costruiscono degli edifici razionali.

—> Nasce una corrente parallela al giusnaturalismo, il *giusrazionalismo.*
- Se nel *giusnaturalismo* la morale ha una sua ragione di esistere.
- Il *giusrazionalismo* guarda al diritto come ad un sistema di norme ordinate e autonomo dalla morale.

> In verità durante questo periodo l'operatività del diritto romano, che viene considerato come punto di riferimento di tutta l'Europa a cui attingere le norme e i principi, entra in crisi:
- Perché la ragione ed il razionalismo portarono alle prime codificazioni:
in Austria, In Prussia, In Francia (con il Codice napoleonico).

‣ *Savigny*

> Pur avendo questo sostrato, la ragione umana ha poi costruito dei corpi normativi che non hanno riferimenti storici (eclissando la storicità).

> Da ciò scaturisce una nuova reazione, come in Germania, dove nasce la Scuola Storica tedesca ad opera di Savigny (fondatore: Friedrich Carl von Savigny) che vuole far rivivere il diritto romano.

> Possiamo affermare che il diritto romano abbia quasi tre vite:
- una sua propria
- una seconda vita avuta da Giustiniano,
- una terza vita con l'approccio savignano.

> Savigny reagì all'impostazione razionalistica per cui il diritto positivo non è più il solo prodotto della ragione, ma è invece espressione viva dello spirito del popolo romano in un determinato momento storico (notiamo quasi la presenza di diritto naturale).
- C'è proprio l'idea che il diritto sia una manifestazione istintiva dell'uomo dettata da contingenze storiche, che non può prescindere dalla storia.

> Con Savigny nasce anche la polemica nasce contro la codificazione.
- Secondo Savigny il codice è tanto inutile quanto dannoso, perché cristallizza\ immobilizza il diritto con un'utopia della sua esaustività; Utopia perché il diritto è sempre in movimento, e non si può irretire, per cui nel momento in cui si racchiude il diritto in un codice, quel diritto è già superato, e quindi diventa dannoso perché non risponde alle esigenze di un popolo che nel mentre ne ha poste di nuove.

- Allo stesso tempo vi era una contraddizione interna poiché Savigny voleva che si attingesse dal diritto romano per applicarlo alla realtà, tuttavia appariva impossibile in quanto il territorio tedesco, da ogni punto di vista, appariva ben diverso dalle situazioni economiche o sociali a cui faceva riferimento il diritto romano. Ma secondo Savigny quello che era importante preservare dal mondo del diritto romano era il metodo dei giuristi: la loro capacità di stare costantemente dietro la prassi e la pratica, e di rispondere dinamicamente a tutte le esigenze che si presentavano ed era quel modo che dava movimento e dinamismo al diritto.

> Guardare alla storia, secondo Savigny, non è solo un guardare indietro ma significa tenere aperta e rendere permanente la discussione intorno a situazioni storiche con i loro condizionamenti.

‣ Da questa scuola storica nascerà sia un filone che riallaccia una visione pura e classica:la corrente detta dei ***pandettisti*** (la pandettistica tedesca), e sono coloro che hanno studiato i testi giuridici romani estrapolandovi delle nozioni astratte (ad esempio quello che noi intendiamo con il negozio giuridico, o anche il diritto soggettivo stesso, insomma tante nozioni che noi abbiamo in maniera astratta e distaccata dall'aggancio storico) che però sono frutto di un ragionamento nato da determinati presupposti.

‣ Nel 1900 fu pubblicato il Codice civile tedesco, nato da questa esigenza purificatoria, e, nonostante le opposizioni, rappresenta un'ammirevole opera di ingegneria legislativa.

- Ciò provocò una sorta di crisi del diritto romano, in quanto l'idea era sempre quella di poter adattare determinati principi all'attualità. Potremmo addirittura sostenere che il *diritto romano muore*, ma persino nel momento in cui il diritto romano si eclissa, in realtà la sua morte ne garantisce la perennità.

> Un'immagine significativa ci è offerta da Goethe che vede il diritto romano come un'anatra che nuotando nello stagno, si immerge e si nasconde in acqua, ma lungi dallo scomparire, fa sempre riemergere il suo collo, così come il diritto romano che c'è sempre stato (ci sono momenti in cui è stato valorizzato in maniera più evidente, e momenti in cui è stato un po più "trascurato"), ma è costantemente presente.

8. Sistema e tempo

Abbiamo visto, quindi, che nei codici i testi normativi vengono ordinati in modo più o meno coerente ma rimangono riconoscibili nella loro puntuale storicità: il tempo è fortemente presente nel codice.

Questo lo si vede nel momento in cui attraverso le *inscriptiones* e le *subscriptiones* ogni testo normativo o giurisprudenziale veniva contestualizzato e collocato temporalmente, indicando, appunto, i nomi degli imperatori e dei destinatari della costituzione, oppure il nome del giurista autore del testo giurisprudenziale.

L'implicazione del tempo all'interno del codice emerge anche dal modo in cui sono distribuite le *constitutiones* all'interno di ciascun titolo: sempre in ordine cronologico e con l'indicazione della durata che più è estesa, più le circonda di autorevolezza e prestigio.
> Materiali antichi coesistono con quelli presenti:
- Già nel codice Teodosiano i materiali non vigenti coesistono con quelli vigenti a fini pedagogici.
- E vediamo come anche nelle *Institutiones* giustinianee vengono ripercorsi degli istituti dall'origine, facendone la ricostruzione storica fino a pervenire alla riforma legislativa contemporanea (es. il Legato pag.396)

———

> Gli uomini del tardo impero erano chiamati ad osservare un diritto che risaliva spesso ad un passato lontano, durante il quale il diritto era formulato in latino: questo elemento non faceva altro che accentuare la distanza con l'epoca corrente.
Nelle regioni orientali, infatti, la lingua franca era il greco, tanto che il latino non aveva alcun rapporto con la pratica quotidiana, era soltanto la lingua dei ceti colti dell'amministrazione burocratica

Il codice

> Partendo dal moderno vediamo cosa s'intende per codice.
- Nel '700 -'800 abbiamo le prime manifestazioni di codice (es. in Francia) o in Italia nel '900;
che sono il frutto di discussioni, nuove esigenze politiche e sociali, e abbiamo visto la contrapposizione tra coloro che resistevano alla tradizione del codice e chi invece era favorevole;
(Ricordiamo ad esempio *Savigny*, che in *polemica anticodificatoria* sosteneva che il codice fosse una realtà dannosa in quanto cristallizza il diritto con una sua utopia della sua esaustività perché il diritto è sempre in movimento, e non si può irretire, per cui nel momento in cui si racchiude il diritto in un codice, quel diritto è già superato, quindi è dannoso perché non risponde alle esigenze di un popolo che pone nuove esigenze).

Struttura e caratteristiche dei codici moderni

Facciamo appello a definizioni di alcuni filosofi che ci spiegano le caratteristiche del codice moderno

1- **Jeremy Bentham**, filosofo che opera tra 700 e 800, è sensibile a questo genere di problematiche ed è un sostenitore della tradizione del codice, vedeva nel codice:
> Un *corpo legale*, (vediamo ancora una volta la metafora del corpo come per il "corpus" Giustinianeo che doveva racchiudere "tutto" il diritto), e quindi un insieme normativo unitario e coerente, ***senza lacune***.

> E rendeva l'idea dell'importanza di ciascuna parte rispetto all'altra attraverso la *metafora dell'orologio* che è un meccanismo in cui tutto deve corrispondere, e quindi ogni parte si chiarisce in relazione all'altra ed è idoneo ad essere smontato e rimontato senza perdere la sua funzionalità.

- Quindi l'idea di codice come un insieme unitario, come un orologio con dei meccanismi interni funzionanti tutti insieme nel loro complesso, nel loro incastro ma capace poi di essere smontato e rimontato perché ciascuna parte può avere una propria autonomia.

2- **François Geny**, (pag. 397) definisce il codice come un *"insieme di disposizioni riguardante una materia di legislazione positiva determinato nei suoi contorni da un'idea generale, espressa ordinariamente dal titolo del codice stesso"*

- Vediamo allora l'aspetto della *monotematicità*: normalmente il codice si riferisce ad una sola materia individuata normalmente dal titolo (es. Diritto Civile, Diritto Penale...).
Ed è ciò che Geny mette in evidenza. (***Univocità tematica***)

3- Se invece consideriamo gli aspetti del codice moderno: **Giovanni Tarello**, filosofo contemporaneo di scuola genovese, affermava che *"Il codice è un documento che contiene una serie di norme ordinate in modo sistematico tali da formate una unità e da realizzare una disciplina completa dei rapporti dei giudici"*
Quindi mette in risalto:
- Il carattere della *sistematicità :* e quindi l'organizzazione sistematica del codice che ha una sua struttura logico-razionale interna, ramificata dei concetti, tale da formare un unicum;
- Il carattere dell'*esaustività* tendenziale : e cioè il codice si pone come un testo che in maniera completa dovrebbe esaurire la normativa con riguardo a quel tema indicato dal titolo.

Ricapitolando:
Il codice moderno si caratterizza per questo:
> Univocità tematica (come diceva Geny) data dal titolo e dalla coerenza e sistematicità interna delle norme.
> La tendenziale completezza (che lo stesso Tarello aveva messo individuato, e cioè che si presume che il codice disciplini in maniera esaustiva il settore indicato dal titolo.
> E la sistematicità, cioè la distribuzione razionale della materia secondo criteri logici.

Queste caratteristiche sono presenti nel codice romano tardo antico? **No**.

Il Codice antico

- Non vi è quella coerenza interna che ne genera un'organizzazione sistematica in senso stretto
- Non vi è univocità tematica perché le tematiche affrontate appartengono a settori diversi
- Non c'è l'aspetto dell'esaustiva, della tendenziale completezza, anche a causa della varietà dei contenuti.

> Innanzitutto dobbiamo avere ben presenti i momenti cardine del diritto (cioè il momento della creazione\produzione e il momento dell'applicazione pratica (per esempio nel caso dei criminali, quando il diritto entra in crisi, allora c'è la controversia, si va in tribunale, e li ci sono le autorità che applicano il diritto in una certa maniera).

> Fino a quel momento, fino all'età tardo antica, c'era stata una produzione normativa enorme, erano state emanate tante di quelle costituzioni dall'eta classica in poi che in maniera alluvionale erano pervenute tra le mani dei tardo antichi creando una sorta di confusione normativa, non si sapeva bene quale norma applicare di volta in volta, c'era una sorta di condizione di smarrimento nel momento del controllo e di applicazione delle norme (non si capiva quali norme bisognasse applicare e in che momento, il che poteva portare anche a dei conflitti)
> Occorreva quindi creare un punto di riferimento unitario e autoritativo, cioè che derivasse direttamente dall'imperatore e dalla sua volontà, anche per aiutare gli operatori del diritto a sapere qual era il diritto applicabile univocamente.
- È questo che porta all'esigenza di racchiudere in un'unica raccolta le costituzioni, tutta la normativa utile, quella che l'imperatore ritiene si debba applicare e che proviene anche dal passato, non solo quella che lui produce: non vale solo il diritto che in quel momento l'imperatore produce di suo, vale anche quello che viene dal passato (non si butta via ciò che viene dal passato, che è durevole, perché è un patrimonio utilizzabile e prezioso che deve combinarsi con il governo del nuovo imperatore).

Ricordiamo che c'è una forte mentalità tradizionalistica, sempre, si da sempre valore alla tradizione, a mio che proviene dal passato.
Mentre noi siamo abituati a guardare al passato come a qualcosa di superato (es. quando subentra una nuova legislazione, quella precedente viene completamente soppiantata, o comunque viene integrata con innovazioni).
Nel mondo romano ciò che viene dal passato ha un valore inestimabile, il tempo entra nelle norme, il codice è una raccolta di costituzioni che possono attenere a materie diverse, non c'è univocità tematica, vengono conservate con la data e con gli imperatori che l'hanno emanata.
- Quindi il tempo entra nel codice, c'è un richiamo al momento e al contesto storico, c'erano tutte le coordinate temporali che portavano quella costituzione al momento in cui era stata emanata (data e imperatore che ha emanato quella costituzione, ma anche i destinatari).
- Quindi abbiamo che questi testi normativi si ordinano in maniera più o meno coerente dando vita ad un pensiero normativo che non esclude il tempo, ma lo implica, abbiamo materiali nuovi che coesistono con quelli antichi, e anni la durata, il tempo conferisce autorevolezza.
Tant'è che ci fu Teodosio II che voleva includere nel codice le costituzioni desuete, quelle che erano cadute in disuso, e questo perché voleva ci fossero tracce della produzione legislativa di un determinato momento storico in quanto avrebbe potuto insegnare ai posteri com'era maturata: la storia diventa *magistra vitae*.
- E questo è segno di una nuova sensibilità, una nuova mentalità che emerge nel periodo del dominato, per cui la legge viene identificata con l'atto normativo dell'imperatore.
- L'unico criterio ordinatore alla base di questi codici è il criterio cronologico.
- E quindi hanno anche la funzione di risolvere quel problema della *confusio legis* ovvero della confusione legislativa che era un problema serio per chi governava, in quanto altrimenti avrebbe perso il controllo dell'amministrazione del territorio.

9. L'utopia della “legge semplice”

Il fine primario dei codici sia di costituzioni sia che descritti giurisprudenziali era la certezza del diritto, di conseguenza ciò a cui ciascun legislatore aspira è la realizzazione dell’***utopia della legge semplice:***

- E cioè la realizzazione di una legge che sia capace di governare tutti i bisogni della prassi senza l'aiuto di interpreti, come se ciascuno fosse capace di essere giureconsulto (egli stesso l'interprete della legge). In altre parole la legge doveva essere di comprensione facile, tale da consentire a chiunque di approcciarsi ad essa senza bisogno di intermediari.

- E questo è perfettamente in linea con il divieto di Giustiniano di interpretazione\ di intermediari, tant'è che voleva che i commentari fossero soltanto strumento di aiuto all'approccio ai testi normativi, e l'interpretazione non doveva essere spiegazione articolata del dato normativo o spunto di riflessioni.

(Dietro questi divieti c’è proprio l’aspirazione alla legge semplice).

> Una cosa del genere è difficile, inafferrabile, per quanto comunque la tendenza sia quella di arrivare alla certezza del diritto, le norme contenute nei codici seppur redatte con l’ausilio dei giuristi, per forza vanno poi interpretate: è un passaggio da cui non si sfugge.

Ma quest’aspirazione è comunque un’utopia ben lontana dalla realtà del mondo antico.

Tant’è che infatti sul diritto codificato tardo antico venne elaborata un’attività interpretativa notevolissima a dispetto di quanto Giustiniano vietava espressamente;

- Si sviluppò tutta una letteratura riassuntiva, parafrastica, con intenti pratici (letteratura tardo antica in generale), e ovviamente ciò andò a perpetrare anche la compilazione giustinianea;

Quindi ad esempio, ci fu, in relazione ai codici Ermogeniano, Gregoriano, Teodosiano, un pullulare di interpretazioni, ma poi anche dopo (nel sesto secolo), attorno al codice giustinianeo si venne producendo una vastissima letteratura che Giustiniano cercò di arginare, ma poi tutto sommato non riuscì a farlo.
Perché l’imperatore voleva evitare i commenti al fine di garantire l’autenticità del dettato normativo , e quindi presidiare la certezza del diritto, ma tantissime epitome, commenti, parafrasi, furono fatte sia per il digesto, sia per il codice sia per le *institutiones*.
> Per altro lo stesso Giustiniano apportava continue correzioni al suo stesso codice, tanto che questo suo atteggiamento gli procurò il rimprovero di emanare costituzioni per poi abolirle.
Il diritto comunque è vivo, si muove, le interpretazioni e gli interventi sono necessari: di fondo c’è la consapevolezza della costante e naturale mutevolezza delle cose di natura, e quindi del diritto che è cosa umana, e per questo non può essere ne eterno ne immutabile.
Per cui lo stesso codice non poteva essere eterno come si voleva raffigurare; a dispetto allora di un’immagine monumentale che si voleva tracciare di una compilazione che si voleva consegnare all’eternità, completo e tendenzialmente esaustivo, che si spiegava da solo; al di la di questo comunque vi era la consapevolezza delle cose umane e quindi allo stesso codice, per cui occorreva una giustificazione dello stesso giustiziano del perché continuava a rivedere i suoi stessi atti normativi.
Pag. 391
Il discorso di Bretone viene intervallato da alcune parole della Const. Tanta relative alla giustificazione che Giustignano tenta di dare a questi suoi interventi.
E dice: “Nulla esclude che...nei lacci delle leggi”
E questo perché è evidente che col passare del tempo e con l’affiorare di nuove esigenze pratiche, è chiaro che la normativa può non essere adeguata, occorre ritornare a disciplinare determinati rapporti, ed i codici non possono impedirlo; Non è che per il fatto che esiste un codice bello e confezionato non si deve poi regolamentare qualcosa che emerge di urgente e necessario.
E quindi è capito della “fortuna imperiale ... smette mai di imitarlo”
E quindi la giustificazione di questo intervento ulteriore rispetto alla redazione del codice, che è necessari per lo stato delle cose, ama ce poi contraddice l’atteggiamento che Giustignano aveva assunto, comunque

va giustificato e legittimato con un fondamento; alla esclude che si possano cerare nuovi rapporti non disciplinati dalle leggi, ed è prerogativa dell'autorità imperiale intervenire a correggere, ricomporre... le regole a seconda di come le novità riaffiorano nella pratica, a seconda di come le novità affiorano nella pratica, e quindi si rida all'imperatore quell'autorità di legge vivente che assume da dio l'autorità e la legittimazione a fare ciò che è necessario fare.
Quindi addirittura imita il compito d dio di ricondurre tutto il quadro alla sua armonia.
L'assolutismo imperiale comunque può fare qualunque cosa, anche rivedere le sue stesse posizioni, però senza contraddirsi, ma legittimandosi.

Mappa cronologica: La Tradizione Giuridica Europea

> Codex come forma libraria (II- IV sec. d.C.)

> Codex come raccolta di materiali giuridici

- Significato improprio= raccolta di testi giurisprudenziali
- Significato proprio = raccolta di costituzioni imperiali (degli imperatori)

(facciamo questa distinzione perché il concetto di riordino può avere in oggetto sia le leges, sia gli iura. E nella raccolta di iura noi assistiamo proprio a questa volontà di racchiudere il patrimonio della produzione intellettuale giurisprudenziale che viene dal passato)

> Fine Ill d. C.

- Codice Gregoriano
- Lacuna del 292
- Codice Ermogeniano

(ricordiamo che sono iniziativa di privati)

> 429-438

- Codice Teodosiano

> 528- 534

- Codice giustinianeo - Digesto - Istituzioni + Novelle

Codificazione giustinianea si colloca:
In Occidente: In Italia, 550 circa
In Oriente: Basilici (fine IX sec.)

> XI sec. —> Scuola Bolognese - "scoperta" del Digesto, rinascita degli studi giuridici

> dal XII sec. —> altre Università europee, sul modello di Bologna
> XII- XIII —> Glossatori
> XIV -XV —> Postglossatori o Commentatori o Consiliatori
> XV-XVI —> Umanesimo giuridico
> XVII - XIX —> Giusnaturalismo moderno
> XIX —> “Scuola storica del diritto in Germania", Savigny
> XVIII-XIX —> Le grandi codificazioni nei paesi europei (alcune sino al 1900)